

دكتور
زكى محمد النجار
أستاذ القانون العام
جامعة الأزهر

الوجيز في العقود الإدارية

طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
ولأئحته التنفيذية وأحدث الأحكام القضائية

الطبعة الثالثة

٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

دمنهور - ميدان ١ طة - خلف مكتب ال يد العمومي

المقدمة

تعد وسيلة التعاقد، هي الوسيلة الطبيعية للإدارة في سبيل تحقيق أغراضها والقيام بمشروعاتها. وقد احتلت تلك الوسيلة أهمية كبيرة — في الوقت الحاضر — نظراً لاضطلاع الدولة بنهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، وزاد الاعتماد على تلك الوسيلة بشكل ملحوظ، بل قد صدر قانون جديد ينظم تلك التعاقدات، ونقصد بذلك القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بديلاً عن القانون (السابق) رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م بشأن تنظيم المناقصات — وجاء القانون الجديد متضمناً أحكاماً جديدة تتلائم ومسيرة التنمية الهائلة التي تشهدها البلاد حالياً، كأحد مفردات التشريعات المشجعة للاستثمار، وذلك بهدف إعادة هيكلة الأعمال وإطارها المؤسس والقانون كجزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

والمسلم به قانوناً أن العقود التي تبرمها الإدارة (وتكون طرف فيها) لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد لأمر في تكييفها القانوني إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أو العام وكان من المسلم كذلك أن هذه العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل في مجال تكوينها مراحل متعددة، يمهّد كل منها لما يليه، ليكون خاتمتها العقد في صورته الكاملة. ذلك إن الإدارة لا تتمتع — في مجال إبرامها لعقودها — بالحرية ذاتها التي يملكها أشخاص القانون الخاص في نطاق العقود التي يدخلون فيها، بل عليها أن تلتزم طرفاً بعينها توصلها إلى اختيار المتعاقد معها، وكثيراً ما

تكون قراراتها الإدارية متضمنة إنهاء علاقة تعاقدية بعد نشوئها، أو ممهدة لعلاقة قانونية جديدة لا تزال في طور تكوينها. وسواء آل أمر العلاقة الجديدة إلي إبرام الإدارة لعقد من عقود القانون الخاص أو لأحد العقود الإدارية، وإن قراراتها التي تتصل بالعقد سواء من ناحية الإذن به أو إبرامه أو اعتماده، تتفصل عنه ويجوز الطعن فيها استقلالاً عن العلاقة التعاقدية في ذاتها، وذلك على العكس من القرارات الصادرة من جهة الإدارة استناداً إلي نصوص العقد الإداري وتنفيذاً له لا تعد قرارات إدارية، وإنما هي قرارات تنبثق عن رابطة تعاقدية، وتدخل في منطقة العقد، وبالتالي لا يرد عليها طلب الإلغاء، وإنما تعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعرض على قاضي العقد وتستتھض له ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء، وتخضع للتقادم الطويل.

وتجدر الإشارة إلي أن التعبير عن الإرادة من الشخص المعنوي العام يجب أن يكون عند حدود أهليته المضبوطة بإطار الأغراض التي نشأ لأجلها فذاك الشخص الاعتباري إنما ينشأ محدوداً بأغراض معينة تقررها أطر المشروعية، فيخط القانون بذلك ملامح أهليته ومناط صلاحيته في التصرف وكسب الحقوق وأداء الالتزامات، ليصير والحال هذه للشخص الاعتباري سلطاناً مقيداً بحدود أهليته المعينة بدورها بحدود الأغراض القائمة لأجلها.

وسوف نتناول بالدراسة النظام القانوني للعقود الإدارية وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م.

ومن جانبنا، نرى أن دراسة أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م — المشار إليه — تستلزم إلقاء الضوء — بإيجاز — على بعض المسائل الهامة — كمسائل أولية — تساعد في التمهيد — الضروري — لهذه الدراسة، ونعرض لتلك المسائل في فصل تمهيدي.

وبذلك نتحدد معالم هذه الدراسة على النحو الآتي:

في فصل تمهيدي: نتناول مسائل أولية جوهرية

والباب الأول: نخصصه لدراسة إبرام العقد الإداري، ونستعرض فيه الاستحداثات التي جاء بها القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، ثم القيود التي ترد على حرية الإدارة قبل إبرام العقد وطرق التعاقد، وأخيراً إجراءات التعاقد.

بينما نتناول في الباب الثاني: تنفيذ العقد الإداري، وبيان حقوق والتزامات كل من طرفيه وأخيراً الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها وضوابط توقيع تلك الجزاءات.

فصل تمهيدي

وفيه عشرة مسائل أولية :

أولاً: استقرار أحكام القضاء والفقه على تعريف العقد الإداري.

ثانياً: في تكييف العقد.

ثالثاً: نفاذ القانون من حيث الزمان فيما يتعلق بالعقود المبدأ ،
والاستثناءات.

رابعاً: شرط الكتابة في العقد الإداري. طبيعته.

خامساً: اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات العقود
الإدارية. القضاء الكامل.

سادساً: إشكالات التنفيذ في العقود الإدارية.

سابعاً: قضاء الإلغاء في منازعات العقود الإدارية (نظرية القرارات
الإدارية المنفصلة).

ثامناً: الوسائل غير القضائية في حسم منازعات العقود الإدارية
التوفيق — الوساطة — التحكيم.

تاسعاً: اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر
منازعات العقود الإدارية. حدوده ومداه.

عاشراً: النظام القانوني للعقود الإدارية.

فصل تمهيدي

وفيه عشرة مسائل أولية

أولاً: استقرار أحكام القضاء والفقه على تعريف العقد الإداري

يمكن القول أن ما انتهت إليه محكمة القضاء الإداري في بواكير أحكامها من أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن يظهر نيته في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه، وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.. وأن علاقة العقد بالمرفق العام إذا كانت ضرورية لكي يعتبر العقد إدارياً، فإنها ليست مع ذلك كافية لمنحة هذه الصفة، اعتباراً بأن قواعد القانون العام ليست ذات علاقة حتمية بفكرة المرفق العام، إذ أنه مع اتصال العقد بالمرفق العام فإن الإدارة قد لا تلجأ في إبرامه إلي أسلوب القانون العام، لما تراه من مصلحتها في العدول عن ذلك إلي أسلوب القانون الخاص، فنتبع في شأنه ما يتبعه الأفراد في تصرفاتهم الخاصة. ومن ثم فإن المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود الأفراد وعقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة ليس هو صفة المتعاقد بل موضوع العقد نفسه متى اتصل بالمرفق العام على أيه صورة من الصور، سواء أكانت من حيث تنظيم المرفق العام أو استغلاله أو تسييره أو المعاونة والمساهمة في ذلك أو استخدام المرفق ذاته عن طريق العقد مشتركاً في ذلك وعلى درجة متساوية مع الشروط الاستثنائية غير المألوفة المضمنة في العقد^(١).

^١ محكمة القضاء الإداري، القضية رقم ٢٢٢ لسنة ١٠ق، في ١٣/١٢/١٩٥٦م.

— وتجدر الإشارة إلي أن الذي اضطردت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في خصوص العقود الإدارية، لم يترتب عليه حدوث تغيير في المبادئ التي أرستها محكمة القضاء الإداري في هذا الخصوص^(١)، بل واستقرت أحكام القضاء العادي، وقضاء المحكمة الدستورية العليا^(٢)، على تلك المبادئ دون تغيير.

وهكذا فإن الفقه والقضاء مستقران على أنه يشترط لكي يكون العقد إدارياً، توافر ثلاثة شروط: أولهما، أن تكون الإدارة طرفاً في العقد. وثانيها: اتصال العقد بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته، مراعاة لوجه المصلحة العامة. وأخيراً أن تأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، أو بمنح المتعاقد معها حقوقاً لا مقابل لها في روابط القانون الخاص، لكونه معاوناً للسلطة الإدارية في تسيير المرفق العام^(٣).

١ حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٣٤ ق في ١٩٩٧/١/٢ م.

٢ المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم ٣٦ لسنة ٣٨ ق (تنازع في ٢٠١٨/٥/٥ م).

٣ ومن أمثلة هذه الشروط أيضاً، سلطة الإدارة في مراقبة تنفيذ العقد وتوجيه أعمال التنفيذ، واختيار طريقته، وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه بإرادتها المنفردة، وسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد معها.. الخ.

وهنا بعض الأمور الأولية، تجدر الإشارة إليها:

١- العبرة في تحديد طبيعة العقد تكون عند إبرامه:

إن العبرة في تحديد طبيعة العقد تكون عند إبرامه يظل العقد إدارياً ولو تغيرت طبيعة الشخص الاعتباري الذي أبرمه من شخص عام إلى شخص خاص، ما دام قد توافرت في العقد الشروط الأخرى اللازمة لاعتباره عقداً إدارياً. بمعنى آخر، متى توافرت للعقد وقت إبرامه مقومات العقد الإداري المشار إليها، ثم تغيره صفة الشخص المعنوي العام، بأن صار شخصاً من أشخاص القانون الخاص بعد أن اكتمل تنفيذ العقد، فإن هذا العقد يظل عقداً إدارياً، ولا ينقلب إلى عقد مدني، بل يبقى العقد خاضعاً لأحكام القانون العام الذي أبرم ونفذ في ظله ومن ثم تدخل المنازعة في شأن الحقوق الناشئة عنه أو المترتبة عليه في اختصاص جهة القضاء الإداري^(١). أما إذا نشأ العقد كعقد مدني، فلا يمكن أن ينقلب بمقتضى قواعد عامة تنظيمية إلى عقد إداري^(٢).

٢- عقود المنتفعين بالمرافق الاقتصادية عقود خاصة:

العلاقة بين المرافق العامة الاقتصادية والمنتفعين بها هي علاقة خاصة، تخضع لأحكام القانون الخاص، لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنها (مثال عقد اشتراك هاتف) بل ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها لجهة القضاء العادي. مرد ذلك تخلف مقومات وخصائص العقود الإدارية في تلك العقود، وبخاصة تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقد.

١ المحكمة الإدارية العليا، الطعن ٢١٠٢٣ لسنة ٥٨ ق، في ٢٢/١٢/٢٠١٥م.

٢ المحكمة الإدارية العليا، الطعن ٢٦٧٨ لسنة ٤٦ ق، في ٢٨/٤/٢٠٠٤م.

هنا يبرز المعيار المميز للعقود الإدارية عن عقود الإدارة الخاصة، يخلص ذلك المعيار في موضوع العقد وليس شكله.

إذاً إذا كان العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني (الخاص) من حيث العناصر الأساسية، فهو توافق بين إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء التزامات تعاقدية، تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية، بيد أن الإدارة تعمل في إبرامها له (في إبرام العقد الإداري) بوصفها سلطة عامة، تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة، كما أنه يفترق من العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله، إما بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص (سواء كانت هذه الشروط واردة في العقد نفسه أم مقرررة بمقتضى القوانين واللوائح) أو بمنح المتعاقد فيه حقوقاً لا مقابل لها في روابط القانون الخاص، بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية، بل يعاون السلطة الإدارية ويشترك معها في إدارة المرفق العام وتسييره واستغلاله تحقيقاً للنفع العام بينما تكون مصالح الطرفين في العقد المدني (الذي يخضع للقانون الخاص) متساوية ومتوازنة، فإن كفتي المتعاقدين في العقد الإداري غير متكافئة تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية، مما يجعل للإدارة في هذا العقد سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد وتوجيه أعمال التنفيذ، واختيار طريقته، وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التي يؤديها بإرادتها المنفردة، وفي توقيع العقوبات على المتعاقد دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر أو اللجوء إلى القضاء.

— المعيار الحاسم في تحديد طبيعة العقد، هو تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص أو خضوعه لنظام غير مألوف في القانون الخاص.

في عبارة واحدة، إذا لم يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير (مألوفة) فإنه يخضع لأحكام القانون الخاص وينتفي عنه وصف العقد الإداري^(١).
ثانياً: في تكييف العقد:

— وفي تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه، فإن العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين وللمحكمة السلطة التقديرية في التعرف على تلك الحقيقة والتحري عن مقصود العاقدين، ولها في سبيل ذلك تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى، واستخلاص ما تقتنع به منها، متى كان استخلاصها سائعاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

— وقضي بأنه إذا تضمن العقد قيوداً على حق المنتفع بالعين محل التعاقد بما ينافي طبيعة الإيجار، تخرج التعاقد من نطاقه، فإنه لا يصح اعتباره عقد إيجار، ومن ثم فإنه لا يخضع في هذه الحالة لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن بل تحكمه القواعد العامة بحسب طبيعة العقد الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين^(٢).

— كما وأن الشرط الذي يتضمنه عقد بيع أرض، بإقامة مشروع معين فيها هو شرط غير مألوف في عقود القانون الخاص، التي تعطي

١ المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٢٧٤٠٢ لسنة ٥٥ ق في ٢٤/٣/٢٠١٥ م.

٢ أ.ع، طعن ١٥٦٣٦ لسنة ١٥.ع، طعن ١٥٦٣٦ لسنة ٥٤ق، في ٢٣/٢/١٦.

للمشتري الحق في التصرف في الأرض محل التعاقد بجميع التصرفات
الجائزة قانوناً^(١).

وبعد عقداً إدارياً، عقد بيع قطعة أرض مملوكة للدولة بغرض إقامة
مشروع سياحي يتضمن شرطاً بأن يتم سحب الأرض إذا لم يتم البدء
في التنفيذ خلال مدة معينة^(٢).

ولكن، هل النص في العقد على حق الإدارة في فسخه بالإدارة
المنفردة، يجعله عقداً إدارياً؟

لا يعد مجرد تضمين العقد - في هذه الحالة - شرط فسخه بالإرادة
المنفردة عقداً إدارياً، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استعمالاً لجهة الإدارة
حقها في الفسخ إعمالاً من جانبها لنص المادتين ١٥٧، ١٥٨ من القانون
المدني، اللتين تجيزان الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين على أن يكون
العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه^(٣).

ثالثاً: نفاذ القانون من حيث الزمان فيما يتعلق بالعقود المبدأ
والاستثناء:

الأصل أن للقاعدة القانونية الجديدة أثراً مباشراً، فتنفذ من الوقت
المحدد لنفاذها. ويقف نفاذ القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، ما لم ينص

١ أ.ع، طعن رقم ١٥٤ لسنة ٣٤ق، في ١٩٩٧/١/٢م.

٢ أ.ع، طعن ٧٩٥٧ لسنة ٤٨ق، في ٢٠٠٦/١/٢٤م ومثاله أيضاً العقد الذي تبرمه هيئة
المجتمعات العمرانية مع شركة لإقامة مشروع للإسكان الحر، على وفق الاشتراطات
والقواعد البنائية المعمول بها في الهيئة، يعد عقداً إدارياً متى أخذت فيه بأسلوب القانون
العام (أ.ع، طعن ٣٠٩٥٢ لسنة ٥٦ق في ٢٠١٠/٩/١٤م).

٣ المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم ٧ لسنة ٢٢ق (تنازع في ٢٠٠١/٥/٥م).

القانون على خلاف ذلك. وتظل المراكز القانونية التي اكتمل تكوينها وترتبت آثارها في ظل القانون القديم خاضعة لحكمة وحدة.

هناك استثناء من هذا الأصل خاص بالعقود، إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتي بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد.

وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية بشرط: ألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز العقدية لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلية.

— والمراد بالقانون معناه الموضوعي العام (التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية والتنفيذية)^(١).

— وسوف نعود لهذه المسألة — تفصيلاً — بعد ما تم إلغاء القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، بموجب القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بإصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة.

رابعاً: شرط الكتابة في العقد الإداري طبيعته:

— يثور التساؤل حول طبيعة الكتابة في العقد الإداري، هل تعد ركناً في العقد (يترتب على مخالفتها بطلان العقد أم لا تعدو الكتابة أن تكون شرطاً متطلباً في العقد) وليست شكلية جوهرية أم أن الكتابة شرط

١ أ.ع، طعن رقم ٢٧٤٠٢ لسنة ٥٥ق في ٢٤/٣/٢٠١٥م، طعن ١٥٦٣٦ لسنة ٥٤ق في ٢٣/٢/١٦.

جوهري؟ أم لا تعد الكتابة سوي شرط غير جوهري ومن ثم غير مؤثر في صحة العقد وسلامته؟^(١)

مجمل القول: أن الأصل في العقود الإدارية أن تكون مكتوبة، إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون العقد الإداري — شأن العقد المدني — غير مكتوب. وفي هذه الحالة تكون الشروط الاستثنائية غير المألوفة، مضمنة في قواعد تشريعية قائمة من الأصل وتخضع مباشرة لنصوصها العقد عند نشأته وبعد إبرامه، وتسري عليه هذه القواعد، بحسبان أن الشروط الاستثنائية غير المألوفة **لا يجب حتماً** أن تكون شروطاً رضائية يتفق عليها طرفا العقد الإداري وقت إبرام العقد ، بل قد يفرضها النظام القانوني سلفاً ويستلزم وجودها النظام الموضوع لإدارة المرفق العام، وكيفية المساهمة فيه أو الاشتراك في إدارته وتسييره.

وبصفة عامة: فإن الكتابة في العقود الإدارية هي شرط لازم في العقود الكبيرة أو ذات الأهمية الخاصة.

بمعنى آخر: القاعدة العامة في العقود الإدارية هي التحرر من الشكليات ذلك أن صحة هذه العقود لا تخضع لشروط خاصة بالشكل.

فالعقد الإداري **عقد رضائي** وليس **عقداً شكلياً** وأنه حين لا يضع القانون أو يفرض طريقة معينة للتعبير عن الإرادة، فإن الإرادة تصبح حرة في إبرام ما تشاء من العقود في الأشكال التي تراها.

— وإذا كان الأصل في مصر هو الكتابة في العقود الإدارية، بل وفي كافة العقود التي تبرمها الإدارة، فيما عدا العقود قليلة الأهمية، فإنه في

١ في تفصيلات ذلك، راجع مؤلفنا (نظرية البطلان في العقود الإدارية — دراسة مقارنة —) جامعة عين شمس ١٩٨١م ص ٢٠٦ وما بعدها.

فرنسا، تخضع كثير من العقود (خاصة عقود الأشغال العامة) – بنص القانون – لشرط الكتابة ولا تلتزم الإدارة بكتابة العقود الإدارية إلا إذا كان هناك نص قانوني يلزمها بذلك.

– وعلى ذلك فإن العقد غير المكتوب وسيلة غير مألوفة في المجال الإداري، إلا أنه يؤدي دوراً مكملاً لبعض أنواع العقود الإدارية، فقد تركز إليه الإدارة مع بعض المتعاقدين للاتفاق معهم على تكميل أغراض التعاقد الأصلي من ناحية من النواحي التي انصب عليها هذا العقد المكمل تنصرف إليه طبيعته العقد الأصلي بحكم ارتباطه ، ومن ثم فلا حاجة البتة إلي استظهار أركان العقد الإداري فيه^(١).

خامساً: اختصاص القضاء الإداري (القضاء الكامل – أو قضاء التعويض –) بالفصل في منازعات العقود الإدارية:

١- تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بجميع العقود الإدارية سواء العقود الإدارية بطبيعتها، وهي تلك التي تتوافر فيها الشروط الثلاثة، سالف ذكرها، أو العقود الإدارية بنص القانون، وهي عقود الالتزام أو عقود الإشغال العامة وعقود التوريد (م/١٠ من ق: رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م في شأن مجلس الدولة).

واختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات العقود الإدارية، هو اختصاص مطلق وشامل، لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، طالما لم يسقط أصل الحق بمضي المدة.

ومن ثم يكون لمحكمة القضاء الإداري في منازعات العقود الإدارية، أن يفصل في القرارات التي تتصل بعملية إبرام العقد، بمقتضى ولايتها

١ أ.ع، طعن رقم ١٠٠٤ لسنة ١٢ق في ١٨/٥/١٩٦٨م.

الكاملة، دون أن تقتصر في شأنها على الإلغاء، بمعنى آخر: وأنه متى توافرت في المنازعة حقيقة العقد الإداري، سواء أكانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه، فإنها تدخل في نطاق ولاية القضاء الكامل (قضاء التعويض) دون ولاية قضاء الإلغاء.

ويترتب على ذلك ألا تنقيد دعوى الإبطال هذه بمدد دعوى الإلغاء.

اختصاص القضاء الإداري (القضاء الكامل) بالمنازعات المستعجلة الناشئة عن العقود الإدارية.

٢- ويختص القضاء الإداري كذلك بالفصل في الأمور المستعجلة المتفرعة عن منازعات العقود الإدارية.

ويقصد بالطلبات المستعجلة، تلك الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر ، أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد إلى الفصل في موضوعه ، أو طرح النزاع بشأنه على قاضي العقد.

ونشير — هنا — إلى أن هذا الاختصاص لا يستمد أصله من اختصاص قاضي الإلغاء بالشق المستعجل من دعوى الإلغاء (قضاء وقف تنفيذ القرار الإداري) وإنما يستمد أصله من الاختصاص الشامل لقاضي العقد الإداري.

— في التزام قاضي العقد بالحدود والضوابط المقررة في الطلبات المستعجلة، فينظر قاضي العقد في قواعد الاستعجال بأن تستظهر الأمور التي يخشى عليها فوات الوقت ، والنتائج التي يتعذر تداركها والضرر

المحقق بالحق المطلوب المحافظة عليه، وكذلك استظهار جديتها أو عدم جديتها.... دون مساس بالناحية الموضوعية للنزاع^(١).

والقضاء الكامل في مباشرته في ولاية الفصل في الأمور المستعجلة، وإن كان لا يفصل في أصل الحق، إلا أنه يحميه مؤقتاً، متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية، بمعنى أنه لا يقرر إلا حلولاً وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل في موضوعها، حتى لو ترتب على تلك الحقوق لحوق ضرر بأحد الطرفين.

— كذلك فإن المنازعة في تفسير عقد إداري تدخل في ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء، ولا يرد عليها وقف التنفيذ المتعلق بالقرارات الإدارية.

— صفوة القول: أن اختصاص القضاء الإداري (الشامل) لأصل منازعات العقود الإدارية وما يتفرع عنها، يستوي في ذلك أن تتخذ المنازعة صورة قرار إداري أو لا تتخذ هذه الصورة، طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري.

١ أ.ع — طعن رقم ٢٠٨٤ لسنة ٣١ ق، في ٢٤/١/١٩٩٥م

— وقد ذهب رأي إلي عدم التزام محكمة القضاء الإداري بضوابط وقف تنفيذ القرار الإداري (الطلبات المستعجلة) في مجال منازعات العقود الإدارية (المستعجلة) والاكتفاء بشرط الاستعجال فقط.

راجع: المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين، العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات، الكتاب الأول ص ١١٠.

سادسا: إشكالات التنفيذ في منازعات العقود الإدارية :

قدما أن المستقر عليه فقها وقضاء أن قضاء العقود الإدارية ينتمي أساساً إلى القضاء الكامل (قضاء التعويض) فيكون للمحكمة أن تنظر ما يكون قد صدر بشأن تلك العقود من إجراءات وقرارات، وذلك باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى هذه المنازعات طالما لم يسقط الحق بمضي المدة كما يكون للمحكمة الاختصاص الشامل لجميع ما يتفرع عن المنازعة الأصلية من أمور مستعجلة.

ومن أهم هذه المنازعات (الإشكال في التنفيذ).

— فما هو المقصود بالإشكال في التنفيذ؟ وما هي الأحكام المنظمة له؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؟ وما هي المحكمة المختصة بنظر إشكال التنفيذ في مادة العقود الإدارية؟

— الإشكال في التنفيذ هو منازعة مستعجلة تتعلق بالتنفيذ، يكون المقصود منها إما إيقاف التنفيذ أو استمراره، وتدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. فيكون التنفيذ هو سببها وتكون هي عارض من عوارضه.

لذلك فإنه يشترط لقبول الإشكال أن يقدم قبل تمام التنفيذ، وأن يستند إلى أسباب جدت بعد صدور الحكم وأن يكون المطلوب فيه الحكم بمجرد إجراء وقتي لحين الفصل في النزاع الموضوعي المتعلق بالتنفيذ أو بأصل الحق، وذلك دون المساس بأصل الحق الثابت بالحكم ، فهو لا يتعلق بحجية الحكم أو نعي أو تجريحا فيه، وإنما يهاجم ويعترض السند التنفيذي.

ويترتب على إقامة الأشكال الأول في التنفيذ — طبقاً لنص المادة (٣١٢) من قانون المرافعات المدنية والتجارية — وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بصفة مؤقتة.

فإذا قضي لصالح المستشكل ظل التنفيذ موقوفاً إلي أن يتم الفصل في موضوع النزاع (النزاع الموضوعي) القائم بشأن التنفيذ أو في خصوص الحق الأصلي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه.

ويترتب هذا الأثر — وقف التنفيذ بصفة مؤقتة — سواء أكان الأشكال مقاماً بصحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ولائياً أو نوعياً، أم قدم أمام المحضر عند الشروع في التنفيذ، وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة، وذلك أخذاً في الاعتبار حتمية الالتزام بالتفسير الضيق لنص المادة (٣١٢) من قانون المرافعات، باعتبار أن الأصل هو الالتزام بتنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، وأن الأشكال الأول الذي يوقف تنفيذها يرد على خلاف هذا الأصل، فحتى ينتج هذا الأثر لابد وأن يتصل بالمحكمة المختصة بنظره ولائياً ونوعياً.

وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن نظام إشكالات التنفيذ والفصل فيها لا يتعارض مع النظام الموضوعي للمنازعة الإدارية.

ولما كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام — بصفة عامة — تحكمها الأصول الكلية المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.. والضوابط التي يتم على أساسها الفصل فيها، كما حدد في المادة (٣١٢) منه أثر يقدمها — وهو ما يسرى — كقاعدة — على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.

وفي عبارة واحدة، ليس هناك ما يتأبى أن تتضمن الدعاوى المتعلقة بالعقود، طلبات مستعجلة وعلى ذلك، فإن محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة منها^(١).

دستور ٢٠١٤ يحسم الجدل حول كافة منازعات العقود الإدارية الموضوعية، والمستعجلة ومنازعات التنفيذ في أحكام محاكم مجلس الدولة.

تنص المادة (١٩٠) من دستور ٢٠١٤م على أن: (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص.... ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها...^(٢)).

وبهذا النص الدستوري يكون قد حسم أي جدل حول اختصاص مجلس الدولة بمنازعات العقود الإدارية أيا كانت طبيعتها، موضوعية أو

١ راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رقم ٥٨ / ١ / ١٢٢ في ٢٦/٥/٢٠٠٥م.

٢ نشير إلي أن التعديلات الدستورية المقترحة (٢٠١٩م) قد عدلت من اختصاص مجلس الدولة سواء فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين.. أو مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.. وسوف نعرض لذلك بعد قليل.

مستعجلة، وكذا اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها.

مجل القول: استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل، لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل في المنازعة المستندة إلي العقد الإداري، لا على أنها من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء، بل على اعتبار أنها من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج بتعذر تداركها، وحماية للحق إلي أن يفصل في موضوعه.

ولا يهم في هذا الشأن أن يصف صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ، إذ العبرة في وصف الطلب بحقيقته وجوهرة وهدفة، حسبما يظهر من أوراق الدعوى، وبناء عليه يتعين نظر هذا الطلب المستعجل في الحدود والضوابط المقررة للطلبات المستعجلة، ويكون ذلك باستظهار الأمور التي يخشى عليها فوات الوقت، والنتائج التي يتعذر تداركها، والضرر المحقق بالحق المطلوب للمحافظة عليه وكذلك استظهار جديتها أو عدم جديتها ، دون مساس بالناحية الموضوعية للنزاع^(١).

كما تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها — على ما تقدم — .

١ أ.ع، طعن رقم ٧٧٩٨ لسنة ٤٥ ق في ٤/٦/٢٠٠٢م، طعن رقم ١٢٥٨ لسنة ٤٦ ق في ٨/٥/٢٠٠١م.

وقدما أن قضاء العقود الإدارية هو المجال الأصيل للقضاء الكامل (قضاء التعويض) فهل يعني ذلك أنه لا مجال لقضاء الإلغاء في مادة العقود الإدارية؟

وهذا ينقلنا إلى المسألة التالية:

سابعاً: قضاء الإلغاء في منازعات العقود الإدارية (نظرية القرارات القابلة للانفصال أو القرارات الإدارية المنفصلة):

من المسلمات أن سلطة قاضي الإلغاء تقف عند الحكم بإلغاء قرار معيب — أما القضاء الكامل فإنه يخول القاضي تصفية النزاع كلية، فيلغي القرارات المخالفة للقانون إن وجدت، ثم يرتب على ذلك نتائج كاملة من الناحيتين (الإيجابية والسلبية) وقدما أن قضاء العقود ينتمي إلى القضاء الكامل، وأن المنازعات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها جهة الإدارة قبل المتعاقد معها، تندرج تحت ولاية القضاء الكامل، حتى لو انصب النزاع على طلب إلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة قبله.

أساس ذلك، إن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للعقد مثل القرارات الصادرة بتوقيع أي من الجراءات العقدية أو فسخ العقد أو إنهائه أو إلغائه، إنما يدخل في منطقة العقد، وتكون المنازعات المتولدة عن تلك القرارات والإجراءات هي منازعات حقوقية تنثير ولاية القضاء الكامل دون قضاء الإلغاء.

مؤدي ذلك عدم تقيد الطعن بالإجراءات والمواعيد المتعلقة بدعوى الإلغاء^(١).

١ أ.ع، طعن رقم ٣٨٦٣ لسنة ٣٦ق، في ٢٩/١١/١٩٩٤م والطعن رقم ٢٤٤٨ لسنة ٣٦ق، في ٧/٣/١٩٩٥م.

وقدما أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وما يتفرع عنها، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وتطبيقا لذلك، قضي بأنه يدخل في ذلك طلب إصدار أمر على عريضة بتوقيع الحجز التحفظي^(١).

وكذلك قضي باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة عن المحافظ بسحب الأراضي المخصصة للمشروع من المستثمر^(٢).

وتجدر الإشارة — أيضا — إلي أن محاكم مجلس الدولة تختص — دون غيرها — بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة بمالها من سلطة عامة، ولو كان موضوع المنازعة علاقة عقدية تختص بها المحاكم المدنية (عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص).

العقد الذي تبرمه الإدارة عملية مركبة تتم على مراحل متعددة :

من المسلمات أن العقد الذي تكون الإدارة أحد أطرافه، سواء كان عقداً إدارياً أم مدنياً، يمر حتى يكتمل تكوينه بمراحل متعددة، ويسلك إجراءات شتى على وفق الأحكام والنظم المطبقة.

وهنا ينبغي التمييز بين العقد الذي تبرمه الإدارة، والإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهئئ لمولده ، ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد إدارياً أو مدنياً، فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته، من حيث كونه

١ أ.ع، طعن رقم ٣٧٢١ / ٤١٢٩ لسنة ٣٥ق، في ٢٣/٢/١٩٩٩م.

٢ أ.ع، طعن رقم ١٥٤ لسنة ٣٤ق (دائرة توحيد المبادئ) في ٢/١/١٩٩٧، طعن رقم

١٥٨١٩ لسنة ٤٩ق، في ١٤/٤/٢٠٠٨م (الدائرة الأولى).

إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني، تحقيقاً لمصلحة عامة يتغيها القانون، ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد عن العقد وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لدي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالاً (نظرية القرارات الإدارية المنفصلة)^(١).

هذه هي النظرية التي ابتدعتها مجلس الدولة في فرنسا ومصر، التي تقوم على جواز الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة، هي نظرية أوسع مدي، فلا يقتصر تطبيقها على العقود التي تبرمها الإدارة، بل تطبيق في كل عملية مركبة، مثل العملية الانتخابية، إذ يجوز للمترشح الطعن بالإلغاء في أي قرار يتعلق بالعملية الانتخابية، طبقاً لنظرية القرارات الإدارية المنفصلة، وقضي بأن: القرار الذي يصدره المجلس الأعلى للآثار بالموافقة على عرض الآثار المصرية بالخارج، المثلو بإبرام اتفاقية في هذا الشأن أشير في ديباجتها إلى هذه الموافقة، يعد قراراً إدارياً منفصلاً عن الاتفاقية، صدر تمهيداً لإبرامها، وليس صحيحاً بأن هذا القرار مجرد عمل تحضيرى للقرار الذي سيصدر عن رئيس الجمهورية بعرض الآثار للخارج، لأن المشرع لم يجعل

١ في تفصيلات نظرية القرارات الإدارية المنفصلة، راجع د. عبد الحميد حشيش، القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، القانون سنة ١٩٧٨م، مؤلفنا، نظرية البطلان في العقود الإدارية، سابق الإشارة إليه ص ٣٢٩ وما بعدها. المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين، العقود الإدارية، مرجع سابق ص ١٢٠ وما بعدها. المستشار/حمدي يس عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية، الجزء الأول، القانون لسنة ١٩٩٨م، ص ١١٦ وما بعدها.

صدور قرار رئيس الجمهورية بعرض الآثار بالخارج بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للآثار ترتيباً على ذلك، يجوز الطعن استقلاً في قرار المجلس الأعلى للآثار المشار إليه^(١).

في القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية،
تفرقة هامة بين نوعين من القرارات.

النوع الأول: القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد وهذه تسمى القرارات المنفصلة المستقلة.

ومن هذا القبيل، القرار الصادر بطرح العمل في مناقصة أو مزيدة والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقصين أو المتزايدين، والقرار الصادر بإلغاء المناقصة أو المزيدة أو بإرسائها على شخص معين أو التعاقد بالطريق المباشر، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية، شأنها شأن أي قرار إداري نهائي، ومن ثم فإنها تخضع لما تخضع له القرارات الإدارية النهائية من أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها أو إلغائها من خلال دعوى الإلغاء.

النوع الثاني: يشمل القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذاً لعقد من العقود الإدارية، واستناداً إلى نص من نصوصه، كالقرار الصادر بتوقيع غرامة التأخير، أو بسحب العمل ممن تعاقد معها والتنفيذ على حسابه، والقرار الصادر بمصادرة التأمين، أو بإلغاء العقد نفسه. فهذا القرار الصادر عن جهة الإدارة استناداً إلى نصوص العقد الإداري وتنفيذاً له، لا يعد قراراً إدارياً، بل ينبثق عن رابطة عقدية،

١ أ.ع، طعن رقم ٩٤٣ / ١٦٤٠ لسنة ٤٠ق، في ٣/٢/١٩٩٤م.

ويدخل في منطقة العقد، ومن ثم لا يرد عليه طلب الإلغاء، بل يعد من المنازعات الحقوقية التي تعرض على قاضي العقد، وتستنهض ولاية القضاء الكامل دون ولاية قضاء الإلغاء.

إذا تستند التفرقة (الجوهرية) هنا بين نوعين من القرارات . معيار التمييز بينهما هو: مدي تمتع الجهة الإدارية بالسلطة العامة في اتخاذ القرار.

فإن كان القرار صادراً من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح... فإن قرارها هنا يكون قراراً إدارياً له خصائص ومقومات القرار الإداري، ومن ثم يخضع هذا القرار لما تخضع له القرارات الإدارية من أحكام، ولا يتبدى ذلك، إلا في تلك القرارات التي تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، مثل الإذن به أو إبرامه أو اعتماده، أو إنهاء علاقة تعاقدية بعد نشؤها، أو تمهد لعلاقة قانونية جديدة، لا تزال في طور تكوينها، هذه القرارات تعد قرارات إدارية بالمعنى الدقيق، سواء آل أمر هذه العلاقة الجديدة إلي إبرام الإدارة لعقد من عقود القانون الخاص أو لأحد العقود الإدارية، وتجوز الطعن فيها من ثم استقلالا عن العلاقة التعاقدية في ذاتها، بطريق الإلغاء.

أما إذا كانت الإدارة تستمد سلطتها في إصدار القرار استنادا إلي نصوص العقد الإداري ذاته وتنفيذا له بوصفها المتعاقد معها فإن قراراتها لا تعد في هذه الحالة قرارات إدارية بل هي قرارات تنبثق عن رابطة عقدية، وتدخل في منطقة العقد، ولا يرد عليها طلب الإلغاء، إذ هي

منازعات حقوقية (وليست منازعات قانونية) تختص بنظرها قاضي العقد، وتستنتهض فيه ولاية القضاء الكامل.

بمعنى آخر: الإجراءات التي تتخذها الإدارة استناداً إلى العقود التي تبرمها، أو إجراءات تنفيذها، لا تكون محلاً لدعوى الإلغاء. لا يمكن الاستناد إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من الأسباب التي تجيز طلب إلغاء ما اتخذته الإدارة.

دعوى الإلغاء هي جزاء لمخالفة المشروعية، بينما الالتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصية (حقوقية)^(١).

وعلى ذلك يمكن القول بأن شروط طلب إلغاء القرار الإداري المنفصل (في العقد الإداري) تتحدد في ثلاثة شروط:

١- أن يقدم طلب الإلغاء من غير المتعاقد، أما المتعاقد مع الإدارة، فليس له إلا دعوى العقد عن طريق القضاء الكامل، بل إنه منذ حكم MARTIN ، يجوز للمتعاقد مع الإدارة ، الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية المنفصلة — على ما سنرى حالاً — .

٢- أن تقام الدعوى في الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء، ووفقاً للإجراءات والشروط المتعلقة بقبول طلبات الإلغاء.

٣- أن يقوم طلب الإلغاء على أساس عدم مشروعية القرار المطعون فيه، وليس إلى مخالفة الإدارة لأي من التزاماتها التعاقدية.

ولكن: ما أثر الطعن في القرار المنفصل على العقد المرتبط به أو على القرار القائم عليه؟

١ أ.ع، طعن رقم ١٩١٨٤ لسنة ٥١ق، في ٢٤/١/٢٠١٢م.

إن الحكم الذي يصدر في الطعون المقامة ضد هذه القرارات المنفصلة، لا يمتد إلا إلى القرار المطعون فيه فحسب.

فالحكم الصادر بإلغاء قرار إداري منفصل (ساهم في تكوين العقد الإداري) لا يؤثر — من الناحية النظرية — في العقد ذاته.

بمعنى أن إلغاء القرارات المنفصلة في العقود الإدارية (وحدها) لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد، بل يبقى العقد سليماً وناظراً حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء، بناء على الأثر المطلق لحكم الإلغاء أمام قاضي (العقد) سواء كان العقد خاصاً إدارياً، وحينئذ يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإلغائه استناداً إلى سبق إلغاء القرارات المنفصلة التي ساهمت في إتمام عملية التعاقد^(١).

ففي حكم مارثان Martin — المشار عليه — لم يأخذ مجلس الدولة الفرنسي بدفع الإدارة بأن القرار المطعون فيه وقد أدى إلى إبرام عقد، لا يمكن أن يكون محلاً لطعن لتجاوز السلطة (طعن بالإلغاء)، ولا يمكن أن ينظرها إلا قاضي العقد، لم يأخذ مجلس الدولة بهذا النظر، وقبل الطعن بتجاوز السلطة (بطريق الإلغاء) على القرار المطعون فيه.

وجاء في تعليق السيد/ روميو على هذا الحكم، أن عدم القبول قبل سنة ١٩٠٥م يتعلق فضلاً عن العقد ذاته، بكل القرارات الإدارية حتى من

^١ ٤٩ . ٣ . ١٩٠٦ . S., Romieu, concl. ٧٤٩, Rec. Masrin, ١٩٠٥, C.E., ٤ aout

ومن المسلم به أن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود، يمثل إفصاح الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني، هو قرار إداري (منفصل) من العقد، يجوز الطعن فيه بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ويمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليه أن كان لهذا التعويض محل.

جانب واحد التي أعدته وجعلته ممكناً، فهذه الأعمال تكون مع العقد — كما قيل — وحدة لا تتجزأ ولا يمكن الطعن فيها إلا طالما لم يصبح العقد نهائياً بعد، وإذ يلحق هذا القضاء ضرراً جسيماً بالغير، وليست له دعوى العقد، فقد اقترح السيد روميو قبول الطعون المقامة من الغير في القرارات الإدارية الممكن فصلها detachables عن العقد، مع العلم أن إلغاء هذه القرارات لا يؤدي حتما ipso facto إلى إبطال العقد.

وهكذا يكون القضاء قد أقر بتوسع أكثر فأكثر فتح الطعن في القرارات القابلة للانفصال عن العقد، ليس فقط للغير ولكن للطرفين، ويعتبر الآن عملاً قابلاً للانفصال (قراراً منفصلاً) كل قرار سابق على الإبرام النهائي للعقد.

بما في ذلك القرار الذي بمقتضاه تقرر الجهة الإدارية إبرام العقد أو إقراره أو رفض ذلك^(١).

ونشير إلى أن عدم جواز الطعن بدعوى الإلغاء في الأعمال ذات الطبيعة التعاقدية، لا يرجع — فقط — لأنها أعمال من جانبين، والطعن بالإلغاء لا يقام إلا ضد عمل من جانب واحد للجهة الإدارية، ولكن كذلك لأن وجود طعن مواد *parallele* أمام قاضي العقد يحول دون قبول طعن الإلغاء.

نخلص مما تقدم إلى أنه في مجال القرارات والإجراءات المرتبطة بعملية التعاقدات التي تبرمها الإدارة فإنه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من هذه القرارات والإجراءات، من حيث إمكان الطعن عليها استقلالاً.

١ أنظر: أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، جي بريبان وآخرين، ترجمة د. أحمد يسري، ص ٨٧ — مبدأ رقم (١٦).

١-القرارات الصادرة من الإدارة في مرحلة ما قبل إبرام العقد، كالقرار الصادر بالإذن بالتعاقد، أو بإرساء المزاد، أو بشطب أحد المقولين، أو بالحرمان من دخول المناقصة أو المزايدة، أو باستبعاد بعض العطاءات، أو العدول عن التعاقد.

٢-القرارات الصادرة من الإدارة في مرحلة إبرام العقد، كالقرار الصادر برفض إبرام العقد، أو باعتماد العقد ذاته أو عدم اعتماده فإن هذه القرارات والقرارات الواردة في البند (١) تعد من قبيل القرارات الإدارية المنفصلة التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء.

٣-أما النوع الثالث والمتعلق بالقرارات التي تصدرها الإدارة ضد العقد ذاته أو بنوده أو تنفيذه، فتدخل في اختصاص قاضي العقد بولاية القضاء الكامل، بحسبانها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى الدقيق، ومثالها، القرار بفسخ العقد، أو بتوقيع جزاء على المتعاقد مع الإدارة (غرامة تأخير — سحب العمل — مصادرة التأمين) أو إلغاء العقد نفسه، فهذه الأعمال لا تعد وأن تكون منبثقة عن رابطة عقدية، وتدخل في منطقة العقد، ومن ثم لا يرد عليها طلب الإلغاء، فهي منازعات حقوقية — على ما تقدم —.

ونشير إلي أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قد استقر على أنه أياً كان البطلان (الإلغاء) الذي لحق إجراءات التعاقد، فإنه إذا ما انعقد العقد مستوفياً أركانه، يكون ملزماً لطرفيه^(١).

١ جلسة ١٤/١٢/٢٠٠٥م ، ملف ٥٤ / ١ / ٤٢٥.

ثامناً: الوسائل غير القضائية في حسم منازعات العقود الإدارية^(١):
السؤال الذي يطرح على بساط البحث هو:
— هل يجوز لجهة الإدارة (المتعاقدة) اللجوء إلي وسائل بديلة (ودية) لحسم منازعات العقود الإدارية، بعيداً عن قضاء الدولة المختص؟
فهل يجوز لجهة الإدارة اللجوء إلي التحكيم — بدلاً عن القضاء — في حسم المنازعات حول العقود الإدارية التي تبرمها؟
— المنتبـع لأحكام القضاء وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وآراء الفقهاء، يجد أن ثمة اتجاهين متعارضين في مدي جواز لجوء الإدارة إلي التحكيم في منازعات العقود الإدارية. فبينما اتجهت بعض الأحكام والفتاوى إلي عدم جواز ذلك، وأيد بعض الفقه ذلك الاتجاه اتجهت أحكام وفتاوى أخرى إلي جواز لجوء الإدارة إلي التحكيم في تلك المنازعات وأبد بعض الفقه ذلك الاتجاه أيضاً.
ونحن — هنا — لسنا بصدد تتبع تلك الاتجاهات بالدراسة والتحليل، بعد ما حسم المشرع منذ عام ١٩٩٧م، ذلك الجدل.
— فنصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م (مضافة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧م) على جواز الاتفاق على التحكيم بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية، بموافقة الوزير المختص، أو من يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك.

١ نشير أننا لن نعرض لهذه الوسائل بدراسة تفصيلية، بل سوف نلقي الضوء على الأفكار العامة والخطوط الرئيسية لكل من هذه الوسائل.

— ثم تلي ذلك صدور القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م، في شأن المناقصات، والمزايدات وقطع باليقين جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ونص في م/٤٢ (المادة الأخيرة من هذا القانون على أنه: يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد)^(١).

— والمسلم به انه إذا تضمن العقد الذي تبرمه الإدارة شرط التحكيم، فإنه لا يجوز تصدي القضاء الإداري (إلغاء أو تعويضاً على ما قدمنا) بوقف تنفيذ وإلغاء أية قرارات إدارية بالعقد، إذ تختص هيئة التحكيم بالفصل في كافة المنازعات الناتجة عنه^(٢).

— وملاحظة أخرى: أن نظام التحكيم — كقاعدة — يقوم على مبدأ حرية الإرادة ، وأنه لا ينال من سيادة الدولة، إذ أن لجوء الدولة إلي التحكيم في عقودها الإدارية إنما يتم بمحض إرادتها وبموافقتها، طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة، وإيكال مهمة الفصل في المنازعات — المذكورة — لهيئة تحكيم يتفق عليها مع المتعاقد معها.

١ نشير إلي أنه على الرغم من عدم النص في م/ ٤٢ — المشار إليها — على عدم جواز التفويض في اختصاص الوزير المختص باللجوء إلي التحكيم، فإن الأحكام قد استقرت على عدم جواز ذلك. ومرد ذلك أن الوزير يمثل الدولة في وزارته، فضلاً عن اعتبارات الصالح العام.

٢ أ.ع، طعن رقم ٨٨٦ لسنة ٣٠ق، في ١٨/١/١٩٩٤م.

— القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، يوسع من الوسائل البديلة لحسم منازعات العقود الإدارية (الطرق الودية).

— فقد نص في م/٩١ منه على أنه: (يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلي القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد).

— كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلي القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلي التحكيم، وتتضمنه شروط العقد، ويتفق عليه الطرفان وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م.

— وبناء علي ما تقدم فقد حسم لجوء الجهة الإدارية إلي الوسائل الودية (الطرق البديلة للاختصاص القضائي) لحسم منازعات العقود الإدارية ومن ثم أصبح جائزاً اللجوء إلي تلك الوسائل وهي التوفيق أو الوساطة أو التحكيم لحسم منازعات العقود الإدارية بموافقة الوزير المختص، وعدم جواز التفويض في ذلك.

ونصت المادة (١٨٠) من اللائحة ، على أنه ، وبمراعاة أحكام المادة (٩١) من القانون، يجوز أن تتضمن شروط الطرح والعقد مراحل وآليات تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفيه، وفي هذه الحالة يتعين على

الجهة الإدارية، قبل مباشرة اجراءات فسخ العقد مع المتعاقد ، اتخاذ الإجراءات الآتية :

- ١- فحص شروط التعاقد بكل دقة، واتخاذ الحل المناسب للمشكلة .
- ٢- قيام إدارة التعاقدات اعداد تصور عن موضوع الخلاف ، وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى .
- ٣- تسوية الخلافات التى نشأت بالطرق الودية ، بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد ، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية ، فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها ، بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
- ٤- يتم توجيه الدعوة للمتعاقد لعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد ، أو ممثل الجهة الادارية بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يوماً ، من تاريخ ظهور الخلاف ، وذلك لمناقشته .
- ٥- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ، يتم اللجوء إلى القضاء ، أو التحكيم ، بحسب مانتص عليه شروط التعاقد.

— وفضلا عن الوسائل الثلاث هذه، فثمة وسيلة رابعة لحسم منازعات العقود الإدارية بديلا عن القضاء، تلك هي المتعلقة باختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر المنازعات — بما في ذلك منازعات العقود الإدارية — بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة

رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م وهو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات^(١).

وسوف نعرض لكل من هذه الوسائل (الطرق) الأربعة بإيجاز، على النحو الآتي:

١- التوفيق:

يعني تضمين العقد الإداري شرط التوفيق لتسوية ما قد يثور من منازعات بشأنه، ذلك الشرط الذي يلتزم المتعاقدان بمقتضاه بإحالة المنازعات المستقبلية التي تثار بشأن تفسير وتطبيق العقد إلي أشخاص يختارونهم للتوفيق بينهم في هذه المنازعات. فالتوفيق هو صورة من صور محاولة إنهاء النزاع صلحاً^(٢)، وأن رأي الموفق — غالباً — غير ملزم، ويتم اللجوء إلي التحكيم إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما ما انتهى إليه الموفق من توصيات ونشير علي ما تقدم، أنه يجوز أن يكون اللجوء إلي هذه الوسيلة قبل اللجوء إلي القضاء أو التحكيم، بشرطين: أولهما أن تتضمن شروط الطرح أو التعاقد جواز ذلك والثاني، موافقة السلطة المختصة.

١ في تفصيلات ذلك، راجع مؤلفنا بعنوان (الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات الإدارية) القاهرة سنة ١٩٩٣م ومؤلفنا: التحكيم في منازعات العقود الإدارية، القاهرة سنة ١٩٩٩م.

٢ يعرف الصلح وفقاً لأحكام القانون المدني، م/٥٤٩ — أنه عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه. وقد يكون الصلح من خلال وسيط من الغير، يعمل على الوصول إلي تسوية ودية بغرض التقريب بين وجهات النظر.

٢- الوساطة:

تعني الوساطة، العقد الذي يتفق الأطراف بموجبة على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح، لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد، بمعنى أن الوساطة — شأن التوفيق — تهدف إلى الوصول إلى الصلح بواسطة طرف ثالث، هو الوسيط.

فالوساطة، تتسم بالطبيعة الرضائية، تلجأ إليها الجهات المنازعة لحل الخلاف بعيداً عن القضاء، وتتمثل في شخص محايد ذي كفاءة وخبرة يطلق عليه اسم الوسيط يختاره طرفي العقد بإرادتهم، ويوظف الوسيط مهاراته لحل النزاعات، بإرادة الطرفين المتنازعين، حيث يسعى إلى إدارة التفاوض والوصول إلى حل يرضي الطرفين، ويوقف النزاع بينهما دون تدخل من القضاء.

بمعنى آخر: تعني الوساطة مسعاً طوعياً ونشاطاً متخصصاً حيث يتبع الوسيط نهجاً إحترافياً، ويوفر منطقة آمنة لأطراف النزاع، بالإضافة إلى أنه يفرز الثقة بنجاح ساعي حل النزاع، دون حاجة إلى تدخل من القضاء، أي أن مهمة الوسيط (أو الموفق) هي إيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة، برأي غير ملزم للأطراف على العكس من التحكيم.

— وتجدر الإشارة إلى أن الصلح جائز في مادة العقود الإدارية ،
وانه ليس به مساس بحق مالى للدولة ، أو بحقوق الخزانة ، طالما كان

مانزلت عنه الادارة جزء كان له مايقابله مما نزل عنه الطرف الآخر ،
ويترتب على الصلح حسم النزاع بين الطرفين ^(١).
والمسلم به، أنه لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وقضى بأن الاتفاقات الحاصلة على كيفية المحاسبة بشأن تنفيذ العقود
الادارية ، لاتعتبر كذلك ،إلا إذا كانت محسوسة بصفة نهائية ، وليست
محلاً للنزاع ، لايجوز التنازل عنها إلا طبقاً لأحكام القانون . أما إذا كان
الحق ذاته محلاً للنزاع وخشيت الجهة الادارية أن تخسر النزاع ، فلا
تثريب عليها إذا لجأت إلى الصلح ^(٢).

٣- التحكيم (أهميته ، والتمييز بينه وبين الوسائل الأخرى) :

— يعد التحكيم أهم الوسائل غير القضائية التي تلجأ إليها الدولة لحسم
منازعات العقود الإدارية بصفة عامة، وعقود التجارة والاستثمار الدولية،
وعقود الإنشاءات الدولية وعقود نقل التكنولوجيا، وعقود مقاولات
الإنشاءات الدولية خاصة، والتي زادت أهميتها في الوقت الحاضر.
— وترجع أهمية التحكيم — وبالتالي فوائده — إلى طابعه الرضائي،
وإلى كونه قضاء خاصاً ومتخصصاً، ويجري اختياره وتسيير إجراءاته
وفقاً لقواعد ارتضاها أطرافه مسبقاً فضلاً عن الفصل السريع في
المنازعات محل التحكيم، وما يتسم به من سرية تمكن أطرافه من الحفاظ
على أسرارهم التي تكون لهم مصلحة في عدم نشرها.

^١ ونشير إلى انه يجوز للمتصالحين أن يتقابلا الصلح صراحة أو ضمناً ، ويستخلص ذلك
التقابل إما صراحة أو ضمناً (من تصرفات المتصالحين التى تتم عن عدم اعتدادهما
بالصلح وتحلفهما من آثاره.

٢ حكم أ.ع ، الطعن رقم ٨٠٣ لسنة ١١ ق.ع ، فى ١٠/٢/١٩٦٨.

— كما يعمل التحكيم على الحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع الشركات، مما يرغب شركات أخرى في التعامل معها في المستقبل .
فالتحكيم يمنح طرفي النزاع الطمأنينة إلى عدالة حكم التحكيم نظراً لإشراكهم في اختيار أعضاء التحكيم. كما تتبدي أهمية التحكيم أيضاً في المحافظة على العلاقات الودية القائمة بين أطراف المنازعة، وأيضاً ترجع أهمية التحكيم إلى ما يتسم به من المرونة والحرية، وتجنب المخاطرة، وذلك كله فضلاً عن تخفيف العبء عن القضاء، وتوفير الوقت والسرعة في حسم النزاع، برأي ملزم لطرفيه.

— وثمة ملاحظة جوهرية، إنه وإن اتفق التحكيم مع كل من التوفيق والوساطة في كونها جميعاً وسائل ودية — غير قضائية يحسم منازعات العقود الإدارية، إلا أنه ترجع أهمية التحكيم إلى كونه ينهي النزاع بين طرفي العقد برأي ملزم (حكم التحكيم) على العكس من الوسائل الأخرى التي لا تتمتع بهذه الخصوصية، إذ يتوقف إنهاء النزاع بالتوفيق أو بالوساطة على قبول طرفي المنازعة ما ينتهي إليه الموفق أو الوسيط بالتراضي، فإن لم يقبل طرفي المنازعة الرأي (غير الملزم) الذي يخلص إليه الموفق أو الوسيط، كان لهما اللجوء إلى التحكيم.

— كما وأن التحكيم يمتاز على ما عداه من وسائل غير قضائية لحسم منازعات العقود الإدارية، في أنه الأكثر تنظيماً تشريعياً، والأكثر قبولاً في منازعات العقود الإدارية الدولية، والعقود التي تبرمها الإدارة بصفة عامة، خاصة العقود ذات الأهمية الخاصة.

— وقدّمنا أنه لا يجوز للجهة الإدارية اللجوء إلى أي من الوسائل الودية (غير القضائية) لحسم منازعاتها التي قد تتور بشأن العقود

الإدارية التي تبرمها، إلا إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد ذلك، وبموافقة الوزير المختص.

— قواعد وأحكام نظام التحكيم :

— ويسري على التحكيم — في هذه الحالة — القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م سابق الإشارة إليه.. وقد أبان قانون التحكيم (رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م) متى يكون التحكيم تجارياً، ومتى يكون دولياً (م/٢، م/٣).

وعرفت م/١٠ التحكيم، بأنه هو اتفاق الطرفين على اللجوء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية (أى أن التحكيم يأخذ أحد صورتين : شرط التحكيم ومشاركة التحكيم).

— ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين (م/١٠) من قانون التحكيم.

— وأنه يعتبر اتفاقاً على التحكيم، كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط التحكم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار الشرط جزءاً من العقد (م/١٠/٣).

— والتحكيم (كعقد رضائي) : تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة (م/١٥) وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً (م/١٥/٢).

— وأوضح قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م في الباب الرابع إجراءات التحكيم (م ٢٥ — ٣٨) كما نظم الباب الخامس من ذات القانون حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات (م/٣٩ — ٥١) فيما أبان الباب السادس عن حالات بطلان حكم التحكيم (المواد ٥٢ — ٥٤) . وأخيراً وفي الباب السابع من القانون — المشار إليه — نص القانون على حجية أحكام المحكمين وتنفيذها (م/٥٥—٥٨).

— وتجدر الإشارة إلي أنه إذا حصل الاتفاق في عقد على عرض جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذه أو تفسيره على محكمين (أو موفق أو وسيط) وأن هذا يشمل كل المنازعات التي بين المتعاقدين بشأن التنفيذ أو التفسير سواء وقت قيام العقد أو بعد انتهائه وأن الاتفاق على التحكيم (أو التوفيق أو الوساطة) لا ينزع الاختصاص من المحكمة، ولكنه يمنعها من سماع الدعوى ما دام شرط التحكيم (أو التوفيق أو الوساطة) قائماً . مما يعني عدم جواز رفع دعوى قضائية في وجود شرط التحكيم (أو التوفيق أو الوساطة).

ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً (م/١٢) ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر موقع من الطرفين أو إذا تضمنه ما تبادلته الطرفين من وسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة (مشارطة التحكيم).

— دور القضاء في منازعة مضمنة شرط التحكيم.

— لا تغل يد القضاء عن المنازعة المضمنة شرط التحكيم، إلا فيما يتعلق بالمنازعات الموضوعية التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بين طرفي

المنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية (م/١٠ من ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤م).

أما فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، فينעד الاختصاص بها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ما لم يكن التحكم تجارياً أو دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر (م/٩ من ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤م)^(١) ويحتل التحكيم موقعاً ممتازاً في العقود (الكبرى) التي تبرمها الدولة الآن.

وقد أبانت المحكمة الدستورية العليا عن المبادئ التي تحكم نظام التحكيم — في مصر — فيما يلي :-

١- للمشرع أن يورد في شأن كافة العقود — حتى ما يكون منها واقعاً في دائرة القانون الخاص — قيوداً يراعى على ضوءها حدود للنظام العام لايجوز اقتحامها.

١ تجدر الإشارة إلي قانون التحكيم، قد اعتمد واضعوه (المشرع) في إعداده بصفة رئيسية على نموذج اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي واليونسترال هي لجنة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لغرض العمل على تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجي لأحكام قانون التجارة الدولية. وقد أولت اليونسترال اهتماماً كبيراً بالتحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية، لأنه البديل الأكثر قبولا من تجارب الدول الصناعية الكبرى من القضاء الذي يخشون عدم حياده ثم قامت اليونسترال بعد ذلك بإعداد نموذج قانون اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي، حتى نفتدي به الدول الراغبة في وضع قوانين للتحكيم التجاري الدولي وتطويرها.

— وأن فكرة النظام العام ، هي أحد خطوط دفاع النظام القانوني عن نفسه ، أو الجماعة عن ذاتها من جموح الارادة الفردية (١).

٢— وأنه وفقاً لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا ، المشار إليه في المادة (٧٢) من هذا القانون ، ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً ، بطريق تحكيم تجرى في مصر وفقاً لأحكام القانون المصري . وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب القانون المصري ، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً (م/٨٧) — من ذات القانون — . (٢)

٣— أن الشريعة العامة التي تنظم التحكيم في مصر ، يعكسها قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

٤— وأن الأحكام التي أتى بها هذا القانون لاينافيها التنظيم القمارن ، ويظهر ذلك بوجه خاص من الرجوع إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي في ١٩٨٥/٧/٢١، والاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي

١ ، ٢— حكم المحكمة الدستورية العليا ، في القضية رقم ٢٥٣ لسنة ٢٤ ق.د، في ٢٠٠٧/٤/١٥ . وفي هذا الحكم قررت المحكمة سريان الأحكام المتعلقة بعقود نقل التكنولوجيا على كافة العقود ذات الشأن ، سواء كان النقل دولياً أو داخلياً ، دون أن يعول على جنسية أطراف العقد ، أو موطنهم ، وكذا بسط ولاية المحاكم المصرية على المنازعات الناشئة عن هذه العقود.

(٢١/٤/١٩٦١) ، واتفاقية نيويورك (١٠/٧/١٩٥٨) ، والاتفاقية المبرمة فيما بين الدول الأعضاء فى منظمة الدول الأمريكية (٣٠/١/١٩٧٥) ^(١) .
٥- التحكيم أصلاً مصدره الاتفاق ، واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فى الحقوق المتنازع عليها . وأن التحكيم نظام بديل عن القضاء فلا يجتمعان ^(٢) .

٦- وفيما يتعلق بالآثار التى يربتها التحكيم على الإتفاق ، قالت المحكمة : " أنه يترتب على إتفاق التحكيم نوعين من الآثار . آثار جانبية، قوامها أنفاذ هذا الاتفاق من خلال عرض المسائل التى يشتمل عليها على محكمين وتسهيل أدائهم لمهمتهم .

والامتناع عن عرقلتها. وآثار سلبية ، جوهرها أن اتفاق التحكيم يعزل جهة القضاء عن الفصل فى المسائل التى أحيلت إلى المحكمين ^(٣) .
تاسعاً: اختصاص الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بنظر منازعات العقود الإدارية، حدوده ومداه ^(٤) :

نتناول هنا أربعة أمور جوهرية هي:

- ١- مبادئ عامة في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- ٢- الطبيعة القانونية للرأي الملزم الصادر من الجمعية العمومية.

١ المحكمة الدستورية العليا ، القضية رقم ١٣ لسنة ١٥ ق.د ، فى ١٧/١٢/١٩٩٤ .

٢ المحكمة الدستورية العليا ، القضية رقم ٨٤ لسنة ١٩ ق.د ، فى ١٦/١١/١٩٩٩ م.

٣ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٨٤ لسنة ١٩ ق، سابق الإشارة إليه .

٤ راجع فى التفصيلات، مؤلفنا بعنوان: الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات الإدارية، سابق الإشارة إليه.

٣- تطبيقات لبعض فتاوى الجمعية العمومية في منازعات الجهات العامة في مادة العقود الإدارية.

٤- حدود حسم بعض منازعات العقود الإدارية من إدارات الفتوى.
قرر المشرع اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر المنازعات - بما في ذلك منازعات العقود الإدارية - بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م وهو اختصاص بديل عن استعمال الدعوى الإدارية كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات.
إذ تنص (م٦٦/د) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن:
(تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين).

١- مبادئ عامة في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:

والبين من الجهات التي عدتها الفقرة السابقة، أنها جميعاً من الأشخاص المعنوية العامة (وجميعها فروع للسلطة التنفيذية) ومؤدي ذلك أنه لو كان أحد طرفي النزاع شخص من أشخاص القانون الخاص، فإن

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لا تختص بنظرة، ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام^(١)، وعلى ذلك :

المبدأ الأول إذا هو: انحسار اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص.

المبدأ الثاني: صدور حكم من جهة غير مختصة ولائياً، لا يحجب اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولائياً بنظرة، وإنزال حكم القانون عليه.

فإذا قضي بعدم الاختصاص بنظر المنازعات ولائياً، نظراً لأن المنازعة بين جهتين من الجهات العامة مما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فإن هذا الحكم لا يحجب اختصاص الجهة المختصة ولائياً بنظرة وإنزال حكم القانون عليه^(٢).

المبدأ الثالث: عدم وجوب اللجوء إلي لجان فض المنازعات قبل العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع^(٣).

ومرد ذلك أن الجمعية العمومية بالرغم مما ناطه المشرع بها من سلطة إبداء الرأي الملزم طبقاً لنص المادة (٦٦/د) من قانون مجلس الدولة، إلا أنها وعلى ما جرى به إفتاؤها لا تستوي محكمة بالمعني الذي عداة المشرع في المادة (١١) من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠م.

١ فتوي رقم ١٠٩٠ في ١٢ / ١٠ / ١٩٩٨م ، ملف رقم ٢٣٢ / ٣٠١٠.

٢ فتوي رقم ١٢ في ٢٣ / ١ / ٢٠٠٠م ، جلسة ٢٢ / ٩ / ١٩٩٩م ، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ٢٩٧٧.

٣ فتوى رقم ٢٦٥ في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م، ملف رقم ٣٢ / ٥ / ٣٢٥٧.

المبدأ الرابع: عدم جواز إعادة نظر نزاع سبق حسمه برأي ملزم^(١).

ذلك إن المشرع وقد أناط بالجمعية العمومية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات بين فروع السلطة التنفيذية، على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لا وجه النزاع وقطعاً له، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم، ومن ثم فإن الرأي الصادر من الجمعية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لا وجه للنزاع، يستنفذ الجمعية العمومية ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى.

المبدأ الخامس : الدفع بالتقادم، لا يجوز إثارته فيما بين الجهات الإدارية، ومن ثم فقد جرى رأي الجمعية العمومية على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها البعض باعتبار أنها جهات يضمها جميعاً الشخص المعنوي الواحد للدولة وباعتبار وحدة الميزانية العامة^(٢).

— وكذلك لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولاً على حكم المادة (٥١٧) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات^(٣).

١ فتوى رقم ١١٣٥ في ٢٥ / ١ / ١٩٩٨م، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ١٥٣٨.

٢ فتوى رقم ٢٥٨ في ٨ / ٤ / ٢٠٠٢م، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ٣١٩١.

٣ فتوى رقم ٢٦٥ في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٢م، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ٣٢٥٧.

المبدأ السادس: عبء الإثبات في المنازعات بين الجهات الإدارية يقع على عاتق الجهة المدعية، إعمالاً للأصل المقرر بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية^(١).

٢- الطبيعة القانونية للرأي الملزم للجانبين:

جرى إفتاء الجمعية العمومية على أن نظرها في طلبات إبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة المحددة في (م ٦٦ / د) من قانون مجلس الدولة، من أنها وإن نظرت هذا النوع من الطلبات باعتبارها تفصل في منازعة بين جهتين عامتين، إلا أن فصلها في المنازعة يكون بإبداء الرأي الملزم للجانبين، دون أن يعتبر ذلك حكماً، تجرى به إجراءات القضاء بالأحكام، أو تجري به إجراءات تنفيذ الأحكام، ومن توابع ذلك أن نظرها للنزاع لا تتعقد به خصومة بين طرفين مما يترتب حقوقاً لكل منهما، من حيث الإجراءات واجبة الإتيان، وإن الرأي الملزم الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية (إنما يكشف عن تطبيق صحيح القانون) على الوقائع التي تقدم إليها من الجهة الإدارية، فإذا ما تبين عدم صحة هذه الوقائع أو بعضها، تعين تصويب الوضع وفقاً لصحيح تلك الوقائع^(٢).

هذا وقد ذهبت محكمة النقض، إلى أن القضاء العادي، وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه

١ فتوى رقم ٦٨٩ في ٤ / ١١ / ١٩٩٩م، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ٣٠٨٢.

٢ فتوى رقم ٣٠٩ في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٠م، جلسة ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠م، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ٢٩٨١.

الولاية، ولا يخالف أحكام الدستور، يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

— لما كان ذلك وكان نص م ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م تنظيم مجلس الدولة، يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، وذلك أن هذه الجمعية ليست مما يتألف منه **القسم القضائي** بمجلس الدولة، ولا تتبع عند طرح المنازعات عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات، أو لأيه قواعد جزائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي، وإنما تختص فقط بجهة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً، على ما أفصح عنه صدر النص سالف الذكر، ولا يؤثر في ذلك ما أضافه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص م/٦٦ المشار إليه إلي مرتبة الأحكام، فلا يجوز الرأي الذي تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي.

لما كان ذلك وكان المشرع لم يضع قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلي جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري، وكانت المنازعة المطروحة حق مما تختص به جهة القضاء العادي، فإن الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، يكون قد انتهى إلي نتيجة صحيحة^(١).

١ الطعن رقم ١١٠٧ لسنة ٥٠ ق في ٢٠ / ٣ / ١٩٨٤م.

— إذا ما يصدر من رأي (مسبب) وملزم في المنازعات التي تختص بنظرها الجمعية العمومية وفقاً لنص م٦٦/د من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢م بتنظيم مجلس الدولة، لا يعدو أن يكون إفتاء في نزاع بين الجهات العامة، لا يرقى إلى مرتبة الأحكام القضائية، بالمعنى الفني الدقيق، ومن ثم لا يعد بديلاً عن التقاضي بين هذه الجهات، ولو نظرياً. نخلص من ذلك ، إلى أن إختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة (م/٦٦) ، إختصاص مانع لاتشاركتها فيه أى جهة قضائية أخرى ، إذ هو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم ، اقتضته اعتبارات التنظيم الإداري للدولة والمصلحة العامة ، للبعد بهذه المنازعات (منازعات الجهات الإدارية) عن اختصاص القضاء ، فضلاً عن الرغبة في عدم شغل القضاء بمنازعات تنشأ بين ممثلين مختلفين لشخص واحد، هو الدولة.

ومن ثم لايجوز لأية جهة التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية ، وتستنفذ الجهة الإدارية ولايتها بالالتزام بالرأى الملزم الذى تصدره. ولايجوز معاودة طرح النزاع مرة أخرى ، حتى لايتجدد النزاع إلى مالا نهاية. وأن اختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة ، متعلق بالنظام العام، غير جائز الاتفاق على مخالفته ، كما ان حسم المنازعات سريعاً ، يأتى عملاً بمبدأ حسن سير المرافق العامة.

٣-تطبيقات لبعض فتاوى الجمعية العمومية في منازعات الجهات العامة في مادة العقود الإدارية.

— عدم توافر المصرف المالي (الاعتماد المالي) لا يصلح سنداً للتعهد عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد^(١).

— النسب المحددة بالقانون لغرامات التأخير ليست من النظام العام^(٢).
إن تحديد المشرع نسب غرامات التأخير التي يجوز توقيعها على المتعاقد عند الإخلال بالتزامه بحددين أدنى وأقصى، بيد أن هذا التحديد ليس من النظام العام، فإذا تضمن العقد المبرم مع جهة الإدارة نسباً أخرى لهذه الغرامة، فلا مناص من الالتزام بأحكامه، إعلاء لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

— عقد المقاوله قد انعقد بين الطرفين دون أن يؤثر في ذلك عدم تحرير العقد، حيث لم تشترط شكلية معينة لانعقاد العقد كما أن عدم اتفاق الطرفين على قيمة المقاوله لا يؤثر في سلامة العقد.. لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية^(٣).

— وفي الحق في فسخ العقد والأثر المترتب على الفسخ:

استظهرت الجمعية العمومية أن فسخ العقد قد يقع بمقتضي الاتفاق حين يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام، وإذا اتفقا على أن الفسخ يقع دون حاجة إلي حكم أو إنذار فيقع فسخ العقد من تلقاء نفسه عند حلول ميعاد الوفاء إن لم يقوم المدين به، فلا تكون هناك حاجة إلي الاغدار ولا إلي رفع الدعوى للحصول على حكم بفسخ العقد. وأياً كان المدى الذي يصل إليه الطرفان

١ فتوى رقم ١٢٦٧ في ٢١ / ٢ / ١٩٩٨ م، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ٣٠١٣ .

٢ فتوى رقم ٨٠٠ في ١٣ / ١٢ / ١٩٩٩ م، ملف رقم ٥٤ / ١ / ٣٥٨ .

٣ فتوى رقم ٢٥٥ في ١٤ / ٤ / ١٩٩٩ م، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ٣٠٠١ .

في اشتراط وقوع الفسخ من تلقاء نفسه عند عدم التنفيذ، فإن الدائن يظل دائماً له الخيار بين طلب التنفيذ وطلب الفسخ فالفسخ مقرر لمصلحة الدائن، ويترتب على الفسخ أن يعود الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض^(١) (وتلك هي ذات أحكام القانون المدني في فسخ العقد).

— في الاتفاق المباشر بين الجهات العامة:

استقر إفتاء الجمعية العمومية على عدم تقيد الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م بالحدود الواردة بالمادة (٧) من هذا القانون في التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر^(٢).

— عقد إداري — تنفيذه وجوب أعمال التحفظات:

يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه (تعد كراسة الشروط هي الدستور الحاكم للتعاقد، يتعين الالتزام بما ورد فيها). وبناء على ذلك فإن قبول الجهة الإدارية للعطاء وبما ورد فيه من تحفظات من بينها اشتراط مقدمة بأحقيته في أي زيادة تطراً على الأسعار بموجب قرارات وزارية وجوب أعمال هذا الشرط والنزول على مقتضاه^(٣).

عقد إداري — تنفيذه — مبدأ حسن النية:

إن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وبطريقة تتفق ومقتضيات حسن النية وهذا مبدأ عام في

١ فتوى رقم ٤٠٦ في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠١م، ملف رقم ٣٢ / ٢ / ٣١١٧ .

٢ فتوى رقم ٥٢٨ في ٩ / ٦ / ٢٠٠٢م ، ملف رقم ٥٤ / ١ / ٣٩١ .

٣ فتوى رقم ٤٩ في ٢١ / ٦ / ١٩٩٩م، ملف رقم ٧٨ / ٢ / ٤٣ .

تنفيذ العقود أيا كانت طبيعتها ، بل وتنص تشريعات المناقصات والمزايدات عليه صراحة.

الاتفاق على صرف أتعاب المكتب الاستشاري المتعاقد معه على دفعات، وجوب دفع المستحقات عن كل دفعة، ولو لم يتم إبرام العقد بسبب إلغاء المنحة، لعدم تمكنه من التعاقد مع إحدى الشركات على نحو ما تقتضي به قواعد البروتوكول الخاص بالمنحة في الموعد المحدد، ولم يكن ذلك راجعاً لخطأ المكتب الاستشاري أو بسببه^(١).

— في شروط الإعفاء من غرامة التأخير — القوة القاهرة:
مفهومها:

إذا تبين من واقع الحال أن التأخير في تنفيذ العقد كان مرده حادثاً فجائياً أو أسباب قهرية، كان من أثرها الإعفاء من تنفيذ الالتزام بل وقف تنفيذه، حتى يزول سبب الحادث فيبقى الالتزام موقوفاً على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث وينحسر في هذه الحالة عن مدة التوقف توقيع غرامة التأخير.

يشترط في الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أن يكون غير متوقع، لا يستطيع دفعه ، وأن يكون من شأنه جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بمعنى أن تكون الاستحالة مطلقة فلا تكون بالنسبة للمدين فحسب، بل تكون بالنسبة لأي شخص يكون في وقف المدين.

وإذا تخلف أحد تلك الشروط، تخلف مناط إعفاء المدين من توقيع غرامة التأخير.

١ فتوى رقم ٥٠٢ في ٤ / ٧ / ١٩٩٩م، ملف رقم ٥٤ / ١ / ٣٤٥.

— في إسناد أعمال مستجدة بعقود المقاولات القائمة بأسلوب الاتفاق المباشر.. شروط ذلك : شرطان:

المبدأ: وجوب تقيد الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م، في إسنادها لبنود الأعمال المستجدة بعقود المقاولات القائمة ولذات المقاول المسند إليه العمل بضوابط وشروط الاتفاق المباشر (الأمر المباشر)، المنصوص عليها في م/٧ من القانون المشار إليه، اللجوء إلي ذلك يقتضي وجود ضرورة فنية، وبشرط مناسبة الأسعار بسعر السوق إعمالاً لنص م/٧٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون^(١).

— الخطأ المادي مستوجب للتصحيح حتما:

إدعاء حدوث خطأ مادي في الأسعار، إلزام الشركتين المتعاقدين على تنفيذ العقد.

وأنه انطلاقاً من اعتبارات حسن النية في تنفيذ العقود وكل الاعتبارات التي تحكم تنفيذ العقد ونزولاً على موجبات حسن النية في تنفيذ التعاقدات، تهيأ وضع الغلط المادي الذي قد يشوب التعاقد، دونا عن جملة الأغلاط التي تعترى التعاقدات جميعاً، غير مؤثر في صحة العقد مستوجباً للتصحيح حتماً^(٢).

١ فتوى رقم ٩٠٢ في ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٢م ، ملف رقم ٧٨ / ٣ / ٦٢.

٢ فتوى رقم ٩٦٣ في ١٩ / ١١ / ٢٠٠٢م ، ملف رقم ٧٨ / ٢ / ٥٨.

— إعمال شرط قيمة فروق الأسعار المترتبة على زيادة الأسعار بموجب قرارات وزارية، شرطه، ثبوت توريد المواد لموقع العمل في تاريخ لاحق على زيادة الأسعار^(١).

تلك بعض من فتاوى الجمعية العمومية لتسمي الفتوى والتشريع في مادة العقود الإدارية يتضح منها دور الجمعية العمومية في تسوية بعض تلك المنازعات ودياً، عن غير طريق القضاء.

٤- تسوية المنازعات (التعاقدية) عن طريق إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة:

أ- في شطب اسم المتعاقد وفقاً للمادة (٢٤):

— تقضي المادة (٢٤) من قانون المزايدات والمناقصات والمزايدات بفسخ العقد تلقائياً في حالتي: استعمال المتعاقد بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد، أو إذا أفلس المتعاقد أو أعسر، (ويعد ذلك مبدأ عاماً في كافة العقود).

— وذات النص في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، م/٥٠ — وسنوضح ذلك عند تناول موضوع " انتهاء العقد".

وتنص المادة (١٣٥) من لائحة المناقصات والمزايدات على أن: تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية — بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة — بشطب أو إعادة قيد أسماء المتعاقدين وتتولي الهيئة نشر هذه القرارات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتجدر الإشارة إلى أن قرار

١ فتوى رقم ٣٣٩ في ١١ / ٥ / ١٩٩٩م، ملف رقم ٧٨ / ٢ / ٤٢.

شطب اسم المتعاقد (وجوبياً) في الحالتين المشار إليهما، هو من القرارات الإدارية المنفصلة، التي تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، على ما قدمنا — ولا يعد من قبيل القرارات التي تصدرها الإدارة تنفيذاً للعقد الإداري، واستناداً إلى نص من نصوصه والتي تنظمها محاكم مجلس الدولة في إطار ولايتها الكاملة الفصل في منازعات العقود الإدارية.

— **ويعد قرار شطب اسم المتعاقد من القرارات الإدارية المستمرة،** بحيث يتمتع عليه الدخول في المناقصات الحكومية في المستقبل ما دام قرار الشطب قائماً وبالتالي منتجا لآثاره.

— **جواز سحب قرار شطب اسم المتعاقد إذا انتفى السبب الذي ترتب** عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات مواعيد السحب أو الطعن بالإلغاء، وذلك بالنظر إلى الآثار المستمرة لقرار الشطب (حيث يظل القرار المستمر محلاً للطعن بالإلغاء ومن ثم جواز السحب للقرار في أي وقت ما ظل قائماً ومنتجاً لآثاره).

وعلى ذلك يجب على الجهة الإدارية نشر قرار الشطب بعد الرجوع إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة^(١).

والمسلم به أنه يجب أن يثبت الغش أو التدليس عمداً، وذلك باستعمال المتعاقد مع الإدارة طرقاً احتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع، يجعل جهة الإدارة تصدر قرارها بالتعامل معه، وليس بالضرورة أن تكون هذه الطرق الاحتيالية طرقاً اعتيادية، تتمثل في سلوك إيجابي من التعاقد، بل قد يكون عملاً سلبياً محضاً في صورة

١ فتوى رقم ٢٠ في ١٤ / ١ / ١٩٩٩م، ملف رقم ٥٨ / ١ / ٨٧.

إخفاء التعاقد عمداً بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها الإدارة، ويمتنع عليها علمها إلا عن طريقه رغم علمه بأهمية هذه المعلومات، وأنها لو كانت تحت بصرها لما تعاقدت معه، كأن يخفي المتعاقد مع الإدارة عن الإدارة عمداً صفة جوهرية في محل عقد التوريد، وكانت محل تقدير عند الترسية عليها وصدور أمر التوريد لها.

— في الإعفاء من الغرامة المقررة قانوناً عن مدة التأخير في تنفيذ العقد في الميعاد المحدد له.

— في هذه الحالة يعفى المتعاقد مع الإدارة من الغرامة بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة (م/٢٣/١ — ق ٨٩ لسنة ١٩٩٨م).
— وللسلطة المختصة — عدا هذه الحالة — بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر (م/٢٣/٢).

— ولا يخل ذلك بحق الإدارة في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير (م/٢٣/٣).
— التزام جهة الإدارة بعرض مشروعات عقودها على جهة الفتوى المختصة قبل إبرامها (م/٥٨/٥٧ لسنة ١٩٧٢م) ، بل ويعد ذلك مبدأ عاماً في كافة عقود الإدارة ، وقد نص عليه — أيضاً — في م/٩٠ من قانون تعاقدات الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ (الجديد) ، الذي ألغى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات.
— والجدير بالذكر أن المشرع لم يفرض ذلك عبثاً، وإنما أراد به أن يجنب الجهة الإدارية مواطن الخطأ، وأن يكفل لهما من أسباب السلامة في إبرام تلك العقود ما تتحقق به المصلحة العامة .

إذا أبرمت الجهة الإدارية عقداً إدارياً وقامت بتوقيعه قبل طلب مراجعته لضرورة ملحة ألجأتها إلى ذلك، ونصت في العقد على قبولها والتعاقد معها على ما عساه أن تدخله جهة الفتوى من تعديلات على العقد عند مراجعته، فإنه يجوز لجهة الفتوى المنوط بها مراجعة العقد — وتبعا لتقديرها — السير في مراجعة العقد رغم توقيعه، مراعاة لهذه الضرورة وفي حدودها^(١).

ونشير إلى أن مراجعة إدارة الفتوى المختصة أو اللجنة المختصة بمجلس الدولة لا تقف عند حدود بنود مشروع العقد، وإنما لتشمل الإجراءات التي سبقتها، وجميع ما يعتبر جزءاً منه للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، ومدى تأثيرها على صحة العقد، إن كان لذلك وجه، بحسبان أن عقود الإدارة (إدارية كانت أو مدنية) تخضع في إبرامها لضوابط وقواعد تحدد من يملكون إبرامها وطرق وإجراءات ذلك.

وغني عن البيان أن هذه المراجعة لا تضيي على إجراءات وبنود العقد الشرعية والصحة إذا كانت قد فقدتها، ولا تطهره من المخالفات التي شابت إبرامه أو بنوده أو تجبرها، وإنما تكشف عنها، وتضعها تحت بصر الجهة الإدارية، وبما يستوجبه ذلك منها من إعادة النظر في العقد، بالتدخل منه كله أو بعضه على ضوء ما أسفرت عنه هذه المراجعة.

— في إفتاء للجمعية العمومية لتسمي الفتوى والتشريع في ٢٠٠١/٥/٧م أجازت مراجعة نموذج موحد لمشروع عقد تطبقه الجهة الإدارية في الحالات المماثلة، ما دامت متطابقة في وقائعها وشروطها بحيث لا يصيبها تعديل أو تغيير في حالة أو أخرى دون مراجعة مستقلة،

١ فتوى رقم ١٤٦ في ١٥ / ٢ / ١٩٩٨م ملف رقم ٥٤ / ١ / ٣٤٤.

ومع ضرورة إتباع سائر الإجراءات المقررة، وبما يحقق الغاية المنشودة^(١).

— تلك بايجاز المبادئ التي تحكم اختصاص كل من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، وإدارة الفتوى المختصة فى مادة عقود الإدارة (بصفة عامة) والعقود الإدارية بصفة خاصة ، أوضحنا فيها أهم المبادئ فى الموضوع — بايجاز مناسب .

— ونشير إلى أن مخالفة الجهة الإدارية بعرض مشروعات العقود على إدارة الفتوى المختصة ، لاينال من صحة العقد ، وإنما يستتبع المسؤولية — بكافة صورها — على المخالف ، وسوف نوضح ذلك تفصيلاً — بعد قليل .

عاشراً: النظام القانوني للعقود الإدارية:

قدمنا أن القانون الذي يحكم تعاقدات الجهات العامة، هو القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، وقد نص هذا القانون فى المادة الثانية من مواد الإصدار، على إلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨م وقد حسم القانون الجديد (١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) مصير المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدوره، فنص فى الفقرة الثانية للمادة المشار إليها على أنه: (واستثناء من حكم الفقرة السابقة تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون نص فى م/٥ من هذا القانون على أن يعمل به اعتباراً من مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره (في ٣/١٠/٢٠١٨م).

١ فتوى رقم ٢٤٧، ملف رقم ٥٤ / ١ / ٣٧٦.

ولا يعدو ما قرره القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م من استمرار المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدوره، محكومة بالقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨م، لا يعدو ذلك سوي ترديداً للمبادئ القضائية المستقرة في نفاذ العقود بصفة عامة، استثناء من الأصل العام.

فتظل المراكز العقدية محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، استثناء من الأصل في سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه، حتى ولو كان مترتباً على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون السابق، بما من شأنه أن يؤدي إلي وحدة القانون المطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة، وتقادياً لتعدد أو ازدواج الأنظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة.

واستثناء من هذا الأصل، تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله ، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم، محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية، وذلك باعتبار أن المراكز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد آثارها لمبدأ سلطان الإرادة، فيظل القانون القديم (النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله ووضع أحكامه في اعتبارهما عند إبرام عقدهما) هو الواجب الأعمال احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن

ويسري هذا الاستثناء على العقود الإدارية شأنه في ذلك شأن سائر العقود^(١).

وعلى ذلك فالمبدأ هو: خضوع جهة الإدارة للضوابط والأحكام الواردة بالقانون الذي أبرم العقد في ظله.

فمثلاً، إذا تضمنت نصوص العقد نصاً صريحاً يحدد نسبة معينة كحد أقصى للغرامات التي توقع على الطرف الآخر، تعين أعمال هذا النص تطبيقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، حتى ولو جاء القانون الجديد بنص يحظر ذلك.

إستحداثات جديدة أخرى:

ثمة استحداثات جاء بها القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م وسوف نعرض لها بالدراسة تفصيلاً في موقعها من هذه الدراسة، ومنها:

فضلاً عن توسع المشرع في خضوع جهات إدارية عديدة، وخاصة الصناديق الخاصة لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م يلاحظ أيضاً توسع المشرع في طرق التعاقد فأضاف إلى طرق التعاقد المنصوص عليها في القانون السابق رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م (وهي المناقصات العامة — المزايدات العامة — المناقصة المحدودة — المناقصة المحلية — الممارسة العامة — الممارسة المحدودة — الاتفاق المباشر) طرق أخرى هي: المناقصة ذات المرحلتين — المزايدة المحدودة — المزايدة المحلية — المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة.. (م/٧) من القانون.

١ راجع على سبيل المثال، فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع رقم ٧٠ في ١٩٩٩/١/٢٨م، ملف رقم ٥٤ / ٣٤٥/١ والفتوى رقم ٤٩ في ٢٠٠٢/١/٢٢م ، ملف رقم ٤٤٠/٢/٤٧.

— كما وأجاز القانون الجديد تسوية منازعات العقود الإدارية بالطرق الودية عند طريق التوفيق أو الوساطة، فضلا عن التحكيم — على ما قدمنا قبلا — (م/٩١).

وأجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م (م/٧٨) للجهات المخاطبة بأحكامه، فضلا عن التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذا القانون. وكذا جواز إنابة بعضها البعض في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد.

وحظر القانون — كما القانون السابق — التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها (م/٧٨).

— وقرر القانون سريان أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة كما أجاز القانون لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة إلي أي من وحداتها التابعة (الفقرة الأخيرة من المادة (٧٨) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م).

وفي مجال التعاقد على الدراسات الاستشارية، أوجب القانون الجديد أن يكون التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين، أو المناقصة المحلية، ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط (م/٧٣).

وأجاز القانون بالنسبة للعمليات ذات الطبيعة الروتينية أو البسيطة أو النمطية، أو التي لها أطر فنية ثابتة، التعاقد عليها بطريق المناقصة

العامة أو المحلية أو الاتفاق المباشر، إذا قدرت الجهة الإدارية أن أيا من هذه الطرق هو الأنسب بحسب طبيعة العملية.

وأجاز القانون للجهة الإدارية التعاقد من خلال مناقصة محدودة، أو مناقصة محلية، أو اتفاق مباشر مع أحد الاستشاريين بذاته إذا قررت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلي على خبراته ومؤهلاته.

ويصدر بإتباع أي من هذه الطرق قرار سبب من السلطة المختصة وفقا لظروف وطبيعة التعاقد وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة.

ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح^(١).

١ تجدر الإشارة إلى أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، قد عرف الاستشارات الاستشارية، بأنها ما يغلب عليه الطابع الفكري أو الإرشادي، ومن ذلك الدراسات الهندسية، أو الاقتصادية، أو المالية، أو الإدارية، أو القانونية، بما في ذلك مهام الإعداد أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام (م/١).

كما عرفت التأهيل المسبق، بأنه إجراء تتخذه الجهة الإدارية، وتعلن عنه للتأكد من توافر القدرات الفنية، والإمكانات المالية والإدارية والبشرية وغيرها لدى الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين، للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة، قبل دعوتهم لتقديم العطاءات، وذلك وفقا لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل (م/١).

ونشير أن الخدمة الاستشارية، هي علاقة بين طرفين، الطرف الأساسي في العقد هو الخبير أو المستشار، سواء كان شخص طبيعياً أم معنوياً، وسواء كان يتخذ شكل المكاتب الاستشارية الخاصة أو المحلية أو العالمية، وهو في غالب الأحوال يكون محترفاً ويتمتع بالمقدرة العلمية والعملية والفنية، ولديه القدرة على عرض أفكاره بطريقة واضحة وبمرونة في التحليل والتقييم. =

— وتلك استحداثات (جديدة) ، جاء بها قانون تعاقدات الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وسوف نعرض تفصيلاً لكل منها في موضعه من هذه الدراسة.

= وتلجأ الدولة (الجهات الإدارية) في عقود الاستشارات عموماً نظراً للمهارات الفريدة لدى الخبير أو المستشار، والتي لا توجد لدى الجهة الإدارية، أو بغرض تدعيم الكوادر الاستشارية الموجودة لديه، أو حل المشكلات المختلفة، أو استحداث طرق عمل أو طرق إيصالات جديدة، أو القيام بإجراءات تسمح بتحسين الأداء.

الباب الأول

إبرام العقد الإداري

أضحى القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، هو القانون العام في كل مسائل العقود الإدارية.

ولما كان هذا القانون قد جاء بأحكام مغايرة (عديدة) عما كان يتضمنها القانون السابق رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م في شأن المناقصات والمزايدات، فإنه يتعين الوقوف على الاستحداثات التي جاء بها القانون الجديد ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م قبل تناول موضوع إبرام العقد الإداري.

كما ويجب — أيضا — تناول القيود التي ترد على حرية الإدارة وهي بصدد إبرام عقودها، وذلك قبل تبيان طرق التعاقد وأخيرا نستعرض إجراءات التعاقد.

وعلى ذلك تتحدد أبعاد موضوع (إبرام العقد الإداري) وتتعين حدوده فيما يلي: ونتناولها في أربعة فصول:

نتناول في الفصل الأول: الجديد في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م.

وفي الفصل الثاني: القيود التي ترد على حرية الإدارة وهي بصدد إبرام عقودها.

وفي الفصل الثالث: نستعرض طرق التعاقد.

وأخيراً وفي الفصل الرابع: نتناول إجراءات التعاقد.

الفصل الأول

الجديد في أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م

بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

١- أهداف القانون:

قدمنا أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، يمثل حلقة في سلسلة التشريعات والتعديلات الاقتصادية المكملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف بشكل عام إلى تبسيط الإجراءات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي في مصر، سواء الخاص أو العام أو التشاركي، وذلك للحد من الفساد المرتبط بتعدد الأطر التنظيمية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار لدفع النمو والتشغيل، ومن أجل تحقيق التقدم المنشود في إصلاح بنية الأعمال في مصر.

والمسلم به أن هذا القانون قد أدخل العديد من التعديلات الجوهرية على سابقة (القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م) تستهدف تطوير عملية التعاقد بآلياتها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط وتحديث بعض الإجراءات المنصوص عليها، أو إحكام السيطرة (سيطرة القانون) على بعض وحدات الجهاز الإداري، أو إعطاء أفضلية في تعاقدات الدولة لأنواع معينة من الشركاء، بغرض تحفيزها على النمو والإنتاج.

لذلك نجد ولأول مرة في التشريعات، أن يفرد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م مادة مستقلة يحدد فيها الأهداف التي يسعى إلى تطبيقها، إذ تنص المادة (٢) منه على: يهدف تطبيق أحكام القانون إلى:

١- تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ

العقود.

- ٢- تحقيق كفاءة وفاعلية الاتفاق العام.
- ٣- تعزيز مبادئ الحركة وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
- ٤- تطبيق أساليب الإدارة الحديثة والانتقال مرحليا إلي استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات.
- ٥- تطوير طرق الشراء والبيع، وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية.
- ٦- توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفي ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.
- ٧- تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبني الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها وكذلك تبني سياسات التعاقد المستدام.
- ٨- تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.
- وأكثر من ذلك فقد نص في م/٨ على أن: تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.
- والبيان أن هذه المواد لا تتضمن أحكاماً موضوعية (ذات صفة تشريعية) ومن ثم فكان محلها المذكرة الإيضاحية للقانون ونرى أنها مواد زائدة، لا مبرر لها ضمن نصوص القانون.

٢-توسيع دائرة اختصاص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م (م/١ من مواد الإصدار):

— في خطوة إيجابية نحو فرض المزيد من السيطرة والرقابة على الصناديق الخاصة في الوحدات الإدارية للدولة، وذلك من خلال إخضاع اتفاقاتها وتعاقدها المختلفة لقانون التعاقدات العامة، وقد تكون هذه الخطوة مقدمة نحو الإلغاء التدريجي للصناديق الخاصة، ودمج مخصصاتها وعائداتها في الموازنة العامة للدولة، وهو إجراء ضروري للحد من الفساد العام المرتبط بغياب آليات الرقابة على الأجهزة والإدارات الحكومية المختلفة.

وجاء نص المادة (١) من مواد إصدار هذا القانون على أن: (يعمل بأحكام القانون المرافق (رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م) في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وتسرى أحكامه على الجهات التي تضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها، والتي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية لأعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين).

— بل وقد أخضع القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ — المشار إليه — الهيئة العربية للتصنيع ، والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، والمخابرات العامة لبعض أحكامه ، من جواز التعاقد مع تلك الجهات بطريق الاتفاق المباشر، بموافقة السلطة المختصة يطل منها (م/٧٨ من القانون).

— ويظهر من ذلك النص المادة (١) ، مدي التوسع في الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، خاصة إذا علمنا أن القانون السابق (رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م) كان ينص في م/١ (من مواد الإصدار) على سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة — من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة — وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية. وجاء القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ليمد أحكامه، على تلك الجهات وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، وبمراعاة الاستثناء الوارد بالمادة.

— وتحقيقا للأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها على نحو ما ورد بالمادة (٢) سالفه البيان، نص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، على أن لا تخل أحكامه بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠م، وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة.

كما لا تخل أحكام هذا القانون بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥م في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

كما ولا تخل أحكام هذا القانون بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م.

٣- في وجوب إنشاء إدارة للتعاقدات، بالجهات الإدارية أيا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي (م/٣).

— وتختص تلك الإدارة، بتخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها.

— ومتابعة تنفيذ العقود التي يتم إبرامها، وتلقي وإرسال الإخطارات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وما تتضمنه العقود المبرمة.

— وكذلك التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، وإعداد وتقديم جميع البيانات والتقارير المطلوبة في شأن التعاقدات العمومية والقيام بجميع المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

— وقد اشترط القانون لشغل وظائف التعاقدات بالجهات الخاضعة لأحكامه أو الاستمرار في شغلها، اجتياز التدريب اللازم لذلك (م/٨٨).

وقد خطرت اللائحة التنفيذية للقانون، على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، النشر على بوابة التعاقدات العامة ، والإعلان ، أو توجيه الدعوات ، بحسب الأحوال، لأى عملية للتعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات ، أو التعاقد على مقاولات الأعمال ، أو تلقي الخدمات ، أو الأعمال الفنية ، أو الدراسات الإستشارية ، مالم يكن لها إعتداد مالى (م/١٥ من اللائحة).

وأجازت اللائحة للجهة الإدارية فى الحالات الطارئة ، أو العاجلة ، أو التكاليفات التى تقتضيها المصلحة العامة ، أن تجرى التعاقدات ذات

الصلة ، بالتنسيق أولاً مع وزارة المالية أو التخطيط ، بحسب الأحوال ،
والتأكد من توافر التمويل اللازم (م ١٥/٢ لائحة).

— **وتأكيداً لمبدأ المساءلة**، نص القانون (م/٨٩) على أنه: مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية، **يؤخذ تأديبياً كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالتعاقدات، والتي يصدر بها قرار من وزير المالية.**

وقد نصت المادة (١٧٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ، على انه يتعين على كافة المتعاملين بالقانون وهذه اللائحة ، الالتزام بأحكامها، وغيرها من القوانين واللوائح ، والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات ، أو نشرات ، أو كتب دورية في هذا الشأن ، ومدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالدولة ، والعاملين بالتعاقدات العامة ، ويجازى تأديبياً كل من يخالفهم ، ودون الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضد المخالفين ، عند الاقتضاء.

٤- **وفي إطار مكافحة الفساد ، ألزم القانون الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأن تمسك سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أي جهة من الجهات الإدارية.. سواء كان المنع ينص في القانون أو بموجب قرارات إدارية، أو لمن صدر ضده حكم نهائي في احدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (وهي جرائم اختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر) أو كذلك من صدر ضده (بحقه) حكم نهائي في جريمة تهرب ضريبي أو جمركي**

(م/٨٥، م/٩٣ من القانون) وتشكل هذه المادة أداة وقائية، تقدم قدراً أكبر من الحماية للتعاقدات، عبر تنقية المتقدمين (للعطاءات) ممن سبق وأدينوا في جرائم المال العام، والتهرب، وردع أصحاب العروض (العطاءات) الجديدة عن الممارسات الإجرامية تجاه المال العام.

— ولا شك أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل من احتمال التلاعب والعدوان على المال العام في التعاقدات.

٥- وفي مجال تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات التعاقدية، نص القانون على وجوب النشر عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها في القانون على بوابة التعاقدات العامة (الانترنت) ، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم نشرها أو عدم النشر عنها، وفقاً لما تقررره السلطة المختصة، على أن يتضمن النشر طريق التعاقد، وشروطه، والأساليب المبررة لإتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (م/٢٠).

وقد نصت المادة (١٨١) من اللائحة ، على أن تلتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، بتسجيل من يتم إخطارهم بصدور أحكام نهائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أو في جرائم التهرب الضريبي ، أو الجمركي في سجل قيد أسماء ممنوعين من التعامل معهم ، بالإضافة إلى نشر بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة.

— ويلحظ من ذلك تأكيد القانون على تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة في مجال التعاقدات العامة.

٦- وفي مجال تحفيز أكبر عدد من المتنافسين في العطاءات المقدمة منهم، ألزم القانون الجهة الإدارية (المتعاقدة) في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر أو أكثر، بتعديل قيمة العقد، وفقاً للزيادة أو النقص في بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر، وبمراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك.

والتزام الجهة بذلك التعديل، يجب أن يتم في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية ، من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر، بحسب الأحوال (م/٠٤٧). ويحصن هذا النص المنافسين من التخوف من تأثير تقلبات الأسعار على قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، خاصة في العقود طويلة الأجل، والتي قد تشهد تغير مستوي الأسعار خلال فترة تنفيذها.

وفي ذلك تنص (م/٩٧) من اللائحة على اشتراطات تطبيق معادلة تغير الأسعار في عقود مقاولات الأعمال ، إذ جاء نص المادة المشار إليها على أنه : " في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم إدارة التعاقدات في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية ، بتعديل قيمة العقد ، وفقاً للزيادة أو الخفض في تكاليف بنود العقد ، التي

طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ، أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الاسناد بالاتفاق المباشر، بحسب الأحوال ، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع باطلاً على اتفاق يخالف ذلك.

وقد أوضحت المادة ذاتها ، كيفية حساب التغيير في الأسعار ، ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعاً أو خفضاً ، وفقاً لتعريفات محددة ، ومعادلات واضحة.

٧- وفي ترشيد الاتفاق العام للوحدات ، أجاز القانون للجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد على استئجار المنقولات، وهي اضافة جديدة، حيث كان يقتصر النص على الاستئجار في القانون القديم (٨٩ لسنة ١٩٩٨م) على العقارات، بينما حدد التعاقد على المنقولات في صورة الشراء (م/٥٣، ٦٧، ٧٢).

— كما أوجب القانون على الجهات الخاضعة لأحكامه، اتخاذ إجراءات التعاقد الكترونياً وفقاً لما يتم ميكنته من إجراءات، من خلال منظومة موحدة ومنظمة ومؤمنة الكترونياً، وعلى ما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن (م/٨٤).

— ولا شك أن هذا النص يعطي مرونة للجهات الإدارية في توفير احتياجاتها المؤقتة من المنقولات، بدون الحاجة إلي شرائها، مما يحد من تعاقدات الشراء غير الضرورية، فضلاً عن ترشيد الاتفاق العام.

— وفي مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوجب القانون (م/٧٥) على الجهة الإدارية، إتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠ % من

قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات — على التفصيل الذى سنوضحه بعد قليل — .

٨- في التعاقد من الباطن: أجاز القانون لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن، على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم، وما يتم إسناده إليهم من بنود، وذلك وفقا للمحددات وأي اشتراطات أخرى تضعها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات (م ٢٥/فقرة ١).

وحظر القانون على المتعاقد تغيير أي من مقاولي الباطن، دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة، بل ونص على أنه وفي جميع الأحوال، يظل المتعاقد دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية من تنفيذ العقد (م ٢٥/فقرة ٢).

التعاقد من الباطن :

وإذ أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ التعاقد من الباطن فى تعاقدات الجهات العامة — على ماتقدم — ، وأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد وضعت محددات واشتراطات لذلك ، فنصت م/٥٧ — من اللائحة — ، على أنه : " يتعين على صاحب العطاء تضمين العرض الفنى المقدم منه ماسيعهد به إلى غيره من الباطن ، على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم ، وخبراتهم ، وماسيتم إسناده إليهم ، وبما يتفق مع المحددات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ، ومنها:

— بيانات وخبرات ماسيعهد إليه من المباطن ، والمستندات الدالة على ذلك.

— ألا يكون من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل الذى تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

— أن يكونوا من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد.

— إقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العمالة ، وفقاً لقوانين التأمينات السائدة ، إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.

ويجوز للمتعاقد أثناء فترة التعاقد أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض من (البنود) من الباطن ، إذا وجد مبررات لذلك ، شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة ، وان توافق على السلطة المختصة .

— **والملاحظة** الجديرة بالإشارة إليها — هنا — هي: أنه يجب أن يكون التعاقد من الباطن في أضيق الحدود، وفي أعمال متخصصة تقتضي طبيعتها تنفيذها عن طريق الاستعانة بمتعاقدين متخصصين من الباطن.

٩- وفي مجال التفويض في الاختصاصات : أجاز القانون للسلطة المختصة أن تفوض أي من اختصاصاتها الواردة به لشاغلي الوظائف القيادية دون غيرهم، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بمراعاة حظر التفويض في بعض الحالات التي حددها القانون (ومن أبرزها اللجوء إلى الطرق الودية في حسم المنازعات بين طرفي العقد كالتوفيق أو الوساطة أو التحكيم) (المواد ٨٤ ، ٩١).

وقد أبانت اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة ، عن ضوابط واجراءات التفويض فى الاختصاصات ، فى المادة (١٦٦) ، وتنص على : مع مراعاة الحالات التى حظر فيها القانون التفويض ، يجوز للسلطة المختصة أن تفوض فى أى من اختصاصاتها لشاغلى الوظائف القيادية دون غيرهم ، على أن يكونوا ممن يشهد لهم بالكفاءة ، والخبرة ، والتمتع بصفات النزاهة والأمانة ، وحسن السمعة ، والخبرة اللازمة لممارسة الاختصاصات المفوضة لهم ، شريطة أن يصدر قرار من السلطة المختصة يتضمن اسم المفوض ووظيفته ، وموضوع التفويض ، ومدته ، وشروطه ، ومتطلباته ، وينتهى التفويض بالغاء القرار الصادر بشأنه ، أو انتهاء مدة التفويض ، أو الغرض منه .

ويحظر على المفوض تفويض الآخرين فى الاختصاصات المفوض فيها ، ويجب على المفوض إعداد تقارير يعرضها على السلطة المختصة بشأن ما اتخذه من اجراءات مفوض فيها، كما يجب على السلطة المختصة الأصلية مراجعة أعمال المفوض بشكل دائم والوقوف على مستوى ادائه ، واتخاذ مايلزم بشأنه.

١٠- وثمة ملاحظة على نص م ٦/٣٥ - فى شأن تفصيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، إذ تنص تلك الفقرة على أن: يعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التى تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً، إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة (١٥%) من قيمة أقل عطاء أجنبي.

— وهنا يلزم تحديد ماهية الجهات المصرية على وجه الدقة، تحاشيا لأي صعوبات عملية عند التطبيق والمأمول أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون ذلك عند إصدارها.

١١- في توسع المشرع في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر (م/٦٢).

— توسع القانون — بشكل كبير جداً — في الحالات التي يجوز التعاقد فيها بطريق الاتفاق المباشر، وذكر حالات يجوز فيها التعاقد بذلك الطريق، وهي:

— الحالات الطارئة الناتجة عن الظروف الفجائية التي لم يكن في الإمكان توقعها أو التنبؤ بها، أو التي تتطلب الضرورة في التعامل معها بشكل فوري، ولا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما.

— وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية، أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد، أو لديه الحق الحصري، أو الاحتكاري لموضوع التعاقد.

— تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا يوجد سوي مصدر واحد.

— عندما يكون التعاقد غير مشمول في عقد قائم، وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.

— الحالات العاجلة، التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما، وذلك لضمان وكفاءة

سير العمل بالجهات الإدارية، وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخير في اتخاذ الإجراءات.

— في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم.

— في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الدولة.

— والواقع أن التوسع (الكبير) في حالات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر = وهو ليس إلا طريقا استثنائيا للتعاقد = قد استغرق الأصل العام في التعاقد، ومن ثم كان يجب عدم التوسع في اللجوء إلى هذا الأسلوب في التعاقد.

— ثم إن هذا التوسع من شأنه الإخلال بأهداف القانون، والمنصوص عليها في م/٢ — سאלفة البيان — وهو ما من شأنه يفتح بابا للتحايل على أحكامه.

— ولا يغير من ذلك ما تطلبه القانون من وجوب التزام إدارة التعاقدات بالجهة المتعاقدة بتوثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، دون أن تحدد ماهية أو إجراءات ذلك التوثيق.

— وكان الأمر يستلزم إضافة عبارة وذلك على النحو الذي تبينة اللائحة التنفيذية إلى عجز الفقرات الواردة بالمواد (٦٣، ٦٤، ٧١) من القانون.

١٢- على أن أهم وأخطر ما استحدثه القانون (١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) هو ما ورد بالمواد (٧٦، ٧٩) ونوضح ذلك فيما يلي:
— نصوص المواد:

م/٧٦: تنص على: (في حالات الضرورة، يجوز لمجلس الوزراء أن يصرح لجهة إدارية بعينها، لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل تلك

الجهة ونشاطها أو طبيعة العملية، التعاقد بأي من طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (٧) من هذا القانون، وفقا للشروط والقواعد التي يحددها.

— كما يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص لجهة إدارية بعينها بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملا التمويل، إذا كان هذا المشروع يحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بنتائج الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وبالدراسة التحليلية للهيكل الفني والمالي له، وعلى أن يكون ذلك بعد موافقة وزيرى المالية والتخطيط، وذلك كله ما لم ينظم التعاقد قوانين أخرى.

وإذا لم ينطو المشروع المقدم على حقوق ملكية فكرية حصرية لمقدمة ورغبت الجهة الإدارية في تنفيذه، يحق لها في ضوء دراستها طرحه للحصول على عطاءات تنافسية له، ويتم التعاقد وفقا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب إتباعها وضوابط إبرامه والتي تقررها اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون، ويعتمدها مجلس الوزراء، ويصدر بها دليل إجرائي ينظمها.

(م/٧٩): وتنص على: استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للجهة الإدارية التعاقد على الصفقات التي تتطلب منها السرعة في اتخاذ قرار التعاقد، بحكم طبيعتها أو تقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية، أو التي تغطي مدي زمني مستقبلي أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة في الأسواق المالية الدولية، أو عقود المشتقات المالية

والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وذلك كله وفقا للممارسات التجارية الدولية المطبقة التي تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية، وتقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون ويعتمدها مجلس الوزراء.

— كما يجوز للجهة الإدارية استثناء من أحكام هذا القانون، إبرام التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف، أو التعاقدات التي تتطلب هيكل تمويليا كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية Boot والبناء والتملك والتشغيل Boo والتصميم والاشتراء والتشييد + التمويل Epc + Finnace وغيرها، وذلك إذا كانت هذه التعاقدات تحقق للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف الاقتصادية والاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، وتتم هذه التعاقدات وفقا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب إتباعها وضوابط إبرامها، والتي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون، ويعتمدها مجلس الوزراء، ويصدر بها دليل إجرائي ينظمها، على أن يضع الوزير المختص بالجهة الإدارية القواعد الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزيرى المالية والتخطيط، ويجب اعتماد هذه القواعد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالجهة الإدارية.

— وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأوضاع إبرام هذه التعاقدات.

(مادة ٨٠) تنص على: يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات

الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل، مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد.

— وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية^(١).

— والبيان أن هذه المواد تتناول بالتنظيم التعاقدات ذات الطبيعة الخاصة التي تبرمها الجهات الإدارية في حالات الضرورة، والتعاقد على المشروعات الاستثمارية المتكاملة شاملة التمويل.

وكذا التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف أو التعاقدات التي تتطلب هيكل تمويليا وهي تعاقدات قد تتضمن

^١ المادة (٤) تنص على: (تنشأ لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية، وتختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وفقا لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر، وبما يسهم في جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية.

— وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها تعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، واتخاذ ما يراه من إجراءات التنفيذ لما ورد به.

— ويصدر بتشكيل اللجنة وقواعد وإجراءات عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

التصرف في أملاك الدولة الخاصة ومثالها عقود نقل التكنولوجيا^(١). وعقود تسليم المفتاح Contrat de en main والذي يعد من أهم عقود نقل التكنولوجيا، وهو من العقود المركبة التي تحتوي على عمليات قانونية كثيرة، يدخل في بعضها عقد البيع، وبعضها في عقد المقاولة، وبعضها في عقد الاستصناع . ويتعامل مع أموال مادية ومعنوية، وتتصهر هذه العناصر لتشكل عقداً واحداً من طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة كل عنصر مما يدخل في تركيبة إذا أخذ على حدة.

وهذا العقد وإن كان طرفاه الجهة الإدارية والمتعاقد معها (شخص طبيعي أم معنوي) إلا أنه لا يمنع من دخول أطراف أخرى في ذلك العقد، كالمقاول من الباطن والمهندس الاستشاري وتمثل هذه العقود جزءاً كبيراً من عقود التجارة الدولية^(٢).

البيان أن هذه النصوص تثير شبهة عدم الدستورية للأسباب الآتية:
— إن اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، لا يدخل في مفهومها توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، فلا تفصل اللائحة عندئذ أحكاماً أوردها المشرع إجمالاً، ولكنها تشرع ابتداء من

١ المعلوم أن طرق التعاقد هي: المناقصة العامة — المناقصة المحدودة — المناقصة المحلية — المناقصة ذات المرحلتين:

— المزايدة العامة — المزايدة المحدودة — المزايدة المحلية

— الممارسة العامة — الممارسة المحدودة

— الاتفاق المباشر، وسنعرض لهذه الطرق جميعها عند دراسة موضوع (طرق التعاقد).

٢ راجع د. محسن شفيق: عقد تسليم مفتاح، محاضرات لطلبة دبلوم دراسات عليا — جامعة القاهرة سنة ١٩٨٢م ص ٥.

خلال نصوص جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون وبها تخرج اللائحة من الحدود التي ضبطتها المادة (١٧٠) من الدستور^(١).

وتقتضى المادة (١٧٠) من الدستور على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية – اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين – بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

كما وتقتضى الفقرة الأخيرة من المادة (٣٢) من الدستور على أن (ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك).

وبالبناء على ذلك، فكان لزاماً أن يتضمن قانون ينظم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، (القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) القواعد والإجراءات الأساسية المنظمة لأحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بشأن الحالات المذكورة، نزولاً على أحكام الدستور – المشار إليها – فلا يكون تدخله قاصراً متخلياً عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، تاركاً إياه لمجلس الوزراء أو اللائحة التنفيذية، بحسب الأحوال على نحو ما أشارت إليه المواد – سابق الإشارة إليها – دون ضابط أو حاكم.

الأمر الذي يثير معه أحكام تلك المواد شبهة عدم الدستورية لمخالفتها نص المادتين ٣٢، ١٠١ من الدستور (وهي المواد المنظمة لضوابط التصرف في أملاك الدولة الخاصة، واختصاصات السلطة التشريعية).

١ حكم الدستورية العليا، القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ق، في ١/٨/٢٠١٧م.

— وملاحظة أخرى: أن الاستثناءات الواردة بالمواد سالفه الذكر، تهدد بخلق ازدواجية في تعاقدات الوحدات الإدارية للدولة. فبينما تواجه التعاقدات الصغيرة والمتوسطة قواعد وضوابط واضحة في القانون تنظم آليات التعاقد، بما يعزز الشفافية والانضباط والمنافسة في العروض، مع السماح لها بتخطي قواعد التعاقد لإبرام اتفاقات مباشرة في حدود مالية واضحة في القانون على الجانب الآخر تتمتع التعاقدات الكبرى باستثناءات كثيرة تخرجها عن التقيد ببند القانون، مما يضعف المنافسة والكفاءة في التعاقدات الكبرى للجهاز الإداري للدولة.

— ونشير أنه لا اعتراض على تمتع التعاقدات الكبرى باستثناءات، تتناسب وأهميتها العملية، لكن يجب أن تكون هذه الاستثناءات وفق ضوابط قانونية وإجراءات ينص عليها في صلب القانون، وليس في اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني

القيود التي ترد على حرية الإدارة قبل إبرام العقد الإداري

تمهيد:

يقصد هنا بالقيود التي ترد على حرية الإدارة قبل إبرام العقد، تلك التي تسبق إجراءات الطرح، ذلك أنه من المسلم به، أن ثمة قيود ترد على حرية الإدارة — أيضا — منذ البدء في اتخاذ إجراءات الطرح وحتى إتمام إبرام العقد، وسوف نتناول تلك القيود — الأخيرة — عند دراسة طرق إبرام العقد.

أما هنا فسوف نتناول القيود التي ترد على حرية الإدارة قبل اتخاذ إجراءات الطرح، وتلك القيود واجبة التقيد بها من قبل الجهة الإدارية أولا.. ويمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: الاعتماد المالي (م/١١ من ق ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م)

ثانيا: إخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي (م١٩/فقرة أخيرة)

ثالثا: إعداد كراسة للشروط والمواصفات (م/١٩)

رابعا: الأذن بالتعاقد

خامسا: الاستشارات السابقة

سادسا: التفويض في الاختصاصات (م٨١)

ونعرض لكل واحد منها في مبحث مستقل، على النحو التالي:

المبحث الأول

التحقق من توافر الإعتمادات المالية

١- النصوص القانونية:

— تنص (م/١١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، على أنه: (يجب على الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح، التحقق من توافر الإعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد، على أن تتضمن شروط الطرح ما يفيد ذلك، ويكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية).

وتنص (م/٧) من قانون المحاسبة الحكومية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١م المعدل بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨م، على أنه: (لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية، إلا في حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة).

والمسلم به أن الجهة الإدارية لا يجوز لها أن تتعاقد أو تلتزم بدفع مبالغ معينة، إلا إذا وجد الاعتماد المالي اللازم لمواجهة هذا الالتزام، وتلك قاعدة عامة تسرى في مجال نشاط الإدارة بصفة عامة.

فما هو الاعتماد المالي؟ وما طبيعته؟ وما هي الآثار التي تترتب على مخالفة القواعد الخاصة للاعتمادات المالية؟ وهل يجوز مقاضاة الجهة الإدارية إذا تقاعست عن طرح مشروع يدخل ضمن اختصاصاتها وإجراء التعاقد لتنفيذه؟ وما هو الجزاء المترتب على تقاعس الجهة الإدارية في تنفيذ المشاريع رغم وجود الاعتماد المالي بدون عذر قانوني؟ وهل ثمة استثناءات ترد على قيد توافر الاعتماد المالي؟

١- ماهية الاعتماد المالي:

الاعتماد المالي هو إذن بالصرف، لكنه ليس ملزماً لمن تقرر له ذلك الاعتماد أن يصرف منه، بل يجوز للجهة الإدارية إلغاء المنافسة بعد إجراءاتها أو تأجيل البت فيها. كما أن للجهة الإدارية أن تنزيه أو تعدل عن إبرام العقد، إذا كانت دواعي المصلحة العامة تقتضي ذلك.

٢- الأثر المترتب على إبرام العقد في مخالفة الاعتماد المالي:

استقر قضاء مجلس الدولة وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على أن — العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير، كعقد من عقود لإشغال العامة أو التوريد مثلاً، ينعقد صحيحاً وينتج آثاره، حتى ولو لم يوجد الاعتماد المالي، أو كانت الالتزامات التي تتحملها الإدارة تزيد على المبلغ المسموح به، أو حتى لو خالفت الإدارة الغرض المقصود منه، أو فات الوقت المحدد لاستخدامه، فمثل هذه المخالفات، لو وجدت من جانب الإدارة، لا تمس صحة العقد ولا نفاذه، بل يبقى صحيحاً وناظراً في مواجهة الإدارة، وتلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد معها عما أصابه من أضرار جراء خطئها، وهو بلا شك خطأ مفترض في جانبها، ولا يخل ذلك بترتيب المسؤولية السياسية أو الإدارية للمخطئ.

وعلة ذلك الحكم ظاهرة، بالنظر إلى الطبيعة الذاتية للالتزامات طرفي

العقد من ناحية، وحماية للغير من ناحية أخرى.

والقول بغير ذلك من شأنه ألا يجازف أحد بالتعاقد مع الإدارة، ولتعطل سير المرافق العامة.

المبدأ إذاً: إبرام عقد دون وجود الاعتماد المالي أو تجاوزه لا يؤثر على صحة العقد وتنفيذه إلا أن ذلك لا يعفي المخطئ من المساءلة.

٣- طبيعة الاعتماد المالي:

مما سبق نخلص أن الاعتماد المالي ليس ركناً أو شرطاً في العقد، يترتب على تخلفه بطلان العقد، بل لا يعدو كونه التزاماً يقع على عاتق الجهة الإدارية وحدها، وتحمل دون غيرها الآثار المترتبة على عدم الالتزام به، وهذه الآثار هي: تعويض المتعاقد معها، ولا يخل ذلك بترتيب المسؤولية الإدارية للمخطئ، وهذا ما نص عليه القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م في المادة (٨٩) والتي تنص على أنه: (مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية، يؤخذ تأديبياً كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالتعاقدات والتي يصدر بها قرار من وزير المالية).

٤- هل يمكن إجبار الجهة الإدارية على التعاقد لوجود الاعتماد

المالي اللازم لذلك؟

من المسلمات أن اعتماد المبالغ المالية المخصصة لتنفيذ وانجاز مشاريع معينة، لا يتم إلا بعد دراسة أهمية وجدوى هذه المشاريع. ويتعين على الجهة الإدارية القيام بأداء المهام المنوطة بها، واستخدام الأموال المعتمدة في الميزانية في تنفيذ المشاريع التي خصصت هذه المبالغ من أجل انجازها وتنفيذها.

لكن المسلم به أيضاً، أنه لا يجوز — من الناحية القانونية مقاضاة الجهة الإدارية المعنية إن هي لم تطرح المشروع للتعاقد، وإجراء التعاقد لتنفيذه رغم وجود الاعتماد المالي، ذلك أنه المستقر فقهاً، أن اعتماد المبالغ اللازمة للصرف على أداء عمل أو تنفيذ مشروع معين، لا يلزم الجهة الإدارية المعنية بإجراء المنافسة والتعاقد على تنفيذه، بحسبان أن

الاعتماد المالي وعلى ما قدمنا لا يغدو أن يكون إذنًا بالصرف ليس ملزماً لمن تقرر له ذلك الاعتماد أن يصرف منه.

لكن تقاعس الجهة الإدارية في تنفيذ المشاريع رغم وجود الاعتماد المالي بدون عذر قانوني أو سبب يتعلق بالمصلحة العامة، يجعل الوزير المختص مسئولاً عن ذلك التقاعس والتقصير أمام البرلمان ونرى أنه لا يجوز الطعن على القرار السلبي لجهة الإدارية بالامتناع عن التعاقد، لأنه لا إلزام عليها بذلك.

ويجب إنجاز البرامج والمشاريع التي رصدت من أجلها المبالغ المعتمدة في الميزانية بكل دقة وسرعة وعلى السلطة المختصة المتابعة الدقيقة لما ينفذ دون تقاعس أو تقصير أو تهاون، والاستشعار الدائم بالمسؤولية والأمانة.

محظورات يتعين مراعاتها في الإعتمادات المالية:

هذا وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (١١) — المشار إليها — على أنه: (ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد.

وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن (يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخططة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة على أن يتم الصرف في حدود الإعتمادات المالية المقررة).

وفي حظر التعاقد بقصد استنفاد الإعتمادات المالية، نصت الفقرة الأخيرة من المادة (١١) — المشار إليها — على ذلك، بل وحظره أيضاً

التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية،
التي تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة السلطة المختصة.

٥- الاستثناءات التي ترد على قيد الاعتماد المالي (استثناءات) :

(١) الجهات ذات الطبيعة الخاصة (م/٧٦ من القانون): فقد أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م لمجلس الوزراء أن يرخص لجهة إدارية بعينها التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي، حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملا التمويل، إذا كان هذا المشروع يحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.... وعلى أن يكون ذلك بموافقة وزيرى المالية والتخطيط، وذلك ما لم ينظم التعاقد قوانين أخرى.

إذا الاستثناء الأول: خاص بالمتعاقدين الذي يتقدم بمشروع استثماري متكامل، شاملا التمويل وهذا الاستثناء تحدده الضوابط الآتية (أربعة ضوابط):

أ — أن يكون من شأن المشروع أن يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

ب — أن يكون الاستثناء بناء على عرض الوزير المختص، وبشرط موافقة وزيرى المالية والتخطيط.

ج — ألا يكون هناك قوانين أخرى منظمة للتعاقد.

د — أن يصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء.

نخلص من ذلك ، إلى ثمة حظرين : أولهما ، حظر تجاوز الاعتماد المالى (السنوى) ، والآخر حظر التعاقد بقصد استيفاء الاعتمادات

المالية ، وحظر التعاقد فى الشهر الأخير من السنة المالية إلا بشرطين : أ- ضرورة العمل تقتضى ذلك.

ب - موافقة السلطة المختصة.

الاستثناء الثانى: عقود الصفقات والمشروعات المركبة والمتشابهة ومتعددة الأطراف، المنصوص عليها فى المادة (٧٩) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م سابق الإشارة إليها.

وقدما أن شرط توافر الاعتماد المالى، لا يسرى على التعاقدات التى تتطلب هيكلا تمويليا - كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية Boot والبناء والتملك والتشغيل Boo، والتصميم والاشتراء والتشييد + التمويل EPC + Finance وغيرها إذا كانت هذه التعاقدات تحقق للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعها إتمامها فى وقت معين وتتحدد ضوابط هذا الاستثناء فى :

أ - أن يتم التعاقد وفق الأطر والإجراءات والشروط التى تقرها لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية، المنصوص عليها فى (م/٤) من هذا القانون.

ب - أن يضع الوزير المختص بالجهة الإدارية القواعد الخاصة بكل مشروع، بالاتفاق مع وزيرى المالية والتخطيط.

ج - وجوب اعتماد هذه القواعد من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالجهة الإدارية^(١).

- والبيان أن مجال هذا الاستثناء ، يتحدد فى أربعة أنواع من العقود، وهى عقود Boot ، وعقود Boo ، وعقود Epc + Finance وأية عقود أخرى ، تحقق لجهة الادارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنمية العاجلة ، أو تلك العقود التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة اتمامها فى وقت معين.

وذلك كله بمراعاة شروط التعاقد التى تقرها لجنة المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية ، المنصوص عليها فى م/٤ من القانون المشار إليه.

(وتجدر الاشارة إلى أن هذه اللجنة من الاستحداثات التى جاء بها القانون الجديد للتعاقدات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨).

المبحث الثانى

إخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي (م/١٩ فقرة أخيرة)

تنص الفقرة الأخيرة من م/١٩ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على أن: (وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفصيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة

^١ وإذ تنص الفقرة الأخيرة من (م/٧٩) المشار إليها على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأوضاع إبرام هذه التعاقدات فقد تكون هذه الفقرة مشوبة بشبهة عدم الدستورية - على ما سبق بيانه - فنحيل إليها.

ملايين جنيهه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها بمدة لا تقل عن خمسة أيام.

كما تلتزم بموافاتها بنسخة من هذه الشروط والمواصفات متى كانت قيمتها تزيد عن عشرة ملايين جنيهه، قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها، أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر، بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وعلى اللجنة أن توافي تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها شروط ومواصفات الطرح، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.

والبين أن المشرع مايز بين العقود من حيث قيمتها التقديرية فيما يتعلق بميعاد إخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، فبينما يجب إخطار اللجنة بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيهه حتى عشرة ملايين جنيهه خلال خمسة أيام، تستطيل هذه المدة بالنسبة للشروط والمواصفات أو العقود التي تزيد على عشرة ملايين جنيهه إلي خمسة عشر يوماً، قبل اتخاذ إجراءات الإعلان أو الدعوة أو الإسناد بطريق الاتفاق المباشر.

الاستثناءات الذي يرد على هذا القيد:

(أ) إذ استثنى القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م من العرض على لجنة تفصيل المنتج الصناعي المصري، العقود الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة (م/١٣) — فقرة أخيرة من ق ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م).

— ومؤدي ذلك عدم سريان أحكام هذا الاستثناء على التعاقدات التي تبرمها الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى والتي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي صدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ب) إن القانون الذى ينظم ضوابط تفضيل المنتج المصري الصناعي في العقود الحكومية، هو القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥م معدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨م^(١).

— وتقضى المادة (٢) من هذا القانون على سريان أحكامه على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على ما سبق بيانه — كما تسري أيضا على عقود المشروعات التي تبرمها أي من الشركات الآتية:

— الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

— شركات القطاع العام.

— شركات قطاع الأعمال العام.

— الشركات التي تكون للدولة، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الشركات المشار إليها في هذه المادة أو الأشخاص

^١ عرفت م/١ من هذا القانون، المنتج الصناعي المصري، بأنه كل منتج صناعي يتم إنتاجه في داخل ج.م.ع أو المناطق الحرة، وفقا للقوانين المنظمة لذلك والمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري، هو كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على ٤٠% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصري يخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.

الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين حصة حاکمة فيها.

— وقد استثنى هذا القانون (٥ لسنة ٢٠١٥م المشار إليه) من تطبيق أحكامه، التعاقدات التي تبرمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وهيئات المخابرات العامة.

— وكذلك لا تسري أحكام القانون ٥ لسنة ٢٠١٥م على عقود المشاركة مع القطاع الخاص، وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها، والتي تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

نخلص من ذلك ، إلى أن أحكام قانون تفضيل المنتج المصري الصناعي فى العقود الحكومية (القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥) ، يسرى على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وكذلك على شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال ، والشركات المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو تلك التى تكون للدولة أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة ، حصة حاکمة فيها.

ويستثنى من ذلك : تعاقدات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمخابرات العامة.

— كما يستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥م أيضا التعاقدات التي تبرمها رئاسة الجمهورية، باعتبارها من الجهات التي تقتضى اعتبارات الأمن القومي سرية تعاقداتها في مفهوم المادة (٢)

من القانون المشار إليه، إعمالاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٣٧ لسنة ٢٠١٥م^(١).

ملاحظات جوهرية:

١- لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام كل من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥م (معدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨م) والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، التعاقد خلال الفترة اللازمة لاختار لجنة تفصيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من الشروط والمواصفات، قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها، أو إسنادها بطريقة المباشر — على ما قدمنا — .

٢- نص القانون ٩٠ لسنة ٢٠١٨م — المشار إليه — في م/١٢ على أنه: (يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها، إذ تبين للجنة تفصيل المنتج الصناعي المصري أن شروط الطرح للعقود المنصوص عليها — في م/١١ من هذا القانون تخالف أحكام هذا القانون).

— ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة (ويقصد بالسلطة المختصة، الوزير، ومن له سلطاته، أو المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، أو الصندوق، أو من يعاد لهم من سلطات في الجهات المنصوص عليها في م/١ من هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه).

١ المعلوم أن القانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨م (المعدل لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥م) قد نص في م ٩١ على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية، والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات، وتشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه وعضوية.

– ويصدر قرار الإلغاء في هذه الحالة، أما من تلقاء نفس السلطة المختصة أو بناء على طلب اللجنة المشار إليها.

– على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص ووزيرى المالية والتخطيط، الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها (٤٠%) بما لا يجاوز (١٠%) في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق الاستثناءات الواردة على هذا القانون (٩٠ لسنة ٢٠١٨م).

– الأثر المترتب على مخالفة ذلك القيد (تفضيل المنتج الصناعي المصري):

فضلاً عن وجوب إلغاء إجراءات المتعاقد قبل البت فيها، يسأل الموظف العام أو العاملين بالجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون (٩٠ لسنة ٢٠١٨م، ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) عن الإخلال بأحكام هذه القوانين، ويعتبر الإخلال بهذه الأحكام، إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة^(١) (المواد ١٥ من القانون ٩٠ لسنة ٢٠١٨م، ٨٩ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م).

صفوة القول : أنه يجب على كافة الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ، التقيد بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥م

١ وقد حددت م/١٦ من القانون ٩٠ لسنة ٢٠١٨م، العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف العام أو العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

(المعدل بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨). وكذلك تخضع لأحكام هذا القانون تعاقدات الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، (شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو تلك التي تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاکمة فيها).

ويستثنى من ذلك : تعاقدات وزارة الدفاع والانتاج الحربي ، ووزارة الداخلية ، وهيئات المخابرات العامة ، ورئاسة الجمهورية . وكل ماتتص عليه اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ . والملاحظة الجوهرية : أن المشرع قد إعتبر الاخلال بتلك الأحكام ، اخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة ، بما يعنى وجوب توقيع أقصى عقاب على المخالف .

المبحث الثالث

إعداد كراسات الشروط

التزام الجهة الإدارية قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في جميع طرق التعاقد، والتعاقد بطريق الاتفاق المباشر أن تعد كراسة للشروط والمواصفات تتضمن الإحالة إلي جميع القواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (م/١٩ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م).

— ويثير إعداد كراسة للشروط والمواصفات قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في جميع طرق التعاقد، والتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، الكلام عن شرط الكتابة في العقود الإدارية ، وطبيعته، والأثر المترتب على مخالفته.

— قدمنا أن عدم الكتابة، تشكل القاعدة العامة في عقود الإدارة (أيا كانت طبيعتها) والاستثناء هو الكتابة، عند يستلزمها القانون Imope La . Loi

— والمسلم به أن مجال القاعدة العامة ضئيل جداً Tres Faible بالنسبة للاستثناء، وهو ما استقر عليه القضاء في اعتبار شرط الكتابة — حينما يستلزمها القانون — شرطاً لصحة العقد، ولست شرطاً متعلقاً بطبيعته (أي ليست ركناً في العقد) هذا أولاً، فقد أصبح إبرام العقود الإدارية، يجب أن يتم في شكل محدد، وتكون مكتوبة، ويتضمنها وثائق محددة، هي كراسات الشروط، بحيث يمكن القول بأن الكتابة هي الأصل العام، وعدم التقيد بها — أي بشكلية معينة أو التحرر من الشكليات — هو الاستثناء، فلا تؤدي العقود غير المكتوبة إلا دور تكميلي لأغراض العقد الأصلي، إذ قد تركز إليه الإدارة مع بعض المتعاقدين، إذا اتفقت معهم على تكميل أغراض التعاقد الأصلي، من ناحية من النواحي التي أنصب عليها. والقضاء مستقر على أن العقد المكمل تنصرف إليه طبيعته العقد الأصلي، بحكم ارتباطه وتعويله عليه، ومن ثم فلا حاجة إلى استظهار أركان العقد الإداري فيه (وخاصة عنصر الشروط الاستثنائية) — هذا ثانياً — .

وإذا كان ذلك كذلك، وكان الأصل في العقود الإدارية هو الكتابة، على خلاف القاعدة العامة في هذا الصدد، فإنه يتحتم على جهة الإدارة إبرام عقودها طبقاً لنماذج عامة موحدة، بل يجب على الجهة الإدارية إدراج بعض الشروط في تلك العقود، وهي الشروط التي تفرضها دفاتر الشروط العامة، والمواصفات التي تطبق على مجموعة من المصالح أو

تلك الخاصة بمصلحة معينة، وأنه لا يجوز للجهات الإدارية أن تخالف هذه النصوص إلا بترخيص خاص وفي أحوال استثنائية محددة هذا ثالثاً، وإن الوثائق التي تضمنها الجهة الإدارية شروط التعاقد، هي ما يطلق عليه كراسات الشروط، وهذه الكراسات متعددة، ومتنوعة، ومعدة سلفاً.. — ويستلزم إبرام العقود الإدارية، وفق كراسات الشروط المحددة لذلك.

— وتتعدد أنواع كراسات الشروط فمنها: كراسة الشروط العامة الإدارية وهي تلك التي تبين القواعد القانونية لكل العقود التي تبرمها الإدارة، وتحتوي هذه الكراسات على مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتحرير ونفاذ العقود.

ومنها أيضاً (كراسة الشروط العامة) (وهي تلك التي تحدد القواعد الفنية المطبقة على طائفة من العقود المحددة سلفاً).

وكذلك توجد (كراسات الشروط الخاصة) وهي تلك التي تحوي الشروط الخاصة بكل عقد، وتكمل كراسات الشروط العامة الإدارية، وبمقتضى هذه الكراسات، يمكن للجهة الإدارية تعديل الأحكام الواردة في الكراسات الأخرى والخروج عليها، تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام، وتعد هذه الكراسات أهم أنواع كراسات الشروط.

— وتشكل كراسات الشروط، الشكل العام للعقود الإدارية وعقود الإدارة بصفة عامة — إذ يجب إبرام عقود الإدارة (مدنية أو إدارية) وفق ما تتضمنه بهذه الكراسات من شروط، ويترتب البطلان على

مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذه الكراسات، ومن ثم يجب إعادة الإجراء الباطل^(١).

وثمة سؤال حول مدى تصور وجود عقد إداري بناء على عقد مكتوب من جانب واحد.

— والمسلم به، أن تحرير العقد الإداري بإرادة منفردة، لا يستبعد في مجال العقود الإدارية، إذ أن قبول المتعاقد مع الإدارة لهذا المحرر الصادر بإرادة منفردة، سواء تم قبل أو بعد تحريره، يكون منتجا لآثاره، بل تعد هذه الطريقة معمولاً بها في مجال العقود الإدارية، في قدر معقول منها، ولا تتنافي وأسلوب إبرام العقد.

— ومن أبرز صور طريقة إبرام العقد الإداري المكتوب بإرادة منفردة من جانب الإدارة، تبادل الخطابات، إذ قد يأخذ العقد — هنا — صورة تبادل المراسلات بين الإدارة والمتعاقد معها (أيا كانت وسيلة ذلك، بما فيها الوسائل التقنية الحديثة).

ويشكل هذا التبادل رابطة عقدية مكتوبة، بشرط أن يكون معبراً تعبيراً صحيحاً عن الإرادة التعاقدية وليس مجرد محادثات بسيطة.

— وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة من التعاقد، تختلف — تماماً — عن العقد غير المكتوب — والتي يعد التعاقد بأسلوب الفاتورة أو المذكرة أكثر تطبيقاته شيوعاً.

إذ القانون والقضاء يجيز هذا الأسلوب في التعاقد رغم أنه لا يتضمن من وثيقة الإبرام، سوي فاتورة المورد أو مذكرة المفاوض . تلك فكرة

١ في تفصيلات ذلك: راجع مؤلفنا — نظرية البطلان في العقود الإدارية، مرجع سابق ص ٢٠٦ وما بعدها.

عامة عن كراسات الشروط، وما يتعلق بها من شرط الكتابة في العقود الإدارية.

وفيما يتعلق بكراسات الشروط وفقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م:

١-أوجب القانون، إذا تطلبت طبيعة العملية التعاقدية، إعداد كراسة للشروط والمواصفات، فإنه يجب تضمين هذه الكراسة ما يلي:
(أ)الإحالة إلي جميع القواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (بحيث تعد هذه القواعد جزءاً لا يتجزأ من شروط العقد).

(ب)كما يجب أن تتضمن كراسة الشروط على وجه الخصوص، طريقة التعاقد، والمواصفات، والأطر الفنية لموضوع التعاقد، ومكان التنفيذ، والبرنامج الزمني المتوقع للإجراءات، ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات، وشروط الطرح العامة والخاصة، والتأمينات، وطريقة السداد، وتوقيات تقديم الشكاوي، وأسلوب التقييم، وشروط فسخ التعاقد، والجزاءات والغرامات، ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمناً حقوق والتزامات طرفي التعاقد، وأي بيانات أخرى بحسب طبيعة العملية.

٢-كما أوجب القانون التزام الجهة الإدارية بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية، والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التي تعدها الوزارات، والجهة المعنية، وفقاً لاختصاصاتها، وطبيعة عملها.

٣- كما أوجب القانون (م/٢٧) أن تتضمن كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة، وتحسب تلك المدة من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

٤- وفي المناقصة ذات المرحلتين (م/٥٨ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) أوجب القانون أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات المتعلقة بهذا النوع من المناقصات، في المرحلة الأولى، الغرض من التعاقد، والأداء المتوقع، والخطوط العريضة للمواصفات الفنية، والميزات والمواصفات التي ترغب الجهة الإدارية في التعاقد عليها، والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، ويطلب من مقدمي العطاءات تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار وكذلك تقديم ملاحظاتهم على شروط العقد المقترحة، وأي شروط أخرى.

وقد عدت المادة (٢) من اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، ومنها:

— إصدار نماذج كراسات الشروط والمواصفات ، وأنماط العقود النموذجية ، والأدلة الإرشادية ، وغيرها التي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقاً لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تقوم بتحديثها بشكل دوري ونشرها على بوابة التعاقدات العامة.

— اعداد نماذج محاضر فتح المظاريف والبيت والممارسة والمزايدة ، وأوامر التوريد ، وأوامر الاسناد ، وغيرها من النماذج المنصوص عليها بهذه اللائحة ، أو التي تتخذها الجهات ذات الصلة.

وكذلك ، إعداد نماذج حصر للعقارات المملوكة للجهات الادارية ،
وادخال مايراد لها من بيانات بقاعدة البيانات المركزية ، المنشأ لديها ،
وتحديثها بصفة دورية.

وأيضاً، امساك سجل مركزى للمتعاملين مع الجهات الادارية ، أو
الممنوعين من التعامل معها، وتسجيل من يتم اخطارها بشطبهم ، أو
اعادة قيدهم ، وفقاً للاجراءات الواردة بهذه اللائحة ، ونشر قرار
الشطب، أو إعادة القيد ، باصدار كتاب دورى يعمم بطريق النشرات
المصلحية ، وينشر على بوابة التعاقدات العامة.

وأوجبّت اللائحة على الهيئة أن تؤدى مهامها، واختصاصاتها
باستقلالية وشفافية وحيادية ، كما ويتعين على كافة العاملين بها تجنب
تضارب المصالح بكافة اشكاله ، ويحظر عليهم الدخول فى المناقصات
والممارسات والمزايدات بأنواعها ، سواء بالذات أو بالواسطة مع أى من
الجهات الإدارية ، إلا إذا كانت الاصناف المشترية لاستعمالهم الخاص ،
وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات عامة أخرى.

سؤال هام جداً:

قدمنا أن المادة (١٩) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م أوجبت أن
تتضمن كراسة الشرط والمواصفات، الإحالة لجميع القواعد والأحكام
والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتعد هذه
الأحكام جزءاً لا يتجزأ من الشروط التي يخضع لها العقد، والسؤال يدور
حول مدى سريان أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على العقود، فيما
لم يرد بشأنه حكم خاص؟

المستقر قضاء وإفتاء، على أن هذه الأحكام تندمج في شروط العقد، وتصير جزءاً لا يتجزأ بها، حيث لافكاك من الالتزام بها، ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها، عدا ما تعلق منها بالنظام العام، وإذا كان العقد لم ينص على استبعاد أحكام لائحة المناقصات والمزايدات فإنه يتعين تطبيق نصوص اللائحة^(١).

كما وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه لا تعتبر لائحة المناقصات والمزايدات مكملة للعقد، بحيث يمكن تطبيق الجزاءات المبينة بها، ما لم يتضمن العقد أحكامها، أو الإحالة إليها، باعتبارها جزءاً مكملًا له^(٢).

كما وانتهت أيضاً، إلى أنه إذا تضمن العقد مخالفة لأحكام اللائحة، تكون العبرة بأحكام العقد نفسه، وقد تضمنت شروطه استبعاد حكما لللائحة في هذا الخصوص – موضوع الفتوى – وعلى ذلك التقت إرادة طرفيه، وشروطه ظاهرة في بيان هذا المعني، ومن ثم وجب الالتزام بها^(٣).

نخلص من ذلك، إلى أن العبرة بأحكام العقد نفسه، بمعنى أن نص العقد يكون هو الواجب التطبيق، احتراماً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين مالم يتعلق الشرط بالنظام العام.

^١ المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٥١١ / ١٦٢٥ لسنة ٣١ق، في ٤/٤/١٩٨٩م.

^٢ فتوى رقم ٤١٧ في ١٥/٤/١٩٦٧م، ملف رقم ١٥٩/٨٨/٢١.

^٣ فتوى ملف رقم ١٩/٢/٧٨، جلسة ١٩/١٢/١٩٩٠م، وفتوى ملف رقم ١٦/٢/٧٨ جلسة ١٩/٢/٧٨.

وفى مراجعة كراسات الشروط :

وقد أوجب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، مراجعة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة نماذج كراسات الشروط (م/٩٠). وتستوجب مخالفة ذلك، مساءلة المخطئ بكافة صور المسؤولية التأديبية، والمدنية أو الجنائية، على نحو ما نقضي به م/٨٩ من القانون المشار إليه.

والملاحظة الهامة .. عدم جواز الاتفاق على استبعاد أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ولائحته التنفيذية ، المتعلقة بالنظام العام^(١).

المبحث الرابع

الإذن بالتعاقد

تنص المادة (١٧) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على أنه: على إدارة التعاقدات أن تعد مذكرة للعرض على السلطة المختصة للموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد وغيرها من الإجراءات، ويجب أن تتضمن هذه المذكرة على وجه الخصوص بيان محل الطرح، وطريقة التعاقد، ومدة سريان العطاءات وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟

فماذا يقصد بالإذن بالتعاقد؟ وما هي صورة؟ وما هو الجزاء الذي يترتب على مخالفته؟

^١ سوف نعرض لهذا الموضوع تفصيلاً ، عند دراسة موضوع " التحفظات فى العقد الإدارى " ، ماهيتها وحدود الالتزام بها.

١- مفهوم الإذن بالتعاقد:

لا يعني الإذن بالتعاقد، أمراً للإدارة بالتعاقد، وليس منحاً للإدارة اختصاص نوعي لم يكن لها، وإتمامه على سبيل الحتم، فلا يعني الإذن بالتعاقد شيئاً من ذلك، كما لا يعني حجراً على الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية بوصفها القوامة على المصلحة العامة، وحسن استغلال المرافق العامة.

فالإذن بالتعاقد لا يختلف جوهرياً عن إذن القضاء للأوصياء أو القامة بالبيع أو بالشراء، لحساب المشمولين بالوصاية أو القوامة. فمثلاً: في التزام المرافق العامة، يجب توافر إرادتان، إرادة السلطة التشريعية بوصفها صاحبة الحق في الترخيص بالتعاقد، وإرادة السلطة التنفيذية، بوصفها صاحبة الحق في إعمال مضمون الترخيص أو الأحكام عنه (أي عن أعماله) فإن لم تعبر إحدى السلطتين عن إرادتهما على النحو المقرر دستورياً وقانونياً، فلا يعتبر العقد قائماً (أي لا تكون بصدد عقد).

صور الإذن بالتعاقد:

أقوي صور الإذن بالتعاقد ما يكون في شكل قانون، إذ لا يجوز منح التزام المرافق العامة إلا بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، هذا فيما يتعلق بحق استغلال الموارد الطبيعية أما فيما يتعلق بالتزام المرافق العامة، في حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، فلا تزيد مدة منح الالتزام عن خمسة عشر عاماً، بناء على قانون (المادة ٣٢ من دستور ٢٠١٤).

وعلى ذلك فإنه يجب إصدار قانون خاص بكل حالة يراد فيها منح التزام بمرفق عام، ولمدة محددة^(١).

— كما قد يأخذ الإذن بالتعاقد في صورة قرار إداري، إذ يجب الحصول مقدماً على موافقة السلطة المختصة، قبل البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد، م/١٧ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م إذ أوجبت هذه المادة على التزام إدارة التعاقدات للحصول على موافقة السلطة المختصة للموافقة على اتخاذ إجراءات الطرح بالتعاقد.

— وقد ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، الجهة الادارية قبل الطرح لعملية التعاقد ، الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ، ذات الصلة بموضوع الطرح ، من الجهات المعنية ، وفقاً للقوانين والقرارات التي تقضى بذلك (م/١٦ من اللائحة).

كما تستوجب بعض التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، ضرورة حصول بعض الهيئات الإقليمية والمصلحية على إذن بالتعاقد من سلطة إدارية أعلى (مثال م/١٥ من ق رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩م بشأن الحكم المحلي).

ويعد الإذن بالتعاقد أو الموافقة (المسبقة) على التعاقد شرطاً أساسياً لصحة الرابطة التعاقدية، وعليه فإن تعاقد الإدارة دون الحصول على

^١ تكرر هذا القيد في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة، المادة (١٣٧) من دستور ١٩٢٣م (م/١٢٣) من دستور ١٩٧١م أما دستور ١٩٥٦ فقد نص على أن يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح التزام المرافق العامة.

هذا الإذن، يؤدي إلى بطلان العقد، ومن ثم لا يستطيع المتعاقد مع الإدارة التمسك في مواجهتها بالعقد، ويكون كل ماله الرجوع عليها بالتعويض، تأسيساً على المسؤولية التقصيرية، وذلك إذا أصابه ضرر من جراء بطلان العقد، أو إذا ثبت أن الإدارة استفادت من العقد الباطل، ولو لم يرتب ضرر للمتعاقد معها، تأسيساً على نظرية الإثراء بلا سبب، بينما لا يجوز للإدارة الرجوع على المتعاقد معها، بما استفاد به من العقد الباطل، تأسيساً على قاعدة عدم المساس بآثار العقد المعلوم، الذي تم في الماضي بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة، تأسيساً على حسن النية، وعدم مسؤوليته عن خطأ الإدارة^(١).

ولا تخل تلك الأحكام، بوجوب مساءلة كل من خالف أحكام القانون أو لائحته التنفيذية (م/٨٩) وقد سبق الإشارة إليها.

المبحث الخامس

الاستشارات السابقة

يقصد للاستشارات السابقة إلزام الجهة الإدارية باستشارة جهة أو جهات متعددة محددة قانوناً قبل إبرام العقد، وذلك لتلافي مخاطر قانونية أو فنية أو اقتصادية، فتلتزم الجهة الإدارية بطلب الرأي (الاستشارة) طبقاً للقانون، حتى ولو لم تلتزم برأي الجهة الاستشارية.

النصوص القانونية:

تنص الفقرة الأخيرة من المادة (٥٨) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م على أنه (ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو

١ راجع مؤلفنا، نظرية البطلان في العقود الإدارية — مرجع سابق — ص ٧٧ — ٧٨.

تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة).

وتقتضي المادة (٩٠) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بأن: (تتولي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، مراجعة مشروعات العقود التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها، ونماذج كراسات الشروط...).

بينما تنص المادة (١٩٠) من الدستور المعمول به (حالياً) دستور ٢٠١٤م، (على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة..... ويتولي وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون.... ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها..) والتي تحيلها إليها الجهة الإدارية^(١).

الأسئلة المطروحة للبحث:

- تحديد الوقت الذي تتدخل فيه استشارة مجلس الدولة.
- مدي التزام الجهة الإدارية برأي الجهة الاستشارية.
- حدود مراجعة مجلس الدولة لمشروع العقد، هل تمتد إلي التقدير والملائمة في العقد محل المراجعة.
- حكم مراجعة العقد بعد إبرامه، ومدي جواز ذلك.

^١ هذه المادة ورد بشأنها مقترحات بالتعديل الدستوري المقترح ، في مجال مراجعة التشريعات، ومراجعة مشروعات العقود ومؤداه ، أن مراجعة العقود المشار إليها بالمادة (١٩٠) يتوقف على أن تحيلها الجهة المتعاقدة إلى مجلس الدولة . ومن ثم فإذا لم تحيلها الجهة الإدارية إلى مجلس الدولة ، فلا إلزام على الجهة الإدارية بمراجعة المجلس فى ذلك .

١- وقت تدخل إدارة الفتوى:

البين من نصوص المواد السابق الإشارة إليها، أن وقت تدخل مجلس الدولة - إدارة الفتوى المختصة - في مجال عقود الإدارة، سابق على إبرام العقد، إذ من الواضح أن دور إدارة الفتوى، ينصب على مشروعات العقود، أي قبل إبرامها.

وهذا الالتزام الذي يقع على عاتق الجهة الإدارية، قبل إبرام عقودها واجب، ولو لم تلتزم برأي الجهة الاستشارية، أي أن الالتزام هنا يقع على عاتق الجهة الإدارية من حيث الالتجاء إلي طلب الرأي (الاستشارة) دون النظر إلي مدي الالتزام به.

وإذ يثور التساؤل حول مدي الالتزام برأي الجهة الاستشارية فهذا محله السؤال التالي:

٢- عدم التزام الجهة الإدارية بما ينتهي إليه رأي إدارة الفتوى:

حقيقة أن القانون حينما أوجب على الجهة الإدارية، أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة قبل إبرام عقودها، ومن ثم مراجعة مشروعات عقود تلك الجهات، لم يشترط ذلك عبثاً، وإنما أراد أن يجنب الجهات الإدارية مواطن الخطأ، وأن يكفل لها من أسباب السلامة في صياغة عقودها، ووضع أحكامها، مما تتحقق معه المصلحة العامة.

ورغم ذلك فالمستقر فقها وقضاء، أن مخالفة ذلك القيد لا يترتب عليها بطلان العقد^(١).

١ راجع مؤلفنا، نظرية البطلان، سابق الإشارة إليه ص ٨٢.

وهنا ثمة اختلاف كبير بين تلك الاستشارة واجبة اللجوء إليها مقدما، وبين الإذن بالتعاقد الذي يترتب على مخالفته بطلان العقد — على ما قدمنا — .

ولكن تكون مخالفة ما انتهى إليه رأي الجهة الاستشارية مبرراً لبطلان العقد، إذا كان ثمة إلزام على الجهة الإدارية بالالتزام بما ينتهي إليه رأي الجهة الاستشارية، وهنا يأخذ حكم الإذن المسبق بالتعاقد.

٣- حدود مراجعة إدارة الفتوى المختصة مشروع العقد المستقر فقها وقضاء أن إدارة الفتوى حين تعطي رأيها في مشروع العقد المرفع إبرامه، إنما تمارس رقابة قانونية سابقة على إبرام العقد، فتقف عند حدود انسجام أحكام مشروع العقد وإجراءاته (فقط) مع القوانين، ولا تمتد إلي الملائمة والتقدير التي ينفرد بها القضاء، وهو بصدد نظر منازعة في العقد^(١).

— وعلى ذلك، فإن رقابة المشروعية التي تمارسها إدارة الفتوى، تقف عند حدود مراقبة إجراءات التعاقد، ونصوص العقد، وكل ما أصبح جزءاً منه من مستندات سابقة على إبرامه.

وتجدر الإشارة إلي أن مراجعة إدارة الفتوى لمشروع العقد، لا تضيف على إجراءاته الشرعية والصحة إذا كانت قد فقدتها، ولا تطهره من المخالفات التي شابت إبرامه أو بنوده، وهذا ينقلنا إلي السؤال الأخير.

١ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في ٢١/١/١٩٩٨م، ملف رقم ٣٤٤/١/٥٤.

٤- حكم مراجعة العقد بعد إبرامه:

ومن المقرر في إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن اكتمال العقد (إبراماً وتنفيذاً) يجعل من غير الملائم مراجعته^(١). كما وأن عدم وجود موافقة من المتعاقد مع الجهة الإدارية على قبول ما يدخله مجلس الدولة من تعديلات على العقد، يجعل من غير الملائم مراجعته^(٢).

قدما أن رقابة المشروعية التي تباشرها إدارة الفتوى على مشروعات العقود (وملحقاتها) تخلص إلى الوقوف على سلامة مشروع العقد وبنوده، وإبداء الرأي للجهة الإدارية طالبة الرأي، في كافة ما ارتأته في هذا الشأن، سواء تعلق ذلك بالإجراءات، أو بنصوص العقد، أو بما أصبح جزءاً منه من مستندات سابقة عليه وبذلك تضع الجهة الإدارية المتعاقدة أمام مسؤوليتها القانونية كاملة، ولا يصبح لديها عذر بعد إيضاح الموقف القانوني لها كاملاً. ومن ثم تتحمل مسؤوليتها إذا لم تر الأخذ بالرأي القانوني.

اكتمال تنفيذ العقد يجعل طلب المراجعة عديم الجدوى.. استثناء:

ونشير إلى أن إبرام الجهة الإدارية للعقد يجعله أمراً واقعاً، ولا يسع جهات الإفتاء في هذه الحالة إلا أن تراجع من الناحية القانونية، لإبداء ما يوجد فيه من ملاحظات، على أن تتدارك الجهة المتعاقدة ما أمكن من هذه الملاحظات مع الطرف الآخر في العقد، إلا إذا كان الزمن المحدد لتنفيذ العقد قد انصرم بأكمله، قبل طلب المراجعة، فلا يكون ثمة جدوى

١ فتوى رقم ١١٩ في ٢٧/١/١٩٩٢م، ملف رقم ٢٩٢/١/٥٤.

٢ فتوى رقم ٤٩١ في ١٦/٧/١٩٩٤م، ملف رقم ٣٢٤/١/٥٤.

— في هذه الحالة — من مراجعته . والاستثناء من ذلك، جواز مراجعة العقد رغم توقيعه وإبرامه، إذا كان العقد ينص على شرط يقضي بقبول المتعاقد مع الإدارة التعديلات التي يمكن أن تدخلها جهة الفتوى على العقد (وذلك مشروط بطبيعة الحال بعدم تمام تنفيذ العقد قبل تدخل إدارة الفتوى المختصة).

وتطبيقاً لذلك، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلي أن وجود بطلان في تشكيل لجان فتح المظاريف أو البت، لعدم حضور مندوب المالية، أو عضو مجلس الدولة، لا يمنع من مراجعة العقد الجاري إبرامه^(١).

في مراجعة نموذج موحد لمشروع عقد تطبقه الإدارة باستمرار:
انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أنه لما كان الهدف الأساسي من وجوب عرض مشروعات العقود قبل إبرامها، تجنب الإدارة مواطن الخطأ وإدراكه المصلحة العامة في إبرام العقود ، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية اعتبار مراجعة نموذج موحد لمشروع عقد تطبقه الجهة الإدارية في الحالات المتماثلة ما دام متطابقة في وقائعها وشروطها نهجاً تترسمه عند إبرام باقي العقود، مع مراعاة إتباع سائر الإجراءات المقررة ، فإذا تراءى لها إجراء تعديل أو تغيير في أي من شروطه، فإنه يتعين عليها حينئذ الرجوع إلي الأصل العام، وهو عرض مشروع العقد محل التعديل أو التغيير على جهة الفتوى المختصة لمراجعته استقلاً^(٢).

١ فتوى رقم ٥٣١ في ٤/٧/١٩٩٣م، ملف رقم ٣١١/١/٥٤.

٢ فتوى رقم ٢٤٧ في ٧/٥/٢٠٠١م، ملف رقم ٣٧٦/١/٥٤.

وأخيراً فإن الطبيعة القانونية لرأي إدارة الفتوى المختصة، لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً ولا يعد قراراً إدارياً، كما ذهب إلي ذلك البعض^(١).

ومن المسلم به إعمال فكرة الضرورة في هذا المجال. فحيث توجد ظروف استثنائية تبلغ حد الضرورة الملجئة التي توجب إبرام عقد دون الرجوع إلى طلب الرأي الاستشاري مقدماً، فإن لهذه الضرورة وزنها، بحيث يعتبر إبرام العقد في هذه الظروف استثنائياً وبشرط أن تقدر الضرورة بقدرها.

وهناك سؤال يطرح نفسه على بساط البحث وهو:

هل يثبت الخطأ مع بذل الجهة الإدارية العناية الواجبة عند إصدار القرار الباطل؟

اختلفت أحكام الإدارية العليا حول مسؤولية الإدارة، في حال قيام القرار الخاطئ على فتوى من جهة الاختصاص أو في مسألة فنية، تتباين فيها الآراء، أو حيث بذلت الجهة الإدارية العناية الواجبة في اختيار عناصر القرار الذي تقرر بطلانه.

ذهب رأي إلي أنه في هذه الحالة ليس هناك خطأ يمكن محاسبة الجهة الإدارية عليه، بمعنى انتفاء ركن الخطأ.

بينما ذهب اتجاه آخر، يري تحقق الخطأ في هذه الحالة، ويمكن أخذ مسلك الجهة الإدارية في الاعتبار عند تقدير التعويض، بوصف أن القرار — هنا — لم يصدر عن تعمد للجهة الإدارية في مخالفة القانون.

١ راجع مؤلفنا، بطلان العقود، سابق الإشارة إليه ص ٢٧٨.

ويستند الاتجاه الأول (انتفاء ركن الخطأ) على أن مسؤولية الإدارة لا تترتب إلا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما، إذ الأحكام لا تبني إلا على اليقين لا على الظن أو التأويل أو الاحتمال، فإذا كان الأمر في التأويل القانوني مما تتفرق فيه وجوه الرأي وتختلف فيه وجهات النظر، وكان لكل رأي ما يبرره، بحيث لا يمكن القطع بأيهما أصح أو أرجح عند جمهرة رجال المهنة أو الفن، فإنها لا تعتبر ارتكبت خطأ إلا إذا خالفت ، ما استقر عليه الرأي ولم يعد محلا للمناقشة بين رجال المهنة أو الفن، وأصبحت جمهرتهم تسلم به، عندئذ يبدو الخروج على هذا الرأي المستقر مرتباً للمسؤولية جسيما كان هذا الخروج أو يسيراً^(١).

— وعلى ذلك فإن اتجاه الجهة الإدارية إلى الجهة التي ناط بها القانون تفسير مواده، إلا وهي الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع، وهي أعلى جهة قضائية في إصدار الرأي، وإتباع الجهة الإدارية ما صدر به الرأي باعتباره هو صحيح حكم القانون، لا يترتب على ذلك أية مسؤولية على الجهة الإدارية، وهو الركن اللازم والأساسي لقيام دعوى التعويض.

الخلاصة:

إن إصدار الجهة الإدارية قرارها بناء على مشورة ذوي الاختصاص المنوط بهم دراسة الحالة، وإبداء الرأي بشأنها، لا يحقق مسؤولية الإدارة،

١ أ.ع في الطعن ٣٤٩ لسنة ٤ ق في ١٩٦٠/٥/٢١ وفي ذات الاتجاه أ.ع الطعن ١٠٠٥ لسنة ٢٥ ق في ١٩٨٢/٤/٢٥، والطعن ٦٠٧٢ لسنة ٤٢ ق في ٢٠٠١/٧/١ م.

حتى ولو استبان فيما بعد خطأ الرأي الفني (أو القانوني) الذي استندت إليه الجهة الإدارية في قرارها.

وتطبيقاً لذلك قضي: أخذ رأي لجنة الفتوى قبل إصدار القرار وتنفيذه ثم إلغاء القرار من المحكمة بعد ذلك، لا مجال للتعويض^(١).

المبحث السادس

التفويض في مجال العقود الإدارية

١- النصوص القانونية:

تنص المادة (٨١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على أنه: (مع مراعاة الحالات التي يحظر هذا القانون التفويض فيها، يجوز للسلطة المختصة أن تفوض في أي من اختصاصاتها الواردة به لشاغلي الوظائف القيادية دون غيرهم، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)^(٢).

وتقضي (م٧٨) منذ ذات القانون، على أنه: (كما يجوز أن تتوب الجهات المخاطبة بهذا القانون — عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد).

ونشير إلى أن ذات نص (م٧٨) تم نقله من (م٣٨) من قانون المناقصات والمزايدات (السابق) رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م.

١ (أ.ع في الطعون: ٦٨٣١ لسنة ٤٤٤ ق في ١٨/٤/٢٠٠٤م، ٨٢٩٦ لسنة ٤٤٤ ق في ٢٧/٣/٢٠٠٥م).

٢ وقدمنا أن المادة (١٦٦) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد فصلت ، ضوابط وإجراءات التفويض ، ونحيل إليها منعا للتكرار .

مؤدي النصوص السابقة، أن التفويض في مادة العقود الإدارية جائز، سواء تفويض السلطة المختصة أي من اختصاصاتها لشاغلي الوظائف العليا (وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م أو إنابة احدي الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ومنها أيضا الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمخابرات العامة) عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.

والتفويض أو الإنابة — على ما تقدم — لا يقف عند حد توقيع العقد، بل يمتد إلي مباشرة كافة إجراءات التعاقد — منذ لحظة الطرح والإعلان وحتى مرحلة إبرام العقد.

ونفصل ذلك فيما يلي:

١- مفهوم التفويض، هو أن يعهد صاحب اختصاص أصيل ببعض صلاحياته إلي أحد مرؤسية بمعنى أن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة وبحسبانه عملا قاتونيا منفرداً إنما ينصرف إلي الاختصاصات الأصلية التي يستمدّها المفوض مباشرة من القوانين واللوائح.

٢- وثمة مبادئ حاكمة في التفويض، أهمها: أنه لا تفويض إلا بنص فالاختصاص لا يفوض ما لم يوجد نص يسمح به، في حدود هذا النص سواء في موضوعه أو فيمن يصدره، أو من يصدر لصالحه. ويجب أن يكون التفويض جزئياً Partirille أي في حدود معينة، ولا يستغرق كل اختصاصات الأصيل، وذلك ما لم يجيزه المشرع، وعلى ذلك يجب أن يقتصر التفويض على المسائل المحددة بقرار التفويض.

كما يجب نشر قرار التفويض، وهو ما يعني أن التفويض لا يفترض، بل يستلزم قراراً صريحاً بذلك، ومن ثم يجب أن يكون التفويض مكتوباً، ومحددًا مدته.

وأخيراً فالقاعدة أنه لا تفويض في التفويض فلا يجوز للمفوض إليه تفويض غيره فيما فوض فيه، بل يجب عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة إليه بنفسه.

في اختلاف التفويض في الاختصاصات عن التفويض في التوقيع
فالتفويض في التوقيع، لا يعني أكثر من مجرد تفويض المفوض إليه بالتوقيع على بعض القرارات الداخلة في اختصاصات الأصيل، باسمه ولحسابه وتحت رقابته دون أن ينتقل الاختصاص ذاته من الأصيل إلي المفوض إليه بالتوقيع.

في انتهاء التفويض:

وتنتهي حالة التفويض في الاختصاصات بانتهاء مدة التفويض أو بانتهاء موضوع التفويض أو بالغاؤه أو بخروج المفوض أو المفوض إليه أو كليهما من السلطة.

٣- تفويض بالشخص والتفويض بالصفة:

البين من نص (م/٨١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م أن إجازة المشرع للسلطة المختصة تفويض أي من اختصاصاتها الواردة بهذا القانون لشاغلي الوظائف القيادية دون غيرهم، تعني تمتع السلطة المختصة بسلطة تقديرية واسعة، في اختيار المفوض إليه، إما بمراعاة شخص المفوض إليه أو بقدر ما يتمتع به المفوض إليه من مركز وظيفي.

ويطلق على اختيار المفوض إليه بالنظر إلي شخصه دون أي اعتبار آخر، التفويض بالشخص إما إذا نظر إلي المركز الوظيفي للمفوض إليه دون النظر إلي شخصه، فيكون التفويض بالصفة.

إذا كانت تلك هي قواعد التفويض الإداري بصفة عامة وفي مجال العقود الإدارية فإن ثمة تساؤلات تطرح في هذا الشأن:

أولاً: هل يعد نص (م/٨١) المشار إليها سلفاً نصاً خاصاً بالعقود الإدارية، استثناء من أحكام القانون الأساسي للتفويض وهو القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٧م والذي أنشأ هرمًا تدريجيًا للتفويض في بعض الاختصاصات بدءاً من رئيس الجمهورية مروراً برئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وانتهاءً بمديري الإدارات، ورؤساء الفروع والأقسام.

الإجابة: نعم، ذلك أن النص قد أعطي السلطة المختصة تفويض ما تراه من شاغلي الوظائف القيادية في بعض الاختصاصات حسبما تراه لا يحدها في ذلك سوي ما تبينه اللائحة التنفيذية وتضعه من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.

ثانياً: ما هو حكم العقد المبني على تفويض باطل، لم يراع المبادئ الحاكمة في التفويض، سابق ذكرها؟ وما حكم تجاوز المفوض إليه حدود التفويض الممنوح له على العقد؟

فماذا هو مصير العقد، إذا كان القرار بالتفويض صدر بغير نص، أو استناداً إلي نص مرتبته القانونية أقل من المرتبة المطلوبة، أو من غير من يحوز لهم التفويض، أو من غير من يجوز التفويض إليهم، أو في موضوع لا يجوز فيه التفويض في ضوء النص الآن....

في كل هذه الحالات يكون القرار بالتفويض مشوباً بعيب مخالفة القانون، مما يستوجب إبطاله. وبناء على ذلك:

فإنه يترتب على التفويض الباطل (في مجال العقود الإدارية) عدم صحة العقد المبرم، ومن ثم فلا يكون العقد المبرم من جانب السلطة المفوضة صحيحاً إلا إذا كان التفويض مشروعاً في النطاق المحدد له زمنياً وموضوعياً. ومخالفة ذلك تستوجب بطلان العقد. بل وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، إذ يري العقد في مثل هذه الحالات منعدماً^(١).

القضاء الحديث يفصل بين بطلان قرار التفويض وبين العقد ذاته:

يذهب القضاء وتستقر أحكامه على أن قرار التفويض الباطل (في العقد الإداري) لا يعد وأن يكون قراراً إدارياً منفصلاً عن العقد ذاته، بمعنى لا تأثير لذلك القرار الباطل على العقد الذي يظل صحيحاً على نحو ما أوضحنا عند دراسة موضوع قضاء الإلغاء في العقود الإدارية، نظرية القرارات الإدارية المنفصلة، فنحيل إليها.

والسؤال المحوري والهام جداً في هذا الشأن، يثور حول مدى فعالية رقابة الإلغاء على القرارات الإدارية المنفصلة في مجال العقود الإدارية.

المسلم به أن ذلك التأثير وتلك الفاعلية تظهر إما في تعديل القرار الإداري المعيب (أي القرار المنفصل عن العقد بعد إلغاؤه بحكم قضائي). أو في مدى إمتداد ذلك إلى إلغاء العقد الإداري. كما قد يرتبط إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد بالحكم بالتعويض. بمعنى واضح وفي

^١ راجع مؤلفنا: البطلان في العقود الإدارية.. مرجع سابق ص ٢٨٠ وما بعدها.

عبارة محددة إن إلغاء القرار الإداري المنفصل من العقد، له تأثير سلبي على باقي العملية التعاقدية.

وقدّمنا أن نظرية القرارات الإدارية المنفصلة لا تثور في مجال العقود الإدارية، إلا في مرحلة إبرام العقد. أما في مجال تنفيذ العقد فلا إبطال، وإنما ترتيب المسؤولية الإدارية. وأنه سواء في إبرام العقد أو في تنفيذه، فإن للأصل إلغاء قرارات المفوض إليه، لمخالفتها المشروعية، فضلا عن المسؤولية التأديبية للمخالف.

هل هناك قرارات لا يجوز التفويض فيها؟

الإجابة: نعم، الاتفاق على تسوية منازعات العقد بالطرق الودية، سواء التوفيق، أو الوساطة، أو التحكيم، فلا يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة اللجوء إلى هذه الوسائل إلا بموافقة السلطة المختصة، ولا يخضع هذا الإجراء ولا يجوز أن يكون محلا للتفويض (م/٩١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، وهو ما كان يجري عليه أيضا القانون السابق رقم ٨٩ لسنة ٩٩٨ في نص (م/٤٢) كما أن ثمة حالات أخرى يحظر فيها التفويض ، سنعرض لها بعد قليل.

كما وأننا نرى وجوب خضوع بعض العقود الكبيرة وذات الأهمية — كقاعدة — لتوقيع السلطة المختصة ذاتها.

وسؤال أخير: هل يجوز إنباء شخص معنوي خاص في إبرام عقد إداري لحساب ومصلحة شخص معنوي عام؟

نعم.. يعد العقد إداريا وبشرط أن يكون العقد متعلقا بنشاط مرفق عام، واتباع فيه وسائل القانون العام. وقدّمنا أنه لم يعد المعيار الشكلي (جهة الإدارة) هو المعمول به في العقود الإدارية وإنما المعيار الموضوعي الذي يستند إلى تعلق العقد بنشاط مرفق عام وتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

تلك هي قواعد التفويض في مجال العقود الإدارية، بإيجاز.

الفصل الثاني

طرق التعاقد

تمهيد:

بينما كان القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م بشأن المناقصات والمزايدات، قد جعل أسلوب التعاقد الأصلي (طريقة التعاقد) ، هو المناقصات العامة أو الممارسة العامة (م/١ من القانون). جاء القانون الجديد رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، **ليجعل من المناقصة العامة، أسلوب التعاقد الأصلي، بغية تحقيق مبادئ العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق الصالح العام، وحماية المال العام، وترشيد الاتفاق، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في إدارته.** وقد أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م (محل الدراسة) على سبيل الاستثناء وبقرار من السلطة المختصة إجراء التعاقد بإحدى الطرق الآتية:

الممارسة العامة، أو الممارسة المحدودة، أو المناقصة ذات المرحلتين، أو المناقصة المحلية، أو الاتفاق المباشر (م/٧).

بينما نص على طريق التعاقد بأسلوب المزايدة العلنية العامة ، أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، في حالة التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات المغلقة.

وأجاز، استثناء — وبقرار من السلطة المختصة — إجراء التعاقد في هذه الحالات بإحدى الطرق الآتية: المزايدة المحدودة أو المزايدة المحلية، أو الاتفاق المباشر.

وقد حدد القانون مجالات التعاقد لكل طريقة من تلك الطرق، واستحدث القانون الضوابط التي تحكم كل طريقة منها. وسنعرض فيما يلي كل طريقة من طرق التعاقد ومجالاتها، طبقاً لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، والضوابط التي تحكم كل طريقة منها.

المبحث الأول

حالات التعاقد بالمناقصة

قدمنا أن المشرع قد رسم لكل طريقة من طرق التعاقد (أساليب التعاقد) حدودها وضوابطها.

وإذ كان القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، جعل أسلوب المناقصة العامة هي الأصل في التعاقد (في مجالات محددة وبضوابط لكل منها) . فإنه قد أجاز التعاقد، بطرق أخرى (وبضوابط محددة) وهذه الطرق هي: المناقصة المحدودة، أو المناقصة المحلية، أو المناقصة ذات المرحلتين.

ونعرض لكل من الأصل العام في التعاقد (المناقصة العامة) ، ثم نتبع ذلك بالطرق الأخرى (الاستثنائية) كل في مطلب مستقل، على ما يلي:

المطلب الأول

حالات التعاقد بالمناقصة العامة

حدد المشرع حالات التعاقد بالمناقصة العامة في الآتي:

شراء أو استئجار المنقولات والعقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية . والبين من ذلك أن المشرع قد أكمل نقصا بالقانون الجديد ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م أغفل عنه المشرع في القانون السابق (٨٩ لسنة ١٩٩٨م) ، فقد كان القانون السابق (٨٩ لسنة ١٩٩٨م) قد مايز في أحكامه (أو لائحته التنفيذية) بين ما يتعلق بشراء المنقولات وتلقي الخدمات والمقاولات من ناحية ، وشراء واستئجار العقارات من ناحية أخرى، طريقا خاصا وأحكاما متفردة لا يتسع أحدهما ليشمل الآخر، وإنما جاء كل من الطريقين مستويا بذاته منفرداً بحكمه، لاعتبارات قدرها المشرع في كل منهما (فقد نص القانون الملغي في المواد من ٢٧ — ٢٩ الباب الثاني، على كيفية شراء واستئجار العقارات، بينما خصص الباب الثالث في المواد من (٣٠ — ٣١) على كيفية بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات)^(١).

وتطبيقا لهذه النصوص، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلي عدم جواز استعارة أحد الطريقين أو مد مظلته لتشمل تعاقدًا تنظمه أحكام الطريق الآخر، وأيدت ما انتهى إليه رأي اللجنة

^١ عرف القانون مقاولات الأعمال بأنها كل ما يدخل ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ويعتمد من وزير الإسكان وتحظر به الهيئة العامة للخدمات الحكومية نشرها على بوابة التعاقدات العامة.

الأولي لقسم الفتوى بمجلس الدولة عند مراجعة مشروع العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها بطريق الاتفاق المباشر، إلي عدم جواز إبرامه بذلك الطريق، إذ أن هذا التعاقد شرع في إجراءاته دون إتباع الإجراءات المقررة لشراء العقارات بالقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م^(١).

وأراد المشرع بالقانون الجديد تصحيح الوضع، وبسط سائر إجراءات التعاقد على شراء المنقولات بما فيها الاتفاق المباشر، على شراء واستئجار العقارات، فنصت م/٦١ منه على: (تسري على شراء واستئجار العقارات ذات الأحكام المنظمة لشراء واستئجار المنقولات، وبما لا يتعارض مع طبيعتها).

ولا شك أن (عبارة) وبما لا يتعارض مع طبيعتها، التي وردت في عجز المادة المشار إليها تضع على عائق اللائحة التنفيذية، ضرورة مراعاة طبيعة كل من مجالات التعاقد الواردة بتلك المادة وجواز التمايز بينها في حالات محددة، حسب طبيعة محل التعاقد وبضوابط محددة.

المطلب الثاني

حالات التعاقد بالمناقصة المحدودة

حددت المادة (٥٧) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م، سبع حالات، يكون التعاقد فيها بطريق المناقصة المحدودة، وهي:

١-العمليات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو استشاريين أو خبراء بذاتهم، سواء في مصر أو الخارج.

^١ فتوى رقم ٢١٤ في ٣/٥/٢٠٠٠ م ، ملف ٥٤ /١/ ٣٦٤.

٢-العمليات التي اتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق بشأنها، وبحيث تتم الدعوة لمن تم تأهيلهم للاشتراك فيها^(١) (وتلك من الاستحداثات الجديدة ، التي جاء بها القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ ، إضافة إلى ماسبق بيانه قبلاً).

٣-التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.

٤-توفير المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالمحافظة على الحياة والصحة.

٥-إذا كان الوقت أو التكلفة اللازمان للطرح بطريقة المناقصة العامة، لا يتناسبان مع قيمة التعاقد.

٦-عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة التي تم طرحها مرة أو أكثر، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلي مناسبة تغيير الطرح.

أما الحالة السابعة ، فقد نصت عليها م/٧٣ من القانون وهي حالة التعاقد على الدراسات الاستشارية^(٢).

١ قدمنا أن التأهيل المسبق، وفقاً لتعريف القانون (م/١) هو إجراء تتخذه الجهة الإدارية، وتعلن عنه للتأكد من توافر القدرات الفنية والإمكانيات المالية والإدارية والبشرية وغيرها، لدى الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أو الاستشاريين للقيام بتنفيذ أحد العقود وبالكفاءة المطلوبة، قبل دعوتهم لتقديم العطاءات، وفقاً لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل.

وقد أوجب القانون الإعلان عن التأهيل المسبق بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وبوابة التعاقد.

٢ وقد عرف القانون الدراسات الاستشارية، بأنها ما يغلب عليه الطابع الفكري أو الإرشادي، ومن ذلك الدراسات الهندسية أو المهنية أو الاقتصادية أو المالية أو الإدارية=

وقد أجاز القانون بمقتضى تلك المادة، جواز التعاقد في هذه الحالة عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين، أو المناقصة المحلية.

إذا فثمة حالات ست، لا يجوز التعاقد فيها إلا بأسلوب المناقصة المحدودة، وهي كما يبين من نص م/٥٧ - تتعلق جميعها، إما بالتعاقدات المرتبطة بالأمن القومي أو المحافظة على الصحة العامة أو المجالات ذات الخبرة المحددة في أشخاص محددين، أو تلك التي لا يسعف الوقت فيها إتباع إجراءات المناقصة العامة، أو تلك التي تري الجهة الإدارية تغيير طريقة الطرح للاعتبار المشار إليه بهذه المادة. كما أجاز القانون، استثناء، في العمليات ذات الطبيعة النمطية أو البسيطة التي لها أطر فنية ثابتة التعاقد عليها بطريق المناقصة العامة أو المحلية أو الاتفاق المباشر، إذا قدرت الجهة الإدارية أن أيا من هذه الطرق هو الأنسب بحسب طبيعة العملية.

كما أجاز القانون للجهة الإدارية التعاقد مع أحد الاستشاريين بذاته من خلال مناقصة محدودة أو محلية أو اتفاق مباشر، إذا قدرت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلي على خبراته ومؤهلاته.

=أو القانونية، بما في ذلك مهام الإعداد والتصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام.

ويقصد ببوابة التعاقدات العامة، الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة الانترنت للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة للجهات العامة وإجراءات التعاقد.

وأوجب القانون (م/٧٣) أن يصدر بإتباع أي من هذا الطرق قرار مسبب من السلطة المختصة، وفقا لظروف التعاقد، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة.

وأجاز القانون، للجهة الإدارية، إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح. إذا الحالات الست الأولى (م/٥٧) لا سبيل للتعاقد بشأنها إلا بطريق المناقصة المحدودة أما فيما يتعلق بالدراسات الاستشارية، فيجوز التعاقد بشأنها بإحدى طرق أربعة: المناقصة المحدودة، أو المناقصة المحلية، أو المناقصة ذات المرحلتين، أو الاتفاق المباشر. وطريق الاتفاق المباشر، إضافة للطرق الأخرى، قاصر على التعاقد مع أحد الاستشاريين بذاته والتعاقدات النمطية، بالشروط والضوابط المشار إليها.

المطلب الثالث

حالات التعاقد بالمناقصة المحلية

نصت على هذه الحالات م/٥٩ من القانون . وقد ربط القانون التعاقد بهذا الطريق (المناقصة المحلية) بالقيمة المالية للتعاقد، فأجاز التعاقد بهذا الطريق فيما لا تزيد قيمته على أربعة ملايين جنيه.

كما قصر المشرع اللجوء إلي هذا الطريق على: الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية (وهي ما تتسم بالإبداع الفني وفقا للطابع الشخصي ومن ذلك الرسم والتصوير وتأليف الكتب والبحوث) والاستشاريين المحليين، الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم

بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد، ومن بينهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

بل أجاز القانون في ذات المادة قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية، فيما لا يزيد على مليوني جنيه، على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي يقع نشاطها في نطاق المحافظة التي قيم في دائرتها تنفيذ موضوع التعاقد.

وقد اتجه القانون صوب التيسير على تلك المشروعات في إجراءات التعاقد إذا جاز القانون للسلطة المختصة، الاكتفاء بتقديم إقرار بديل عن التأمين المؤقت في العملية محل الطرح، بل وأجاز — أيضا — للسلطة المختصة صرف دفعة مقدمة، وفقا لما تعتمده، على أن تتضمن شروط الطرح ذلك.

ورغبة في تشجيع تلك المشروعات والاهتمام بها، أجاز القانون، في حالة عدم تقدم أي منها للمناقصة، إعادة الطرح وتوجيه الدعوة لهم ولغيرهم، ولكن في هذه الحالة، لا يتم استثناء تلك المشروعات من التأمين المؤقت، إذ الإعفاء من التأمين المؤقت مرهون بتقدم تلك المشروعات في المناقصة في الطرح الأول للعملية موضوع التعاقد.

وبخصوص تلك الحالة (المناقصة المحلية) أوجب القانون قبل الطرح إخطار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لإعلام أصحاب بتلك المشروعات بالمحافظة التي يتم بدائرتها التنفيذ، لحثهم عن تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة.

مجل القول: ربط المشرع إتباع أسلوب المناقصة المحلية بالقيمة المالية للتعاقد، وأعطى المشرع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مميزات خاصة، تشجيعاً لها، ودعماً لدورها في تنمية المجتمع المحلي.

ملحوظة جوهريّة: من المسلم به أن المشرع في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م قد حظر بأي حال من الأحوال تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها (بطريق المناقصات – بكل صورها –) إلي طريق تعاقد آخر ، بل ويعد التعاقد بغير الطريق الذي حدده القانون باطلاً ، مع عدم الاخلال بالمسئولية (بكافة صورها) على عاتق المخطئ ، بل ، ونرى أن التعاقد بغير الطريق الذي رسمه القانون ، اخلاً جسيماً ، يستوجب توقيع أشد العقاب على المخالف .

المبحث الثاني

التعاقد بالمزايدة

المطلب الأول

المزايدة العامة

أوجب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، أن يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة وجاز استثناء، بقرار مسبب من السلطة

المختصة، بناء على عرض إدارة التعاقدات، إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:

— المزايدة المحدودة

— المزايدة المحلية

— الاتفاق المباشر

(المادة (٢) فقرة (٢) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م)

وأخضع المشرع هذه العمليات للقواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات أو استئجارها، فيما لم يرد به نص خاص، وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص أو الاستغلال، بالحصول على العرض الأعلى سعراً (م/٧٠).

كما ونظم المشرع التعاقد في الخارج على بيع أو تأجير العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، بأن أوجب إتباع الإجراءات المعمول بها في الدولة محل التعاقد، وسريان أحكام هذا القانون (١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) فيما لم يتعارض معها (م/٧٢). وأنه في حالة تعذر ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد، وفقاً للشروط والقواعد التي يعتمدها، بناء على اقتراح الوزير المختص بالجهة الإدارية — ذات المادة —.

التفرقة بين ما إذا كان التعاقد داخلياً أو خارجياً:

وهكذا تتحدد مجالات التعاقد بطريق المزايدة العامة، أو المزايدة بالمظاريف المغلقة، لدي بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو

استغلال العقارات والمشروعات، وبديهي أن تخضع التعاقدات لهذه العمليات، للقواعد والإجراءات المنظمة للمناقصات العامة أو المناقصة بالمظاريف المغلقة، وبما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص أو الاستغلال بالحصول على العرض الأعلى سعراً. هذا إذا كان محل التعاقد في تلك الحالات داخلياً، إذ تحكمه القواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م.

أما في حالة التعاقد في الخارج، فقد أخضع القانون، مجالات التعاقد في الحالات المشار إليها للإجراءات المعمول بها في الدولة محل التعاقد، ولا تسري أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على تلك الحالات، فيما لا يتعارض مع قانون الدولة محل التعاقد. وإذ تحسب المشرع لتعذر تحقيق ذلك الأمر، فاشتراط موافقة مجلس الوزراء على التعاقد، وفقاً للشروط والقواعد التي يعتمدها، بناءً على اقتراح الوزير المختص بالجهة الإدارية محل التعاقد.

المطلب الثاني

حالات التعاقد بالمزايدة المحدودة والمزايدة المحلية

قدمنا أن المادة (٧) فقرة (٢) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بعد أن حددت حالات التعاقد بالمزايدة العامة أو المزايدة المغلقة، أجازت للسلطة المختصة، وبقرار مسبب منها وبناءً على عرض إدارة التعاقدات، إجراء التعاقد في الحالات السابقة بإحدى طرق المزايدة المحدودة أو المزايدة المحلية أو الاتفاق المباشر.

وفيما يتعلق بطريق المزايدة المحدودة، فقد تحدد نطاق حالات التعاقد بشأنه فيما نصت عليه المادة (٦٨) من القانون، وهي:

— الأصناف التي يخشي عليها من التلف ببقاء تخزينها (أي التي تستوجب سرعة التصرف فيها).

— الأصناف التي تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها.

— الحالات العاجلة، التي لا تحتمل إجراءات المزايدة العلنية العامة، أو بالمظاريف المغلقة.

— الحالات التي سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، لأكثر من مرة، ولم تقدم عنها أي عروض أو لم يصل ثمنها إلي الثمن الأساسي، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلي مناسبة تغيير طريقة الطرح.

ويلاحظ هنا، مدي التماثل بين تلك الحالات ومثلتها في طريق المناقصة المحدودة، إذ بينما المزايدة تستهدف الحصول على أعلى سعر، تكون المناقصة بالإرساء على الأقل سعراً وجودة فنية.

وأما فيما يتعلق بطريق المزايدة المحلية، فشأنه في ذلك — أيضا — شأن المناقصة المحلية، قد ربطه المشرع بقيمة التعاقد، فقصر إتباع هذا الطريق على التعاقدات، فيما لا يجاوز الثمن الأساسي فيها ستمائة ألف جنيه بل وقصر الاشتراك في تلك المزايدات (المحلية) على المتزايدين المحليين، الذي يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي ينفذ بدائرتها موضوع التعاقد.

وهنا أيضا يسري ذات القيد، المشار إليه في م/٧ من القانون، بعدم جواز تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة (المناقصات، والمزايدات بأنواعها المختلفة) إلى طريق تعاقد آخر بأي حال من الأحوال.

ووجوب أن يتم التعاقد في هذه الحالات وفي غيرها في الحدود، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

المبحث الثالث

التعاقد بالممارسة

تحددت حالات التعاقد بالممارسة العامة، في م/٥٤ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بينما تناولت م/٥٥ من ذات القانون، حالات الممارسة المحدودة فقد نصت م/٥٤ على أن:

يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة في الحالات التي تتوافر فيها الشروط الآتية (ثلاثة شروط):

— أن يكون متاحاً للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد.

— أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمي، والتي يتم على أساسها تحديد مدي استجابة العروض فنياً.

— أن يكون معلوماً للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات للمشاركة في العملية، لضمان تحقيق المنافسة الفعالة.

— والواضح من نص المادة — المشار إليها — خضوع مجالات التعاقد بالممارسة العامة لضوابط محددة، كونها ترد على مجالات دقيقة، خاضعة للقياس الكمي وفق معايير محددة، فضلاً عن وجوب توافر عدد معقول من المتنافسين، بما يسمح بالمفاضلة بينهم.

وقد أجاز القانون م/٥٥ التعاقد بطريق الممارسة المحدودة (وبمراعاة حكمي البندين ١، ٢ من المادة السابقة) في أي من الحالات الآتية:

١- الأصناف التي يتم تصنيعها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها أو الأصناف التي تقتضي صيغتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.

٢- التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.

٣- الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود حالياً بسبب عدم وجود بدائل لها، وتكون متوافرة لدي أكثر من مصدر (لتحقيق المنافسة الفعالة).

إن التعاقد بطريق الممارسة (بنوعيتها) ذا طبيعة خاصة في محل التعاقد، يجب مراعاتها عند اتخاذ إجراءات الطرح.

المبحث الرابع

الاستثناءات التي ترد على طرق التعاقد المحددة

١- حالة إبرام اتفاقية إطارية (م/٦٥) من القانون:

أورد المشرع في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بعض الاستثناءات على طرق التعاقد المحددة بأحد أسلوبَي المناقصة أو الممارسة على ما تقدم. إذ أوجب القانون على ما أوضحنا عدم جواز تحويل أي من طرق التعاقد بالمناقصة (بأنواعها)، أو الممارسة بنوعيهما إلى طريق آخر فلكل منهما مجاله وقواعده وشروطه وضوابطه القانونية في القانون ولائحته التنفيذية.

إلا أن المشرع قد خرج على تلك الطرق العامة المحددة في مجالاتها التعاقدية، وأجاز التعاقد بأي من الأسلوبين المناقصة أو الممارسة حال إبرام اتفاقية إطارية (م/٦٥).

وتنص م/٦٥ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على أنه: (يجوز للجهة الإدارية طرح احتياجاتها أو احتياجات جهة إدارية أخرى أو أكثر، بإتباع طريق المناقصة أو الممارسة بنوعيهما أو طريق الاتفاق المباشر) وبما يتفق وطبيعة العملية محل الطرح وإبرام اتفاق إطاري مع من يقع عليه الاختيار، يتضمن القواعد والشروط التي سيحري من خلالها إصدار أوامر التوريد أو الإسناد، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١- الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف أو لتنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الخدمات الاستشارية، والتي تتسم أي منها بالعمومية أو شيوع الاستخدام.

٢- توقع الجهة الإدارية وفقاً للمجري العادي للأمور، بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية المطلوب، أن الحاجة ستنشأ إليها مستقبلاً بصورة عاجلة، دون أن يكون معلوماً لديها على وجه الدقة توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها.

٣- الحالات الأخرى التي تري الجهة الإدارية مناسبة إتباع هذا النمط من التعاقدات بما في ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات أو ترميم الاحتياجات وغيرها من الحالات المماثلة.

أي أن السماح للجهة الإدارية بجواز التعاقد بأي طريق من طرق التعاقد (جميعها) المناقصة أو الممارسة بنوعيهما — أو الاتفاق المباشر، تتحدد مجالاته في الاتفاقية الإطارية تلك التي يبين منها للجهة الإدارية أنها حالات متكررة، تتسم بالعمومية، أو تلك التي تتوقع الجهة الإدارية الحاجة العاجلة لها مستقبلاً كما أعطي المشرع للجهة الإدارية سلطة تقديرية في إتباع أي من هذه الطرق، إذا رأت أنه الأسلوب المناسب لها. وتتعدد مجالات التعاقد في هذه الحالة، فتشمل الأصناف، أو تنفيذ الأعمال، أو تقديم الدراسات الاستشارية (بأنواعها المختلفة).

— واشترط القانون بذات المادة ٦٥ أن تتضمن شروط الطرح المواصفات الفنية والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب، ومعدلات الاستهلاك التاريخية، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد، أو أطر الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية بحسب الأحوال.

— وأحال القانون على اللائحة التنفيذية له، بيان قواعد وإجراءات إبرام أو إنهاء الاتفاقية الإطارية، وأنماطها المختلفة ومدتها، وإصدار

أوامر التوريد أو الإسناد، وأداء التأمين وفقاً لها م ٣/٦٥ (وسوف نعود لهذه النقطة تحديداً ، بعد قليل ، بالدراسة الموجزة).

٢- التعاقد بالمسابقة للحصول على عمل ابتكاري:

أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م للجهة الإدارية عدم التقيد بطرق التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون وأن تعلن عن مسابقة للحصول على عمل ابتكاري يتم اختياره من خلال لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة، تشكل بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض، وفقاً لعناصر وأسس التقييم المعلنة لتحديد العمل الفائز (م ١/٦٦ من القانون).
— ويكون الإعلان عن المسابقة بإحدى الصحف القومية واسعة الانتشار، بالإضافة إلى النشر عنها على بوابة التعاقدات العامة.

المبحث الخامس

إلغاء المزايدة (أو المناقصة) أو الممارسة

أولاً: حالات الإلغاء الوجوبي للتعاقد:

- ١- في المناقصة أو الممارسة: أوجب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م إلغاء المناقصة أو الممارسة في حالات محددة، هي: (م/٣٧):
 - (أ) إذا استغني عنها نهائياً.
 - (ب) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
 - (ج) إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو^(١) إذا تبين ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار^(٢).
 - (د) إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات.
- والمعلوم أن الفساد في أبسط تعريف له، يعني سوء استخدام الموقع الوظيفي، بهدف تحقيق منافع شخصية، أو هو كل عمل يتضمن

^١ يعرف التواطؤ — وفقاً لأحكام القانون المشار إليه — بأنه ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر، قبل أو بعد تقديم العطاء، لتحقيق غرض غير مشروع، أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة، بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات، أو تثبيت أسعار العطاءات بشكل غير تنافسي (م/١).

^٢ بينما يعرف الاحتيال بأنه أي فعل أو امتناع عن فعل، يؤدي إلى تضليل الطرف الآخر، بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ العقد.

سوء استخدام المنصب العام، لتحقيق مصلحة خاصة^(١).

— بينما يعرف القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م الفساد، بأنه: أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ العقد.

— وربما يثور التساؤل حول الفساد الذي يوجب إلغاء المناقصة أو الممارسة أو المزايدة، هل هو فساد الموظف العام أم فساد أحد المتنافسين في التعاقد؟

الإجابة عندي، أن الفساد أياً كان نوعه، يترتب عليه إلغاء التعاقد، على الرغم من أن تعريف القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م للفساد، ربما ينبئ أنه الفساد المتعلق بأطراف العقد.

— ولا يخل إلغاء التعاقد، بمسائلة الموظف المخالف إذا تحققت في شأنه مبررات المسؤولية، خاصة في حالة إذا تبين وجود نفعي أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات.

ثانياً: حالات الإلغاء الوجوبي للمزايدة:

— أوجب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م إلغاء المزايدة وجوباً في الحالات الآتية:

(أ) إذا استغني عنها نهائياً.

^١ راجع: مؤلفنا بعنوان: مشكلات الإدارة العامة (الفساد الإداري) ط/٢ — ٢٠١١م، ص ٢٥.

(ب) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

(ج) إذا لم تصل نتيجتها إلي الثمن أو القيمة الأساسية.

(د) إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين المتزايدين، أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار (م/٣٨).

ثالثاً: حالات الإلغاء الجوازي للتعاقد: (م/٣٧، ٣٨) من القانون:

١- في المناقصة أو الممارسة أو المزايدة: يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد مستوفي للشروط هذا السبب يشمل كافة صور التعاقد الثلاثة، ويضاف إلي تلك الحالة، الحالات الآتية في شأن المناقصة أو الممارسة:

(ب) إذا لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد، ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح، وبشرط أن يكون العطاء مطابقاً للشروط ومناسباً للقيمة التقديرية.

ويلاحظ هنا أسباب الإلغاء بشكل واضح.

(ج) بل إنه يجوز إلغاء المناقصة أو الممارسة، إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة، عدم جدوى إعادة الطرح، والآثار المترتبة عليه.

(د) إذا اقترنت العطاءات كلها أو بعضها بتحفظات.

رابعاً: الآثار المترتبة على إلغاء التعاقد:

١- بداية، يجب أن يكون قرار إلغاء التعاقد مسبباً.

٢- وأن يصدر من السلطة المختصة.

٣- ويجب أن ترد قيمة كراسة للشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات، عدا مقدمي العطاءات التي تبين وجود تواطوء بينهم، أو ممارسات احتيالية، أو فساد، أو احتكار.

— واستثناء تلك الفئات من رد ثمن كراسات الشروط والمواصفات، والتأمين المؤقت، يعد أمراً منطقياً، بل ويجوز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، أن كان لها محل.

خامساً: الطبيعة القانونية لإلغاء التعاقد:

قدما أن القرارات الصادرة من الجهة الإدارية في مرحلتي التعاقد، سواء السابقة على إبرام العقد، أو مرحلة إبرام العقد، تعد جميعها قرارات إدارية منفصلة، يجوز الطعن فيها بالإلغاء، ويطبق في شأنها أحكام نظرية القرارات الإدارية، سواء من حيث شروط قبول الطعن في هذه القرارات، ومواعيد الطعن فيها، وكذلك شروط طلب وقف تنفيذ تلك القرارات، وتدخل هذه القرارات في اختصاص قاضي الإلغاء.

— على العكس من القرارات الصادرة بتنفيذاً للعقد، فتدخل جميعها في اختصاص قاضي العقد — القضاء الكامل — مثل قرارات الفسخ، أو

الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها... والمعلوم أن قرار إلغاء التعاقد يجب أن يصدر من السلطة المختصة.

سادساً: البطلان جزاء إخلال جهة الإدارة بطريقة التعاقد المحددة قانوناً:

— من المسلمات أن المشرع قد ألزم الجهة الإدارية بالتعاقد بطريق أو بطرق محددة، في بعض الحالات المنصوص عليها قانوناً. وعليه إذا ولت الجهة الإدارية وجهها عن هذه الطرق (والإجراءات المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية) كان تصرفها مخالفاً للقانون، وعليها أن تعيد نظرها في العقد بالتحلل منه كاملاً، أو بعضه، في ضوء ما تسفر عنه المراجعة.

— وقدّمنا أن إلغاء القرار الإداري المنفصل في عملية التعاقد، لا يترتب عليه بطلان العقد، وإن كان له تأثير سلبي على عملية التعاقد. وقد أوجب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م الالتزام بالطريقة المحددة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها، وحظر تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها إلى طريق تعاقد آخر (م/٧) ولا شك أن البطلان يعد جزاء مخالفة ذلك الخطر، فضلاً عن المساءلة — على ما فصلنا —.

المبحث السادس

التعاقد بطريق الاتفاق المباشر

— البين من مطالعة القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (محل الدراسة)، أنه قد توسع إلي حد كبير (جداً) في حالات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بما نال كثيراً من الأصل العام في التعاقد، (أسلوب المناقصة العامة أو المزايدة العامة — على نحو ما فصلنا قبلاً) على الرغم من أن التعاقد بهذا الطريق (طريق الاتفاق المباشر) يعد استثناء من الأصل العام.

— ويكفي أن نشير إلي أن المشرع قد نص على هذا الأسلوب في التعاقد في إثني عشرة مادة (المواد ٧، ٣٠، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٧٤، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠).

— ونعرض للأحكام المنظمة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فنبين حالات التعاقد الجوازية والوجوبية وأحكام الترسية وذلك على النحو الآتي:

أولاً: يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، في أي من الحالات الآتية (م/٦٢) من القانون:

- ١- الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية، التي لم يكن في الإمكان توقعها أو التنبؤ بها، أو التي تتطلب الضرورة التعامل معها بشكل فوري، ولا تحتل إتياع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيتها.
- ٢- وجود مصدر واحد فقط، لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد، أو لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد.

٣-تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا يوجد سوي مصدر واحد.

٤-عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم، ونقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.

٥-الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيتها، وذلك لضمان سلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخر في اتخاذ الإجراءات.

٦-في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم.

٧-في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

وقد ألزم المشرع الجهة الإدارية في الحالات الثلاث الأخيرة (٥، ٦، ٧) الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر فيها. — ويلاحظ هنا أن هذه الحالات السبع — جميعها — يجوز للجهة الإدارية التعاقد فيها بطريق الاتفاق المباشر، وليس لازماً إتباع الطريق — هذا — في تلك الحالات، إذ يجوز التعاقد بشأنها بأي من طرق التعاقد الأخرى، مع وجوب الالتزام بالطريقة المحددة لكل حالة من حالات التعاقد، على نحو ما نص عليه في (م/٧) من القانون — وعلى ما قدمنا — قبلاً ولكن إذا اتجهت إرادة الجهة الإدارية إلي إتباع هذا الطريق، عليها بيان أسباب ذلك، بحسبان أن طريق الاتفاق المباشر، يعد استثناء على الأصل العام في التعاقد على ما تقدم.

كما يجوز للجهة الإدارية طرح احتياجاتها أو احتياجات جهة إدارية أخرى أو أكثر باتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك في الحالات الآتية: (م/٦٥) من القانون.

٨- الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الدراسات الاستشارية، والتي تنسم أي منها بالعمومية أو شيوع الاستخدام.

٩- توقع الجهة الإدارية وفقا للمجري العادي للأمر بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية المطلوبة، أن الحاجة ستنشأ إليها مستقبلا، بصورة عاجلة، دون أن يكون معلوماً لديها على وجه الدقة توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها.

١٠- الحالات الأخرى التي ترى الجهة الإدارية مناسبة إتباع هذا النمط من التعاقدات، بما في ذلك استهداف تنمية الصناعات، أو ترميط الاحتياجات، وغيرها من الحالات المماثلة.

— ففي هذه الحالات — كسابقها — يجوز للجهة الإدارية التعاقد بشأنها بأي أسلوب من أساليب وطرق التعاقد، بما فيها طريق الاتفاق المباشر، ويجب أن يبين أيضا سبب إتباع هذا الطريق في التعاقد وطرح طرق التعاقد الأصلية، فيجب بيان طبيعة العملية محل الطرح، وإبرام اتفاق إطاري مع من يقع عليه الاختيار، يتضمن القواعد والشروط التي سيجرى من خلالها إصدار أوامر التوريد أو الإسناد.

— وقد أوجب القانون في تلك الحالات، أن تتضمن شروط الطرح المواصفات الفنية، والبيانات والإحصاءات لمعدلات الطلب، ومعدلات

الاستهلاك التاريخية، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح أو التعاقد، أو آخر الخدمات أو الدراسات الاستشارية بحسب الأحوال.

— وتعد الاتفاقية الإطارية من الاستحداثات الجدية بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م والمعلوم أن الاتفاقية الإطارية، تأتي تعميقاً لفكر الشراء المجمع (بأن يكون الطرح مركزياً، التعاقد والتوريد لا مركزياً)، لتحقيق فكر اقتصاديات التوزيع الكمي، وترشيد النفقات، وسرعة تلبية احتياجات الجهات الحكومية، وبمراعاة جودة التوريدات وتنميتها.

وتعد تلك القواعد والإجراءات، فضلاً عما قد تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون، بمثابة ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر.

— وكذلك أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م للجهة الإدارية التعاقد بطريق الاتفاق المباشر (وبمراعاة أحكام المادة (٦٢) المشار إليها قبلاً) في الحالات الآتية: (م/٧٤) من القانون.

١١- التعاقد مع أي من مقدمي الخدمات الأساسية التي تمتلك الدولة فيه حصة حاکمة، تسمح لها بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارته، أو التحكم على أي نحو في القرارات الصادرة من مجلس إدارته، أو من الجمعية العامة له على تقديم الخدمات الأساسية ومن ذلك الكهرباء، والمياه، والغاز، وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام ذات الطبيعة المماثلة والمحددة أسعارها من الدولة.

ونظراً لحيوية هذه الخدمات وأهميتها، استثنى المشرع مقدمو الخدمات الأساسية من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة، ومن أداء التأمين بنوعية، ويكتفي بما يقدم فهم من تعهدات أو مخالفات تقرها السلطة المختصة.

والسلطة المختصة التفويض في أي من هذه الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة (الفقرة الأخيرة من م/٧٤).

وربما يثور التساؤل حول مدى جواز التفويض في اختصاصات السلطة المختصة بصفة عامة، ومرد ذلك التساؤل نص المشرع صراحة في عجز المادة (٧٤) سالف الإشارة إليها — على جواز التفويض في اختصاصات السلطة المختصة في هذه المادة.

— قدمنا أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م قد نص صراحة على جواز التفويض في اختصاصات السلطة العامة — كقاعدة — بشاغلي الوظائف القيادية دون غيرهم، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (م/٨١ من القانون).

— على أن ثمة حالات لا يجوز التفويض فيها، نص عليها صراحة، وأبرزها لجوء الجهة الإدارية للتعاقد لحل منازعاتها التعاقدية بالطرق الودية (م/٩١ من القانون) والتعاقد بالطريق المباشر.

١٢- وكما أجاز القانون مجلس الوزراء التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، فضلا عن حالات الضرورة، الترخيص للجهة الإدارية (المحددة بعينها) التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي، حال تقدمه (بمشروع استثماري متكامل) شاملا التمويل إذا كان المشروع يحقق للجهة الإدارية الأهداف الاقتصادية والتنمية للدولة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة وزير المالية والتخطيط (م/٨٧) من القانون.

ويلاحظ أن المشرع في هذه الحالة قد استوجب صدور قرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من مجلس الوزراء، وبضوابط محدودة.

ونشير أن هذه ليست الحالة الوحيدة التي يسلتزم فيها موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بهذا الطريق (الاتفاق المباشر)، بل واستوجب القانون أيضا اعتماد مجلس الوزراء للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب إتباعها وضوابط إبرام العقد في حالة الصفقات الكبيرة، والتعاقدات ذات الطبيعة المركبة والمتشابكة، أو متعددة الأطراف، أو تلك التي تتطلب هيكلًا تمويليًا كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية Boot والبناء والتملك والتشغيل Boo والتصميم والاشتراء والتشييد والتمويل Eoetfinance (م/٧٩).

— وقد سبق تناول هذه الحالات بالدراسة والتعقيب بملاحظاتنا على هذه المواد — قبلًا — فيخيل إليها منعا للتكرار.

١٣- كما أجاز القانون لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وأجهزتها في حالات الضرورة، التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي، التعاقد بأي من طرق التعاقد (المناقصة المحدودة، أو المناقصة ذات المرحلتين، أو المناقصة المحلية، أو الممارسة المحدودة) أو الاتفاق المباشر.

— وأجاز القانون للسلطة المختصة تفويض أيًا من اختصاصاتها المقررة في هذا الشأن (م/٧٧) من القانون.

١٤- وأيضًا أجاز القانون للجهات المخاطبة بأحكامه التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بموافقة السلطة المختصة بكل منها، بل وبدون التقييد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بالقانون، وكما أجاز لها أن تتوب عن بعضها في مباشرة.

وإجراءات التعاقد في مهمة معينة، وفقا للقواعد المعمول بها في
الجهة الإدارية طالبة التعاقد.

ومن القانون سريان أحكام تلك المادة على كل من الهيئة العربية
للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمخابرات العامة.
كما أجاز القانون لأي من تلك الجهات جميعها إسناد التعاقدات
المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة إلي أي من وحداتها التابعة.
ولكنه حظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها
(نظرا لطبيعتها الخاصة) (م/٧٨ من القانون).

— ونرى أنه لا يجوز في هذه الحالات المنصوص عليها في المواد
٧٧، ٧٨ من القانون، التفويض في اختصاصات السلطة المختصة، نظراً
لحماية تلك الحالات وخطورتها وطبيعتها الخاصة.

١٥- وأخيراً، أجاز القانون التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات
بالبيع أو التأجير، أو الترخيص بالانتفاع ، أو بالاستغلال في حالات
الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقضيها المصلحة
العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية
أو المحافظ المختص (م/٨٠).

ونرى أنه تحقيقاً لأهداف القانون المنصوص عليها في م/٢، لا يجوز
التفويض في هذه الاختصاصات.

ونشير إلي أن النص على جواز التعاقد في الحالات الخمسة عشر —
المشار إليها — يقصد به الدلالة على أن لجؤ الجهة الإدارية لهذا الطريق
في التعاقد، لا يعدو أن يكون — على ما قدمنا — طريقاً استثنائياً من
الأصل العام في التعاقد، يجب أن يتم وفق الضوابط والقواعد

والإجراءات القانونية لكل حالة من هذه الحالات، وعلى ما توضحه –
أيضا – اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م
وأدل على ذلك ما نص عليه صراحة من وجوب توثيق مبررات
إتباع طريق الاتفاق المباشر، على نحو ما تبينه اللائحة التنفيذية (م/٦٤).
– ولا يغير من ذلك أن التوسع في حالات التعاقد بطريق الاتفاق
المباشر، أمر غير محمود، لأنه يتم على حساب الأصل العام في التعاقد،
وينتقص منه وربما كان دافع المشرع في ذلك التوسع، التسارع في
المشروعات التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة، بما ينعكس إيجابا
على المصلحة العامة، وتحقيق الرفاهية للشعب.

ثانيا: حدود تعاقد الجهات الإدارية بطريق الاتفاق المباشر:

مايز المشرع في الحدود المالية للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بين
الحالات المنصوص عليها في المادة (٦٢) سالف الإشارة إليها، سبع
حالات، وبين حالات التعاقد على شراء العقارات أو استئجارها.
فبينما حدد المشرع حدود ترخيص رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة
ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، التعاقد
بطريق الاتفاق المباشر، فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه، بالنسبة لشراء
استئجار المنقولات، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية أو الدراسات
الاستشارية، وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
إلا أنه بالنسبة للوزير ومن له سلطاته أو المحافظ، فقد وسع من
الحدود المالية للترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، فيما لا يجاوز
قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراءه أو استئجار المنقولات، أو تلقي

الخدمات، أو الأعمال الفنية، أو الدراسات الاستشارية وعشرين مليوناً بالنسبة لمقاولات الأعمال.

— وقد حظر المشرع التفويض في الاختصاصات في هذه الحالات بينما أجاز القانون لمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر وذلك فيما يجاوز اختصاصات الوزير أو المحافظ.

— وأجاز القانون بموافقة السلطة المختصة، التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات، أو الأعمال، أو تلقي الخدمات منخفضة القيمة، والتي لا تتجاوز ٢٠٠٠٠ جنية في المرة الواحدة، ولا تتجاوز ١٠٠٠٠٠ جنية خلال السنة المالية وأجاز القانون التفويض من السلطة المختصة في هذه الحالة فقط.

— وفيما يتعلق بالوزير المختص بالصحة، بالنسبة للأعمال واللقاحات والعقاقير الطبية، ذات الطبيعة الإستراتيجية، وألبان الأطفال، يجوز له الترخيص بالتعاقد بالاتفاق المباشر في حدود اختصاصات الوزير، ولا يجوز له تفويض اختصاصاته في هذا الشأن.

— وفيما يتعلق بشراء أو استئجار العقارات، أجاز القانون للجهة الإدارية التعاقد بشأنها بطريق الاتفاق المباشر، بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، وذلك فيما لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ جنية (خمسمائة ألف جنية) بالنسبة للاستئجار ومليون جنية للشراء خلال العام المالي.

— وترتفع سلطة الوزير أو المحافظ لما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيها بالنسبة للاستئجار وعشرة ملايين جنيها بالنسبة للشراء، في العام المالي.

ويكون لمجلس الوزراء التعاقد فيما يجاوز تلك الحدود وبمراعاة توثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، على نحو ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز لرئيس الهيئة ومن يمثله في الجهات الإدارية أو الوزير أو المحافظ تفويض سلطاته في الاختصاصات الممنوحة له بالتعاقد بهذا الطريق (م/٦٤) من القانون.

— والأمر المسلم به أنه يترتب البطلان على مخالفة طريقة التعاقد، أو يجاوز الحدود المالية التي يجاوز التعاقد بحدودها — على نحو ما تقدم . —

وبمراعاة أنه لا يجوز تفويض الاختصاصات في مجالات التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر، أو في الحدود المالية المسموح بها في التعاقد، لكل من سلطات التعاقد (السلطة المختصة) على ما تقدم.

مجل القول:

— إنه متى حدد المشرع طريقة معينة، وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة، فإن طريقة التعبير عن الإرادة تختلط حالئذا بمشروعيتها فلا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا بإتباع هذه الطريقة.

— بمعنى آخر: إلزام المشرع الجهة الإدارية بطريقة أو طرق محددة في بعض الحالات المنصوص عليها قانوناً، فإذا أولت الجهة الإدارية وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون. وعليها أن تعيد

نظرها في العقد، بالتحلل منه كاملاً، أو بعضه، في ضوء ما تسفر عنه المراجعة.

وتطبيقاً لذلك، قضي بأن القرار الذي يصدره المحافظ بتخصيص قطعة أرض داخل نطاق محافظته بالأمر المباشر، متجاوزاً حدود الأمر المباشر، يعد بمثابة عقد باطل، رغم إلباسه حلة التخصيص^(١).

وأنه فيما يتعلق بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر:

فقد توسع المشرع في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، في حالاته بطريقة كبيرة، على الرغم من أنه طريق استثنائي في التعاقد. ويمكن القول أن المشرع في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، قد اتجه صوب التوسع الحريص في التفويض، بهدف تسير العمل التنفيذي، وتحقيق فكر اللامركزية.

فخطر التفويض في مجالي: اللجوء إلى الطرق الودية، لحسم منازعات العقود الإدارية، وقصر استخدام ذلك الحق على الوزير المختص بالجهة الإدارية دون غيره من سلطات التعاقد، وكذلك في مجال التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، عدا الحالة (قليلة القيمة المشار إليها في م/٦٣ من القانون، على ما أوضحنا).

وفيما عدا هذين المجالين، يجوز للسلطة المختصة أن تفوض في أي من اختصاصاتها الواردة (بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) لشاغلي الوظائف القيادية، دون غيرهم، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (م/٨١) من القانون.

^١ أ.ع. طعن رقم ١١٠٠٨، لسنة ٤٨ق، في ٢٢/٦/٢٠١١م، طعن رقم ٣٣٢٩٣ لسنة ٥٥ق، في ٢٨/٦/٢٠١٦م.

والمعلوم أنه يقصد بالوظائف القيادية، هي وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة، من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية، أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات، طبقاً للتعريف الوارد بالمادة (٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م.

والجدير بالذكر أن قرار التفويض يجب أن يحدد الاختصاصات والسلطات المفوضة، بصيغة لا تحتمل التأويل أو التفسير، ولا تترك مجالاً للأعمال التقدير ويجب أن يكون قرار التفويض محدداً الموضوعات تحديداً دقيقاً، بحيث لا يفرط صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه إياها القانون، تطبيقاً للقاعدة، أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه^(١).

— ومن المسلمات أن طريق التعاقد بالاتفاق المباشر، يتمتع بخصائص عديدة، عما عداه عن طريق التعاقد، بسبب طبيعته الاستثنائية، ويمكن إبرازهم تلك الخصائص في أنه:

(أ) لا تطبق بشأنه الاشتراطات العامة للمناقصات العامة، والتي من بينها الالتزام بأداء التأمين الابتدائي والنهائي وعدم استلزام حضور ممثلي المالية ومجلس الدولة.

(ب) عدم جواز التفويض في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، فعلى السلطة المختصة ممارسة اختصاصاتها بنفسها، وفي الحدود المالية

١ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رقم ٤١٦ في ٢٢/٥/١٩٩٣م.

المسموح بها، ولا يجوز لها تفويض تلك الاختصاصات إلي غيرها عدا حالة العقود منخفضة القيمة.

(ج) أجاز القانون (م/٧٨) للجهات المخاطبة بهذا القانون (١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) التنازل عن العقود فيما بينها، استثناء من الأصل العام في عدم جواز ذلك، والمنصوص عليه صراحة في المادة (٩٢) من القانون.

(د) أوجب القانون على إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية، توثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني

إجراءات التعاقد

تمهيد:

قدّمنا أن ثمة قيود تقع على عاتق الجهة الإدارية، قبل التعاقد، مثل ضرورة توافر الاعتماد المالي، والإذن بالتعاقد، والاستشارات السابقة.. الخ. وأن ثمة قيود أخرى، ترد على سلطة التعاقد، وهي بصدد إبرام العقد وسوف نعرض لها في هذا الفصل من الدراسة.

وأنه من المسلمات أن العقود التي تبرمها الإدارة، لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل في مجال تكوينها مراحل متعددة، يمهّد كل منها لما يليه، ليكون خاتمتها العقد في صورته الكاملة كما وأن على الجهة الإدارية أن تلتزم طرقاً معينة توصلها لاختيار المتعاقد معها.

— وفي عبارة واحدة، أن الإدارة لا تتمتع في مجال إبرامها لعقودها بالحرية التي يملكها أشخاص القانون الخاص في نطاق العقود التي يدخلون فيها.

— وتبدأ أولى مراحل إبرام العقد بصدر قرار السلطة المختصة على البدء في اتخاذ إجراءات الطرح، وفق مواصفات محددة، ثم الإعلان عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد — سابق تناولها بالدراسة —، ويلي ذلك تلقي العطاءات على نحو ما يحدده القانون، وتشكيل لجان

فحص العروض (العطاءات) المقدمة، وكذا تشكيل لجان البت في التعاقد،
حتى الوصول إلى مرحلة الترسية وطريقة وآلية الترسية.
وعلى ذلك تتحدد إبعاد البحث في إبرام العقد وتتعين أبعاد على
النحو التالي:

أولاً: القيود التي ترد على حرية الإدارة في مرحلة إبرام العقد.

ثانياً: الإعلان عن التعاقد.

ثالثاً: تقديم العطاءات.

رابعاً: أحكام التأمين المؤقت والتأمين النهائي.

ونعرض لكل واحد من هذه الموضوعات في مبحث مستقل، على ما

يلي:

المبحث الأول

القيود التي ترد على حرية الإدارة في مرحلة إبرام العقد

يمكن إجمال هذه القيود فيما يلي^(١):

— يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة:

١- مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء ومراعاة اعتبار الجودة والتكلفة، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام (م/٨) من القانون.

٢- أن يكون الطرح على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة، أو معايير أداء عامة وكافية، توضع بمعرفة لجنة فنية متخصصة، وبوصف موضوع الطرح وصفا موضوعيا وعماماً، وكذا مراعاة المواصفات القياسية المصرية أو الدولية، مع تجنب الإشارة إلى علاقة تجارية معينة، أو اسم تجاري، أو براءة اختراع، أو تصميم، أو نوع أو منتج، أو بلد معين، ويستثنى من ذلك الأصناف التي يتعذر توصيفها، بإضافة عبارة ما يعادلها، أو ما يماثلها، أو ما يكافئها في الأداء (م/١٤).

١ إن هذه القيود وتلك التي سبق تناولها تحت عنوان القيود التي ترد على حرية الإدارة بصدد إبرام العقد الإداري يكملان بعضهما البعض فالقيود السابق الإشارة إليها هي قيود سابقة على التعاقد أما تلك القيود فهي معاصرة لإبرام العقد وكلاهما يكمل بعضه لوحدة الغرض القانوني منهما وتأثير كل منهما على العقد.

٣- إعداد إدارة التعاقدات مذكرة أو أكثر على السلطة المختصة، للموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد وغيرها من الإجراءات ويجب أن تتضمن هذه المذكرة على وجه الخصوص بيان محل الطرح، وطريقة التعاقد، ومدة سريان العطاءات، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (م/١٧).

وأوجب القانون ألا تقل مدة سريان العطاءات عن خمسة وأربعين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً، وفقاً لطبيعة العملية، وتحسب مدة سريان العطاءات اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف المغلقة. وبمراعاة جواز استثناء تلك المدد وفقاً لطبيعة العملية (م/٢٧).

٤- كما يجب على الجهة الإدارية، قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك وجميع طرق التعاقد بما فيها التعاقد بطريق الاتفاق المباشر إذا تطلبت العملية ذلك، أن تعد كراسة للشروط والمواصفات، تتضمن الإحالة إلى جميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية — وقد تناولنا ذلك بتفصيل مناسب قبلاً (م/١٩). — وقدّمنا أن عدم تضمين العقد أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ولائحته التنفيذية، باعتبارها جزءاً مكملًا للعقد، يترتب عليه عدم إمكان تطبيق الجزاءات المبيّنة بهما.

٥- ويحظر على الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات.

ولا يسري ذلك الحظر على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم، إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية.. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣م في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولية في الدولة، وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفي والمهني (م/٢٦) من القانون.

٦- كما يجب على الجهة الإدارية التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم، وغيرها من المعايير الموضوعية التي تحددها الجهة الإدارية، ضمن شروط الطرح، وبما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (م/٣٢).

ونشير إلي أن مخالفة تلك القيود يترتب عليها المساءلة القانونية، بكافة صورها، على نحو ما قرره المادة (٨٩) من القانون، وقد سبق تناولها بالدراسة قبلا.

المبحث الثاني

الإعلان عن طلب التعاقد

أولاً: القاعدة وما يرد عليها من استثناء:

على العكس من القانون السابق للمناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م والذي لم يتطلب الإعلان عن التعاقد، سوي في كل من المناقصة العامة والممارسة العامة (وهي طرق التعاقد الأصلية التي نص عليها هذا القانون) اتجه القانون الجديد رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م إلي تطلب الإعلان والنشر عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد (المنصوص عليها في م/٧ من هذا القانون) على بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها، وفقاً لما تقررته السلطة المختصة (م/٢٠).

وهكذا يكون القانون الجديد للتعاقدات العامة، قد مد الإعلان عن التعاقد، ليشمل كافة طرق التعاقد، بما فيها طريق التعاقد بالاتفاق المباشر ولم يستثن من ذلك الإجراء سوي ما تقررته السلطة المختصة بنفسها من العمليات المرتبطة بالأمن القومي.

ثانياً: كيفية الإعلان:

- ١- الإعلان على بوابة التعاقدات العامة، يشمل كافة طرق التعاقد — على ما تقدم — (م/٢٠ فقرة ١).
- ٢- في حالة التعاقد عن طريق المناقصة العامة الداخلية، أو المزايدة العلنية العامة أو المزايدة بالمظاريف المغلقة، يجب الإعلان عنها مرة واحدة، بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

أما المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية، فيكون الإعلان عنها مرة واحدة، بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وبأحدى الصحف الدولية، وبالإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات (م/٢٠ فقرة ٢) وفيما يتعلق بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية، أو الممارسة المحدودة، أو المزايدة المحدودة، أو المزايدة المحلية، فيجب توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح، من بين المسجلين بسجلات الجهات الإدارية أو غيره، بموجب كتب موصي عليها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، بخمسة عشر يوما على الأقل. — في وجوب الإعلان بذات الطريقة (المحددة) في حالة تأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة.

— كما يجوز، وبموافقة السلطة المختصة، في كافة حالات الإعلان أو الدعوة إلى التعاقد، الإعلان في أكثر من صحيفة مصرية أو دولية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد، في الحالات التي تقتضي ذلك. وعلى ذلك يكون القانون الجديد، قد نظم الإعلان أو الدعوة إلى التعاقد بطريقة عامة على بوابة التعاقدات العامة لكافة صور التعاقد، ثم أبان من كيفية الإعلان أو الدعوة إلى التعاقد بالنسبة لكل طريقة على حدة.

واستثني من ذلك تلك العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها.

ونص لأول مرة على وجوب الإعلان عن تأجيل فتح المظاريف أو المزايدة، بذات طريقة الإعلان عنها، على نحو ما حدد القانون.

ثالثاً: مشتملات الإعلان:

من المسلمات أن الإعلان أو الدعوة إلي التعاقد، يجب أن تتضمن الجهة التي تقدم إليها العطاءات.. وآخر موعد لتقديمها.. وتفصيلات موضوع التعاقد.. ومبلغ التأمين النهائي.. وثمان كراسة الشروط وملحقاتها.. وأي بيانات أخرى ترى الجهة الإدارية ضرورة النشر عنها لصالح العمل.

— وقدمنّا أن مدة سريان العطاءات يجب ألا تقل عن خمسة وأربعون يوماً ولا تجاوز تسعين يوماً، وفقاً لطبيعة العملية، بل ويجوز تجاوز تلك المدد إذا تطلبت عملية التعاقد ذلك، وذلك بموافقة السلطة المختصة، وفي هذه الحالة يجب إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمدة سريان عطاءاتهم لهذه المدة، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت، على أن يتم ذلك كله قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوماً.

وفي حالة عدم قبول صاحب أي عطاء مد مدة سريان عطاءه كتابة، يستبعد ذلك العطاء، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء (م/٢٧ فقرة ٢).

ويقع على اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بيان أي تفصيلات أخرى في كيفية الإعلان ومشتملاته.

وقد عدت المادة (٣٧) من اللائحة ، البيانات التي يجب أن تتضمنها

الدعوة ، أو الاعلان عن التعاقد ، وهى :

— اسم الجهة الادارية الطارحة ، وعنوان ادارة التعاقدات بها ، ورقم

التليفون ، والفاكس ، والبريد الالكتروني للادارة .

- اسم العملية ورقمها، وطريق التعاقد.
- وصفاً موجزاً وواضحاً لموضوع التعاقد.
- مكان وميعاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وثمنها، والاشارة إلى إمكانية الاطلاع على بيانات العملية ، ومستندات الطرح الخاصة بها على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.
- موعد ومكان انعقاد جلسة الاستفسارات إن وجدت ، وجلسة فتح المظاريف ، أو الممارسة، أو المزايدة بحسب الأحوال.
- مبلغ التأمين المؤقت ، ونسبة التأمين النهائي.
- وهكذا يكون القانون قد حدد حد أدنى لمدة تقديم العطاءات وحد أقصى لذلك ولم يشر القانون إلى حالة تقصير المدة على نحو ما كان يجري عليه العمل في ظل القانون القديم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م.

رابعاً: الطبيعة القانونية للإعلان:

استقرت أحكام القضاء وإفتاء مجلس الدولة، على أن الإعلان (أو النشر) عن إجراء التعاقد أياً كانت طريقة التعاقد — ليس دعوة إلى التعاقد وأن التقدم بالعطاء وفقاً للمواصفات والاشتراطات المحددة بالإعلان هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد^(١).

وعلى ذلك فإن الإعلان عن الحاجة إلى التعاقد، يكون عن طريق النشر في الصحف اليومية واسعة الانتشار، أو بأحدي الصحف الدولية، أو كليهما، وكذا بالإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات وقد يكون الإعلان — انصب — بخطابات مصحوبة بعلم الوصول.

^١ أ.ع طعن ٣٣٣ لسنة ١٠ اق في ١٢/٢/١٩٦٧م، طعن رقم ٣٣٦٣ لسنة ٣٦ ق في ١٢/٣/١٩٩٦م.

ويؤثر التساؤل، حول أثر مخالفة قواعد الإعلان، وفقاً للضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية فهل يلحق البطلان بالإجراء المخالف؟ وما أثر ذلك على العقد ذاته؟

المستقر فقها وقضاء أن إغفال ضوابط الإعلان ومشتملاته، وخاصة المدة المحددة لسريان العطاءات والبيانات الجوهرية، من شأنه أن يجعل إجراءات التعاقد باطله، لإخلالها بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة ومبادئ الشفافية.

بل ولا تملك لجنة البت سلطة التجاوز عن مخالفات النشر الجوهرية، مما يوجب أن تتم إعادة الإجراءات مرة أخرى^(١).

وعلى ذلك وأن عدم النشر وفقاً للقواعد المنظمة كذلك، يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويترتب على ذلك الإغفال، عدم تحقيق الغاية من الإجراء (الإعلان)، مما يعني وقوع عيب شكلي في إجراءات المناقصة (عملية التعاقد) يؤثر على قرار الترسية ويؤدي إلى بطلانه^(٢).

ولكن هل بطلان القرار الصادر بالترسية، يسبب مخالفة إجراءات الإعلان عن التعاقد، يؤثر على صحة العقد الذي تم إلينا وعليه؟^(٣)
— والمستفاد مما تقدم أن الإعلان عن التعاقد لا يعد قراراً إدارياً منفصلاً يطبق في شأنه أحكام نظرية القرارات الإدارية — على ما تقدم،

١ فتوى اللجنة الثانية رقم ١٢٢ في ١٤/١/١٩٨٨م، ملف رقم ٨٦٠/٢٩/٣١ (فتوى إدارة الإسكان).

٢ فتوى اللجنة الثانية رقم ١٢٢ في ١٤/١/١٩٨٨م، ملف رقم ٨٦٠/٢٩/٣١ (فتوى إدارة الإسكان).

٣ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم ٥١٢ في ١٧/٨/١٩٨٥ ملف رقم ١٤/١/٦٧.

وهنا يلحظ التفرقة بين ما إذا كانت مخالفة إجراءات الإعلان عن التعاقد جوهرية، وذات تأثير على عدد العطاءات المقدمة في المناقصة، أم أنها مخالفة بسيطة، لم تؤثر في عدد العطاءات المقدمة في المناقصة، والمخالفة الجوهرية هي وحدها التي يترتب عليها البطلان، ومن ثم بطلان قرار الترسية، ولكن لا تأثير لذلك البطلان على العقد الذي تم البناء عليه.

المبحث الثالث

تقديم العطاءات

— قدمنا أن الفقرة والقضاء مستقران على أن إعلان الإدارة من إجراء مناقصة أو مزيدة أو ممارسة.. عن طريق التقدم بعطاءات، ليس إلا دعوة إلي التعاقد، وأن التقدم بالعطاء، وفقا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها، هو الإيجاب، الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد.

— وتقضى المادة (٢٣) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويكون فتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية عامة، بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يرونه لحضور جلسة فتح المظاريف، شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.

— ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا وقدمنا أنه وفقا لأحكام المادة (٢٧) من القانون، يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمسة

وأربعين يوماً، وألا تجاوز تسعين يوماً، وفقاً لطبيعة العملية وتحسب مدة سريان العطاءات من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

— وأوضحنا أن المادة (٢٨) من القانون، قد أبانت عن تولي إجراءات جميع طرق التعاقد، لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وفقاً لأهمية وطبيعة التعاقد ويجب أن يتضمن قرار تشكيل تلك اللجان موعد انتهائها من أعمالها.

— وتباشر هذه اللجان عملها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تتولي أحدهما فتح المظاريف، وتتولي الأخرى البت في المناقصة، على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف جنيه، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة.

— وفيما يتعلق بتشكيل اللجان ، نصت اللائحة على أن يكون تشكيل اللجان ، وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٨) من القانون ، على أن تكون برئاسة موظف تتناسب درجته الوظيفية وخبراته مع قيمة وأهمية وطبيعة العملية ، ويضم إليها عضواً من إدارة التعاقدات ، وعضواً من الإدارة الطالبة أو المستفيدة ، ويجوز للسلطة المختصة ضم عضو أو أكثر من الجهة الإدارية أو غيرها، وبعد أقصى ثلاثة أعضاء، حسب طبيعة وأهمية العملية . وفي جميع الحالات ، يجب ألا يجاوز عدد أعضاء اللجنة خمسة عشر عضواً . وتكون للجان البت أمانه فنية من ضمن أعضائها (م/٦٠).

وتقوم **لجنة البت** باعداد محضر يتضمن ما انتهت إليه توصياتها، بناء على دراستها من قبول، أو استبعاد للطلبات ، مع ذكر أسباب عدم القبول تفصيلاً ، وترفع محضرها للسلطة المختصة للاعتماد (م/٦٨ من اللائحة).

وإذا اختلف أعضاء لجنة البت في الرأي حول قبول أو رفض أى من العطاءات ، فيتم اثبات ذلك تفصيلاً في محضر اللجنة ، ويكون الفصل فيه للسلطة المختصة (م/٨٥).

— ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون واعتماد أعمالها (م/٢٨ — فقرة أخيرة). واستلزم القانون وفقاً لأحكام المادة (٢٩)، أن يشترك في عضوية لجان فتح المظاريف، ولجان البت في المناقصة، ولجنة الممارسة ممثل لوزارة المالية، إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه.

— وخص المشرع حالة شراء أو استثمار أو بيع أو تأخير العقارات التي تتم في الخارج بأن استلزم أن يشترك في العضوية ممثل لوزارة المالية، وعضو إدارة الفتوى المختصة، إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسي ثلاثة ملايين جنيه.

وكذلك أوجب المشرع اشتراك ممثل لوزارة الإسكان في عضوية اللجان المشار إليها في حالات شراء أو استئجار العقارات.

وفي جميع الحالات لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ممثل وزارة المالية وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال، وممثل لوزارة الإسكان في الحالات التي تتطلب ذلك.

— وأخيراً: أوجب المشرع في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م (م/٢٢) أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته، ونص على استبعاد كل مقدم عطاء أو متزايد لم يسدد مبلغ التأمين المحدد. وأبانت تلك المادة، حالة رد التأمين، وحالة مصادرته وسنوضح تفصيل ما أجمل على الوجه الآتي:

أولاً: كيفية تقديم العطاءات (لجنة فتح المظاريف):

١- تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي، ويحتوي مظروف العرض الفني، على جميع البيانات الفنية ذات العلاقة بطبيعة التعاقد، وطريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتنفيذ، وبيان مصادر ونوع المهمات والأجهزة المعروضة وأسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على العملية وبيان الشركات التي يحتمل التعاقد معها من الباطن، وكل ما يتعلق بالوضع الفني والقانوني للجهة مقدمة العطاء وكذلك يجب أن يتضمن العطاء التأمين الابتدائي (المؤقت).

— وفي المجمل، يجب أن يحتوي المظروف الفني على كافة البيانات والمستندات التي تري الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة، وتوافر الكفاية الفنية والمالية لدي مقدمي العطاءات.

— والمعلوم أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م قد أجاز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلي غيره من الباطن، ومن ثم كان على مقدم العطاء بيان تلك الجهات وما سيتم إسناده إليهم من بنود وخبراتهم.

— وحظر المشرع على مقدم العطاء تغيير أي منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة، بل وفي جميع الأحوال، يظل المتعاقد دون غيره مسؤولاً أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد (م/٢٥ من القانون).

٢-مدة سريان العطاء:

— يلتزم المتعهد (مقدم العطاء) بالبقاء على عطائه (ويمثل التقدم بالعطاء ركن الإيجاب في عملية التعاقد) بعد تقديمه، مدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً، وفقاً لطبيعة العملية. ويجوز استثناء، تجاوز الحد الأقصى إذا تطلبت العملية ذلك، وذلك حال موافقة السلطة المختصة على هذه المدة.

كما واشترط القانون إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطائهم لهذه المدة، ومدد صلاحية التأمين المؤقت، وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاء بخمسة عشر يوماً.

وعلى ذلك، يجب أن يكون قبول مقدم العطاء من فترة سريان عطائه صريحاً ومكتوباً ولقد تحسب المشرع لحالة عدم قبول بعض مقدمي العطاءات مد مدة سريان عطائه كتابة، وفي هذه الحالة يتم استبعاد ذلك العطاء، ويرد إلي مقدم العطاء تأمينه، فور انتهاء مدة سريان العقد (م/٢٧).

ويرتد التزام مقدم العطاء بالبقاء على إيجابه أو سحبه، غلي الإرادة المنفردة له.

وتختلف مدة تقديم العطاءات باختلاف طريقة التعاقد ، فبينما لا تقل المدة فى المناقصة العامة، والممارسة العامة ، والمزايدة العلنية العامة ، والمزايدة بالمظاريف المغلقة عن عشرين يوماً ، تحتسب من تاريخ الاعلان باحدى الصحف اليومية ، ويجوز تقصير هذه المدة فى حالة الاستعجال إلى أربعة عشر يوماً ، بشرط موافقة السلطة المختصة.

أما فى المناقصة المحدودة ، والمناقصة المحلية ، والممارسة المحدودة ، والمزايدة المحلية، فلا تقل المدة عن أربعة عشر يوماً ، تحتسب من تاريخ توجيه الدعوة ، على أنه يجوز استثناء بموافقة السلطة المختصة تقصير هذه المدة إلى عشرة أيام.

والعبرة فى ذلك ، مراعاة إعطاء الوقت الكافى لأصحاب العطاءات لدارستهم لكراسة الشروط والمواصفات ، واستيفاء المستندات اللازمة لتقديم عطاءاتهم (م/٤٦ من اللائحة).

٣-حظر التقدم بأكثر من عطاء:

حظر القانون على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشاركة بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير فى اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.

— ورتب المشرع على مخالفة ذلك الحظر وجوب استبعاد العطاءات المخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية أو فسخ العقد أو

التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهائي، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بالجهة الإدارية، إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد.

(م/٣٣) من القانون وتبدو العلة من ذلك في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي مخالفة لهذا القانون ٣ لسنة ٢٠٠٥م أي أن المشرع قد أجاز للجهة الإدارية توقيع أي من الجزاءات التي تملكها على المتعاقد معها، بدءاً من استبعاد العطاءات المخالفة ومصادرة التأمين المؤقت والتأمين النهائي وحتى فسخ العقد والتنفيذ على الحساب والتعريض عن أية خسارة تلحق بالجهة الإدارية.

— هل يجوز قبول عطاء بعد الميعاد المقرر لتقديم العطاءات؟ بالطبع، لا يجوز ذلك، لما في ذلك من إخلال صريح بالمبادئ التي يقوم عليها التعاقد، وبخاصة مبدأ المساواة بين المتناقصين.

— والمعلوم على ما قدمنا أنه يجب تضمين كراسة الشروط مدة سريان العطاءات، ومكان وزمان تقديمها، بحسبان أن المناقصة دعوة التعاقد بشروط محددة موقوته بزمان معلوم، وتحسب مدة سريان العطاءات اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية (م/٢٧).

٤- في تشكيل لجنة فتح المظاريف:

— وفقاً لأحكام المادة (٢٨) من القانون، تتولي إجراءات جميع طرق التعاقد، لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وفقاً لأهمية وطبيعة التعاقد واستلزم القانون أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها وتباشر اللجان عملها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

إذ يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف (ولجان البت) في المناقصات ولجنة الممارسة، قرار من السلطة المختصة، ويجب أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة العناصر المشار إليها (بغرض تحقيق الرقابة الفنية والقانونية والمالية على التعاقد) وبمراعاة تضمين تلك اللجان ممثلي وزارة المالية والإسكان، في الحالات المشار إليها في م/٢٩ - المشار إليها آنفاً -.

- وهنا يثور التساؤل حول مدى جواز التفويض في ذلك الاختصاص.

البيان من نص م/٢٨ المشار إليها أنه لم يحظر التفويض في اختصاصات السلطة المختصة في تشكيل لجان التعاقد. وعليه فالتفويض جائز في هذه الحالة، بل أنه قد قضي بأنه لو صدر قرار تشكيل اللجنة من غير المختص بذلك، فإن اعتماد السلطة المختصة لعمل اللجنة يصح ما شاب قرار تشكيلها من بطلان^(١).

هـ- فئات يحظر عليها التقدم بعطاءات أو عروض (م/٢٦):

(أ) قدمنا أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، قد حظر على الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات وكذلك لا يجوز لهؤلاء الموظفين والعاملين، الدخول بالذات أو بالواسطة في المزايدات بأنواعها، إلا إذا كانت الأصناف المشتراه، لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة

^١ أ.ع. طعن رقم ٧٧٩ لسنة ٣٠ ق في ٥/٣/١٩٨٨م.

للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم، ولا تخضع لإشراف هذه الجهة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣م في شأن حظر تعارض المصالح (م/٢٦ من القانون).

(ب) ونشير إلي أن الدستور قد حظر على عضو مجلس النواب، طوال مدة العضوية، أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات (م/١٠٩ من الدستور).

ونضيف أنه فضلاً عن بطلان تصرفات عضو مجلس النواب في الحالات المشار إليها، فإنه يجوز مساءلته تأديبياً، بل ويجوز النظر في إسقاط العضوية عنه، لإخلاله بواجبات العضوية (م/١١٠ من الدستور).

— وقدما أنه يتعين على الجهة الإدارية التحقق من حسن السمعة فيمن يتم التعامل معها، وغيرها من المعايير الموضوعية التي تحددها الجهة الإدارية ضمن شروط الطرح (م/٣٢) . بل وأكد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على ذلك مرة أخرى في م/٣٤ وهذا ما استقر عليه القضاء وإفتاء مجلس الدولة ويعتبر استبعاد من لا يتوافر فيهم هذا الشرط من المبادئ العامة للقانون في عقود الإدارة، بصفة عامة.

— ويحرم من التعاقد مع الإدارة كل محكوم عليه بعقوبة جنائية (م/٢٥ عقوبات) وكذلك كل مقاول من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وكذلك يحرم من التعاقد مع جهة الإدارة من صدر قرار بشطبه من سجل المتعهدين أو المقاولين وأيضا يمنع التعامل مع كل من يستعمل الغش أو التواطؤ أو التلاعب مع جهة الإدارة.

وبصفة عامة: تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية كبيرة، في استبعاد من ترى من دائرة التعاقد، ولا يحدها في ذلك سوي قيد الانحراف بالسلطة، ذلك أن قرار استبعاد الشخص من التعاقد أيا كانت طبيعته كشخص عادي أو شخص معنوي، لا يعدو أن يكون قرار إداريا منفصلا يساهم في عملية التعاقد، ويخضع هذا القرار للأحكام العامة في القرارات الإدارية، وخاصة وجوب الطعن عليه في الميعاد المحدد لدعوى الإلغاء.

٦- في وفاة مقدم العطاء:

تنص م/٢٤ من القانون على أنه: (في حالة وفاة مقدم العطاء، إذا كان شخصاً طبيعياً، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير بحصة حاکمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، قبل البت، جاز للجهة الإدارية استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا وكيلًا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة).

— ومؤدي ذلك أنه في حال وفاة مقدم العطاء، أيا كانت طبيعته القانونية شخص طبيعي أو شخص معنوي، فإن للجهة الإدارية إما استبعاد عطائه ورد التأمين المؤقت له أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن توافق السلطة المختصة على الوكيل المختار من الورثة للاستمرار في الإجراءات. وقدما أن قرار الاستبعاد من

الإجراءات، يعد قراراً إدارياً منفصلاً، يجوز الطعن عليه بالإلغاء، على ما سبق تفصيله.

ثانياً: لجنة البت في العطاءات (م/٣٤ من القانون):

١- تقضى م/٣٤ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على أنه: (تتولي لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمواصفات المعلن عنها، وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءات المالية، وحسن السمعة في مقدمي العطاءات، وذلك كله وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بكماسة الشروط).

— وقدمنا أن لجان التعاقد (سواء لجنة فتح المظاريف أو لجنة البت)، تشكل بقرار من السلطة المختصة ويجب أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقاً لأهمية التعاقد، وعلى أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها.

وتباشر هذه اللجان عملها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون (م/٢٨).

— وقد أجاز القانون للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها، بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة، ومدى مطابقتها للشروط وعلى أن تقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها إلى لجنة البت (م/٢٤ من القانون).

— كما أوجب القانون ضرورة أن يشترك في لجان البت في المناقصات ولجنة الممارسة ممثل لوزارة المالية، إذا زادت القيمة

التقديرية عن مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا زادت القيمة عن مليوني جنيه.

— ويجب أن يشترك في عضوية لجنة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع، أو الاستغلال ممثل لوزارة المالية، متى بلغ الثمن الأساسي مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، متى بلغ الثمن الأساسي مليوني جنيه.

— وأنه في التعاقدات التي تتم في الخارج، في شأن شراء أو استئجار أو بيع العقارات يجب أن يشترك في عضوية لجنة البت الأعضاء المشار إليهم، متى بلغت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسي ثمانية مليون جنيه (م/٢٩).

— وفي حالات شراء أو استئجار العقارات، يجب اشتراك ممثل لوزارة الإسكان.

— ونص صراحة على أنه وفي جميع الأحوال لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا، إلا بحضور ممثل وزارة المالية، وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بحسب الأحوال، وممثل لوزارة الإسكان، في الحالات التي تتطلب ذلك (م/٢٩/٢).

— وهكذا يكون القانون قد حسم بشكل قاطع، قيمة التعاقد، وطبيعة التعاقد، التي يلزم فيهما حضور ممثل وزارة المالية، وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وكذا ممثل وزارة الإسكان، في الحالات التي تطلب ذلك، ورتب البطلان على عدم حضور هؤلاء جميعهم في لجنة البت.

اختصاصات لجنة البت:

— أبانت عن هذه الاختصاصات المادة (٣٤) من القانون، ولجنة البت هي التي تتولي دراسة العطاءات المقدمة وفق أحكام هذا القانون وللائحته التنفيذية، والوقوف على الشروط والمواصفات المعلن عنها، والتحقق من شروط الكفاءة الفنية والملاءة المادية وحسن السمعة في مقدمي العطاءات، وذلك كله وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بكماسة الشروط.

— بمعنى آخر، تتولي لجنة البت المفاضلة بين العروض المقدمة واختيار أفضلها فنياً ومالياً، تمهيداً للتعاقد مع مقدمها أو إلغاء المناقصة، إذا توافرت حالات الإلغاء على ما تقدم.

أسئلة جوهرية (خمسة أسئلة جوهرية):

يثأّر في شأن عمل لجان البت تساؤلات جوهرية تدور حول مدي علانية جلسات لجان البت؟

- ومعايير وضوابط المفاضلة بين العطاءات؟
- ومدي أجازة التفاوض بعد فتح المظاريف؟
- والطبيعة القانونية لقرار لجنة البت؟
- وأخيراً حدود مسؤولية لجنة البت.

١- عدم وجوب علانية جلسات لجنة البت:

— لم يفصح المشرع عن علانية جلسات لجان التعاقد، سوي فيما يتعلق بلجنة فتح المظاريف — م/٢٣، سابق الإشارة إليه — . وبناء عليه فإن سكوت المشرع عن مدي التزام الجهة الإدارية بعلانية جلسات لجان

البت، يعني أن التقرير بعلانية جلسات لجان البت، أو عدم علانيتها، يخضع لتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة وموافقة السلطة المختصة. ومن ثم يجوز أن تكون جلسات لجان البت سرية، إلا إذا رأت الجهة الإدارية (وموافقة السلطة المختصة علانيتها) وفقا لظروف موضوع التعاقد وطبيعته.

٢- معايير وضوابط المفاضلة بيد العطاءات:

من المسلمات أن فتح مظاريف العروض المالية، يقتصر على العروض المقبولة فنياً (م ٢٣ / فقرة أخيرة من القانون). — كما أنه في جميع الأحوال يجب أن يتم البت والإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان العطاءات — على ما تقدم — (م ٢٧/فقرة ٢) . ومن ناحية ثالثة، فإنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف جنيه، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة. وأخيراً: لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان (فتح المظاريف ولجان البت) واعتماد أعمالها (م ٢٨/٣، ٢). — هذا وقد أبانت المادتين (٣٥، ٣٦) من القانون عن الضوابط والمعايير التي تلتزم بها لجنة البت في عملها ويمكن إجمالها فيما يلي (اثنى عشر ضابطاً):

(أ) يتم ترسية المناقصة أو الممارسة مع صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، أو الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط المحددة عناصره وأسسها بشروط الطرح، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات.

– ويقع باطلا التعاقد مع غير صاحب اقل العطاءات المستوفي الشروط والمواصفات^(١).

(ب) أن يؤخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات، بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته.

(ج) لا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.

(د) طلب تفضيل العطاء الأقل سعرا، المنخفض انخفاضا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية.

(هـ) التوصية باستبعاد العطاءات التي تثير الريبة ويتعذر التنفيذ بها.

(و) مراعاة أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية (يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة قيمة (١٥%) من قيمة أقل عطاء غير مستوفي كما يعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا، إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة قيمة ١٥% من قيمة أقل عطاء أجنبي.

(ز) في المزايدة، تتم الترسية على مقدم أعلى سعر مستوفي للشروط، بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية.

(خ) التحقق من شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية، وحسن السمعة، فيمن يتم التعامل معهم، وغيرها من المعايير التي تحددها الجهة الإدارية ضمن شروط الطرح.

^١ أ.ع – طعن رقم ٥٥٢ لسنة ١٤ ق، في ١٩٧٣/١/٢٧ م.

(ط) يجب أن توثق لجنة البت جميع أعمالها كتابة.

(ى) في جميع الأحوال يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بموجب خطاب يرسل بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه بالبريد الإلكتروني.

— كما يخطر باقي مقدمي العطاءات، كتابة، بما انتهت إليه الجهة الإدارية من قرارات، مع وجوب إتاحة الفرصة لإيضاح أسباب عدم قبول العطاء، لمن يطلب من مقدمي العطاءات.

(ك) التوصية بإلغاء المناقصة أو الممارسة، بجميع أنواعها، إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات، أو ممارسات احتيالية، أو فساد، أو احتكار، أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات^(١).

١ قدمنا — قبلاً أسباب أو حالات الاستبعاد للعطاءات .ويمكن أبرز أهم تلك الحالات في: العطاء المقدم ممن لم يشتري كراسة الشروط — أو من أحد الأشخاص الممنوعين من التعامل — وكذلك العطاء غير المصحوب بالتأمين الابتدائي كاملاً — أو الذي يقدم متأخراً — ولم يستوف شروط قبول العطاء المتأخر — وأيضاً يستبعد العطاءات في حالة إذا كان مقدماً من شركة باطلة أو غير مشهورة — أو المقدم من شخصين لا تجمعهما رابطة قانونية، ويستبعد كذلك العطاء — غير الموقع من صاحبه — أو إذا فقد مقدم العطاء شرط حسن السمعة — وكذلك يستبعد العطاء غير المطابق للشروط والمواصفات الفنية. وفي عبارة واحدة، نخلص معايير وضوابط استبعاد العطاءات من قبل لجنة البت في حالات عدم تحقق مصلحة المرفق العام، فنيا وماليا وإداريا.

ونشير إلى أنه لا يجوز حجب أي عطاء يقدم في المناقصة من لجنة فتح المظاريف لأي سبب ولو ورد بعد الميعاد^(١) ، ومرد ذلك إن البحث في مدي مطابقة العطاءات لشروط المناقصة من اختصاص لجنة البت.

(ل) وأخيراً: ترفع لجنة البت محضرها متضمناً توصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه ويجب أن يشتمل قرار الترسية على الأسباب التي بني عليها (م/٣٦).

٣- في مدي إجازة التفاوض بعد فتح المظاريف (التحفظات):

قدماً أن المشرع أوجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، وأن على لجنة البت أن تجري المفاضلة والمقارنة بين المتنافسين لتحديد صاحب العطاء الأقل على أساس القيمة الرقمية لبنود العطاءات، حينما تخلو جميع العطاءات من أي تحفظات أو اشتراطات يمكن تقييمها مالياً، وأنه يتعين على الجهة الإدارية أن تتعاقد مع صاحب العطاء الأفضل الذي عينته لجنة البت في المزايدة (أو المناقصة) ، ولا تملك أن تستبدل به غيره، ولو كان منصوباً في الشروط على أن لها الحق في رفض أو قبول أي عطاء دون إبداء الأسباب، لمخالفة هذا الشرط لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وما تضمناه من قواعد تحقيق المساواة بين جميع المتزايدين.

ولا يغير من ذلك جواز إلغاء المناقصة (أو المزايدة أو الممارسة) في احدي الحالات المنصوص عليها قانوناً، ومنها اقتران العطاءات كلها أو بعضها بتحفظات.

١ أ.ع: طعن رقم ٣٤١٩ لسنة ٣٢ق، في ٢٩/٤/١٩٨٩م بل إن مخالفة ذلك القيد يترتب عليها المسؤولية التأديبية.

في حالة وجود تحفظات:

— على أنه في حالة وجود تحفظات أو اشتراطات مالية مقترنة بكل أو بعض العطاءات أو ببعضها دون البعض الآخر، لا يكفي بالقيمة الرقمية للعطاء لتحديد أولويته الحقيقية وما يترتب عليها من آثار. بل يتعين إضافة قيمة التحفظات والشروط الخاصة التي يمكن تقييمها مالياً.

* تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية محل اعتبار عند البت في أولوية العطاءات.

* وجوب إعادة ترتيب أولوية العطاءات على ضوء ما يسفر عنه تقييم التسهيلات المقترنة بالعطاءات، بغية الوصول إلى صاحب العطاء الأقل^(١).

— وعلى ذلك فإنه يجب الاعتداد بالتحفظات والشروط الخاصة بالعطاءات والتي يمكن تقييمها مالياً، في مجال المقارنة بغية تحقيق صاحب العطاء الأقل، بل ومن شأن ذلك إعلاء المساواة بين المتناقصين، والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، فلا تكون الأولوية التي تجري ترتيب العطاءات على أساسها محض أولوية خادعة، تستند إلى قيمة رقمية لا تعبر عن حقيقة الحقوق المالية المطلوبة للتعاقد، وإنما يبتغي كل متناقص من ورائها أن يظفر بمزيه التفاوض مع جهة الإدارة، باعتباره صاحب العطاء الأقل سعراً من حيث القيمة الرقمية، ثم ينزل بعد ذلك عن تحفظاته ذات القيمة المالية أثناء التفاوض أو يتمسك بها، تبعاً لما يتكشف له من موقف بقية المتناقصين.

١ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ٦٤ في ١٢/١/١٩٨٨م.

والجدير بالذكر أن التحفظات ذات القيمة المالية، ليست هي التحفظات الوحيدة التي يمكن التفاوض حولهما، وإنما جاءت التحفظات ذات القيمة المالية، باعتبارها الأكثر شيوعاً، حسبما كشفت عنه التطبيقات العملية، فهذه التحفظات (المالية أو غيرها) يجب الاعتداد بها عند ترتيب أولوية العطاءات.

— وهنا تجدر الإشارة إلي أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م قد ألزم الجهة الإدارية، بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين على العمالة، وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية، إذا تطلبت العملية (م/٢٣) ذلك، وكانت تلك التأمينات من التحفظات التي يوردها المتناقصين أو المتزايدين في شروط تعاقدهم.

— وقضي بأن تخلف صاحب العطاء الأقل عن إيداع التأمين المؤقت الواجب إيداعه، كشرط للنظر في العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة، اعتماداً على وجود مبالغ مودعة لدى جهة الإدارة كتأمين نهائي منه عن عقد سابق، يعتبر بمثابة تحفظ اقترن بالعطاء، ومن ثم يجوز التفاوض معه لإيداع مبلغ التأمين^(١) إعمالاً لرخصتها في تسيير المرفق العام مستهدفه المصلحة العامة.

إذا المبدأ هو: إجازة التفاوض بعد فتح المظاريف مع صاحب العطاء الأقل، المقترن بتحفظ أو بتحفظات، للنزول عن تحفظاته كلها أو بعضها، وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة الواجب مراعاته بالنسبة لمقدمي العطاءات ولا ضرر على الجهة الإدارية منه.

^١ أ.ع، طعن رقم ٢٨٨ لسنة ٩ق في ٩/٥/١٩٥٩م.

فلا يجوز إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل عطاء، متى كان مستوفيا لجميع المواصفات والشروط، أو كانت المفاوضة قد أسفرت عن جعل عطائه أصلح العطاءات.

تخلص مما تقدم إلي أن الأصل في العقد الإداري أن الإيجاب يوجه على أساس الشروط العامة المعلن عنها، والتي تستقل جهة الإدارة بوضعها، دون أن يكون للطرف الآخر، حق الاشتراك في ذلك، إلا أنه إذا كان للمتعاقد مع الإدارة شروط خاصة لا تؤثر على الشروط الجوهرية (ولا تتعارض مع النظام العام) المعلن عنها، ففي هذه الحالة للإدارة أن تتفاوض مع صاحب العطاء الأقل، للنزول عن كل أو بعض تحفظاته، فإذا ما أسفر التفاوض عن تمسكه ببعض التحفظات، فطالما قبلت الإدارة هذا التمسك، أصبحت هذه التحفظات (وهي كل شرط يضعه مقدم العطاء في عطائه، ويكون مختلفا عن الشروط التي تضعها جهة الإدارة، أو يكون غير وارد فيها، ويعتبر تعديلا من المتناقص لشروط العطاء، أو بعبارة أدق تحفظا منه مقترنا بعطائه) جزءا من العقد، وواجبة التطبيق كحكم من أحكامه، أي أصبحت هذه التحفظات جزءاً لا يتجزأ من العقد^(١).

^١ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ٣٩٢ في ٣/٤/١٩٨٥م، ونقض مدني ٦٢ لسنة ٢٧ق، س ١٥ ص ٨٥٧، مشار إليه في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية في أربعين عاما، مبدأ رقم ١٢٢ ص ٢٦٩.

٤- الطبيعة القانونية لقرار لجنة البت:

إنه وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) ، هناك ثلاث جهات تتولي التعاقد، هي لجنة فتح المظاريف، ولجنة البت، وجهة التعاقد.

وإن قرار لجنة البت بتحديد من يجب التعاقد معه، باعتباره صاحب أفضل العطاءات، ليس هو الخطوة الأخيرة في التعاقد، ولا يعدو أن يكون إجراء تمهيديا ضمن العملية المركبة للعقد الإداري، ثم يأتي بعد ذلك دور الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقد.

قرار لجنة البت ليس هو القبول الذي يتم به العقد، تصديق الجهة الإدارية، وإخطارها المتزايد (أو المتناقص) هو القبول، وهو وحدة الذي يترتب عليه الآثار القانونية، ويتم به التعاقد.

قرار لجنة البت هو قرار إداري نهائي تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية، ومن بينها وجوب الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونا، وهو ستون يوما من تاريخ النشر أو الإعلان^(١).

ونشير إلى سلطة الجهة الإدارية في إبرام العقد مقيدة إذا رأت إبرامه، وتقديرية إذا رأت العدول عنه^(٢).

وأخيرا، حدود مسؤولية لجنة البت:

المبدأ العام أورده القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، في م/٨٩، بالنص على أن مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في إقامة الدعوى المدنية أو

١ حكم أ.ع - طعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٣٣ ق في ١٩٩٥/١/٤م.

٢ حكم أ.ع - طعن ٣١٣ لسنة ٤ ق في ١٩٦٠/٢/١٣م.

الجنائية، يؤخذ تأديبياً كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالتعاقدات، والتي يصدر بها قرار من وزير المالية.

(أ) إنه لما كانت اللجان الإدارية للتعاقد، تشكل من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة (مالية وقانونية وإدارية وفنية...) يثير تساؤلاً، حول مسؤولية اللجنة، فهل تعد مسؤولية اللجنة تضامنية، أم يسأل كل عضو عما يخصه، ومن ثم إذا قصر في ذلك يكون خطأ مستوجباً المساءلة والعقاب، ومن ثم يخرج عن المساءلة، من يخرج تخصصه وخبرته عن نطاق الحالة التي وقع بها الخطأ.

بمعنى آخر: هل تعد مسؤولية لجنة البت تضامنية (تشتمل جميع أعضاء اللجنة، أم هي مسؤولية فردية، تجد حدودها عند العضو المخالف لواجباته والقيام بعمله بدقة وأمانة؟).

القاعدة، ليست هناك مسؤولية تضامنية في خصوص لجان التعاقد، إلا ما كان مرتبطاً بوقائع يسأل عنها أعضاء اللجنة كلهم. وفي غير ذلك يمكن لسلطة التأديب أن تغاير في العقوبة بين عضو في اللجنة وعضو آخر فيها، حسبما يتراءى لها من الظروف والملابسات، وعلى ضوء تخصص كل عضو وخبرته.

— أي أنه يمكن القول باستقرار القضاء التأديبي، على عدم تطبيق مبدأ المسؤولية التضامنية باطلاق، على مسؤولية أعضاء اللجان (بصفة عامة). وإنما يسأل كل عضو عن الخطأ في حدود تخصصه، إلا إذا كانت الواقعة محل الخطأ من الوقائع المتعين معرفتها وإدراكها من كافة

أعضاء اللجنة، بوصفها من الأمور المتاحة للكافة، فعندئذ، يسأل الأعضاء عن هذه الواقعة مجتمعين، مثل عدم وجود عضو مجلس الدولة في اللجنة^(١).

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المسائلة واجبة، ولو لم تؤثر على صحة العقد أو تؤدي إلى بطلانه.

وتطبيقاً لذلك، قضي بأن مخالفة شروط تقديم التأمين الابتدائي، للنظر في العطاءات، يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة، يستوجب المساءلة^(٢).

— كما يعد سبباً للمساءلة، عدم إبلاغ الممثل القانوني للجهة الإدارية مصلحة الضرائب عن كل الأعمال أو الصفقات التي تجريها الجهة، أو طرح العملية في ممارسة رغم أنها لا تقتضي الاستعجال^(٣).

— وإن قيام العامل برئاسة لجنة الممارسة، ثم لجنة البت، ثم لجنتي الفحص والاستلام، يشكل مخالفة لحكم القانون تستوجب المساءلة التأديبية^(٤).

كما أن التزام لجنة البت في العطاء، بالاسترشاد بالأسعار السابقة، وأسعار السوق إغفالها هذا الإجراء، يجعل قراراتها مخالفة للقانون، مسؤولية أعضاء اللجنة دون استثناء مسؤولية إدارية^(٥).

١ حكم الإدارية العليا، طعن رقم ٦٥٥٥ لسنة ٤٢ق، في ٢٦/٩/١٩٩٨م، وطعن رقم

١٩٠٢ لسنة ٤٢ق، في ٧/٤/٢٠٠١م، طعن ٢٨٢٧ لسنة ٢٧ق، في ١٧/١١/١٩٨٧م.

٢ أ.ع طعن ٣١٧٤ لسنة ٢٩ق في ٣١/٣/١٩٩٠م.

٣ حكم أ.ع طعن ١٦٧٥ لسنة ٣٩ق في ٢٢/٢/١٩٩٧م.

٤ أ.ع طعن ١٢٠٥ لسنة ٣٤ق في ٣٠/٣/١٩٩١م.

٥ فتوى رقم ٧٨٤ في ٢٦/٦/١٩٦٧م.

المبحث الرابع التأمين الابتدائي

تمهيد:

— أوجبت كافة قوانين المناقصات والمزايدات، أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت، لضمان جدية مقدم العطاء، بل وأجازت استبعاد كل مقدم عطاء أو متزايد، لم يسدد مبلغ التأمين المحدد بكراسة الشروط والمواصفات.

والمسلم به ان التأمين المؤقت محدد بمبلغ معين من القيمة التقديرية للعطاء، ويجب إيداع هذا التأمين في المظروف الفني وليس المالي.
— وتستقر أحكام القضاء وفتاوى مجلس الدولة على عدم جواز قبول العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً.

— المسلم به أن تقديم التأمين المؤقت هو إجراء جوهري، يتوقف عليه عدة حقوق لجهة الإدارة، ونصت كافة قوانين التعاقدات مع الجهات الإدارية على حق الإدارة في التأمين، إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل ميعاد فتح المظاريف.

— وقد نظم قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م) أحكام التأمين المؤقت، في أكثر من مادة من مواد القانون، وخاصة المواد ٢٢، ٢٤، ٣٧، ٤٠، ٤٢.

— والجدير بالذكر أن أحكام التأمين المؤقت (والنهائي)، ثابتة ومستقرة، وأن تغيرت نسبة التأمين المؤقت (والتأمين النهائي) في العطاءات، بحسب طبيعتها.

وسوف نعرض للأحكام المنظمة للتأمين المؤقت (والنهائي)، في عقود الإدارة، في النقاط الآتية:

أولاً: ماهية التأمين المؤقت، وطبيعته القانونية:

ماهية التأمين:

التأمين المؤقت، هو مبلغ من المال محدد (قانوناً)، يلتزم مقدم العطاء بتقديمه مع عطاءه، ويودع في المظروف الفني، وتحدد كراسة الشروط والمواصفات، قيمته وكيفية تقديمه، وذلك لضمان جدية العطاءات، سواء قدم نقداً أو بسندات أو كفالة مصرفية.

— والتأمين (المؤقت والنهائي) شرع أصلاً لمصلحة الإدارة، وسن حمايتها، ولا يتصور أن يكون قيداً عليها، أو ضاراً بحقوقها، أو معوقاً لجبرها ومانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للإضرار الأخرى التي تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد، بتنفيذ شروط العقد الإداري : وبناء على ذلك لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة، التحلل من التزاماته العقدية بحجة عدم وفائه بالتأمين المؤقت والنهائي، ما دام أن هذا الوفاء مقرر لمصلحة الإدارة، التي اطمأنت إلي ملاءة المتعاقد معها.

والقاعدة أنه يجب تقديم التأمين المؤقت (الابتدائي) كاملاً مع العطاء، ضماناً لسلامته، وحرصاً على تحقيق المساواة بين المتنافسين، وضماناً لجديتهم.

— وقد مايزت اللائحة في تحديد مبلغ التأمين المؤقت ، وفقاً لطبيعة التعاقد . فبينما يكون مبلغ التأمين المؤقت بأى قيمة بما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها في عمليات شراء أو استئجار المنقولات ، والتعاقد على مقاولات الأعمال ، وتلقى الخدمات ، والأعمال الفنية الاستشارية شريطة

ألا يصل الحد الأقصى له مايجاوز نسبة (١٥%) من القيمة التقديرية (م٢٠/١).

— يكون مبلغ التأمين المؤقت فى عمليات شراء أو استئجار العقارات ، بأى قيمة ، شريطة ألا يصل الحد الأقصى له مايجاوز نسبة (٥٠%) من القيمة التقديرية (م٢٠/٢) .

— وفى عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات ، والترخيص بالانتفاع ، أو باستغلال العقارات ، والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية ، يكون تحديد مبلغ التأمين المؤقت ، حسب طبيعة وأهمية المزايدة (م٢٠/٣).

وأوجب اللائحة فى جميع الحالات ، عدم المبالغة فى تحديد التأمين المؤقت ، لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط للمشاركة فى العملية محل الطرح.. ويتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت ، واعتماده من السلطة المختصة .. وعلى أن يتم تضمين مستندات الطرح مبلغ التأمين المؤقت (م٢٠/٢) فقرة أخيرة.

وعن كيفية أداء التأمين المؤقت ، نصت اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن يؤدى التأمين المؤقت بأى من الوسائل التى يصدر بتحديدھا قرار من وزير المالية، ومنها وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحويل الالكترونى ، أو بأى صورة من الصورتين الآتيتين:

١— بموجب خطاب ضمان مصدراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة ، وألا يقترن بأى قيد أو شرط ، وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الادارية مبلغاً يوازى التأمين المطلوب.

..... وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة ، على أن يتعهد المصرف المحلى بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازى التأمين المطلوب، وأنه ملتزم بادائه بأكمله عند أول طلب منها، دون الالتفات إلى أى معارضة من صاحب العطاء.

٢- يجوز لصاحب العطاء ، طلب سداد التأمين المؤقت خصماً من مستحقاته التى تقر الجهة الإدارية صلاحيتها للصرف من عمليات أخرى، من ذات الجهة الإدارية ، وفى تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية (م/٢١ من اللائحة).

الطبيعة القانونية للتأمين المؤقت (أو الابتدائي):

قدما أن مجالات القانون العام تختلف عن مجالات القانون الخاص، فى مادة العقود التى تبرمها الإدارة، إذ تتميز الإدارة فى مجال العقود الإدارية، بأنها تعمل فى إبرامه بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بملكيتها المتعاقد معها، بقصد تحقيق نفع عام، أو مصلحة مرفق من المرافق العامة.

— ولما كان التأمين الابتدائي يعد ضمانه لتنفيذ العقد، فضلاً عن تحقيق مبدأ المساواة بين المتنافسين — على نحو ما بينا آنفاً — فلا يعد التأمين المؤقت (أو الابتدائي) عربوناً أو له وصف العربون، المنصوص عليه فى المادة (١٠٢) من القانون المدني.

— إذا التأمين المؤقت (أو الابتدائي) مقصود به تحقيق أمرين هما: ضمان جدية العطاءات، والمساواة بين المتنافسين. وهذا ما نص عليه

القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، في المادة (٢٢) بأنه: (في غير حالات التعاقد بالإنفاق المباشر المطلوب فيها سداد تأمين مؤقت، يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته).

ثانياً: الأثر المترتب على عدم تقديم التأمين المؤقت:

— لم ينص المشرع صراحة على البطلان كجزاء لمخالفة قاعدة وجوب تقديم التأمين المؤقت كاملاً مع العطاء، إلا أن القواعد العامة تستوجب تقرير البطلان عند عدم تقديم التأمين المؤقت كاملاً، ومرد ذلك أن تقديم التأمين المؤقت هو إجراء جوهري، يتوقف عليه عدة حقوق للإدارة، إذ يصبح التأمين حقاً للإدارة، إذا سحب مقدم العطاء عطاءه، قبل فتح المظاريف، ولا يحتاج ذلك إلى إنذار تقدم العطاء، أو الالتجاء إلى القضاء^(١).

— والواقع إن هذا الشرط مقرر لمصلحة الإدارة، دون ترتيب البطلان، كجزاء على مخالفته، بل تعد مخالفة هذه القاعدة (تقديم التأمين المؤقت مع العطاء) إخلالاً بواجبات الوظيفة، يستوجب المساءلة، وليس البطلان^(٢).

وهذا ما نص عليه صراحة في م/٢٢ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، إذ قررت أنه، إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للجهة الإدارية، دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، أو يجوز استدائه من

^١ فتوى رقم ٩٨٠ في ٢٢/١٠/١٩٨٩م، ملف رقم ٤٤/١٥٨/٤٢٣.

^٢ أ.ع. طعن ٣١٧٤ لسنة ٢٩ ق في ٣١/٣/١٩٩٠م.

أي مبالغ مستحقة، أو تستحق لديها، أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور.

وهنا ثمة تفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: عدم تقديم مقدم العطاء التأمين المؤقت المحدد قانوناً، في عطاءه.

الحالة الثانية: انسحاب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية.

في الحالة الأولى: يستبعد كل مقدم عطاء أو متزايد، لم يسدد مبلغ التأمين المحدد كاملاً، ويعد عطاءه كأن لم يكن وأن قبول الإدارة هذا العطاء، يكون غير صحيح، ولا ينتج أثراً يتم به العقد الإداري^(١).
والمستقر فقها وقضاء، عدم ترتيب البطلان على عدم إيداع التأمين المؤقت، إذا اطمأنت الإدارة إلى ملاءة مقدم العطاء^(٢).

أما في حالة انسحاب مقدم العطاء من العملية، قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للجهة الإدارية، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات، سواء إنذاراً ولجوء إلى القضاء، بل ولا يتوقف حق الإدارة، في هذه الحالة، على حصول ضرر بها، فالتأمين يصح من حق الجهة الإدارية، ولو لم يصبها ضرر، جراء انسحاب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف.

١ أ.ع. طعن رقم ٢٨٨ لسنة ٤٤ ق في ٩/٥/١٩٥٩م.

٢ أ.ع. طعن ٥٣٥ لسنة ١٠ ق، في ٨/٣/١٩٦٩م، طعن ١٣٨٦ لسنة ٨ ق في ١٤/٣/١٩٦٤م.

والسؤال: هل يجوز لمقدم العطاء التحلل من التزامه بإيداع التأمين المؤقت المحدد قانوناً مع عطاءه، بمقولة أنه لم يتقدم بالتأمين المؤقت مع العطاء؟

هل يجوز لجهة الإدارة قبول مثل هذا العطاء المجرد من التأمين؟ أم يتعين عليها استبعاده وعدم التعويل عليه وعدم الاعتداد به؟ وإذا هي قبلته، فما هو الأثر الذي يترتب علي ذلك القبول؟

— **المسلم به على ما قدمنا أن إيداع التأمين المؤقت من مقدما لعطاء في الوقت المحدد، شرط للنظر في عطائه، أيا كانت صورة التأمين (نقدا أم سندات أم كفالة مصرفية) وهذا الشرط مقرر للصالح العام، دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا اطمأنت الجهة الإدارية إلي ملاءة مقدم العطاء، بحسبان أن الحكمة المتوخاه من إيداع التأمين المؤقت، ضمان جدية مساهمة المتقدم بالعطاء في المناقصة، والتحقق من سلامة قصده في تنفيذ العقد، في حالة رسو العطاء عليه.**

— **ولا جدال في أن من حق الجهة الإدارية أن تستبعد العطاء المجرد غير المصحوب بالتأمين المؤقت الكامل، إلا أنها إذا قدرت مع ذلك أن تقبل مثل هذا العطاء، لأنه يتفق ومصلحتها، أو لأنها اطمأنت إلي صاحبه، فلا تثريب عليها في ذلك ولا يقبل الاحتجاج بعدم دفع التأمين المؤقت إلا ممن شرع تقديم التأمين ضماناً لحقوقه، وهو إما جهة الإدارة، لكي تضمن جدية العطاءات المقدمة إليها، وإما أولئك المتقدمون الآخرون الذين أودعوا التأمين كاملاً، إذ في قبول عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت، إخلالاً بمبدأ المساواة بين أصحاب العطاءات.**

– أما من قبلت جهة الإدارة عطاءه، فلا يقبل منه التحدي بأنه لم يدفع التأمين، ما دام التأمين غير مشروط لمصلحته.

– ولا يجوز للمقصر أن يستفيد من تقصيره، لأن في ذلك خروجاً على مبدأ ضرورة تنفيذ العقود بحسن نية.

وعلى ذلك، فلا يجوز لمن قدم عطاءه في مناقصة أو مزيدة أن يتحلل من التزامه، بمقوله أنه لم يتقدم بالتأمين المؤقت مع العطاء، وإلا كان في ذلك حض على العبث بمصلحة الإدارة، والمصلحة العامة، ومصلحة المرفق الفنية. فيجب أن يرد على مثل هذا المتلاعب قصده، بحيث إذا هو نكل عن تنفيذ ما التزم به حق عليه الجزاء، بل وإلزامه بالتعويض^(١).

وقدما أن تخلف صاحب العطاء الأقل عن إيداع التأمين المؤقت الواجب إيداعه، كشرط للنظر في العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة، اعتماداً على وجود مبالغ مودعة لدى جهة الإدارة كتأمين نهائي منه عن عقد سابق، يعتبر بمثابة تحفظ اقترن بالعطاء، يجوز التفاوض معه لإيداع مبلغ التأمين المؤقت^(٢).

وسؤال آخر: هل تعديل العطاء قبل فتح المظاريف – يعد عدولاً عن العطاء – ومن ثم يعتبر تقديم عطاء جديد؟

١ أ.ع. طعن ١٣٨٦ لسنة ٨ق، في ١٤/٣/١٦٤، مج س ٩ ص ٧٩٨.

٢ أ.ع. طعن ٢٨٨ لسنة ٤ق، في ٩/٥/١٩٥٩م.

— تفرقة بين حالتين: إذا كان من المسلمات أن يلتزم مقدم العطاء بعطاءه، ولا يكون له إلا أن يعدل عنه كلية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية (وهنا يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للإدارة، دون حاجة إلى أي إجراء آخر).

وأنه في مجال تعديل العطاء، ثمة تفرقة بين ما إذا كان التعديل بما يزيد عن الأسعار التي تقدم بها مقدم العطاء (ولو كان ذلك التعديل قبل جلسة فتح المظاريف) وبين ما إذا كان التعديل يتضمن خفض الأسعار. والقضاء مستقر على أن التعديل بما يزيد عن الأسعار التي تقدم بها مقدم العطاء غير جائز، ويعتبر انسحاباً من العملية، يستوجب توقيع جزاء مصادرة التأمين دون حاجة إلى أي إجراء آخر، ولا يعد ذلك عطاء جديداً.

أما في الحالة الثانية إذا كان التعديل يتضمن خفض الأسعار، فهذا جائز قانوناً، ولا يجوز أن تقاس عليه حالة رفع الأسعار^(١)، وعلة ذلك تحقيق مصلحة المرفق العام الفنية والمالية، ومراعاة المصلحة العامة.

ثالثاً: مدة سريان العطاء . ومدة الارتباط به : تفرقة:

— ثمة تفرقة بين ميعادي سريان العطاءات، والارتباط بها . فبينما المدة الأولى في سريان العطاء (إيجاب مقدم العطاء) تسري منذ التقدم بالعطاء حتى نهاية مدة سريان العطاءات المحددة قانوناً، بالمادة (٢٧) من القانون، وهي — على ما قدمنا — لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً، وفقاً لطبيعة العملية، وحسب ما يرد في

١ أ.ع. طعن ١٢٥٥ لسنة ٢٥ ق، في ١٩٨٢/٦/٢٦ م — مج س ٢٧، ص ٧٢١.

كراسة الشروط والمواصفات ، فإن مدة الارتباط بالعطاء، تبدأ من حيث تنتهي مدة سريان العطاء، ذلك أن إيجاب مقدم العطاء، لا يسقط بمجرد انقضاء مدة سريان العطاء، وإنما يبقى قائماً، إلي أن يصل إلي علم الجهة الإدارية طلبه سحب التأمين المؤقت.

إذا فثمة اختلاف كل من المجالين، مما لا يسوغ معه أن يمتد أثر الموقف الذي يتخذه مقدم العطاء في المجال الأول إلي المجال الثاني، إلا إذا أفصح مقدم العطاء صراحة، واقترن إفصاحه بقبول الجهة الإدارية. وهذا عين ما قصده المشرع في الفقرة الثانية من المادة (٢٧) من القانون، فيما قرره من وجوب إخطار مقدمي العطاءات على مد مدة سريان العطاءات، المدة التي توافق عليها السلطة المختصة، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت، فإن وافق مقدم العطاء (كتابة) على مد سريان مدة عطاءه، استمر (إيجابه) حتى صدور قرار إرساء التعاقد على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، وأن لم يقبل يستبعد سريان العطاء.

— ولكن ماذا لو ترك مقدم العطاء التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان عطائه، هل يعد ذلك قرينة (بسيطة) قابلة لإثبات العكس على قبوله استمرار ارتباطه بعطائه؟

المؤكد أن تقدم مقدم العطاء بطلب لاسترداد التأمين المؤقت ينفي هذه القرينة^(١).

١ أ.ع. طعن ٢٣٩ لسنة ١١ق، في ١٤/٦/١٩٦٩م.

رابعاً: حالات رد التأمين المؤقت:

حدد المشرع حالات رد التأمين المؤقت فيما يلي:

١- القيمة التقديرية للتأمين المؤقت:

— المسلم به أن القانون قد أناط بالسلطة المختصة تحديد مبلغ التأمين المؤقت، ضمن شروط الطرح، وأوجب عليها تقديره دون مبالغة، وبما لا يجاوز نسبة ١,٥% من القيمة التقديرية، في عمليات شراء أو استئجار المنقولات، والتعاقد على مقاولات الأعمال، وتلقي الخدمات، والأعمال الفنية، والدراسات الاستشارية.

— بينما لا يجاوز التأمين المؤقت نسبة ٠,٥% من القيمة التقديرية في عملية شراء أو استئجار العقارات.

— وترك للسلطة المختصة تحديد مبلغ التأمين المؤقت في عمليات بيع وتأجير المنقولات، والعقارات، والمشروعات، والترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات والمشروعات، حسب طبيعة وأهمية المزايدة (م/١٦) من القانون وقد أبانت اللائحة التنفيذية للقانون ذلك ، على ما قدمنا.

— والمعلوم أن تحديد قيمة التأمين المؤقت (والتأمين النهائي) وطريقة السداد، وأمور أخرى عديدة، يجب أن تضمنها كراسة الشروط والمواصفات.

٢- (أ) ويجب رد التأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً، دون توقف على طلب منهم.

(ب) وكذلك يجب رد التأمين المؤقت إلي المتزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة فوراً، دون توقف على طلب منهم نص على هاتين الحالتين في (م/٢٢) من القانون.

(ج) في حالة وفاة مقدم العطاء، أيا كانت طبيعته (شخص طبيعي، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير، بحصة حاکمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة في العطاء، قبل البت، يرد التأمين المؤقت، ما لم تسمح الجهة الإدارية بالاستمرار في الإجراءات) (م/٢٤).

(د) ويجب رد التأمين إلي مقدم العطاء، الذي لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة (م/٢٧).

(هـ) يجب رد التأمين المؤقت (وثن كراسة الشروط) إلي أصحاب العطاءات، في حالة إلغاء المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، إذا كان سبب الإلغاء راجعاً إلي أنه:

— لم يقدم سوي عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

— إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.

— إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية.

ويستثنى من ذلك، مقدمي العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم، أو ممارسات احتيالية، أو فساد أو احتكار، فأولئك لا يرد إليهم التأمين المؤقت ولا يرد إليهم أيضاً ثمن كراسة الشروط (م/٢٧) من القانون.

خامساً: التأمين النهائي:

— من المسلمات أن التأمين (أيا كان نوعه مؤقتاً أو نهائياً) قد شرع ضمناً لجهة الإدارة ، ليؤكد حسن نية مقدم العطاء، ويضمن ملاءمته وإمكانياته لتنفيذ العقد وجديته، فضلاً عن توقي الأخطاء التي قد تصدر عن المتعاقد معها، وبما يسمح للإدارة حق مصادرة التأمين (اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر)، بل والرجوع عليه بالتعويضات المقابلة للإضرار الأخرى التي تكون لحقت بالإدارة من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد.

وقضي بأن للإدارة الحق في توقيع غرامة التأخير، كما أن لها الحق في مصادرة التأمين، عند وقوع الإخلال دون حاجة لإثبات الضرر.

والأسئلة التي تطرح — هنا — تنور حول:

ماهية التأمين النهائي ، كيفية تقديره ، الأثر المترتب على عدم سدادده ونعرض لكل ذلك فيما يلي:

١- ماهية التأمين النهائي:

— أوجبت المادة (٤٠) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م على صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي بنسب معينة، وحالات محددة.

— وعلى ذلك فإنه إذا قبل العطاء، فإن على صاحبه أن يكمل خلال مدة معينة من تاريخ إخطاره بقبول عطائه التأمين المؤقت إلى النسبة المحددة للتأمين النهائي (وهي نسب بالطبع أعلى من التأمين المؤقت) وذلك ضمناً لتنفيذ التعاقد، أي لا يلزم بالتأمين النهائي سوي المتعاقد الذي قبل عطائه، وبمجرد إخطاره بقبول عطائه.

٢-قيمة التأمين النهائي وكيفية تقديمه والمدة المحددة لذلك

(م/٤٠):

— تختلف قيمة التأمين النهائي، باختلاف طريقة التعاقد، وكذا تختلف باختلاف طبيعة عملية التعاقد (محل التعاقد).

— إذ حدد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م قيمة التأمين النهائي في عمليات شراء أو استئجار المنقولات، والتعاقد على مقاولات الأعمال، وتلقي الخدمات، والأعمال الفنية، والدراسات الاستشارية، بنسبة (٥%) من قيمة العقد، ويجب أن يؤدي التأمين النهائي، في خلال مدة عرشة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، هذا بالنسبة للعقود التي تتم في الداخل، بينما تزداد المدة إلى عشرين يوماً، إذا كان التعاقد في الخارج.

ويتم الإخطار بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس.

— في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، تحجز ما يعادل (٥%) من مستحقات المتعاقد، وذلك في حالات التعاقد التي تتطلب بحسب طبيعتها، ضمان متعاقد لسلامة محل العقد.

— في عمليات شراء العقارات، تحجز نسبة (٣%) من الثمن، وترد إلى البائع فور التسجيل، أو مضي عام من تاريخ تسلم العقار للجهة الإدارية، أيهما أبعد، لمواجهة إصلاح أي عيوب قد تظهر خلال هذه المدة.

— في حال بيع المنقولات يجب على من يرسى عليه المزداد، أن يسدد نسبة (٣%) من قيمة ما تم ترسيته عليه فور الرسو.

– وفي عمليات بيع العقارات والمشروعات يجب على من ترسو عليه المزايدة أن يسدد (١٠%) من قيمة ما تم ترسيته عليه فور الرسو.

– وفي حالة تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات والمشروعات، يجب على من يرسو عليه المزداد، في العقود التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات، أن يقدم تأميناً نهائياً، بما يعادل (١٠%) من القيمة الكلية الراسي بها المزداد، عن مدة العقد بالكامل، فور رسو المزداد.

ويجب أن يظل التأمين النهائي سارياً طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات، يحسب التأمين النهائي الواجب تقديمه بواقع (١٠%) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، ويحدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية، أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.

– وفي عقود التوريد، لا يحصل من صاحب العطاء الفائز التأمين النهائي، إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الإدارية بصفة نهائية خلال المدة المحددة لأداء التأمين النهائي، ما لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان أما في الحالات التي تتطلب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل العقد، فيتم خصم نسبة (٥%) من مستحقاته.

وفيما يتعلق بالتأمين النهائي ، وقد أوجبت اللائحة على صاحب العطاء الفائز سداد قيمة التأمين النهائي ، خلال المدة المحددة لذلك ، وأنه حال عدم التزام صاحب العطاء الفائز لذلك، يجب على إدارة التعاقدات

اعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة ، باقتراح منح صاحب العطاء الفائز مهلة إضافية بما لايجاوز عشرة أيام عمل (م ١/٨١). وإذا لم يقدّم صاحب العطاء الفائز بسداد التأمين ، يتم اتخاذ أحد الاجرائين التاليين ، وبما يحقق مصلحة الجهة الادارية ، وهما :

١- الغاء العقد.

٢- التنفيذ بواسطة أحد العطاءات التالية فى الترتيب بشرط أن يكون فى حدود القيمة التقديرية.

وفى جميع حالات عدم سداد التأمين النهائى ، يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الادارية ، كما يكون لها أن تخصم قيمة أى خسائر فعلية تلحق بها، تسبب فيها صاحب العطاء الفائز، وفى حالة عدم كفايتها لديه، يتم خصمها لدى أية جهة ادارية أخرى ، مع عدم الاخلال بحقوقها فى الرجوع عليه قضائياً ، بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى (م ٢/٨١).

— ويكون إداء التأمين النهائى ، بذات الوسائل المتبعة فى أداء التأمين المؤقت (الدفع الالكترونى — خطاب ضمان).

ويكون التأمين النهائى سارياً لمدة تبدأ من وقت سريانه إلى مابعد انتهاء العقد بثلاثة أشهر، مالم يتفق على غير ذلك (م ٨٢).

فى رد التأمين النهائى:

— لما كان التأمين النهائى ضامناً لتنفيذ العقد، وأنه يجب رده، أو ما تبقى منه فور إنتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد، بغير طلب خلال مدة

عشر أيام عمل، ما لم تعدل مدة التعاقد . وإذا تجاوزت قيمة التأمين المؤقت التأمين النهائي، وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب.

— وقد أحال القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م إلى اللائحة التنفيذية، تحديد الصور، والشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين النهائية وكيفية أدائه، وردده واستبداله، والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه (م/٤٢).

٣- في الأثر المترتب على عدم أداء التأمين النهائي:

أخذ القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بكل ما استقر عليه القضاء وإفتاء مجلس الدولة، في هذا الصدد، فنص في (م/٤١) على أنه: (إذا لم يقيم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المدة المحددة، جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار يرسل له بالبريد السريع، وتعزيزه بالبريد الإلكتروني ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر).

إلغاء العقد، أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه، بحسب ترتيب أولوياتها (على حساب صاحب العطاء الفائز) ، وكذا مصادرة التأمين الابتدائي (وبمراعاة عدم جواز الجمع بين الاجرائين) ، وأيضا للجهة الإدارية أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة، أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء.

بل وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيما كان سبب الاستحقاق. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً، بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

— وقدمنّا، أن تراخي مقدم العطاء الفائز في التعاقد عن تكملة التأمين النهائي يعد إخطاره بقبول عطائه لا يؤثر في صحة انعقاد العقد الذي يتم من تاريخ الإخطار.

وقضي بأن تجاوز جهة الإدارة عن التأخير في الوفاء بقيمة التأمين النهائي وقبوله، يقطعان بأن جهة الإدارة أبقت على العقد^(١).

وفي هذه الحالة يصبح قيمة التأمين ديناً مستحقاً للإدارة في ذمة المتعاقد، فضلاً عن جواز اتخاذ الإدارة ما تراه من جزاءات أو المطالبة بالتعويض كما حالة عدم السداد.

ونشير إلي أنه لا اختلاف في حالي التراخي في تكملة التأمين، أو عدم أدائه ، إذ الجزاءات متعددة في كلا الحالتين، حسبما ترى جهة الإدارة على ما قدمنا.

— وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الإدارية النزول عن شرط سداد قيمة التأمين (المحددة قانوناً) لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتناقصين، وبحسبان أن هذا الشرط هو شرط جوهري في التعاقد، يترتب علي النزول عنه فقدان الإدارة لضمائنه من الضمانات التي شرعت لصالحها، لضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وهو ما قد يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما بعد.. ولكن لا تأثير له على صحة التعاقد.

^١ أ.ع. طعن ١٠٧٣ لسنة ٣١ ق، في ١٦/١/١٩٩٠م الطعن ١٢١٩ لسنة ٣٣ ق، في ٧/٧/١٩٩٢م، الطعن ٣٣٧٨ لسنة ٣٨ ق، في ٤/٣/١٩٩٧م.

سادساً وأخيراً: الخطوة الأخيرة في إبرام العقد (القبول في العقد

الإداري):

قدّمنا أن قرار لجنة البت بالترسية، لا يعني إبرام العقد، إذ لا بد من اعتماد السلطة المختصة للتعاقد، فهذا الإجراء وحدة (اعتماد قرار لجنة البت من السلطة المختصة) هو الذي يعتبر قبولا.

ويلزم تطابقه مع الإيجاب حتى إذا وصل القبول إلي علم من وجه إليه، اعتبر العقد مبرما من تاريخ هذا الوصول، ما لم ترى السلطة المختصة غير ذلك (إذ قد ترى السلطة المختصة إلغاء التعاقد كليا)^(١).

وفي ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة (٣٥) من القانون ١٨٢

لسنة ٢٠١٨م على أن: (ترفع لجنة البت محضرها متضمنا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد، أو لتقرير ما تراه وفي جميع الأحوال يجب تسبيب القرار الصادر باعتماد قرار لجنة البت وتوصياتها).

^١ فتوى الجمعية العمومية رقم ٢٨٧ في ٢٧/٣/١٩٦١م.

وقدّمنا أن للسلطة المختصة إلغاء المناقصة أو المزايدة سواء قبل البت فيها، أو بعده وأن سبب الإلغاء قبل البت قد حددت حالاته م/٣٧ من القانون، والمادة (٣٨) أيضا، ويخضع إلغاء المناقصة أو المزايدة بعد البت لتقدير الجهة الإدارية (السلطة المختصة) إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

— القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م يستلزم إخطار جميع مقدمي العطاءات بنتائج قرارات لجنة البت بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء، فور اعتماد السلطة المختصة لها مع حفظ حق هؤلاء في التقدم بشكواهم خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار.

— بينما أوجب إخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه، خلال مدة لا تجاوز يومين، بعد انقضاء مدة السبعة أيام على ما تقدم.

— وأكثر من ذلك نشر قرارات لجان التعاقد، ونتيجة الترسية في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض، والمحدد لها مكان ظاهر للكافة، كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة.

وعلى أن يشمل الإعلان:

١- نتائج القرارات، وأسبابها بالقبول، أو الاستبعاد، أو الإلغاء، أو الترسية للعطاءات.

٢- القيمة النهائية للمشروع، وقيمة المكون الصناعي المصري.

٣- منشأ الصنع وبلده المنتجات التي تضمنتها العقود التي أبرمت لشراء منتجات صناعية (م/٣٩ من القانون).

الباب الثانى

تنفيذ العقد الادارى

تمهيد وتقسيم :

قدمنا أنه فى مجال العقود الإدارية ، تبرز بعض الاختلافات الجوهرية ، فى بعض المسائل عن مثيلاتها فى عقود القانون الخاص ، ذلك أن العقد الادارى ، يتميز بأن أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام ، ويتضمن أحكاماً استثنائية غير مألوفة لامثيل لها فى العقود الخاصة، فهو فى مجمله يعد علاقة مركبة لاتتحدد أحكامه على وفق نصوص العقد الموقع بين الطرفين فحسب ، بل تمتد أيضاً إلى كل ماسبق مرحلة التوقيع على العقد ، وكان محل توافق وحاز رضا الطرفين.

والمعلوم أن مرحلة ابرام العقد — على ماتقدم — تنتهى باعتماد السلطة المختصة قرار لجنة البت بترسية (المناقصة أو الممارسة) ، وإخطار الراسى عليه المزاد (أو المتناقص) بقرار السلطة المختصة ، بالكيفية التى حددها القانون وجوباً ، ومن ثم التوقيع النهائى على العقد . ومن ثم فان حملة مايكلل هذه الشروط من توافق عليها ، بالاضافة إلى الشروط العامة التى تظلل المزايدة ، تنصهر جميعها فى وحدة واحدة ، وتستحيل جزءاً لايتجزأ من الأحكام الواردة بالعقد الموقع بين الطرفين ، إذ تتخرط جميع هذه الشروط فى أحكام العقد ، بحيث يضحى العقد الإدارى فى نهاية الأمر جزءاً واحداً ، متضمناً بين دفتيه أحكامه الأصلية، وماسبقه من شروط وموافقات .

ومن ثم تترتب حقوق والتزامات الطرفين ، وفق ذلك ، ويحتج به فى مواجهتهما من منطلق أنه عقد واحد (١).

وانه بتمام إبرام العقد الإدارى (صحياً)، ودخولة حيز التنفيذ فانه (أى العقد الإدارى) يعد هو قانون المتعاقدين ، وأن الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين ، نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة ، باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها (٢).

والمسلم به ، أن تخضع العقود لأصل عام من أصول القانون يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبها حسن النية ، وهو أصل مطبق فى العقود الإدارية ، شأنها فى ذلك شأن العقود المدنية ، ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقاً لشروط العقد الذى يربطه بجهة الإدارة ، فهو شريعتهم التى تلاقى عندها إرادتهما، ذلك أن النص الذى يتحدد باتفاق الطرفين فى العقد الإدارى يقيد طرفيه كأصل عام ، ويصبح واجب النفاذ ، ويمتنع الخروج عليه (٣).

المبدأ المهيمن على تنفيذ العقد الإدارى : سمو المصلحة العامة فى تنفيذ العقد.

١ أ.ع ، طعن رقم ٣٤١٠٤ لسنة ٥٤ ق ، فى ٢٤/١/٢٠١٧.

٢ نقض مدنى ، طعن ١٧٦٨٧ لسنة ٧٧ ق ، فى ٨/٣/٢٠١٠ .

٣ أ.ع — طعن ٨٦٤٣ لسنة ٥٠ ق ، فى ١٦/٦/٢٠١٥.

من المسلمات ، أن العمل على دوام سير المرافق العامة بانتظام وإطراد ، يعد المبدأ — الأهم — الذى يهيمن على تنفيذ العقد الإدارى ، ويظهر ضرورة الحفاظ على هذا المبدأ جلياً فى نطاق تنفيذ العقد الإدارى، فهذا المبدأ هو الذى يبرر السلطات الاستثنائية لجهة الإدارة فى تنفيذ العقد الإدارى ، كما وأنه المبدأ الذى يبرر للجهة الإدارة أن تخرج — فى بعض الأحيان — عن التزاماتها التى وافقت عليها ، وأوردتها فى العقد الذى أبرمته مع المتعاقد معها ، بمعنى أن إظهار هذا المبدأ يجعل من اليسير معرفة أسباب حرص المشرع على إعطاء الجهة الإدارية السلطات الاستثنائية الغير مألوفة فى العقد المدنى. ذلك أن المشرع حريص على أن تستطيع جهة الإدارة من خلال العقد الإدارى ، أن تحقق إشباع الحاجات العامة ، وتحافظ على سير المرافق العامة بانتظام وإطراد ، وهذا هو الدور الرئيسى لها فى أى نظام سياسى أو اقتصادى. وانه إذا كان الأصل المستقر عليه ، هو ضرورة احترام مبدأ الالتزام العقدى ، إلا أن من مقتضى مبدأ دوام سير المرافق العامة ، انه لايجوز النزول عن شرط من شأنه ان يحل الجهة الادارية من سلطاتها الأساسية تجاه المتعاقد المتقاعس معها، فلايجوز الاعتذار بشرط ورد فى العقد الإدارى يمنع الجهة الإدارية من إستعمال سلطتها فى تعديل العقد ، (أو توقيع الجزاءات الادارية على المتعاقد معها، متى توافرت أسباب توقيعها، أو فسخ العقد ، أو انهاؤه بارادتها المنفردة) فمثل هذه الشروط إن وجدت فى العقد ، فهى شروط باطلة ، لايعتد بها ، لتعلقها بالنظام العام . ذلك أن العقود الادارية تختلف عن العقود المدنية ، فى أنها تستهدف تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة.

وفى عبارة واحدة : إن طبيعة العقود الادارية وأهدافها، وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة ، تفترض مقدماً حدوث تغيير فى ظروف العقد ، وملايساته ، وطرق تنفيذه ، تبعاً لمقتضيات سير المرفق العام^(١).

وتطبيقاً لذلك ، قضى بأن مبدأ سير المرافق العامة بانتظام وإطراد ، يمنع الدفع بعدم التنفيذ، فلا تسرى المادة (١/١٥٧) مدنى ، فى مجال العقود الادارية ، والتي تقضى بأنه فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد الطرفين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر من اذاره المدين ، ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين ، إذا كان له مقتضى.

وتعد قاعدة عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ للعقد ، من المبادئ المستقرة باجماع الفقه والقضاء. ومرد ذلك ، ما تتميز به العقود الادارية من طابع خاص ، مناطه تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. ومن ثم فلا يسوغ للمتعاقد مع الادارة الامتناع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق ، بحجة أن ثمة اجراءاته ادارية قد أدت إلى الاخلال بالوفاء بأحد التزاماتها قبله ، بل يتعين عليه ، ازاء هذه الاعتبارات أن يستمر فى التنفيذ ، مادام ذلك فى استطاعته ، ثم يطالب جهة الادارة بالتعويض عن إخلالها بالتزامها، إذا كان لذلك مقتضى ،

^١ أ.ع - طعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ق ، فى ١١/٢٤/١٩٩٨.

ولأن له فيه وجه حق ، فلا يسوغ له الامتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة ، وإلا حقت مساءلته عن تبعه فعله السلبي ^(١).

بل يعد مبدأ دوام سير المرافق العامة ، هو أساس نظريات التوازن المالي (فى العقد) ، كما وأنه — أى المبدأ — هو سبب ظهور هذه النظريات (. وتشمل نظريات التوازن المالي للعقد، نظرية الظروف الطارئة فى العقود الادارية ، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، ونظرية عمل الأمير ^(٢)).

وهكذا تتحدد أبعاد البحث فى تنفيذ العقد الادارى ، وتتحدد معالمه ، فى تناول ثلاث مبادئ جوهرية هى : مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقد الادارى ، ومبدأ جواز تعديل العقد الادارى بإرادة الجهة الادارية ، ومبدأ التوازن المالي فى العقد الادارى.

ونتناول كل واحد منها ، فى فصل مستقل على النحو الآتى :

^١ أ.ع — طعن ١٧٣٤ لسنة ٣٩ ق ، فى ٤/٤/٢٠٠٠ ، طعن ٦١٨ لسنة ٤٠ ق ، فى ١٩٩٩/٢/٩.

^٢ فى تفصيلات ذلك ، رسالة الدكتور / على محمد عبد المولى ، بعنوان : الظروف التى تطرأ أثناء تنفيذ العقد الادارى — دراسة مقارنة ، جامعة عين شمس سنة ١٩٩١م.

الفصل الأول

مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقد الإدارى

المبادئ العامة فى تنفيذ العقد الإدارى لاتخل بمبدأ حسن النية فى

تنفيذ العقد :

من المسلمات أن علاقة المتعاقدين فى العقود الادارية ، لاتستند إلى شروط العقد فقط ، وإنما تستند أيضا إلى القواعد القانونية التنظيمية الخاصة بالمرافق العامة ، بمعنى أن جهة الادارة لاتستمد امتيازاتها فى نطاق العقود الإدارية من نصوص العقد ، وإنما من طبيعة المرفق العام واتصال العقد به ، ووجوب الحرص على انتظام سيره واستدامة تعهد الادارة وإشرافها عليه ، بما يحقق المصلحة العامة ، ومن هنا يحق للإدارة مباشرة السلطات ولو لم ينص عليها فى العقد^(١). وهذا أولا.

وانه يترتب على فكرة علو المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة ، والتي تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإدارى ، ويترتب عليها أن يكون للإدارة سلطة الاشراف والتوجيه على تنفيذ العقود، وان لها دائما حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة ، بما يتراءى لها أنه أكثر إتفاقاً مع الصالح العام ، دون أن يتحدى الطرف الآخر ، بقاعدة " أن العقد شريعة المتعاقدين " ، بشرط ألا يصل التعديل إلى حد فسخ العقد كلية ، وإلا جاز للطرف الآخر فسخه ، وبشرط أن يكون له الحق فى التعويض إذا أختلت الموازنة فى الشروط المالية ، كما يترتب عليها كذلك أن للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد ، إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام ، وليس للطرف الآخر إلا الحق فى التعويض إن كان له

^١ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ٥٤٧ ، فى ١٥/٨/١٩٦٢.

وجه ، وهذا على خلاف الأصل فى العقود المدنية ، التى لايجوز أن يستقل أحد الطرفين بفسخها أو إنهائها دون ارادة الطرف الآخر^(١). وهذا ثانياً.

وافثناء مجلس الدولة مستقر – أيضا – على أن الادارة تراعى فى الشروط الجزائية المنصوص عليها فى عقد ما ، ملائمتها لطبيعة هذا العقد ، وقيمته ، وموجبات السرعة فى تنفيذه فى وقت معين ، وطريقة معينة ، حتى تكفل انتظام سير المرافق العام ، هذا فضلا عن أن المتعاقد مع الإدارة ، يقبل التعاقد وهو عالم مقدماً بجميع الشروط ، والظروف المحيطة بالعقد^(٢) هذا ثالثاً.

وربما كان صحيحاً ، ماذهب إليه بعض الفقه من أنه فى مجال تنفيذ العقد الادارى والسلطات التى تملكها الادارة ، ليس ثمة كلام عن حقوق والتزامات الطرفين فى العقد إلا فى خصوص امكانية تحديد المسؤولية العقدية ، من خلال أحكام القضاء. إذ كل ماتناوله القضاء (والفقه)، يتعلق بالتزامات الإدارة فى احترام شروط التعاقد ، والالتزام بحسن النية ، والالتزام باعادة التوازن المالى للعقد ، والتزامات المتعاقد مع الادارة بالتنفيذ الشخصى للعقد ، وتنفيذه فى المدة المحددة ، وضمان سير المرفق العام ، والالتزام بتنفيذ الأعمال محل التعاقد ، وتسليمها ، والالتزام بتنفيذ الأعمال محل التعاقد ، وتسليمها ، والالتزام بضمان سلامة الأعمال^(٣).

^١ أ.ع – طعن رقم ١٥٢ لسنة ٢٠ ق ، فى ١٩٥٧/٤/٢٠.

^٢ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ٦٣٧ فى ١٩٥٦/١٠/٢٥.

^٣ المستشار حمدى يس عكاشه ، العقود الادارية ، مرجع سابق ، ص ٣٥١.

ومرد ذلك أن الإدارة لا تهدف من وراء إبرام العقود الادارية إلى تحقيق ربح مالى ، وإنما تحقيق مصلحة عامة ، وتسيير مرفق عام ، لسد حاجة المواطنين.

إن اعمال هذه المبادئ العامة فى تنفيذ العقد الادارى ، لا تتعارض مع وجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النية ، ذلك أن هذا المبدأ (مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقد الادارى) ، هو اصل مطبق فى العقود الادارية ، شأنها فى ذلك شأن العقود المدنية — عدم إخلال ذلك ، بما تتميز به العقود الادارية من طابع خاص ، مناطه احتياجات المرفق ، وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة.

وقد أكدت على ذلك المبدأ جميع أحكام القضاء، وإفتاء مجلس الدولة. كما وقد نص على أن يكون تنفيذ العقود طبقاً لما اشتملت عليه ، وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النية ، وفى الحدود ، ووفقاً للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بهذا القانون ، ولائحته التنفيذية (م/٤٣) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

(٢) فماذا يعنى مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقد الادارى ؟

— وماهى الحدود التى يتم الالتزام بها فى هذا الشأن ؟

أولاً: مفهوم مبدأ حسن النية :

(أ) مبدأ حسن النية من المبادئ العامة للقانون :

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ القانونية العامة ، حتى أنه بلغ حداً من الرسوخ فى أنه فى حالة عدم النص عليه ، يمكن الاستدلال عليه من خلال مظاهره ، كالالتزام بحدود القانون (وبمراعاة أن العقد هو قانون المتعاقدين) ، وعدم الالتجاء فى تنفيذ العقود ، بما يخالف القانون ،

كالغش والتواطؤ باعتبارهما من مظاهر سوء النية . بل لقد أصبح مبدأ حسن النية جزءاً لا يتجزأ من النظم القانونية ، من الصعب انكار وجوده. والمعلوم أن مبدأ حسن النية يجد صдаاه فى العديد من نصوص القانون ، فضلاً عن النص عليه صراحة فى القانون المدنى (م/ ١٤٧) ، وذات النص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ (المادة ٤٣) ، والتي تنص على أن " يكون تنفيذ العقود طبقاً لما اشتملت عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفى الحدود ، ووفقاً للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية " .

— ويرتبط مبدأ حسن النية ، بمبدأ الشفافية ، التي تخضع له طرق التعاقد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة (رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨)^(١) .

— كما وانه للادارة تغليظ الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب فى تنفيذ العقد الادارى ، يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته^(٢) .

^١ قدمنا انه فى حال الغاء المناقصة ، والممارسة (م / ٣٧) ، أو المزايدة (م / ٣٨) نص على رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات ، عدا مقدمى العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات إحتيال ، أو فساد ، أو احتكار .

^٢ أ.ع ، طعن رقم ٩٥ لسنة ٩ ق ، فى ١٤/٥/١٩٦٦ . وتجدر الاشارة إلى إنه ولذات العلة ، تغلط الجزاءات على المتعاقد الذى يشرع فى رشوة احد موظفى الجهة الادارية ، أو يتواطؤ معه اضراً بها .

كما وان هناك علاقة وثيقة بين مبدأ حسن النية وقاعدة القوة الملزمة للعقد ، التى تفرض على المتعاقد تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد بحسن نية . ومن ثم فان الإخلال بما تستوجبه القوة الملزمة للعقد ، من وجوب تنفيذه ، ووجوب مراعاة الأصول القانونية والأخلاقية فى ذلك ، يعنى الإخلال بالتزام المتعاقد بحسن النية ، سواء تم الإخلال عمداً ، أو دون قصد الإضرار بالمتعاقد الآخر ، بأن يكون الإضرار تم باهمال أو تقصير أو قلة احتراز.

وأخيراً ، يعد مبدأ حسن النية من المبادئ الحاكمة لتنفيذ العقود ، وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء المدنى والإدارى على السواء. اذ تخضع العقود لأصل عام من أصول القانون ، يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وهو أصل مطبق فى العقود الادارية ، شأنها فى ذلك شأن العقود المدنية ، وبمراعاة أن تطبيق هذا المبدأ يمتد ليشمل ما هو لصيق بالعقد ويعتبر من مستلزماته^(١).

(ب) مبدأ حسن النية ونظرية التعسف فى استعمال الحق :

إن مقتضى إعمال مبدأ حسن النية ، ألا يتعسف أى طرف فى العقد فى المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه ، وأن يبسر كل طرف للآخر تنفيذ التزاماته ، إذا ما واجهته صعوبات تؤخر إتمامها.

— وقضى بأنه ، إذا تعثر المتعاقد مع الإدارة فى التنفيذ لظروف خارجة عن ارادته ، بعضها يرجع إلى جهة الادارة ، وتفهمت الادارة تلك الظروف ، فان ذلك يستوجب منحة مهلة إضافية للتنفيذ ، تكون معقولة فى ضوء مناخ الاستثمار ، وما يحيط به من طفرات وعثرات ،

^١ فتوى الجمعية العمومية رقم ٨٨١ فى ١٢/٢/١٩٩٥ ، ملف رقم ٢/٣٢/٢٥٩٤.

إذا قامت الجهة الادارية باعمال الشرط الفاسخ فى العقد فى هذه الحالة ، غير آخذة بهذا النظر فى تطبيق مبدأ حسن النية ، فان قرارها يكون مخالفاً للقانون ، مستوجباً الالغاء (١).

وقضى أيضا ، بأن : " مايرد ببنود العقد ، يقيد كأصل عام طرفيه ، فلا يحوز تعديلها إلا باتفاقهما الكامل ، ولايجوز لجهة الادارة أن تتعسف فى استعمال حقوقها الواردة بالعقد ، أو تتحرف بسلطتها لغير المصلحة العامة (٢).

ومبدأ عدم جواز التعسف فى استخدام الحق ، يسرى على طرفى العقد ، فلا يتعسف أى طرف فى المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه (٣).

(٢) تطبيقات عملية لمبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود الادارية :

وتطبيقاً لمبدأ وجوب تنفيذ العقد الادارى طبقا لما اشتمل عليه بما يتفق ومبدأ حسن النية ، فقد قضى بأن :

— المقابل المالى يختلف باختلاف العقود الادارية ، وتتنوع صوره بحسب طبيعة العقد ، الشروط المتصلة بالمقابل النقدى ، تولد مراكز ذاتية ، تتحدد باتفاق الطرفين ، فلا يملك أى طرف التحلل منها ، أو الخروج على أحكامها دون موافقة الطرف الآخر ، أو بناء على نص فى القانون ، وذلك نفاذا لمبدأ ثبات أو جمود الشروط التعاقدية المتعلقة

١ أ.ع — طعن رقم ١٠٧٨٢ لسنة ٤٩ ق ، فى ٢١/٢/٢٠٠٩.

٢ أ.ع — طعن رقم ١٤٤٩٤ لسنة ٤٩ ق ، فى ٢٣/٩/٢٠٠٨.

٣ أ.ع — طعن رقم ٣٤٦٤٦ لسنة ٥٦ ق ، فى ٦/٣/٢٠١٦ ، فتوى الجمعية العمومية ، رقم ٨٩٦ ، فى ٧/١١/١٩٩٣ ملف رقم ٢٢٦٢/٢/٣٢.

بالمقابل النقدي ، سواء تعلقت هذه الشروط بكيفية تحديد هذا المقابل ، أو حالات ومواعيد وأساليب الوفاء به.

— وأن الثمن المتفق عليه في العقود الادارية ، يقيد طرفيه كأصل عام ، لا يوجد مانع قانوناً من الاتفاق على تعديله ، إذا ما تلاقى ارادة الجهة الادارية والمتعاقد على ذلك.

— وأن الغلط المادى ، لا يؤثر في صحة العقد ، ويجب تصحيحه.

— وقضى أيضا بأنه : إذا ثبت ان البضاعة الموردة تتفق مع المواصفات في التركيب ، وان الشوائب اللاحقة بها لا تؤثر على صلاحيتها للاستعمال ، فلم يكن ثمة ما يحول — تطبيقاً لمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية — دون قبول الكميات الموردة ^(١).

— والتزام جهة الادارة بتسليم الأصناف محل التعاقد ، بالحالة التى كانت عليها وقت انعقاد العقد — مسئولية الادارة عن كل نقص فى مقاديرها ، بحسب ما يقضى به العرف الجارى عليه العمل فى المعاملات ^(٢).

— كما وأن التحفظ العام للمقاول بشأن محاسبته على أى زيادة تطرأ فى أسعار مواد البناء ، يندرج ضمن شروط العقد ، ويعد جزءاً منه يلزم طرفيه ، سواء كان مصدر الزيادة قراراً سيادياً أو رفع الجهة المنتجة للسلعة سعرها ^(٣).

^١ أ.ع — طعن ١٥٢٠ لسنة ٢٢ ق ، فى ١٩٥٧/٤/٢٠.

^٢ أ.ع — طعن ٩٥٤ لسنة ١٢ ق ، فى ١٩٦٩/٤/١١.

^٣ أ.ع — طعن ٤٥٢٧ لسنة ٤٦ ق ، فى ٢٠٠٤/٦/٦.

— وأنه إذا تجاوزت مدة تنفيذ الأعمال الحد المعقول بسبب عدم قيام الإدارة بالتزامها باداء مقابل الأعمال لعدم توافر الاعتماد المالى ، فلها أن تعيد النظر فى الأسعار المتعاقد عليها أصلا ، فى ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ ، حتى لاتختل اقتصاديات العقد ، وتجاوز المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، على نحو يعوق المتعاقد مع الادارة من النهوض بتنفيذ التزامه ، ليس فى ذلك ما يخالف النظام العام^(١).

(٣) حدود الالتزام بمبدأ حسن النية — الدفع بعدم التنفيذ :
المبدأ : — الأصل أنه لايجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يدفع بعدم تنفيذها التزاماتها ، ولو ثبت أن هناك إهمالاً أو تقصيراً منها.
استثناءات : تستثنى من هذا الأصل حالتان :

الأولى : إذا ترتب على تقصير جهة الإدارة استحالة التنفيذ.
والثانية : إذا اتفق الطرفان فى العقد على الخروج على هذا الأصل.
— إذاً : الأصل أنه لايجوز للمتعاقد مع الادارة أن يتوقف عن تنفيذ التزاماته ، كما لايجوز له الدفع بعدم التنفيذ ، لأن هذا الدفع ، كأصل عام غير جائز فى العقود الادارية ، لاتصالها بالمرافق العامة التى يجب أن تسير بانتظام واضطراد ، فلايجوز للمتعاقد مع الادارة أن يوقف سير المرفق لأى سبب ، حتى لو كان الخطأ أو التقصير من جانب الادارة فى تنفيذ التزاماتها التعاقدية ، وإلا كان مخالفاً بالتزاماته قبلها^(٢).

^١ أ.ع — طعن ٤٤٦٥ لسنة ٥١ ق ، فى ٢٠/١١/٢٠٠٧ ، وفتوى الجمعية العمومية رقم ٥٤١ ، فى ٨/٧/١٩٩٣.

^٢ أ.ع — طعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٤١ ق ، فى ١٢/٥/١٩٩٨.

كما ولايجوز للمتعاقد مع الادارة - كأصل عام - ، أن يمتنع عن التنفيذ بحجة وجود إجراءات ادارية أدت إلى اخلال الإدارة بأحد التزاماتها قبله ، ويتعين عليه أن يستمر في التنفيذ خلال الميعاد المحدد ، ثم يطالب الجهة الادارية بالتعويض إذا كان له مقتض.

على أن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه ، ولايسوغ إعماله إلا فى الحالات التى يكون فيها المقاول فى موقف يسمح له بتذليل تلك الاجراءات ، والتغلب عليها دون ضرر جسيم يصيبه.

أما أن تخل الادارة بالتزام جوهرى أساس عليها فى العقد ويتعذر استمراره بدون ، كأن تتوقف عن سداد مستحقات المقاول لمدة تجاوز القدر المعقول ، مما يؤدى إلى اضطراب الموقف المالى له بطريقة تؤثر فى معدلات تنفيذه للأعمال ، ففى هذه الحالة ، لاوجه للقول بالتزام المقاول بالاستمرار فى التنفيذ ، وتوقيع غرامة تأخير عليه ، إذا لم يسلم الأعمال فى الميعاد المحدد سلفاً^(١).

- والمسلم به أنه إذا قدرت الجهة الادارية أن عدم تنفيذها لالتزاماتها، يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزامه فى الموعد المحدد ، فلايجوز محاسبة المتعاقد معها عن أى تقاعس أو تراخى فى تنفيذ التزاماته ، إذا تأخرت الجهة الادارية فى تنفيذ التزاماتها المقابلة .

- وإعمالاً لمبدأ حسن النية فى تنفيذ العقد ، تتحمل الجهة الادارية العلاوات الاجتماعية .

وإعمالاً لمبدأ حسن النية ، فقد انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن :

^١ أ.ع - طعن رقم ١١٤٨٨ لسنة ٥١ ق ، فى ٢٠٠٩/٦/٩ .

— الزيادات التى تطرأ بمقتضى القوانين واللوائح ، على أجور العاملين فى المشروع ، خلال مدة تنفيذ العقد ، وطبقاً لما تبنيه نصوصه — لايقف هذا الحق عند حدود الزيادات التى تقررها القوانين واللوائح ، وتبتغى بها رفع الأجور الأساسية للعاملين ، وإنما ينشأ فى كل حالة يزيد فيها الأجر الأساسى طبقاً للقانون ، أو يفرض فيها على صاحب العمل منح العاملين مبالغ ينسب عليها مفهوم الأجر ، كالعلاوات الاجتماعية . ينبغى على الجهة الادارية المتعاقدة أن تتحقق قبل أداء هذا التعويض الناشئ عن زيادة أجور العاملين بمقدار العلاوة الاجتماعية ، من أن المقاول المتعاقد معها ، أو فى عماله فى المشروع حقهم هذه العلاوة ، وإذا كان ذلك كذلك ، مما يفترض فى شركات القطاع العام للمقاولات ، فلا تكلف باثباته ، بحسبان أن أموال هذه الشركات مملوكة للدولة ، وهى تنزل على حكم القانون فى مسائل العاملين وأجورهم ، ولا تخالطها أدنى مظان فى هذا الصدد ، فان الأمر يختلف بالنسبة إلى غيرها من مقالى القطاع الخاص ، فينبغى أن يتقدم هؤلاء بما يدل على قيامهم بالفعل بأداء هذه العلاوة إلى عمالهم فى المشروع ، خلال مدة تنفيذ العقد ، ليحسب مايؤدى إليهم فى حدود التكلفة الإضافية الفعلية (١) .

الخلاصة :

— من المسلم به أن الغرض الأصلى من إبرام العقد — أيا كانت طبيعته — هو السعى إلى تنفيذ بنوده ، فالعقد إنما وضع لتحقيق الهدف الذى يبتغيه المتعاقدان ، فيلتزم كل طرف باحترام بنود العقد ، وتنفيذه بحسن نية .

— ويعتبر مبدأ حسن النية ، من أسمى وأرقى المبادئ الأخلاقية التى عرفها القانون . ويشمل مبدأ حسن النية كل مراحل العقد ، سواء فى

^١ فتوى الجمعية العمومية رقم ٦٠٥٧ ، فى ٢٦/١٢/١٩٩٢ .

مرحلة الاجراءات السابقة على ابرامه ، وحتى آخر إجراء فى إبرام العقد ، وانتهاء بمرحلة تنفيذ العقد بل وانقضاؤه ، إذ يجب على طرفى العقد مراعاة مبدأ حسن النية من استقامة ونزاهة وانتفاء الغش والتواطؤ والتحايل.

— ومبدأ حسن النية — كمبدأ عام من المبادئ القانونية العامة — ، يعنى أنه قاعدة أساسية ، وهامة تتحكم فى غيرها من القواعد ، أى أنه قاعدة أساسية يرتكز عليها قواعد قانونية ثانوية، ذات تطبيق تقنى.

— ومن خصائص مبدأ حسن النية ، أنه ذو صفة ذاتية ، فهو التزام مفروض على طرفى التعاقد أثناء تنفيذ العقد ، فيصبح كل منهما دائن بهذا الالتزام ، ومديناً فى الوقت نفسه ، وإن ما يقتضيه هذا المبدأ من التزامات ، قد يختلف من طرف لآخر ، حسب موقعه وحالته ، والظروف والملابسات المحيطة به ، وهو مبدأ أخلاقى ، ويتبين ذلك من الالتزامات التى تعنى الأمانة ، والنزاهة ، والثقة ، والتعاون ، وهى قواعد أخلاقية .

— وانه وإن كان المشروع قد نص على مبدأ حسن النية فى مرحلة تنفيذ العقد ، إلا أنه منصوص عليه ضمناً ، فى أكثر من موقع فى المرحلة السابقة على التعاقد.

— وتؤكد الأحكام والتطبيقات القضائية فى مبدأ حسن النية فى العقود الادارية ، صحة وسلامة ما ذكر كاملاً.

الفصل الثانى

تعديل العقد الادارى

تمهيد وتقسيم :

١- سلطة الإدارة فى تعديل العقد، أو فى تعديل طريقة تنفيذه ، هى الطابع الرئيسى لنظام العقود الإدارية ، بل هى من أبرز الخصائص التى تميزها عن العقود المدنية . مقتضى هذه السلطة أن جهة الإدارة مستهدفة تحقيق حسن سير المرافق العامة فى أداء الخدمات العامة على النحو الذى يحقق المصلحة العامة ، تملك من جانبها وحدها وإرادتها المنفردة، وعلى خلاف المؤلف فى تعاملات الأفراد فيما بينهم ، حق تعديل العقد أثناء تنفيذه ، وتعديل التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد ، فتزيد من أعبائه أو تنقصها، بشرط أن تقتضى حاجة المرفق أو المصلحة هذا التعديل ، ودون أن يحتج فى مواجهتها بفكرة الحق المكتسب ، أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين . أساس ذلك ، تميز العقود الادارية عن العقود المدنية بطابع خاص ، مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره ، وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة . يقوم التعاقد فى العقود الادارية على أساس أن نية الطرفين قد انصرفت عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة . الادارة فى ممارستها لسلطة تعديل العقد تستعمل حقا، وهذه السلطة لاتستمد من نصوص العقد ، بل من النظام العام لحسن سير المرافق العامة . ومن ثم فإن سلطة الادارة فى التعديل أو الانهاء للعقد الادارى ، مقرر بغير حاجة إلى النص عليه فى العقد ، وإلى موافقة الطرف الآخر عليه ، فإذا

أشارت نصوص العقد على حق الإدارة فى إجراء هذا التعديل ، فان ذلك لا يكون إلا مجرد تنظيم لسلطة التعديل ، وبيان أوضاع وأحوال ممارستها ، وما يترتب على ذلك ، دون أن يكون فى ذلك أى مساس بالحق الأصيل المقرر للجهة الإدارية فى التعديل ، فلا يجوز لجهة الإدارة نفسها أن تتنازل عن ممارسة هذه السلطة. يشمل حق الإدارة فى تعديل العقد حقها فى إنهاء العقد قبل الأوان ، باعتبار أن الإنهاء ينصب على الشرط الخاص بمدة العقد . فاللإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد إذا استجدت ظروف تستدعى ذلك ، كما لو أصبح العقد غير ذى فائدة للمرفق العام ، أو أضحى لا يحقق المصلحة العامة المقصودة ولا يكون للطرف الآخر سوى الحق فى التعويض إذا توافرت شروط استحقاقه^(١).

٢- نص القانون :

تنص المادة (٤٦) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، على أنه : " إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد ، يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص ، وبما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند لعقود المقاولات ، وبما لا يجاوز (١٥%) من كمية كل بند لباقي العقود ، بذات الشروط والمواصفات والأسعار ، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك.

— ويتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ، أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال ، ووجود الاعتماد المالى اللازم ، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية

^١ أ.ع ، طعن رقم ٣٩٨٦ لسنة ٣٥ ق ، فى ١٥/١١/١٩٩٢.

المتعاقد فى ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلى إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص " (١).

نخلص إلى أنه من الحكم الشامل — المشار إليه — ومن نص المادة (٤٦) — المشار إليها — إلى أن تناول سلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى بالدراسة ، يتضمن استعراض المسائل الآتية :

أولاً : الأساس القانونى لسلطة الإدارة فى تعديل العقد.

ثانياً : شروط استعمال الحق فى تعديل العقد الإدارى.

ثالثاً : حدود التعديل.

رابعاً : القيود التى ترد على سلطة الإدارة فى تعديل العقد.

خامساً : مدى تعلق سلطة تعديل العقد الإدارى بمبدأ حسن النية.

سادساً : وأخيراً ، طبيعة سلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى.

سابعاً : حكم خاص بشأن عقود المقاولات.

ونعرض لكل من هذه المسائل على النحو الآتى :

أولاً : الأساس القانونى لسلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى :

— قدمنا أنه يهيمن على تنفيذ العقد ، ثلاث مبادئ حاكمة هى : المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد . وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة . وأخيراً مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود (بل وفى كل مراحل إبرام العقد أيضاً).

هذه المبادئ الثلاثة (مجتمعة) تعد هى الأساس القانونى لسلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى. — والبين أن المبدأ الأول والثانى

^١ نص على حق الإدارة فى تعديل العقد الإدارى ، فى م/٧٨ من اللائحة التنفيذية للقانون (السابق) فى المزايدات والمناقصات ، رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٨.

يقومان على فكرة السلطة العامة ، بحسبانها المعيار المميز للعقود الادارية عن العقود المدنية. ومن المسلمات أن سلطة الادارة فى تعديل العقد تعد الطابع الرئيسى لنظام العقود الادارية ، وأبرز الخصائص التى تميزها عن العقود المدنية.

— ذلك أن للادارة (دوماً) — وإرادتها المنفردة — حق تعديل العقد أثناء تنفيذه ، كلما إقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل، انطلاقاً من اضطلاع السلطة العامة بتحقيق المصلحة العامة ، وانها — أى السلطة العامة — هى المنوط بها حماية تلك المصالح.

— وان سلطة الادارة فى تعديل العقد الادارى ، تباشرها الادارة (وحدها) دون حاجة إلى النص على هذا التعديل فى العقد ، أو إلى موافقة الطرف الآخر عليه ، بحسبانه أن تلك السلطة من المبادئ العامة الحاكمة فى تنفيذ العقود الادارية بصفة عامة.

— والملاحظ أن نص القانون على سلطة الادارة فى تعديل العقد الادارى ، لاتعدو ترديداً لما استقر عليه القضاء فى هذا الشأن. وإذا كان ذلك كذلك ، فان مذهب إليه بعض الفقه ، من القول بأن أساس سلطة الادارة فى تعديل العقد الادارى يرجع إلى فكرة تغير الظروف ، ويجعلها شرطاً لوجود سلطة تعديل الادارة لعقودها^(١).

^١ اتجه إلى هذا رأى د. ثروت بدوى فى رسالته عن " عمل الأمير " . راجع تعليقا على ذلك — تفصيلاً — رسالة د. محمد سعيد أمين بعنوان " الأسس العامة للالتزامات وحقوق المتعاقد مع الادارة فى تنفيذ العقد الادارى ، ع . سنة ١٩٨٤ ، ص ١١٨ ومابعدها.

والفقه القضاء مستقران على أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص ، مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره ، وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، وهذه الفكرة هى التى تحكم الروابط التى تنشأ عن العقد الإدارى . وينبنى على هذه الفكرة أن للادارة سلطة إنهاء العقد .. كما وان لها سلطة تعديل العقد ، بحيث لا يصل التعديل إلى الحد الذى يخل بتوازنه المالى " (١) .

كما واستقر افتاء مجلس الدولة ، على أنه من المبادئ الأساسية المستقرة ، أن الجهة الادارية المتعاقدة تملك من جانبها وحدها وبارادتها المنفردة ، وعلى خلاف المؤلف فى معاملات الأفراد فيما بينهم ، حق تعديل أثناء تنفيذه ، وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها، على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد ، فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر ، أو تنقصها ، وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقد عليها بالزيادة أو النقص ، على خلاف ماينص عليه العقد ، وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل ، من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب ، أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين " (٢) .

نخلص من ذلك إلى " حق الجهة الإدارية فى تعديل شروط العقد ، وازدادة شروط جديدة اليها، بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام ، كما أن لها سلطة إنهاء العقد ، إذا ما قدرت ان هذا الإجراء

^١ راجع على سبيل أ.ع ، طعن ٤٣٩ لسنة ١١ ق فى ١١/٥/١٩٦٨ ، والأحكام العديدة المشار إليها فى المؤلف القيم للدكتور محمد ماهر أبو العينين ، العقود الإدارية - سالف الإشارة اليه ، ص ١٠٥ ومابعدھا.

^٢ فتوى الجمعية العمومية رقم ٩٨٤ فى ٢٨/١١/١٩٧٣ ، ملف ٣٠/٩/٧.

يقتضيه الصالح العام. ليس للمتعاقد معها الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وبشرط ألا يصل التعديل إلى حد فسخ العقد كليا ، وان يكون للطرف الآخر الحق في التعويض ، إذا أصابه من جراء هذا التعديل ضرر ... وان هذا الضرر لايجوز افتراضه ، وعلى أساسه يقدر التعويض " (١) .

والقضاء مستقر على أن حق الادارة في تعديل العقد ، كلما اقتضت المصلحة العامة وحاجة المرفق ذلك ، لايشمل التعديل موقع التنفيذ (٢) . وان سلطة الادارة في تعديل العقد ثابتة بغير حاجة إلى النص عليه ، حيث يرتكز هذا الحق على سلطة الادارة الضابطة في العقد المتصلة بالصالح العام . وان نص القانون (أو اللائحة) على التعديل ، لايعدو أن يكون مجرد تنظيم سلطة التعديل ، وبيان أوضاعه ، وأحوال ممارسته له، ولايجوز للادارة التنازل عن ممارسة هذه السلطة ، لتعلقها بالنظام العام.

وفي عبادة واحدة ، يرتد الأساس القانوني لاستعمال الادارة سلطتها في تعديل العقد الإداري ، على فكرتي السلطة العامة (بوصفها القوامة على المصلحة العامة) ، وفكرة حاجة المرفق العام (٣).

^١ فتوى الجمعية العمومية رقم ٥٤٠ في ١٦/٥/١٩٩٣ ، ملف ٢١/٢/٧٨ .

^٢ فتوى الجمعية العمومية رقم ٩٨٤ في ٢٨/١١/١٩٧٣ ، سابق الإشارة إليها .

^٣ نص م / ٤٦ (من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨) على تضمين كراسة الشروط والمواصفات مضمون التعديل ، وضوابطه ، لايعدو أن يكون امعالمبدأ الشفافية الذي يستهدفه القانون .

ويوازن حق الادارة فى تعديل العقد — على ماتقدم — وجوب تعويض المتعاقد عما قد يلحقه من ضرر نتيجة هذا التديل.

ثانيا : شروط استعمال الحق فى تعديل العقد الادارى :

المستفاد من نص م/٤٦ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ — سابق الاشارة إليها — ومما استقر عليه قضاء وافتاء مجلس الدولة ، ان ثمة شروط محددة ، لاستعمال الادارة حقها فى التعديل ، يمكن اجمالها فى ستة شروط ، هى :

الشرط الأول :

١ — ان تستجد بعد ابرام العقد الادارى ظروف تستدعى اجراء التعديل على مضمونه.

وهذا الشرط ورد فى صدر المادة (٤٦) — المشار إليها — .

ومؤدى ذلك : ان استعمال الادارة حق تعديل العقد الادارى بارادتها المنفردة ، يجب أن يكون لضرورة طارئة تبرر ذلك . أى انه يجب أن تكون ثمة حاجة يقتضيها تسيير المرفق او ادارته اجراء التعديل فى شروط العقد . ومن هنا نعلم ان سلطة التعديل تختلف من عقد لآخر ، حسب طبيعة المرفق وظروفه . ومن أمثلة ذلك ، ان للادارة سلطة تعديل العقد ، إذا كان عدم التعديل قد يفضى إلى تأخير فى العمل ، أو الاضرار بالمرفق ، من الناحية الاقتصادية والفنية ، أو إذا كان التعديل يؤدى إلى توفير مبالغ مالية كبيرة للادارة .

— ويؤكد ذلك ان عقود التوريدات الكبيرة ذات المدد الطويلة يكون تغير الظروف فيها أكثر من غيرها.

الشرط الثانى :

يجب أن يقتصر التعديل على نصوص العقد المتصل بسير المرفق العام ، ونطاق ومقتضيات العمل المطلوب تنفيذه من المتعاقد ، فلا يجوز أن يتناول التعديل النصوص المتعلقة بالمزايا المالية المتفق عليها ، والتي يستفيد منها المتعاقد معها حرصاً على مصلحته الخاصة ^(١) .

ومرد ذلك ، ان المتعاقد مع الادارة ، يهدف إلى تحقيق الربح المادى، وينبغى على الادارة احترام امكاناته المادية والفنية من اجل تنفيذ العقد.

٣- الشرط الثالث : يجب ألا يؤثر تعديل العقد على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه.

ذلك أن الشروط المتعلقة بتحديد المقابل المالى فى العقد ، وأساليب ومواعيد واجراءات الوفاء به ، تعد شروطاً تعاقدية ، لا يملك أى طرف التحلل منها ، أو تعديلها بآرادته المنفردة.

ومفهوم المقابل المالى ، لا يقتصر على الثمن أو الاجرة ، أو الفائدة ، وانما يشمل أيضاً ، كل شرط مالى يتضمن ميزة مالية ، أو فائدة اقتصادية للمتعاقد ، كالضمانات وغيرها — متى قدم المتعاقد تحفظات بشأن هذه الشروط ، وقبلتها جهة الإدارة ، فانها تعد جزءاً من العقد ^(٢) .

ومن المسلمات أن المقابل المالى يختلف باختلاف العقود الإدارية ، وتتنوع صورة بحسب طبيعة العقد . وان الشروط المتصلة بالمقابل النقدى ، تولد مراكز ذاتية تتحدد باتفاق الطرفين ، فلا يملك أى طرف

^١ فتوى الجمعية العمومية رقم ٩٨٤ فى ١٩٧٣/١١/٢٨ سالفه الإشارة.

^٢ أ.ع — طعن ٣٨٥٥ لسنة ٤٢ ق ، فى ٢٠٠٦/١١/١٧ .

التحلل منها، أو الخروج على أحكامها إلا بموافقة الطرف الآخر ، أو بناء على نص فى القانون ، وذلك نفاذاً لمبدأ ثبات الشروط التعاقدية المتعلقة بالمقابل المادى (النقدى) ، سواء تعلقت هذه الشروط بكيفية تحديد هذا المقابل ، أو حالات ومواعيد وأساليب الوفاء به ^(١) .

إذا يعد الثمن المتفق عليه من أهم أركان العقد ، والباعث على إبرامه، والشروط المتعلقة به ، شروط تعاقدية ، لايجوز التحلل منها أو تعديلها بارادة منفردة ، لأى من طرفى العقد.

مبدأ أولوية العطاءات : مفهومه ، شروط تطبيقه ، ومداه

يقصد بمبدأ أولوية العطاءات : ان محاسبة المقاول تتم على أساس الكميات المنفذة فعلاً على وفق أسعار عطاءه ، بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ، ولو زادت أو قلت عنها، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الاخلال بأوليته فى ترتيب عطاءه ، باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعراً.

الهدف من هذا الشرط هو مراعاة العدالة فى التعامل ، وهو مايستلزم مراعاة ألا تؤدي مغالاة صاحب العطاء فى أسعار الأعمال أو الفئات التى ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ ، وانقاص أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى التى يتوقع تخفيضها أو انقاصها إلى التعاقد معه ، باعتبار أن العطاء فى جملته أقل العطاءات سعراً ، ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض أولوية خادعة ، استنفذت أغراضها ولا تصادف الحقيقة.

^١ أ.ع — طعن ٢٥٨ لسنة ٤٦ ق فى ٢٠٠٤/١٢/١٤ ، طعن ١٥٧ لسنة ٤٧ ق فى ٢٠٠٤/١٢/١٤ ، وطعن ٣٦٠٤٩ لسنة ٥٧ ق ، فى ٢٠١٤/٤/٢٦ .

وفى المقابل يتم استبعاد صاحب العطاء التالى له لسبب يرجع إلى طريقة إعداد عطائه ، رغم أن هذا العطاء كان الأصلح سعراً ، والأكثر مطابقة للواقع . عنى المشرع بأن يرد على المتناقص صاحب الأولوية الظاهرية قصده بالنص على أن تظل الأولوية التى رتبت العطاءات وأرسيّت المناقصة بناء عليها مصاحبة للعقد حتى تمام التنفيذ ، وأن يراعى إعمال هذا الشرط لدى حساب ختامى العملية ، بحيث إذا فقد هذه الأولوية ، تعين محاسبته عما قام بتنفيذه من أعمال على أساس قيمتها حسب أسعار العطاء التالى (١) .

— مبدأ أولوية العطاءات ، وهدفه مراعاة العدالة فى التعامل :
أ— يعنى ان محاسبة المقاول تتم على أساس الكميات المنفذة فعلاً ، على وفق أسعار عطائه ، بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات .

ب — كما ويستلزم هذا المبدأ ، وجوب عدم المغالاة من صاحب العطاء فى اسعار الأعمال أو الفئات التى ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ.

ج — وإعمال هذا المبدأ ، يقتضى ايضاً ، التصدى لأى أولوية خادعة ، لاتصادف الحقيقة ، يلجأ إليها مقدم العطاء مع الادارة ، بسبب يرجع إلى طريقة إعداد عطائه بحرفية كبيرة (كان يتجه المتعاقد مع الادارة إلى المغالاة فى أسعار الأعمال أو الفئات التى ينتظر زيادة كمياتها عند التنفيذ ، وانقاص اسعار الأعمال أو الفئات الأخرى التى

١ أ.ع — طعن رقم ٦٧٣٠ لسنة ٤٧ ق ، فى ٢٠٠٥/٣/٥ .

يتوقع تخفيضها أو انقاصها، مما يوحى بأن عطائه فى جملته أقل العطاءات على غير الحقيقة.

د- لأجل ذلك عنى المشرع بالنص على أن تظل الأولوية التى رتبت العطاءات ، وارسيت المناقصة بناء عليها ، مصاحبة للعقد حتى تمام تنفيذها ، بل وان يراعى اعمال هذا الشرط لدى حساب ختامى العملية ، بحيث إذا فقد هذه الأولوية ، يعن محاسبته (أى المتناقص) ، عما تم تنفيذه من أعمال ، على أساس قيمتها حسب أسعار العطاء التالى ، ومن ثم يكون المشرع ، قد رد على المتناقص صاحب الأولوية الظاهرية قصده.

وكما تقول المحكمة الادارية العليا ، إن أعمال شرط أولوية العطاء ، قصد به أن يقدم المتناقص فى عطائه صورته صادقة لأسعاره ، وان ترتب جهة الادارة العطاءات على هدى من ذلك ، دون مغالاة من صاحب العطاء ، فى أسعار الأعمال أو الفئات التى ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ ، أو انقاص فى أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى نقصانا ينأى بها عن الحقيقة ، وصولاً إلى التعاقد مع جهة الإدارة ، باعتبار أن العطاء فى مجمله أقل العطاءات المقدمة سعراً ، ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض أولوية خادعة ، استنفذت أغراضا ولا تصادف الحقيقة.

شروط تطبيق المبدأ :

— ونشير إلى أن تطبيق مبدأ " أولوية العطاءات " ، إلا حيث يوجد عطاء أو عطاءات أخرى ، كانت مستوفية للشروط ، لكنها أكثر سعراً ،

فلم تتم الترسية عليها ، أما العطاءات المستبعدة فلا تدخل فى المقارنة ، وذلك لانتفاء مظنة التحايل التى تقرر الشرط من أجلها.

وهكذا ، يتم تطبيق مبدأ " أولوية العطاءات " ، بمقارنة إجمال أسعار المقاول المنفذ ، باجمالى أسعار غيره من العطاءات المقبولة التى كانت تعلو سعره عند الترسية ، وذلك بافتراض أن كل من تلك العطاءات قد نفذ الأعمال نفسها الواردة بالحساب الختامى ، فإذا كان اجمالى سعر المتعاقد أزيد من أى منها ، وجب خصم المبلغ الزائد ليصبح أقل منها جميعاً^(١) .

— مدى مبدأ أولوية العطاءات :

— والمعلوم أن يصاحب مبدأ أولوية العطاءات العقد فى مسيرته ، حتى تمام تنفيذه — ومؤداه — بإيجاز — أن ماينفذه المتعاقد مع الادارة هو الأساس لحساب مايستحق من مبالغ مالية محسوبة طبقاً لاسعاره المبينة بعطائه ، بصرف النظر عن المقادير أو الأوزان أو الكميات الواردة بمقايضة الأعمال ، لأنها تقريبية ، ومن ثم فإن أعمال شرط أولوية العطاء، يتم بعد انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال التى كلف بها^(٢) .

مجمل القول : أن المقابل المالى من أهم حقوق المتعاقد مع الادارة ، وتحدد الشروط التى تتعلق بتحديد بدقة وقت التعاقد ، ولايستطيع أحد طرفى العقد تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر ... ذلك ان قيمة العقد تعد

^١ أ.ع — طعن ٢٥٨٦٣ لسنة ٥٧ ق ، فى ٢٨/٦/٢٠١٦ .

^٢ أ.ع — طعن ٩٦٩ لسنة ٤٢ ق ، فى ٣١/١٠/٢٠٠٠ ، طعن / ١١٤٤٧ / ١١٦٩٢ لسنة ٤٩ ق فى ٢٩/٤/٢٠٠٨ ، طعن ٣٥٢ لسنة ٢٧ ق فى ٢٧/٢/٢٠٠٧ .

من ثوابته ، دون النظر إلى تقلبات السوق ، أو العملة ، أو التعريفية الجمركية ، وغيرها من المسائل المتوقع حدوثها لدى التعاقد مع الإدارة. القول بغير ذلك يؤدي إلى زيادة القيمة أو نقصها تبعاً للتغيير في سعر تحويل العملة ، وهو أمر يتنافى مع ثبات شرط المقابل المالي للعقد ، وهو أمر غير جائز كأصل عام ، مالم يتم الاتفاق على غير ذلك ^(١). وان سلطة الإدارة في تعديل العقد ، سواء في الكميات ، أو حجم العقد بالزيادة أو النقص ، يجب أن يكون في حدود النسب التي أوردتها المشرع ، وأيضاً بشرط ألا تؤثر الزيادة أو النقص في أولوية المتعهد أو المقاول في ترتيب عطائه.

وقدّمنا ، ان اجراء الإدارة تعديل العقد ، دون مراعاة المزايا المالية للمتعاقد معها، سوف يقضى تصرفها هذا الى عزوف اعداد كبيرة من الراغبين في التعاقد مع الإدارة ، مما يؤثر سلباً على أداء المرافق العام ، وتعطيل تقديم خدماته.

٤- الشرط الرابع : الحصول على موافقة السلطة المختصة :

من المسلمات ان العقد الإداري لا ينشأ ولا يتعدل ، إلا بإرادة صحيحة من جهة الإدارة ، صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الإرادة . ويجوز للإرادة أن تعدل من شروط العقد الإداري ، وانه لاسبيل إلى قيام هذا التعديل والاعتداد به قانوناً ، مالم تلتزم جهة الإدارة عند اجرائه قواعد الاختصاص المقررة ، فلايتأتى إلا من السلطة المختصة باجرائه. وان التعليمات الصادرة من غير هذه السلطة لاتنتج أثراً في تعديل وتحويل آثار العقد ، وتغيير مقتضاه ^(٢) .

^١ أ.ع - طعن رقم ٢٥١٩ لسنة ٣٤ ق ، في ١٩٩٣/٨/٣٠.

^٢ أ.ع - طعن رقم ٨٤٥ لسنة ١٩ ق ، في ١٩٨٠/١١/٢٢.

وقد نص على هذا الشرط صراحة ، فى م / ٤٦ — سالف الإشارة إليها — ، والتي استلزمت بنص قاطع لتعديل العقد ، الحصول على موافقة السلطة المختصة ، أو مجلس الوزراء ، بحسب الأحوال .

— وقدمنا ، أن مؤدى المواد (٧٦ ، ٧٩) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يستلزم موافقة مجلس الوزراء على التعاقد ، ومن ثم يلزم موافقتها — أيضا — فى حال تعديل التعاقد ، محل هذه المواد . وان يقصد بالسلطة المختصة ، وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ، الوزير ومن له سلطاته ، أو المحافظ ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، أو الصندوق ، أو من يعادلهم من سلطات فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، كل فى نطاق اختصاصه (م/١ من القانون).

— وباعتقادنا ، أنه لايجوز التفويض فى هذه الاختصاصات سواء من جانب مجلس الوزراء ، أو من السلطة المختصة .

الشرط الخامس :

٥- وجود الاعتماد المالى اللازم .

وهذا الشرط نص عليه صراحة فى م / ٤٦ — المشار إليها — ، بان استلزمت لتعديل العقد ، وجود الاعتماد المالى اللازم ، كما وان الفقه والقضاء على استلزام ذلك الشرط ، لصحة تعديل العقد الادارى .

وسبق لنا دراسة الاعتماد المالى وطبيعته وآثاره إلخ فنحيل الى ماسبق دراسته ، منعاً للتكرار .

وقد قضى بأن صدور قرار الجهة الادارية بالعدول عن التعاقد مع الشركة ، استناداً إلى اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة فى تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع إلى مشروعات أخرى من حق الشركة المطالبة بالتعويض .

وقد أوردت اللائحة التنفيذية للقانون سبعة ضوابط يجب مراعاتها، إذ قررت الجهة الادارية تعديل العقد ، هى :

- وجود ضرورة ، وأسباب داعمة لتلك التعديلات.
- الحصول على موافقة السلطة المختصة ، أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال — على التعديل.
- أن تكون التعديلات على بنود العقد الأصلي ذاته ، وبالشروط والمواصفات ذاتها، والأسعار المتعاقد عليها.
- إعداد ملحق للعقد متضمناً تلك التعديلات.
- الحصول من الإدارة المالية على سماح البند ، فى حالة التعديل بالزيادة.
- أن يكون التعديل خلال مدة تنفيذ العقد ، ولايدخل فيها مدة الضمان.
- إلا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه.
- وعلى أن تتولى إدارة التعاقدات توثيق تلك التعديلات ، والمستندات المؤيدة لها، وحفظها بملف العملية ، ويتم النشر عن القيمة النهائية بعد التعديل على بوابة التعاقدات العامة (م/٩٦ من اللائحة).

الفصل الثالث

التوازن المالى للعقد

تمهيد وتقسيم :

— انطلاقاً من الطبيعة الذاتية للعقد الإدارى ، ومدى صلته بالمرفق العام وضرورة استدامته وحسن سيره ، وبالنظر إلى سلطات الإدارة الخطيرة فى مواجهة المتعاقد معها، وحتى يمكن الموازنة بين تلك السلطات وحقوق المتعاقد المقابلة لها، خلق مجلس الدولة الفرنسى نظريات عمل الأمير ، والظروف الطارئة ، والصعوبات المادية غير المتوقعة ، واضعاً نصب عينيه، اعتبارات العدالة والطبيعة الذاتية للعقود الإدارية ، على اعتبار أن العقد الإدارى يكون فى مجموعة كلاً من مقتضاه وجوب التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين، وتعادل كفة الميزان بينهما، وذلك بتعويض المتعاقد فى أحوال وبشروط معينة ، حتى ولو لم يصدر خطأ من جانب الإدارة ، مع اختلاف مقدار التعويض ، فتارة يكون كاملاً وتارة يكون جزئياً ، وأياً كانت الأسانيد التى قامت عليها هذه النظريات والقواعد ، واختلاف الرأى فى مبرراتها، فانه مما لاشبهة فيه أنها تترد فى الحقيقة إلى أصل واحد وهو العدالة المجردة ، التى هى قوام القانون الإدارى ^(١).

ومن المعلوم أن من طبيعة العقود الادارية ، انها تحقق بقدر الإمكان توازناً بين الأعباء التى يتحملها المتعاقد ، وبين المزايا التى ينتفع بها ، اعتباراً بأن نصوص العقد تؤلف فى مجموعها كلاً من مقتضاه التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين ... إذ يجب أن ينظر إلى العقد كوحدة

١ حكم محكمة القضاء الإدارى فى ١٩٥٧/٦/٣٠.

من حيث تحديد الحقوق المالية للمتعاقد ، فإذا انتهى تدخل الإدارة فى العقد بالتعديل إلى الإخلال بهذه الحقوق ، كما حددت عند إبرام العقد ، فيجب إعادة التوازن المالى للعقد إلى ماكان عليه .. إذ أن هذا التوازن المالى أمر مفترض فى كل عقد ادارى ، ومن حق المتعاقد مع الادارة أن يعرض على مقتضاه ، دون حاجة إلى النص على ذلك فى العقد ، لأنه ليس مما يتفق مع العدالة والمصلحة العامة ، أن يتحمل المتعاقد وحده عبء التعديل ، ويحرم عليه الاحتفاظ بالتوازن المالى للعقد. وقد اضطرد القضاء وتواترت أحكامه على الاستعانة بنظريات ثلاث فى إعادة التوازن المالى للعقد ، وهى نظريات عمل الأمير والظروف الطارئة ، والصعوبات المادية غير المتوقعة. وسوف نعرض لكل واحدة منها على مايلى :

المبحث الأول

نظرية فعل (أو عمل) الأمير

١- شروط تطبيق نظرية فعل الأمير :
استقر قضاء الادارية العليا ، على أن شروط تطبيق هذه النظرية هى:

- ١- أن يكون ثمة عقد من العقود الادارية.
- ٢- أن يكون الفعل الضار صادراً من جهة الادارة المتعاقدة.
- ٣- أن ينشأ عنه ضرر للمتعاقد ، لايشترط فيه درجة معينة من الجسامة.
- ٤- اقتراف أن الادارة المتعاقدة لم تخطئ حين اتخذت عملها الضار ، فمسئوليتها عقدية بلاخطأ.
- ٥- أن يكون الاجراء الصادر من الادارة غير متوقع.

٦- أن يلحق المتعاقد ضرر خاص لا يشاركه فيه سائر من يمسّه القرار العام.

— تعريف فعل الأمير :

فعل الأمير ، بأنه عمل يصدر من سلطة عامة متعاقدة ، دون خطأ من جانبها، لم يكن فى الوسع توقعه ، وتوقع الآثار المترتبة عليه ، ينجم عنه تسوئ مركز المتعاقد فى عقد إدارى ، ويترتب عليه إثارة مسئولية الادارة العقدية دون خطأ ، والتزامها بتعويض المتعاقد معها، تعويضاً كاملاً ، عن كافة الأضرار التى تلحق به من جراء ذلك ، بما يعيد التوازن المالى للعقد^(١). وهنا ثمة ملاحظات عديدة ، هى :

(أ) ان الاجراء المكون لعمل الأمير ، سواء كان إجراء عاماً أو خاصاً ، يجب أن يكون صادراً من جهة الادارة المتعاقدة ، ومن ثم لا يمكن تطبيق هذه النظرية إذا كان مرجع الاجراء الضار إلى غير الادارة المتعاقدة.

(ب) ان مسئولية الادارة فى نطاق نظرية عمل الأمير ، وان كانت مسئولية عقدية ، إلا أنها مسئولية عقدية بلا خطأ (أى تقوم على أساس المخاطر)، أما إذا انطوى تصرف الإدارة على خطأ فلا مجال لتطبيق النظرية ، وهنا تسأل الادارة على أساس المسئولية العقدية ، طبقاً للقواعد العامة على أساس الخطأ^(٢).

(ج) ان الاجراء الصادر من جهة الادارة المتعاقدة ، يجب أن يكون غير متوقع وقت إبرام العقد ، أو لم يكن فى الامكان توقعه أثناء إبرام العقد ، فإذا توقعت نصوص .

١ راجع د. على عبد المولى ، الظروف التى تطرأ أثناء تنفيذ العقد الادارى — رسالة دكتوراه ، ١٩٩١ ، ع. شمس ، ص ٧ وما بعدها.

٢ راجع فى تفصيلات ذلك ، رسالة د. حمدي حسن الحلفاوى ، بعنوان : ركن الخطأ ، مسئولية الادارة الناشئة عن العقد الادارى ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠١.

العقد هذا الاجراء، لم يكن للمتعاقد مع الإدارة أن يتضرر ، إذ انه أبرم العقد وهو مقدر لها الظروف ، الأمر الذى يترتب عليه تعذر الاستناد إلى هذه النظرية.

مثال ذلك : أن تكون الشركة (المتعاقدة) قبلت فى بنود العقد دفع الاتاوات كما قبلت بالثمن الذى تقرره الحكومة فيما بعد ، فليس لها بعد ذلك التمسك بنظرية المخاطر ، ومطالبة الحكومة بتعويضها ، عما يكون قد لحقها من خسارة ، لأنها كانت على علم بالاتارة ، والثمن المقرر البيع به ^(١).

— بيد أن محل عدم التوقع لا ينصب فقط على الاجراء فى حد ذاته ، فى جميع الفروض ، ولكن يمكن أن ينصب عدم التوقع على النتائج المترتبة على الاجراء ، ومدى حدة هذه النتائج ، حتى ولو كان الاجراء ذاته متوقعاً ^(٢).

(د) أن يكون العمل الضار صادراً من جهة الادارة المتعاقدة ، فإذا ما صدر هذا الفعل عن شخص معنوى عام غير الذى أبرم العقد تخلف أحد شروط تطبيق النظرية ، ومن ثم امتنع تطبيق أحكامها ، ولكن ذلك الامتناع لا يحول دون تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، إذا ما توافرت شروطها ^(٣).

(هـ) لا يشترط فى الضرر المترتب على عمل الأمير أى قدر من جسامة ، بل إن النظرية قد تجد مجالاً للتنفيذ ، حتى ولو تمثل الضرر فى مجرد انقاص الربح الذى كان يأمل المتعاقد فى تحقيقه.

١ حكم محكمة ق.أ فى القضية رقم ٢٨٦ لسنة ١١ ق ، فى ١٩٦١/٤/٢ .

٢ راجع ، د. على عبد المولى ، رسالته السابق الاشارة إليها ، ص ٩ .

٣ حكم أ.ع — الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ١٠ ق ، فى ١٩٦٨/٥/١١ .

(و) ويشترط لقيام الحق في التعويض تأسيساً على نظرية "عمل الأمير". أن تصدر الحكومة تشريعاً عاماً جديداً يمس مركز المتعاقد معها بضرر خاص ، والضرر الخاص يتحقق إذا ما أصاب التشريع الجديد. على الرغم من عمومية نصوصه — المتعاقد وحده دون مجموع الشعب، أو أن ما أصابه بضرر من الجسامة ، بحيث يتجاوز بكثير ما أصاب مجموع الشعب (١).

وعلى ذلك إذا كان التشريع عاماً بتناول عدد غير محدد من الأفراد ، فليس ثمة محل لتعويض عن أى ضرر يصيب الأفراد من تطبيقه. مثال ذلك : ارتفاع سعر العملات الأجنبية بالنسبة للجنيه المصرى ، لايجوز المطالبة بالتعويض عما أصاب الشركة من ضرر من جراء ذلك، استناداً إلى نظرية عمل الأمير ، لأن الضرر الذى أصاب الشركة ليس ضرراً خاصاً ، وإنما تحمّلته فى ذات الظروف الخاصة لسائر المواطنين.

— ولكن قد يعد ذلك حادثاً استثنائياً ، فى حكم المادة ١٤٧/٢ من القانون المدنى ، تطبق فى شأن نظرية الظروف الطارئة ، وليس نظرية فعل الأمير.

مثال آخر : فقد رفضت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع اعتبار القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٦٤ (الخاص بالتأمينات الاجتماعية) من قبيل الاجراءات العامة ، التى تؤدى إلى تطبيق نظرية فعل الأمير ، لأنه وان حمل الشركات أعباء مالية ... إلا أنه لم يصنف الأعباء على شركات المقاولات وحدها، وإنما حمل بها أرباب الأعمال جميعاً على

١ حكم محكمة ق.أ ، القضية رقم ١٩٥ لسنة ٧ق ، فى ٣٠/١/١٩٥٥.

اختلاف مستوياتهم وتباين انشطتهم ، ومن ثم لايتوافر في هذا القانون وصف عمل الأمير ، لأنه لم يلحق بهذه الشركاء ضرر خاص ^(١). وقد أقر القضاء مبدأ اعتبار تشريعات العامة من قبيل الظروف الطارئة ، إذا توافرت شروطها.

(ز) الحالات الاستثنائية التي قبل المجلس التعويض فيها :

— حالتان ، قبل المجلس التعويض فيهما ، هما :
— حالة النص على التعويض في القانون (أو الاجراء العام) ، أو العقد ، وحينئذ يطبق القضاء هذه النصوص باعتبارها تعبيراً عن ارادة المشرع أو المتعاقدين.
ولكن مجلس الدولة الفرنسي ، لم يقف عند هاتين الحالتين ، بل منح التعويض في حالات استثنائية على أساس نظرية عمل الأمير.
فقد قبل مجلس الدولة الفرنسي ، تعويض المتعاقد مع الادارة ، عن الاجراءات العامة ، والتي لاتؤثر في شروط العقد مباشرة .
— إذا مس الاجراء العام ، موضوعاً جوهرياً ، كان له دوره الحاسم في دفع الفرد إلى التعاقد.

— وإن يكون من شأن الاجراء العام أن يلحق بالمتعاقد ضرراً خاصاً لايشاركة فيه سائر من يمسمهم الاجراء العام ، والأثر المترتب على تطبيق نظرية عمل الأمير ، هو : منح المتعاقد المضار من جراء العمل الصادر من السلطات العامة ، تعويضاً كاملاً . بل وقد يتحرر المتعاقد من التزاماته كاملة إذا ترتب على عمل الأمير استحالة تنفيذ تلك الالتزامات ، كأن يصدر تشريع يحرم الاستيراد بالنسبة لسلعة لايمكن الحصول عليها إلا من الخارج . كما أن للمتعاقد مع الادارة ، حق طلب

١ فتواها في ١٠/٢/١٩٦٥ — مج س ١٥ ، ص ٣٠٩ .

فسخ العقد ، إذا زادت أعباؤه بدرجة كبيرة لانتحمله امكانياته المادية أو الفنية ، فضلاً عن التعويض أن كان له مقتضاه.

المبحث الثانى

نظرية الظروف الطارئة

تمهيد : قدمنا أنه بالنسبة لنظرية فعل الأمير ، فإنه يمكن تعريف هذا الفعل بأنه ، كل إجراء تتخذه السلطات العامة ، ويكون من شأنه زيادة الأعباء المالية للمتعاقدين مع الادارة ، او الالتزامات التى ينص عليها العقد.

أما نظرية الظروف الطارئة ، فإن تطبيقها رهين بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإدارى ، حوادث أو ظروف طبيعته كانت أو اقتصادية ، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة ، أو من عمل إنسان آخر ، لم تكن فى حساب المتعاقد عند إبرام العقد ، ولا يملك لها دفعاً ، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة ، تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً ، ومؤدى هذه النظرية — بعد توافر شروطها — إلزام جهة الادارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من الخسارة التى لحقت به.

فإذا لم يترتب على الظرف الطارئ أى خسارة ، أو كانت الخسارة طفيفة بالنسبة إلى مجموع عناصر العقد الإدارى ، أو كانت فى حدود الخسارة العادية المألوفة فى التعامل ، أو انحصر أثر الظرف الطارئ فى تقويت فرصة الربح على المتعاقد ، بانقاص أرباحه كلها أو بعضها، فإنه لا يمكن ثمة مجال لأعمال نظرية الظروف الطارئة ، لتخلف أحد شروطها وأهمها^(١).

١ فتوى الجمعية العمومية رقم ٧٥٤ ، فى ١٣/٧/١٩٧١ ، ملف رقم ٥٠/١٤٤/٢٥ ع.

وعلى ذلك ، سوف نعرض لشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، والآثار المترتبة عليها، على مايلي :

أولاً : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة :

١- تواترت أحكام القضاء، على أن مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة ، ان تطرأ خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية، واقتصادية ، لم تكن فى حسابان المتعاقد عند إبرام العقد ، ولا يملك لها دفعاً ، وان يكون من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة ، تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً ، وان تكون من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة أو من انسان آخر.

وعلى ذلك ، فثمة شروط أربعة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة

هى:

أ- وقوع ظرف طارئ (أيا كانت طبيعته) خلال تنفيذ العقد الإدارى.

ب - أن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن ارادة المتعاقدين.

ج - أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع للمتعاقدين.

د- أن يؤدى الظرف الطارئ إلى قلب اقتصاديات العقد ، بأن يلحق بالمتعاقدين مع الادارة خسائر فادحة.

٢- وهنا - أيضا - ثمة ملاحظات :

أ- يلزم لأعمال نظرية الظروف الطارئة ، أن تختل اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً ، يجب فى التقدير كذلك النظر إلى مجموع عناصر العقد، وكامل مدته - ذلك أن نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة ، التى هى قوام القانون الإدارى ، كما أن هدفها هو تحقيق المصلحة العامة ، وكفالة حسن سير المرافق العامة .

ب - أخذ القانون المدنى بنظرية الظروف الطارئة ، فنص فى المادة

٢/١٤٧ على أن : " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ، لم يكن فى الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفذ الالتزام التعاقدى ، وأن

لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ،
جاز للقاضي تبعاً للظروف ، ويعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد
الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف
ذلك.

ج — قضى بأن ارتفاع الأصناف والمواد التي تعهد المورد على
توريدها ارتفاعاً باهظاً، يعتبر ظرفاً طارئاً ، لم يكن في الحسبان توقعه
عند التعاقد ، طالما أنه يترتب عليه زيادة أعباء المورد بتحميله خسائر
فادحة ، إلى حد الاختلال بتوازن العقد اختلالاً جسيماً . وأن مقتضى
تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة ، هو إلزام جهة الإدارة بمشاركة
المتعاقد معها في هذه الخسائر ، ضماناً لتنفيذ العقد الإداري تنفيذاً
سليماً^(١).

وقضى — أيضاً — بأن وقوع الحادث الطارئ بعد المدة المحددة في
العقد للتنفيذ ، جواز تطبيق النظرية ، في هذه الحالة ، مادام الحادث قد
وقع أثناء المهلة التي وافقت الإدارة على منحها للمتعاقد بعد انتهاء هذه
المدة (أى وقوع الحادث الطارئ أثناء امتدادا لمدة المحددة للعقد ،
مادامت قد وافقت جهة الإدارة على امتدادها)^(٢).

د — يتعين الأخذ في الاعتبار بجميع العناصر المؤثرة في اقتصاديات
العقد ، ومنها كامل العقد ، ومدته ، فيفحص في مجموعة كوحدة واحدة ،
دون الوقوف على أحد عناصره .

أساس ذلك : انه قد يكون في العناصر الأخرى ما يحزى ويعوض
المتعاقد عن العنصر أو العناصر الخاسرة^(٣) .

١ حكم أ.ع. طعن رقم ٢١٥ لسنة ٦ ق ، في ١٩٦٢/٦/٩ .

٢ ذات الحكم السابق.

٣ أ.ع. طعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق ، في ١٩٨٧/٥/١٦ .

هـ - ليس مؤدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، بعد توافر شروطها ، أن يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد ، للمتعاقد أن يدعو الادارة إلى مشاركته فى تحمل نصيب من الخسارة ، التى حاقت به نتيجة تنفيذ العقد فى ظل الظروف الطارئة ، إذا رفضت جهة الادارة يلجأ المتعاقد إلى القضاء - يقتصر دور القضاء فى هذه الحالة ، على الزام الادارة بالتعويض المناسب ^(١) ، دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية.

و- لا تنطبق هذه النظرية ، إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع فى أمور متوقعة ، قبل تنفيذ العقد، وفقاً للسير الطبيعى للأمر ، وللنظام المعتاد للعمل فى الادارة العاملة ^(٢).

ز- وقضى بأن الارتفاع غير المتوقع لأسعار الزئبق أثناء تنفيذ العقد (عقد التوريد) مما ترتب عليه زيادة أعباء المورد بتحميله خسائر فادحة، إلى حد الاختلال بتوازن العقد اختلالاً جسيماً ، اعتباره ظرف طارئ ، لاقوة القاهرة ^(٣).

- وقضى أيضاً ، بأن : تحرير سعر الصرف للعملة ، يعد ظرفاً اقتصادياً طارئاً ، يقتضى هذا من طرفى التعاقد السائد والمشاركة ، للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات يجب على جهة الادارة مشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيبه من الخسارة التى حاقت به مدة قيام الظرف الطارئ، هذا رهين بالآ يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد تاريخ تحرير سعر الصرف لسبب يرجع إلى المتعاقد ^(٤) .

١ أ.ع. طعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٢٩ ق ، فى ١١/٢٠/١٩٨٥.

٢ أ.ع. طعن رقم ٥٤٩ لسنة ٣٥ ق ، فى ١٤/٤/١٩٩٣.

٣ أ.ع. ، طعن ٢١٥٠ لسنة ٦ ق ، فى ٩/٦/١٩٦٢.

٤ أ.ع - طعن رقم ٢٢٣٦٧ لسنة ٥٣ ق ، فى ٣٠/١١/٢٠١٠.

— وفى أحدث أحكامها، قررت المحكمة الادارية العليا ، أن غلق المعابر الحدود به (وهو من أعمال السيادة) من شأنها التأثير فى العقود الادارية ، كظروف طارئة ، تتوافر فيها جميع شرائطها ، كما ولا تعد خطأ من جانب الجهة الادارية ، الأثر المترتب على ذلك : مشاركة المتعاقدين مع الدولة فى تحمل الخسائر والأعباء ، ولا يعد إغلاق الحدود (المعابر الحدودية) قوة قاهرة ، تستوجب الأعفاء الكلى من الالتزامات التعاقدية.

ح — مدى تعلق نظرية الظروف الطارئة بالنظام العام :
لا تتعلق هذه النظرية بالنظام العام ، وان الذى يتعلق منها بالنظام العام ، هو عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف م ٢/٤٧ — سابق الإشارة إليها .

فيقع باطلاً كل اتفاق يهدف إلى حرمان المدين (المتعاقد مع الادارة) من الاعتماد بها ، أو قبول تحمل قدر من الخسارة أكبر مما يناسب مع عدالة توزيع الخسائر والأعباء.

ثانيا : الآثار المترتبة على تحقق شروط نظرية الظروف الطارئة :
— إن مقتضى نظرية الظروف الطارئة (الحوادث الطارئة) ، — بعد توافر شروطها — ، الزام جهة الادارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى الخسائر والأعباء التى أحاقّت به طوال فترة قيام ظرف الطارئ ، ضمناً لتنفيذ العقد الادارى تنفيذاً سليماً، واستدامة لسير المرفق العام الذى يخدمه ، مرضائه للصالح العام.

— ويستوى أن يحصل التنفيذ من المتعاقد مع الادارة نفسه ، أو تقوم به جهة الادارة نيابة عنه ، عند الشراء على حسابه.

— كما أن تطبيق هذه النظرية لايغى المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير والمصاريف الادارية (١).

— ونشير إلى أن دور القاضى يقتصر على الحكم بالتعويض المناسب، دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية.

بمعنى : أن يفرض على الدائن (الجهة الادارية) التزام ينشأ من العقد الادارى ، هذا الالتزام هو أن يدفع الدائن للمدين (المتعاقد مع الادارة) تعويضاً لكفالة تنفيذ العقد تنفيذاً صحيحاً ، متى كان من شأن الظروف أو الأحداث غير المتوقعة أن تنقل كاهن هذا المدين بخسارة يمكن اعتبارها قلباً لاقتصاديات العقد. على أن التعويض الذى يدفعه الدائن ، يكون تعويضاً جزئياً ، عن الخسارة المحققة التى لحقت بالمدين. أى أن التعويض الذى يدفع طبقاً لهذه النظرية ، لايشمل الخسارة كلها، ولايغطى إلا جزءاً من الأضرار التى تصيب المتعاقد ، أى أن الخسارة يجب أن تكون واضحة ومتميزة .

— وقضى بأن : " ليس للمدين أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت ، أو لفوات كسب ضاع عليه ، كما يجب أن تكون الخسارة واضحة متميزة ، ومن ثم يجب لتقدير انقلاب اقتصاديات العقد ، واعتبارها قائمة ، ان يدخل فى الحساب جميع عناصر العقد التى تؤثر فى إقتصادياته واعتبار العقد فى ذلك وحدة واحدة ، ويفحص فى مجموعه لا أن ينظر إلى أحد عناصر فقط ، بل يكون بمراعاة جميع العناصر التى يتألف منها . من ثم فان انقلاب اقتصاديات العقد مسألة

١ أ.ع — طعن ٢١٥٠ لسنة ٦ق ، فى ١٩٦٢/٦/٩ ، طعن ١٥٦٢ لسنة ١٠ق فى ١٩٦٨/٥/١١ — سابق الإشارة إليهما.

لا تظهر ولا يمكن التحقق من وجودها إلا بعد انجاز جميع الأعمال المتعلقة بالعقد^(١).

— نخلص من ذلك ، أن التعويض الذى تلتزم به جهة الإدارة ، لا يستهدف تغطية الربح الضائع أيا كان مقداره ، أو الخسارة العادية المألوفة فى التعامل ، وإنما أساسه تحمل الجهة الادارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة وفادحة تتدرج فى معنى الخسارة الجسيمة ، بغرض اعادة التوازن المالى للعقد بين طرفيه ، فى سبيل المصلحة العامة^(٢).

وقدما أنه يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، بعد المدة المحددة فى العقد للتنفيذ ، مادام الحادث قد وقع أثناء المهلة التى وافقت الادارة على منحها للمتعاقد ، بعد انتهاء هذه المدة.

وقدما — ايضا — ، أنه لا تنطبق هذه النظرية ، إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع فى أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد ، وفقاً للسير الطبيعى للأمور ، وللنظام المعتاد للعمل فى الادارة العاملة.

ونشير إلى أن نظرية الظروف الطارئة ، تختلف — تماماً — عن القوة القاهرة ، إذ أن من شأن نظرية الظروف الطارئة ، أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً مهدداً بخسارة فادحة ، بينما القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، وأن الظروف الطارئة لاتعفى المدين من تنفيذ الالتزام ، على العكس من الثانية (القوة القاهرة).

— وقدما أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ، كانت قد انتهت إلى أن قرار الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه المصرى ، يعد من قبيل الظروف الطارئة (حادثاً استثنائياً عاماً) ، تستوجب مشاركة الادارة فى الخسائر

١ أ.ع — طعن ٤٦ لسنة ١٤ اق ، فى ١٧/٦/١٩٧٢.

٢ أ.ع — طعن ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق ، فى ١٦/٥/١٩٨٧.

والأعباء التي لحقت بالمتعاقد معها بالقدر الذي يحد منها ويردها إلى الحد المعقول.

والجدير بالذكر ، أن المتعاقد مع الإدارة لايجوز له التوقف — وجه حق — عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ، رغم الظروف الطارئة بل يجب عليه أن يستمر في تنفيذ العقد حفاظاً على سير المرفق العام بانتظام وإطراد . ماذا ماتوقف — دون وجه حق — جاز لجهة الإدارة أن تنفذ العقد على حساب المتعاقد المتخلف ، أو تقرر إنهاء العقد ومصادرة التأمين^(١).

— وقضى بأن الزيادة في تكاليف العقد ، نتيجة تقرير مبدأ الاجازة الأسبوعية مدفوعة الأجر، لاتعد ظرفاً طارئاً يبرر مطالبة الجهة الادارية بها^(٢).

— وقضى ، بأن تكبد المتعاقد مع الادارة بعض المصروفات نتيجة تقرير ضريبة المبيعات ، لاتعد ظرفاً طارئاً ، ذلك أنه ليس من شأن زيادة التزامات شركات المقاولات (نتيجة تطبيق هذه الضريبة) أن تلحق بها خسائر فادحة ، تتجاوز كل تقديرات الخسارة ، بما يبرر التدخل لاقالتها من عثرتها، والوصول بهذه الخسارة إلى الحد المعقول، ذلك أن شركات المقاولات كانت تلتزم قبل ضريبة المبيعات باداء ضريبة الاستهلاك ، والفرق بين الالتزامين ، وان تحققت به بعض الخسارة ، إلا أنه ليس من شأنه وحده أن ينتج خسارة فادحة ، ومن ثم ينتفى بذلك أحد شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة^(٣).

١ طعن رقم ٧٦٧ لسنة ١١ ق ، فى ١٩٦٩/٧/٥ .

٢ رقم ١٢٥٥ ، فى ١٩٨٦/٢/١٤ .

٣ طعن ٥٤٠ لسنة ٣٥ ق ، فى ١٩٩٣/٤/٤ ، طعن ١٧٤٩ لسنة ٣٧ ق ، فى ١٩٩٧/١٢/ .

وقد استقرت إدارات الفتوى على عدم اعتبار ارتفاع سعر الدولار ظرفاً طارئاً.

المبحث الثالث

الصعوبات المادية غير المتوقعة

تمهيد :

تعد نظرية الصعوبات المادية ، نظرية قضائية — شأنها فى ذلك شأن نظريتي فعل الأمير ، والظروف الاستثنائية ، فهذه النظريات (جميعها) من خلق مجلس الدولة الفرنسى ، وتستهدف فى مجموعها ، إعادة التوازن المالى للعقد الإدارى .

— وتعد عقود الأشغال العامة ، أبرز مجالات تطبيق هذه النظرية وتجمل هذه النظرية فى أنه : " إذا ماصادف المتعاقد فى تنفيذ التزاماته صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية خالصة ، ولا يمكن توقعها بحال من الأحوال عند إبرام العقد ، وتؤدى إلى جعل التنفيذ مرهقاً ، فأن من حقه أن يطالب بتعويض كامل عما تسببه هذه الصعوبات من أضرار " (١).

— ويلاحظ تمايز هذه النظرية عن نظرية فعل الأمير ، فى أن الصعوبات التى تجيز تطبيقها، لاتكون ناشئة عن فعل الإدارة المتعاقدة ، كما هو الشأن فى نظرية فعل الأمير.

— كما تتمايز عن نظرية الظروف الطارئة ، فى وجوب تعويض المتعاقد مع الإدارة تعويضاً كاملاً ، وليس جزئياً ، كما فى نظرية الظروف الطارئة — على ماتقدم — .

ونعرض فيما يلى :

— لشروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية.

١ راجع : المستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين ، العقود الادارية ، مرجع سابق

— ثم نبين الآثار المترتبة على تحقق هذه الشروط.

أولاً — شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية :

يشترط لتطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ومن ثم تعويض المتعاقد مع الإدارة — وفقاً لهذه النظرية — ، توافر شروط خاصة ، يمكن اجمالها فيما يلي :

١— أن تكون الصعوبات مادية وغير عادية واستثنائية.

٢— أن تكون هذه الصعوبات طارئة ، أى غير متوقعة ، أو مالم يمكن توقعه ، أو لم يكن فى الوسع توقعهما عند التعاقد.

٣— أن تؤدى هذه الصعوبات إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً.

وبديهي : ألا تكون هذه الصعوبات من صنع أحد المتعاقدين ونفصل — ماأجملناه — على النحو الآتى :

— فى هذه الحدود والضوابط ، يكون من حق المتعاقد مع الإدارة الرجوع عليها بالعويض . أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط ، فإن النظرية لا تنطبق ، ولا يستحق المتعاقد مع الإدارة أى تعويض.

وفى ضوء أحكام القضاء، يعد من قبيل الصعوبات المادية:

— وجود طبقات مياة غزيرة أثناء تنفيذ عقد بناء معين ، يحتاج سحبها وتجفيفها إلى نفقات غير عادية.

— وجود طبقات صخرية عند حفر أحد الآثار ، تحتاج — أيضاً — إلى نفقات باهظة وآلات خاصة فى قطعها ورفعها لتنفيذ الأعمال.

أى أنه يقصد بالصعوبات المادية ، تلك الصعوبات التى لم تدخل فى حساب طرفى العقد وتقديرهما عند التعاقد ، وتجعل تنفيذ الالتزام أشد وطأه على المتعاقد مع الإدارة ، وأكثر تكلفة ، مما يوجب — من باب العدالة — تعويضه عن ذلك ، بزيادة الأسعار المتفق عليها فى العقد ، زيادة تغطى جميع تكاليف الأعمال التى تحملها المتعاقد مع الإدارة.

والتعويض هنا — وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء والافتاء، لا يتمثل في معونة مالية جزئية تمنحه جهة الإدارة للمتعاقد معها، بل يكون تعويضاً كاملاً عن جميع الأضرار التي يتحملها^(١). وبناء على ذلك، لا محل لتطبيق النظرية عندما تكون كل ملابسات المشروع تحت نظر الشركة (المتعاقدة)، وعلى علم بها أولاً بأول، وبمراحل تنفيذ العقد^(٢).

وقضى بأن: "تتبيه الإدارة من تعاقد معها إلى صعوبات معينة في التنفيذ، مؤداه: عدم مسئوليتها عما يصادفه المتعاقد معها من هذه الصعوبات في الحدود المعقولة التي يصل إليها التقدير العادي للأمور، دون ما يجاوز هذه الحدود — أساس ذلك: أن تفسير العقد على أساس النية المشتركة للمتعاقدين، يقتضى القول بأن الاعفاء من المسئولية عما جاوز الحدود المعقولة لم يكن مقصوداً. من أيهما، لأنه لم يخطر ببالهما، تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة على الزيادة التي يكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد^(٣)."

— وأنه ولما كانت الصعوبات المادية (متوقعة أو غير متوقعة)، لا ترقى إلى مستوى الحوادث الطارئة الموجبة لالزام الإدارة بتحمل نصيب في الخسارة الفادحة التي تختل بها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً — فإنه لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة حق مطالبة الجهة الإدارية المتعاقدة معه، بزيادة فئات الأسعار، مشاركة منها في الخسائر التي

١ فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة، رقم ٩٥ — فى ١٩٦٤/٢/٤.

٢ أ.ع — طعن رقم ٨٠٠ لسنة ٣٤ ق، فى ١٩٩٢/٥/١٩.

٣ فتوى رقم ٩٥، فى ١٩٦٤/٢/٤ — سابق الإشارة إليها.

تكون قد لحقته بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة ، مهما ترتب عليها من ارهاق للمقاوم^(١).

ومن التطبيقات الهامة فى أحكام القضاء ، انه بالنسبة للعقود الجزافية، وهى التى تتضمن تحديد أجر لكمية الأعمال المطلوبة ، وتحديدًا اجمالياً لما تلتزم به الادارة بدفعه من ثمن يقابلها، فان هذا الطابع الجزافى فى تحديد الثمن لايحول دون تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة^(٢) ، ومنح المتعاقد تعويض عن الصعوبات الاستثنائية وغير المتوقعة التى صادفها أثناء التنفيذ ، وعلى الرغم من النص فى العقد على تحميل المتعاقد مخاطر التنفيذ ، مادام ان كان من شأن الصعوبات المادية فى هذه الأحوال أن تخل باقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً — تبعاً لانتهيار الأسس التى قام عليها تقدير الثمن المتفق عليه. ثانياً — الآثار المترتبة على تحقق شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية .

إذا توافرت شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ، على النحو الذى أوضحناه، فان المتعاقد مع الإدارة يستحق تعويضاً كاملاً من الادارة ، لإعادة التوازن المالى بين حقوقه والتزاماته. البين هنا ، أن التعويض فى نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، هو تعويض كامل ، عن جميع الأضرار التى يتحملها ، وذلك بدفع مبلغ إضافى على الأسعار المتفق عليها. — وفى جميع الأحوال ، يشترط لاستحقاق المتعاقد مع الادارة التعويض بموجب هذه النظرية ، أن يستمر فى تنفيذ التزاماته العقدية ،

١ أ.ع — طعن رقم ٢١١ لسنة ١١ اق ، فى ١٤/٦/١٩٦٩.

٢ فتوى رقم ٩٥ فى ٤/٢/١٩٦٤ — سالف الإشارة إليها.

برغم وجود هذه الصعوبات فهو لا يستطيع التوقف عن التنفيذ ، إلا إذا أصبح هذا التنفيذ مستحيلاً ، استحالة مطلقة بسبب القوة القاهرة .
— ومن ثم إذا تسرع المتعاقد مع الإدارة وتوقف عن التنفيذ ، بحجة هذه الصعوبات ، فإنه يصبح عرضة لتوقيع الجزاءات المقررة من جهة الإدارة (انتهاء العقد ومصادرة التأمين) ، وقد يفقد حقه فى التعويض بموجب هذه النظرية إثر هذا التوقف ، وذلك كله تمليه اعتبارات تأمين سير المرفق العام بانتظام واضطرابه .

خاتمة :

القوة القاهرة — مفهومها وآثارها :

١— عناصر المسؤولية العقدية :

تقتضى أحكام المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ ، وضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
— وأنه إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه عيناً ، كان مسئولاً عن التعويض لعدم الوفاء ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لايد له فيه .

٢— أنواع الاستحالة :

استحالة التنفيذ نوعان : إما أن تكون استحالة فعلية ، أو استحالة قانونية ، وذلك فى الوقت الذى يجب فيه التنفيذ .
أ— الاستحالة الفعلية : هى من مسائل الواقع الذى يقدره القاضى ، ويختلف التقدير بحسب الظروف والملابسات .

ب — الاستحالة القانونية : وهى الاستحالة التى ترجع إلى سبب أجنبي ، وهو الحادث الفجائى أو القوة القاهرة أو خطأ المدين ، أو فعل الغير . ويجب أن يكون الحادث الفجائى أو القوة القاهرة أمراً غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع . فإن توافر هذان الشرطان ، كان الحادث أجنبياً عن الشخص لايد له فيه ، والمعيار المعتمد فى عدم الاستطاعة ، هو أن

يكون عدم الاستطاعة من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمر ، أى المعيار هنا ، موضوعى لاذاتى (شخصى) ، لا يكتفى فيه بالشخص العادى ، ولكن يتطلب أن يكون عدم الامكان مطلقاً ، كما يجب أن يكون الحادث الفجائى أو القوة القاهرة مستحيل الدفع.

٣- الأثر المترتب على نوعى الاستحالة :

أ- إذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين لا ينقضى الالتزام ، وإن كان تنفيذه العينى قد أصبح مستحيلاً ، ووجب التنفيذ عن طريق التعويض ، وبذلك يتحول محل الالتزام من التنفيذ العينى إلى التعويض.

ب - أما إذا كان من شأن الحادث الفجائى ، ممكن دفعه حتى ولو استحال توقعه ، لم يكن ثمة قوة القاهرة .

إذ يجب أن يكون من شأن الحادث الفجائى جعل التنفيذ مستحيلاً استحالة مطلقة ، لا بالنسبة إلى المدين وحده ، بل بالنسبة إلى أى شخص يكون فى موقف المدين ، وهذا هو ما يميز القوة القاهرة أو الحادث الفجائى.

وعلى ذلك ، فإذا كان الحادث الفجائى أو القوة القاهرة ، هو السبب الوحيد فى وقوع الضرر انعدمت علاقة السببية ، فلا تتحقق المسؤولية وقد يكون من أثره لا الاعفاء من تنفيذ الالتزام ، بل وقف تنفيذه ، حتى يزول الحادث ، فيبقى موقوفاً ، على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث.

- إذا كانت تلك هى أحكام القوة القاهرة ، كما نظمها القانون المدنى ، إلا أن القضاء الإدارى قد اطرده على الأخذ بهذه الأحكام ، باعتبارها من الأصول العامة التى يجب النزول عليها فى تحديد روابط القانون العام ،

مادامت تتسق مع تسيير المرافق العامة ، وتكفل التوفيق بين ذلك ، وبين المصالح الفردية الخاصة ^(١).

وتطبيقاً لذلك ، قضى بأن : اصرار الحكومتين الفرنسية والإيطالية على منع تصدير الأسلحة المتعاقد عليها ، اعتباره سبباً أجنبياً تتحقق به القوة القاهرة ^(٢).

وأن عدم وفاء إحدى شركات التصدير بالتزامها المتفق عليه ، بتدبير كميات من الأرز من السوق وتصديرها إلى الخارج ، خلال مدة محددة إلا ببعض هذا الالتزام — انصراف العملاء في الخارج عن الشراء من الشركة المصدرة نتيجة لمنافسة الشركات في الخارج لها ، لعرضها الأرز بسعر أقل مما عرضته هذه الشركة ، لايعتبر من قبيل القوة القاهرة ، تحقق المسؤولية التعاقدية ^٣. وتكون الشركة مسئولة عن عدم تنفيذ التزاماتها.

١ أ.ع — طعن رقم ٦٨٩ لسنة ٤ ق ، في ١٢/١٢/١٩٦٩.

٢ أ.ع — طعن ٦٨٩ لسنة ٤ ق . سابق الإشارة إليه.

٣ فتوى ٥١٦ في ١٦/٨/١٩٦٢.

الباب الثالث

الجزاءات فى مجال العقود الادارية

(الاجراءات والجزاءات التى توقعها الادارة على المتعاقد المقصر)

تمهيد وتقسيم :

— للجزاءات فى العقود الادارية ، نظرية عامة تستمد أصولها من الخصائص الذاتية لتلك العقود ، ومدى اتصالها بفكرة النفع العام .
ومن المسلمات أن نظام الجزاءات فى العقود الادارية لا يستهدف فقط إعادة التوازن بين الالتزامات المتبادلة التى تنشأ بين طرفى العقد ، ولا يتسم بطابع العقوبات التى توقع على المتعاقد مع الادارة ، بل إن هدفه الأساسى الوصول إلى تنفيذ الالتزام المتصل بسير المرفق العام ، أو استبعاد الاختلال الذى يكون قد لحق به . يترتب على هذه الفكرة نتيجة هامة محصلها أن الادارة تتمتع بهذه الحقوق والسلطات حتى ولو لم ينص عليها فى العقد ، بمعنى أن الادارة لا تستمد امتيازاتها فى نطاق العقود الادارية من نصوص العقد ، بل من طبيعة المرفق العام واتصال العقد به ، ووجوب الحرص على انتظام سيره واستدامة تعهد الادارة له ، واشرافها عليه بما يحقق المصلحة العامة . ومن هنا يحق للادارة مباشرة السلطات ولو لم ينص عليها فى العقد^(١) ، وبحكم أن هذا الاختصاص من النظام العام ، اذ لا تملك الإدارة التنازل عنه والتحلل من مباشرته .
إذاً سلطة الإدارة فى توقيع الجزاء على المتعاقد معها بارادتها المنفردة أساسها تغليب المصلحة العامة ، وضمان استمرار سير المرافق العامة ، ولا تحتاج إلى نص . وتستعمل الادارة امتيازاتها لضمان احترام

١ . أ.ع ، طعن ٦٢٩٣ لسنة ٤٩ ق ، فى ٢٢/٥/٢٠١٧ .

المتعاقد لالتزاماته ، وتوقيع الجزاء عليه كلما أخل بأحد هذه الالتزامات دون حاجة إلى القضاء ، بل ودون حاجة إلى نص عقدي يمنحها هذا الحق. كما ولا تتقيد الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها بالجزاءات المنصوص عليها في العقد ، على أن ذلك لا يمنع القول بوجود بعض القيود المفروضة على سلطة توقيع تلك الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة ، وان هذا المتعاقد لا يعدم الضمانات التي تحميه من عسف الإدارة ، بمعنى : ان الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها ، لا تملك توقيعها إلا إذا توافرت الضوابط اللازمة لذلك ، وان توقيع الجزاء رهين بتوافر هذه الضوابط ، أو الشروط الشكلية.

— وتتنوع الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقدين معها، لعدم قيامهم بتنفيذ التزاماتهم قبلها إلى جزاءات مالية ، وجزاءات ضاغطة ، وجزاءات فاسخة ، والعقوبات الجنائية.

— وسوف نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول ، نتناول في الفصل الأول الأحكام العامة (أو المبادئ العامة) في توقيع الجزاءات في العقد الإداري ، بينما نتناول في الفصل الثاني أنواع الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها ، وأخيراً نعرض في الفصل الأخير ضمانات توقيع الجزاءات في العقد الإداري.

الفصل الأول

المبادئ العامة فى توقيع الجزاءات التعاقدية

— يمكن إجمال المبادئ العامة فى توقيع الجزاءات التعاقدية فيما يلى:

١- الهدف من نظام الجزاءات فى العقود الادارية^(١) :

— قدمنا أن نظام الجزاءات فى العقود الادارية ، أو سلطة الادارة فى توقيع الجزاءات على المتعاقد معها، اساسها تغليب المصلحة العامة ، وضمان استمرار سير المرافق العامة ، أو استبعاد الاختلال الذى يكون قد لحق به ، ذلك أن اخلال المتعاقد مع الادارة بالتزاماته التعاقدية لا يقتصر . فقط — على أن يكون إخلالاً بالتزام عقدى ، وانما أيضا فيه مساس بالمرفق العام الذى يتصل بالعقد. فالادارة المسئولة عن حسن سير المرافق العامة لها حقوق قبل المتعاقد معها بعقد إدارى ، ومنها حق توقيع الجزاء حالة إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم ، وهذه الحقوق حقوق أصلية وغير قابلة للسقوط ، وسابقة لكراسات الشروط ، فضلا عن تعلقها بالنظام العام ، إذ لا تملك الادارة التنازل عنها أو التحلل من مباشرتها.

— ويتفرع من هذا الهدف عدة نتائج :

أ- ان الادارة تترخص فى اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء ، بحسب ماتراه أصلح لضمان سير المرافق العامة.

باستثناء حالة النص على الزام الإدارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها فى وقت معين ، فات الادارة تترخص فى اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء، بحسب ماتراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة ، ومن

^١ راجع : equignot (G.): contribution a la theorie general du contrat

admnistratifs, ١٩٤٥ , P. ٨٥٦

ثم فلا تثريب عليها إذا رأت في حدود سلطتها التقديرية ان تثريث في توقيع الجزاء بالمتعاقد المقصر، حتى يفيء إلى الحق من حيث النهوض بالتزاماته ، وقد يكون في هذا التريث تحقيق المصلحة.

ب - من الجزاءات مايتعلق بمرحلة إبرام العقد ، ومنها مايتعلق بمرحلة تنفيذه .

قدما قبلاً أن للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد ، ومصادرة التأمين وخضم فرق أولوية العطاء، وشطب الاسم ، وهي جزاءات تملك توقيعها على المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد ، أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في معاملته معها. وان جهة الادارة تعتمد إلى تضمين عقودها جزاءات تتلاءم مع طبيعة العقود الادارية ، وهي وان كانت غير مألوفة في العقود الخاصة ، فانها تبغى من تلك الجزاءات أن تحقق ضغطاً على المتعاقد معها ليبذل جهده في تنفيذ التزامه ، تحقيقاً لاحتياجات المرافق العامة ، وضمان حسن سيرها بانتظام واضطراد^(١).

(ج) توقع المتعاقدين ان في العقد الادارى خطأ معين وترتيب جزاء محدد له - وجوب التقيد بما ورد في العقد.

- انه إذا ماتوقع المتعاقدان في العقد الادارى خطأ معيناً ووضعاً له جزاء بعينه ، فانه يجب أن تنقيد جهة الادارة والمتعاقد معها بما جاء في العقد ، ولايجوز لايهما مخالفته ، كما لايصح في القانون القضاء على غير مقتضاه^(٢) بمعنى آخر ، إذا نظم العقد جزاء الاخلال بالالتزام

^١ أ.ع ، طعن رقم ١٤١٢٧ لسنة ٥٧ ق ، في ٢٠١٦/٨/٢ .

^٢ أ.ع ، طعن رقم ٥٠١ لسنة ١٤ ق ، في ١٣/١١/١٩٧١ .

ووضع له جزاء معيناً ، لم يجز اللجوء إلى القانون إلا فيما لم ينص عليه في العقد^(١).

— فليس للجهة الادارة مخالفة نص العقد أو تطبيق في شأنه نصوص القانون ، كما ولايجوز للمحكمة أن تقضى على غير مقتضى نص العقد.

— مجمل القول : انه لايجوز للادارة بل ولا تستطيع ان تستبدل الجزاء الذى اتفقت عليه الأطراف ، بجزاء آخر لم يرد النص عليه في العقد.

إذ أن مبدأ السلطة الملزمة للنصوص مازال له احترامه في نظر العقود الادارية ، طالما لا تتعارض مع القواعد العامة ، بشرط ممارستها تحت رقابة القضاء.

٢- سلطة الادارة في توقيع الجزاءات بارادتها المنفردة :

— ان تمتع سلطة الادارة بسلطة توقيع الجزاءات في العقد الادارى بارادتها المنفردة ، إنما يستند إلى امتياز المبادرة Lr Privilege du Preamble ، وهو يعطى الادارة حق توقيع الجزاءات في العقود الادارية وتنفيذها بالقوة الجبرية ، دون حاجة إلى إذن القضاء، ولايغير من ذلك خضوع الإدارة لرقابة القضاء في ذلك.

— وتتمتع الادارة بسلطة تقديرية في تحديد الجزاء الملازم ، بشرط مراعاة الشروط والنصوص التعاقدية.

— والاستثناء الوحيد — طبقاً لأحكام مجلس الدولة الفرنسى — ، هو جزاء الاسقاط ، حيث لايمكن للادارة توقيع هذا الجزاء في حق صاحب

^١ أ.ع ، طعن رقم ٥٥٥٩ لسنة ٤٣ ق ، في ٢٩/٨/٢٠٠١.

الامتياز للمرفق العام ، إلا بطريق القضاء ، بحكم خطورة هذا الجزاء ، مالم يكن ثمة نص صريح فى العقد يمنح الادارة حق توقيع جزاء الاسقاط بارادتها المنفردة^(١). والبيان ان هذا الجزاء تطبيقاته قليلة (جداً) فى القضاء المصرى^(٢).

(٣) مدى سلطة الادارة فى استبدال الجزاءات المنصوص عليها بجزاءات أخرى غير منصوص عليها :

والسؤال : هل يجوز للجهة الادارية أن تستبعد أحد الجزاءات المنصوص عليها فى العقد لتطبق جزاء آخر غير منصوص عليه فى العقد ؟ على العكس من اتجاه مجلس الدولة الفرنسى ، الذى يجيز الاستعاضة عن الجزاء العقدي بجزاء آخر أشد منه ، أو أقل منه^(٣) ، يجرى مجلس الدولة المصرى على وجوب الالتزام بتوقيع الجزاء ذاته المنصوص عليه فى العقد دون غيره.

وقضى بأنه لايجوز زيادة قيمة الغرامة التأخيرية كجزاء على المتعاقد عن قيمتها المنصوص عليها فى الشروط الخاصة للعقد^(٤).

^١ انظر : C.E. 1929, co;pagnie de Navigation sud. Atlantique, Rec., P. 892.

^٢ راجع : د. جابر جاد نصار ، العقود الادارية — القاهرة ، سنة ٢٠٠٠ ، ص ٢١٤.

^٣ انظر : C.E., Girou, 2 Juill. L924, Rcc, P.629.

^٤ أ.ع ، طعن رقم ٥٩٣ لسنة ١٥ ق ، فى ١٢/١/١٩٧٣ ، وأحكام أخرى عديدة ، سبق الإشارة إليها.

ولكن ، يجوز للادارة توقيع جزاء أشد من الجزاءات المتفق عليها في حالة ارتكاب المتعاقد معها مخالفة جسيمة^(١).

(٤) تعدد وتنوع الجزاءات في العقود الادارية :

من المسلمات أن الادارة تستطيع الجمع بين جزاءات متعددة ، مادام قد تحقق السبب الذي يستوجب كل منها. إذ كل سبب من الأسباب التي تؤدي إلى توقيع هذه الجزاءات ، يستقل عن الآخر في الطبيعة ، والغاية، وليس ثمة ما يمنع الجمع بين جزاءات متعددة . فمثلا: غرامة التأخير ليست مرتبطة باثبات الضرر الذي يقع من جراء هذا التأخير في التنفيذ ، بل يعتبر وسيلة للتهديد لمنع التأخير. وجزاء يوقع بسبب التأخير في التوريد . أما الشراء على حساب المتعهد بالتنفيذ المباشر ، فيكون بعد ان يثبت عجز المورد عن التوريد (حالة التقصير البسيط)، بينما الغاء العقد يكون عن تكرار العجز في التوريد (التقصير الجسيم).

— وأجاز القضاء الاداري الجمع بين الجزاءات ، لعدم تنافر هذه الجزاءات مع بعضها، مثل الجمع بين جزائي الفسخ ومصادرة التأمين^(٢).

— كما وان جزاء عدم إكمال صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي، هو الغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي ، أو التنفيذ على الحساب ، بل ويجوز تحميل صاحب العطاء المقصر فروق الأسعار والمصاريف^(٣).

^١ فتوى رقم ١١٩٦ ، في ١٢/٢٨/١٩٩١.

^٢ أ.ع ، طعن رقم ٤١٦٨ لسنة ٩٩ ق ، في ١١/٢٤/١٩٥٧.

^٣ أ.ع ، طعن رقم ٢٢٨١ لسنة ٤٣ ق ، في ٨/٢٩/٢٠٠٠.

(٥) مدى وجوب الأعذار قبل توقيع الجزاء :

— القاعدة المستقرة فقهاً وقضاءً ، هي أن اعذار المتعاقد مع الادارة قبل توقيع الجزاء ، ليس وجوبياً ، وإنما يجوز للادارة أن تلجأ إليه اختياريًا .

— فقد لا يكون للاعذار معنى ، كما فى حالة النص على استحقاق غرامة التأخير لمجرد حصول التأخير كواقعة مادية . وإنما الأعذار قد يكون أثناء تنفيذ العقد للفت انتباه المتعاقد مع الادارة على عدم ملائمة نسبة إنجازهِ للأعمال محل التعاقد مع المدة المنقضية من العقد ، ويتجه مجلس الدولة الفرنسى ، إلى ضرورة اعذار المتعاقد بالجزاء فى كثير من الحالات ، إلا أنه رغم ذلك يستثنى من ضرورة الأعذار قبل توقيع الجزاء ، حالة ماذا تضمن العقد نصاً صريحاً باعفاء الادارة من الأعذار ، أو حالة الضرورة الملحة التى تضيفها الظروف على تنفيذ العقد .

— كما هو الشأن فى توريدات المهمات العسكرية خلال فترة الحرب . أو فى حالة عدم جدوى الأعذار ، كما لو أعلن المتعاقد — من تلقاء نفسه

— رفضه تنفيذ العقد ، باعتباره لاغياً^(١).

— اما مجلس الدولة المصرى ، فقد حرى قضاؤه على اعمال قاعدة الإعذار ووجوبه ، كلما نص العقد على ذلك ، وهى حالات ترتبط بطبيعة

^١ انظر : المستشار / حمدى يسن عكاشة ، العقود الادارية ، مرجع سابق ، ص ٢٤٧ / ٢٤٨ .

الجزاء الذى ستوقعه الإدارة ومدى خطورته ، كجزاء فسخ العقد، أو سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد ، وهو مانص عليه صراحة فى القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ (على ماتقدم قبلاً).

النتائج المترتبة على الأعذار ان كان واجباً :

إذا كان الأعذار واجباً — فى بعض الحالات — أما بنص القانون ، أو طبقاً لنصوص العقد، فإن النتائج المترتبة على الأعذار — فى هذه الحالة — تخلص فى :

(أ) — يجب إلا يحاسب المتعاقد على تقصيره إلا من وقت اعذاره ، واعتباراً من هذا الوقت — فقط — يستحق التعويض العقدى.

(ب) — فوات وقت طويل بعد الأعذار دون توقيع الجزاء ، لايعتبر بالضرورة تنازلاً ضمناً عن تطبيق الجزاء ، ولايلزم معه اعذار جديدة^(١).

(ج) — تفاوض الإدارة مع المتعاقد بعد اعذاره على أسس جديدة ، ولم يحقق هذا المسعى أية نتيجة ، لايعتبر الأعذار قائماً قانوناً ، ولايجوز للإدارة توقيع الجزاء المعذر به ، دون اعذار المتعاقد من جديد^(٢).

— هذا ولم يشترط القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ولا أحكام القضاء إعذار المتعاقد — كاجراء وجوبى — قبل توقيع جزاء الفسخ . إذ تتمتع الجهة الادارية بالحق فى فسخ العقد الادارى دون حاجة للنص عليه فى العقد ودون أعذار^(٣) . وقد نص على ذلك صراحة فى المواد

^١ C.E., ٢٨Dec., ٩٢٧, Soc. (industrielle foncière Rec., ١٢٨٣.

^٢ C.E., ١١ Juill ١٩٢٩, Entre Prise Helage, Rec. ٤٢٧.

^٣ حكم محكمة القضاء الادارى ، فى القضية رقم ١٨٢٧ لسنة ١٠ ق ، فى ١٩٥٧/٣/١٧.

(٥٠، ٥١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (وسوف نعود إلى ذلك تفصيلاً).

(٦) رقابة القضاء على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات :

أ- حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها.

— المستقر فقهاً وقضاء وإفتاء ، فرض القضاء الإداري رقابته على الجهة الإدارية في استعمالها لسلطاتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها أو مقدم العطاء ، ولا تتقف هذه الرقابة عند حق التأكد من مشروعية الجزاء ، بل تمتد في بعض الأحوال إلى مراقبة مدى ملاءمة الجزاء للتقصير المنسوب إلى المتعاقد معها ، أو مقدم العطاء^(١).

— ذلك أن سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات ، سواء في مرحلة إبرام العقد ، أو في مرحلة تنفيذ العقد (استناداً إلى نصوص العقد أو تنفيذاً له) ، بارادتها المنفردة على مقدم العطاء أو المتعاقد معها ، ليست سلطة تحكمية ، وإنما هي سلطة قانونية تخضع كباقي السلطات التي تتمتع بها الإدارة للرقابة القضائية ، للتحقق من مدى مشروعيتها والتحقق من أن الإدارة تستهدف — من خلالها — حسن سير المرافق العامة باستمرار وتحقيق المصلحة العامة من تنفيذ العقد.

— والرقابة القضائية على تلك القرارات — وعلى ما تقدم — تعد ضماناً للمتعاقد توازن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء ، وتمنعها من الانحراف ، وتحافظ على حقوق المتعاقد مع الإدارة ، تجاه قرارات الإدارة غير القانونية ، كما وإن هذه الرقابة القضائية لا تتقف عند حد

^١ أ.ع — طعن ١٤١٢٧ لسنة ٥٧ ، سابق الإشارة إليه.

التحقق من مشروعية الجزاء ، بل تمتد — أيضا — إلى مراقبة مدى ملاءمته للتقصير المنسوب إلى المتعاقد أو مقدم العطاء.

— كذلك تستهدف هذه الرقابة — فضلا عن كل ذلك — تحقيق العدالة المرجوة من القضاء. وللقضاء في ممارسته لهذه الرقابة أن يحكم بتعويض المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي قد تكون لحقته ، أو تخفيف الجزاء الموقع ، أو استبدال الجزاء بجزاء أخف ، أو ابطال هذه القرارات إذا كانت تقبل الطعن.

(ب) حق المتعاقد في الطعن على الجزاء الموقع عليه من النظام العام :

إن حق المتعاقد مع الإدارة في اللجوء إلى القضاء لرفع ما فرض عليه من جزاءات ، هو حق مكفول دستورياً وقانونياً ، وبعد من النظام العام ، ومن ثم فإن أى شرط في العقد يقضى باستبعاده يعد باطلاً ولا أثر له.

(ج) الطعن على القرارات التي تصدرها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد تدخل في اختصاص قاضى العقد (القضاء الكامل)^(١).

قدمنا أن القرارات التي تصدرها جهة الإدارة استناداً إلى نصوص العقد أو تنفيذاً له ، تدخل في منطقة العقد ، لايتقيد سحبها بمواعيد الالغاء ولايعصمها من هذا السحب فوات هذه المواعيد، إذ يجوز العدول عنها في أى وقت إذا تبين فساد ماقامت عليه من اسباب ، بحسبان إنه انما ينحسر عنها وصف القرار الإدارى بما يتفرع عنه من السحب والالغاء . ذلك أن هذه القرارات لاتعد من القرارات الادارية المنفصلة.

^١ راجع ماسبق دراسته تحت عنوان :القرارات الادارية المنفصلة فى العقود الادارية.

مجل القول : أن الاجراءات التى تتخذها الادارة استناداً إلى العقود التى تبرمها ، أو اجراءات تنفيذها ، لاتدخل فى نطاق دعوى الالغاء ، ومرد ذلك أن تلك القرارات تكون مستندة إلى أحكام العقد ، ومن ثم فإن المنازعة التى تثار بشأنها هى من المنازعات الحقوقية التى تكون محلاً للطعن على أساس ولاية القضاء الكامل.

فلا يتقيد الطعن عليها بالاجراءات والمواعيد المتعلقة بدعوى الالغاء، وتكون قابلة للطعن فيها أو سحبها مالم يسقط الحق بمضى المدة. — وتطبيقاً لذلك ، قضى بأن قرار الادارية بفسخ العقد لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه الادارة كمتعاقد وليس كسلطة عامة ، ومن ثم يكون الطعن فيه أمام قاضى العقد وليس قاضى الالغاء ، وعلى ذلك ، لايجوز الاحتجاج باكتساب المتعاقد مركزاً قانونياً فى هذا الشأن^(١).

^١ أ.ع ، طعن رقم ٢٣٤٨ لسنة ٣٦ ق ، فى ١٩٩٥/٣/٧ .

الفصل الثانى

أنواع الجزاءات التعاقدية

- قدمنا أن الجزاءات التى تملك الادارة توقيعها على المتعاقد المقصر متنوعة ، ولكن يمكن — مع ذلك — ردها إلى أربعة أنواع :
- ١— الجزاءات المالية .
 - ٢— الجزاءات الضاغطة.
 - ٣— الفسخ.
 - ٤— العقوبات الجنائية.
- وسوف نعرض لك واحد منها فى مبحث مستقل على النحو الآتى :

المبحث الأول

الجزاءات المالية

— الجزاءات المالية نوعان : منها مايقصد به تغطية الضرر الحقيقى الذى يلحق الادارة نتيجة لخطأ المتعاقد، ومنها مايقصد به توقيع العقاب على المتعاقد ، بغض النظر عن أى ضرر يلحق الادارة ، كغرامات التأخير ، والفوائد ، والتعويضات ، والمصاريف الادارية ، ومصادرة التأمين.

— وتبدو الجزاءات المالية حاضرة فى حالات مثل : امتناع المتعاقد عن التنفيذ ، أو التنفيذ بمواصفات مخالفة لمواصفات العقد ، أو التأخير فى التنفيذ عن المواعيد المحددة ، أو التنازل عن تنفيذ العقد لمقاول من الباطن دون موافقة جهة الإدارة.

— فى هذه الحالات يعطى القانون الجهة الادارية المتعاقدة سلطة توقيع جزاءات مالية متعددة منها : غرامة التأخير ، ومصادرة التأمين ، والتعويض.

— والبين أن هذه الجزاءات المالية عبارة عن مبالغ مالية محددة سلفاً
تلتزم بها الادارة المتعاقد معها الذى يخل بالتزاماته التعاقدية.
— ومن المسلمات أن الجزاءات المالية من الشروط الأساسية فى
جميع العقود الادارية ، كنوع من الجزاء يتحمله المتعاقد مع الإدارة
بسبب اخلاله فى تنفيذ التزاماته التعاقدية ، ومن ثم حمل المتعاقد مع
الادارة على الانضباط والدقة فى التنفيذ فى المواعيد المحددة . وان
توقيع الجزاءات المالية على المتعاقد المقصر لايغفیه من تنفيذ التزاماته
التعاقدية ، حتى لايتأثر سير المرافق العامة بانتظام وإطراد.
ولما كانت غرامة التأخير ، أهم وأبرز صور الجزاءات المالية ،
فسوف نعرض لها — تفصيلا — ، على أن نتناول الجزاءات المالية
الأخرى ، بشئ من الإيجاز.

المطلب الأول

غرامة التأخير

— وسوف نتناول هنا الأحكام العامة فى موضوع " غرامة التأخير " ،
فنعرض لماهيتها . وطبيعتها القانونية . وأوجه التفرقة بينها وبين الشرط
الجزائى ، وكذا التفرقة بينها وبين الغرامة التهديدية ، وأيضا التفرقة
بينها وبين التعويض ، وتقديرها ، وحالات الاعفاء منها ، وشروط ذلك.

أولا : ماهية غرامة التأخير ، وطبيعتها القانونية :

— تعد غرامة التأخير أبرز صور الجزاءات المالية التى تملك الإدارة
توقيعها على المتعاقد معها.

— وهى عبارة عن مبالغ مالية تذكر قيمتها فى العقد كجزاء على
الاخلال بالالتزامات التعاقدية من جانب المتعاقد مع الادارة ، عن كل يوم

تأخير ، وللإدارة حق استيفاء هذه الغرامات بمجرد تأخر المتعاقد معها عن المواعيد المحددة دون حاجة لاثبات الضرر ، إذ الهدف منها حسن سير المرافق العامة.

— وقدّمنا أن سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد المقصر هي سلطة مستقلة عن نصوص العقد ، ولو لم ينص عليها في العقد.

— التكييف القانوني لغرامة التأخير :

— المستقر عليه فقهاً وقضاء أن غرامة التأخير هي جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد معها ، إذا تأخر في تنفيذ التزاماته عن الموعد المحدد. وإن اقتضاء هذه الغرامة منوط بتقدير جهة الإدارة المتعاقدة ، بوصفها القوامة على حسن سير المرافق العامة والقائمة على تنفيذ العقد. وهي جزاء توقعه الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد اثبات عدم حصوله^(١).

— كما وهي (أى غرامة التأخير) صورة من صور التعويض الاتفاقى ، يفترض في مجال العقود الإدارية تحقق الضرر بمجرد وقوع التأخير ، ويجوز للطرف الآخر اثبات انتفاء ركن الخطأ^(٢).

بل تستحق غرامة التأخير بمجرد التأخير في التوريد ، حتى لو رخصت جهة الإدارة للمتعاقد في مهلة إضافية دون حاجة إلى إثبات حصول الضرر^(٣).

^١ أ.ع — طعن رقم ٦٨٧٨ لسنة ٥٥ ق ، فى ٢٦/٣/٢٠١٧.

^٢ أ.ع — طعن رقم ١٠٣٩٤ لسنة ٤٧ ق ، فى ٧/١٢/٢٠٠٤.

^٣ أ.ع ، طعن ١٢٩٥ لسنة ٣٤ ق ، فى ٢٩/٦/١٩٩٣ =.

كما وتعد غرامة التأخير ضماناً لتنفيذ العقد فى الميعاد ، يجوز توقيعها دون حاجة على صدور حكم بها ، ولكن يشترط لاستحقاقها حصول الاخلال العقدى فى جانب المتعاقد المقصر .

ثانيا : القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ، جاء بأحكام مغايرة عن سابقة (القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨)، فى مجال غرامة التأخير :

— فقد نص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فى المادة (٤٨) ، على أنه : " إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى ، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد ، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة اعطاؤه مهلة لاتمام التنفيذ ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه ، إذا كان التأخير راجعاً لسبب خارج عن إرادته.

— وفى حالة عدم الالتزام بالتنفيذ ، لسبب راجع إلى المتعاقد ، يحصل مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر ، (وفقاً للنسب المحددة بذات المادة) ويحسب مقابل التأخير من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ، إذا رأت الجهة الادارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة . أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه ، فيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختامى العملية.

= — ونشير إلى أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قد خرج على هذا المبدأ ، فنص على عدم تحصيل مقابل للتأخير ، إذا كان التأخير راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته.

— ويتم تطبيق معادلة تغيير الأسعار للكميات التي نفذت خلال المهلة، بشرط أن يكون التأخير راجعاً لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، على أن يعدل الجدول الزمني بما يتفق عليه الطرفان ، إذا تطلب الأمر ذلك ، وبما يتناسب مع مدة التأخير.

— وفي جميع حالات تحصيل مقابل التأخير ، يكون الاعفاء منه بقرار من السلطة المختصة ، إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد . وللسلطة المختصة أو كلياً ، إذا لم ينتج عن التأخير ضرر، ويجوز للسلطة المختصة استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ارتأت ذلك.

— ولايخل تحصيل مقابل التأخير ، بحق الجهة الادارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.

التعليق على المادة (٤٨) :

(١) لم يغير نص م / ٤٨ (سالف الاشارة اليه) من تمتع الجهة الادارية المتعاقدة بسلطة تقديرية واسعة فى توقيع جزاء غرامة التأخير على المتعاقد المقصر، فى حالة التأخر فى التنفيذ عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى ، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد. بل وتمتعها — ايضا — بسلطة التنفيذ المباشر فى اقتضاء غرامة التأخير .

(٢) أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ للسلطة المختصة إعطاء المتعاقد معها مهلة لاتمام تنفيذ العقد ، دون تحصيل مقابل للتأخير ، بشرط أن يكون التأخير راجعاً لسبب خارج عن إرادة المتعاقد معها ، وذلك على العكس من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، الذى كان يجيز توقيع الغرامة

التأخيرية على المتعاقد (كقاعدة) ولو تم اعطاؤه مهلة إضافية لاتمام التنفيذ (م/٢٣ من ق ٨٩ لسنة ١٩٩٨).

(٣) جاء القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، بتفرقة جوهريّة في كيفية حساب مقابل التأخير ، فنص على أن يحسب مقابل التأخير من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ، مالم يكن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه ، فيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختامى العملية . بينما كان القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، يجعل احتساب مقابل التأخير من قيمة ختامى العملية ' ولم يأخذ بهذه التفرقة.

(٤) وفي خصوص الاعفاء من تحصيل مقابل التأخير ، أناط القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بالسلطة المختصة اعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير ، إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن ارادة المتعاقد ، بل وأجاز القانون — أيضا — للسلطة المختصة في غير هذه الحالة اعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئياً أو كلياً ، إذا لم ينتج عن التأخير ضرر . ولم يشترط القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ (كسابقة القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨) أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، وإن أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ للسلطة المختصة استطلاع رأى ادارة المختصة بمجلس الدولة إذا ارتأت ذلك ، إذ لم يعد هذا الاجراء لازماً حال اعفاء الإدارة المتعاقد معها من غرامة التأخير.

(٥) وأخيراً ، نص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على ما استقر عليه الفقه والقضاء ، في التمييز بين غرامة التأخير والتعويض . فنص على أن تحصيل مقابل التأخير بالارادة المنفردة واتباع اسلوب التنفيذ المباشر في اقتضائها ، لايحل بحق الجهة الادارية في الرجوع (قضائياً) على

المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من اضرار بسبب التأخير.

(٦) كما جاء ق ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بأحكام مغايرة فى نسب غرامة التأخير على ماسنعرض له بعد قليل.

محمل القول : ان غرامات التأخير المقررة قانوناً ، وتلك المنصوص عليها فى العقود الادارية ، هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها ، حرصاً على سير المرفق العام بانتظام ، ولايتوقف استحقاقها على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء احلال المتعاقد بالتزامه . كما لايعفى منها إلا إذا أثبت أن اخلاله بالتزامه يرجع إلى أسباب خارجة عن ارادته (كالقوة القاهرة ، أو خطأ جهة الادارة المتعاقد معها).

ثالثاً : التمييز بين غرامة التأخير والشرط الجزائى :

تختلف غرامة التأخير (المنصوص عليها فى /٤٨ من ق ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بطبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية (المنصوص عليه فى م/٢٢٤ من القانون المدنى). فبينما الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدماً ، يستحق فى حالة إحلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، فيشترط فيه مايشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام ، من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الآخر ، اعدار الطرف المقصر، وصدور حكم به ، فإن غرامة التأخير فى العقود الادارية — على ماقدمنا — اساسها ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها، حرصاً على سير المرافق العامة بانتظام وإضطراب ، وللجهة الادارية حق توقيعها بمجرد حصول التأخير ، ولو لم يترتب عليه ضرر ، ودون حاجة إلى

تنبيه أو انذار أو اتخاذ اية اجراءات قضائية أخرى ولايقبل من المتعاقد مع الادارة إثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيرها في تنفيذ التزامه.

والسؤال : هل هناك ما يمنع من الاخذ بإجراء الشرط الجزائي في العقود الادارية ؟

قلنا أن الشرط الجزائي هو أحد الأساليب التي تتخذها الإدارة ، والمقصد منه حث المدين (المتعاقد معها) على وجه جدى حاسم للوفاء بالالتزام المقرر فى المواعيد المحددة تفادياً لأضرار التأخير — فلا تلتزم الادارة بإثبات حصول الضرر ، غير انه يجوز للمتعاقد معها إثبات انعدام الضرر ، أو عدم تناسبه مع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه . ولك ذلك تحت رقابة القضاء ، الذى له سلطة تحديد قيمة التعويض النهائى الناشئ عن عدم التنفيذ أو التراخى فيه . إذا ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بأسلوب الشرط الجزائي (التعويض التهديدى) فى مجال العقود الادارية ، ويخضع فى ذلك لأحكام المادة (٢٢٤) من القانون المدنى — سالف الإشارة إليها — ، من وجوب اثبات الضرر، واعدار المتعاقد المقصر ، ولايطبق إلا بحكم القضاء ، وليس بارادة الجهة الادارية المنفردة .

وسؤال آخر ، هل يجوز الجمع بين غرامة التأخير والشرط الجزائي ؟ نعم يجوز الجمع بينهما. وقضى بأنه يجوز للمحكمة تخفيض قيمة الشرط الجزائي (التعويض التهديدى) المتفق عليه والمستحق للادارة عن التأخير فى التنفيذ ، متى تبين لها تنفيذ المتعاقد التزامه ، وسداده غرامة

التأخير، وبمراعاة قيمة العملية ، وضالة الضرر الذى لحق بجهة الإدارة من جراء التأخير فى التنفيذ^(١).

وبعبارة أخرى ، إذا استقر الاخلال بالتزام ، واتضح التعويض ومناطه حدوث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام ، أو التأخير فى تنفيذه ، ومدى تعنت المدين ، يترك الأمر للقاضى فى تحديد التعويض النهائى الناشئ عن عدم التنفيذ أو التراخى فيه ، دون حاجة إلى الزام الادارة باثبات وقوع الضرر ، وهو مناط الخلاف الوحيد بين علاقات القانون العام والقانون الخاص ، مؤدى ذلك ، افتراض حصول الضرر فى مجال القانون العام ، على أن يسمح للمتعاقد المدين باثبات انعدام الضرر أو عدم التناسب الجسيم بين ضرر تافه تحقق وتعويض جسيم اتفق عليه ، مما يدخل فى رقابة الانحراف^(٢).

رابعا : وكذلك ، تختلف غرامة التأخير عن الغرامة التهديدية :

ذلك أن الغرامة التهديدية لاتعدو وسيلة غير مباشرة لحث المدين على تنفيذ التزامه عيناً ، تكون بحكم قضائى ، فهى — كما نص م/٢١٣ مدنى — ، تتسم بأنها غرامة تهديدية — وقائية — ولاتعدو ديناً محققاً فى ذمة المدين.

خامسا : النسب المحددة بالقانون لغرامات التأخير :

نص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ (م/٤٨) ، سالف الإشارة إليه — على أنه فى حالة عدم الالتزام بالتنفيذ ، لسبب راجع إلى المتعاقد ، يحصل

^١ حكم أ.ع ، فى الطعن ٦٨٧٨ لسنة ٥٥ ق فى ٢٦/٣/٢٠١٣.

^٢ أ.ع — طعن رقم ٢٤٥ لسنة ٢٧ ق ، فى ١٢/١٢/١٩٨٧ ، مح س ٣٣ — ص ٣٩٤.

مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أى إجراء آخر ، وفقاً لمايلي :

١- فى مقاولات الأعمال : بما لايجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (١٠%) من نسبة العقد، إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية . ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك.

٢- فى باقى العقود ، بما لايجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (٣%) من قيمة العقد ، إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعقد. ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك.

— وهنا يلحظ أن القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، قد جاء بحكم جديد، مغايراً لما كان يجرى عليه القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، فيما يتعلق بنسب غرامات التأخير ، إذ بينما تحدد غرامة التأخير فى عقود المقاولات ب (١٠%) من قيمة العقد ، (٣%) فى باقى العقود ، وهو الحد الأقصى لغرامات التأخير فى القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، رفع القانون نسب غرامة التأخير فى عقود المقاولات إلى (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير (١٠%) من المدة الكلية للعملية ، وإلى (٥%) فى باقى العقود ، إذا جاوزت مدة التأخير (١٠%) من المدة الكلية للعقد.

أى أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قد ربط نسب غرامة التأخير فى العقود الادارية ، بمدة التأخير فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

— وهنا يلحظ أن المشرع قد استهدف من خلال رفع نسبة غرامة التأخير ، فى كل من عقود المقاولات ، وسائر العقود الادارية ، المدين

على عدم الاخلال بتنفيذ التزاماته التعاقدية فى المواعيد المحددة بمراسة الشروط ، الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

ونشير إلى أن تحديد نسب غرامة التأخير ، ليس من النظام العام ، فإذا تضمن العقد المبرم مع جهة الادارة نسباً أخرى لهذه الغرامة ، فلامناص من الالتزام بأحكامه^(١).

تطبيقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدي . أما فى حالة عدم ورود نص صريح فى العقد يضع حداً أقصى للغرامة ، فان نسبة الحد الأقصى المقررة فى القانون ، تكون هى النسبة الملائمة التى يتعين ألا تتجاوزها قيمة الغرامات المتوقعة على المتعاقد.

— وقدما أن القضاء يراقب جهة الادارة فى استعمالها لهذا الحق ، وسلطته فى هذا الخصوص واسعة ، لاتقف عند حد مراقبة مشروعية الجزاءات التى توقعها الادارة ، بل قد تمتد فى بعض الحالات إلى مراقبة مدى ملاءمتها للتقصير المنسوب إلى المتعاقد معها.

سادساً : المبادئ القضائية المستقرة فى مجال غرامة التأخير :

إذا كان ذلك كذلك فى بيان ماهية غرامة التأخير ، وطبيعتها القانونية، ومدى اختلافها عن كل من الشروط الجزائى ، والتعويض ، والغرامة التهديدية . فان ثمة مبادئ قضائية استقر عليها فى مجال غرامة التأخير ، أهمها :

(١) مناط توقيع غرامة التأخير هو انتهاء مدة العقد دون الانتهاء من تنفيذ مشموله . لايجوز فرض غرامة تأخير فى حالة عدم أداء التأمين النهائى خلال المدة المحددة^(٢).

^١ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، رقم ٨٠٠ فى ١٢/٢/١٩٩٩.

^٢ أ.ع — طعن ١٧٠٥٧ لسنة ٥٣ ق ، فى ٢٩/٥/٢٠١٢.

(٢) للادارة أن تشتتزل قيمة الغرامة من المبالغ التى قد تكون مستحقة للمتعاقد ، دون أن تلتزم باثبات حصول الضرر، ودون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أية اجراءات قضائية أخرى ، ولايقبل من المتعاقد مع الادارة اثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيرته فى تنفيذ التزامه (١).

(٣) لايعفى المتعاقد من الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع على قوة قاهرة (أو كأن يكون التأخير بفعل الغير ، أو كأن يكون العقد منوطاً بعده مقاولين مع تأخير أحدهم فى تنفيذ التزاماته) أو إلى خلل من جهة الادارية المتعاقد معها (٢).

(٤) إذا استبان من الظروف والملابسات أن الادارة لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها — يعد ذلك اعفاء ضمناً للمتعاقد معها من تطبيق الغرامة عليه ..

— ويترتب على ذلك أن يكون للمتعاقد الحق فى استرداد ماخضم من مستحقاته من غرامة التأخير (٣).

(٥) خلو العقد من النص على غرامة تأخير يمنع من توقيعها ، بحسبانها تعويضاً اتفاقياً. فلايجوز توقيعها إلا إذا نص فى العقد عليها (٤). بمعنى آخر .. إذا تضمن العقد شرطاً خاصاً ينظم غرامة التأخير ، يحول دون تطبيق القانون ولائحته التنفيذية ، وجوب التقيد

^١ أ.ع — طعن ٧٤١ لسنة ٢٧ ق ، فى ١٩٨٥/٥/٢٨ ، مج س ٣٠ — ص ١١٧٩.

^٢ أ.ع — طعن ٢٥٥١ لسنة ٣١ ق ، فى ١٩٨٩/٥/٣٠ ، مج س ٣٤ — ص ١٠٧٣.

^٣ فتوى رقم ٢٢٦ فى ١٩٨٨/١/٢٥.

^٤ فتوى رقم ٤١٧ فى ١٩٦٧/٤/١٥ — ملف رقم ١٥٩/٨٨/٢١.

بنص العقد، ذلك أن النسب المحددة بالقانون لغرامة التأخير ليست من النظام العام — على ما قدمنا — .

(٦) غرامة التأخير — طبقاً لنص م/٤٨ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ — يجوز للجهة الادارية المتعاقدة توقيع تلك الغرامات بالنسب والأوضاع المبينة عن كامل ختامى العملية ، أو عن الجزء المتأخر منها فقط ، حسبما يترأى لها بالنسبة لامكانية الانتفاع بما تم من أعمال على استقلال أو عدم امكانية ذلك ^(١).

٧— إذا تسلمت الادارة الأعمال المسندة للمقاول تسليمياً ابتدائياً ، فلا يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التأخير ، ولا ينال من ذلك مجرد الادعاء بأن التسليم الابتدائي لم يكن بدقة ، وان الادارة لم تصدر التأمين المؤقت ولم تنفذ العقد على حساب المقاول ^(٢).

٨— اخطار المتعاقد مع الادارة بأنها ستضطر لإلغاء العقد وتصادر التأمين ، لا يحول دون حقها في اقتضاء غرامة التأخير ^(٣).

٩— يمكن اعتبار عنصر الضرر أحد العوامل التي تستهدى بها جهته الادارة إذا ما اتجهت إلى الاعفاء من توقيع الغرامة ^(٤).

^١ نشير إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ ، فى شأن المناقصات والمزايدات ، كانت تنص على ذلك فى م/٩٣ منها — راجع فى ذلك حكم أ.ع — طعن رقم ٣٧٧ لسنة ٣٤ ق ، فى ١٣/٣/١٩٩٠.

^٢ أ.ع — طعن رقم ٢٣٤٨ لسنة ٣٦ ، فى ٧/٣/١٩٩٥.

^٣ أ.ع — طعن ٥٦٢ لسنة ١٥ ق ، فى ١٣/٤/١٩٧٤ ، مج س ١٩ — ص ٢٦٥.

^٤ فتوى رقم ٨٤٥ فى ٦/٩/١٩٦٥ — ملف رقم ١٩/١٣٩/٤٦٩.

١٠- لاملح لتوقيع الغرامة إذا ثبت أن المورد أورد تحفظاً في العطاء بالنسبة للمدة خلاف المدة المحددة في الشروط العامة للممارسة ، وقبلتها الادارة (١).

١١- لايجوز للمتعاقد مع الادارة أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته ، إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة . هذا الأصل يجوز للطرفين الخروج عليه عند التعاقد ، خاصة إذا ما قدر أن عدم تنفيذ الجهة الادارية لالتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزامه في الميعاد ، وليس في ذلك ما يخالف النظام العام (٢).
— ويلاحظ أن هذه التطبيقات القضائية ، هي توكيد لما تم تناوله تفصيلاً.

المطلب الثاني

الجزاءات المالية الأخرى

— قدمنا أن الجزاءات المالية التي تملك الجهة الادارية توقيعها على المتعاقد معها حال تقصيره أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ، متعددة ، تشمل فضلاً عن غرامات التأخير، مصادرة التأمين والفوائد والمصاريف الادارية والتعويضات.

— وقد تناولنا جزاء مصادرة التأمين (حالاته وشروطه) ، عند دراستنا لموضوع التأمين المؤقت والتأمين النهائي — قبلاً — ، فيخيل إليها منعاً للتكرار.

^١ فتوى رقم ٤٩٣ ، في ١٩٩٥/٦/٢٤.

^٢ راجع المستشار أحمد منصور — الدليل الاجرائي لقضاة مجلس الدولة في لجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات والمزايدات ، ص ٥٤.

ونعرض فيما يلي — بإيجاز — للجزاءات المالية (الأخرى) :

أولاً : مصادرة التأمين : (١) حالاته :

— أوضحنا (قبلاً) أن المشرع فى القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، قد تناول أحكام التأمين المؤقت فى العقود الادارية فى المواد (١٦،١٨) منه، بينما تناول أحكام التأمين النهائى فى المواد (٤١،٤٠) . وقلنا أن المشرع أوجب مصادرة التأمين المؤقت (فى حالة الغاء المناقصة أو الممارسة) من مقدمى العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم ، أو ممارسات إحتيال ، أو فساد أو احتكار، وهو ذات الحكم فى حالة الغاء المزايدة ، بالنسبة للمشار إليهم ، على الرغم من عدم النص على ذلك صراحة — كما الحال فى الغاء المناقصة والممارسة ، لذات العلة (م/٣٨).

وقلنا — أيضاً — أن التأمين المؤقت يصبح من حق الجهة الادارية ، إذا لم يرق صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائى خلال المدة المحددة. كما يكون للجهة الإدارية أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها (كتعويض) إذا تبين أن المتسبب فيها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوقها فى الرجوع عليه قضائياً ، بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى (التنفيذ المباشر) — (م /٤١).

— كما أوجب المشرع مصادرة التأمين المؤقت فى حالة التقدم بأكثر من عطاء لعملية واحدة مالم شريكاً (مقدم العطاء) مع الغير بحصة غير مؤثرة ، بل أن المشرع قرر فضلاً عن ذلك استبعاد العطاء المخالف

لذلك الخطر ، أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب ، وأيلولة التأمين النهائي إلى الجهة الادارية ، وأيضا تحميل المتعاقد بأى خسارة تلحق بها، إذا تبين لها مخالفة الخطر بعد التعاقد (م/٣٣) — القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

— كذلك للجنة الادارية مصادرة التأمين المؤقت فى حالة سحب العطاء بناء على طلب مقدمة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف ، دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء على القضاء، أو اتخاذ أى اجراءات ، أو اقامة الدليل على حصول ضرر ، أو استئذانة من أى مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أى جهة ادارية أخرى لصاحب العطاء المذكور (م/٢٢).

(٢) تمتع الجهة الادارية بسلطة تقديرية (واسعة) فى مصادرة التأمين :

— أن حق الادارة فى مصادرة التأمين (فى جميع الأحوال المشار إليها) عند قيام أسبابه ، وماترتبه من إخلال (المتعاقد أو مقدم العطاء) ، بالالتزامات التعاقدية ، مما يرتبط بسلطتها التقديرية التى تنأى عن الرقابة القضائية ، طالما كانت متفقة مع مبدأ الشرعية وغيرمتسمة باساءة استعمال السلطة.

بيد أنه يلزم إصدار قرار صريح — من الجهة الادارية ، يرتب هذا الأثر فى حق المتعاقد معها (أو مقدم العطاء) جزاء اخلاله بشروط التعاقد.

— كما وان هذا الحق — مصادرة التأمين — تملكه جهة الادارة ، دون حاجة إلى القضاء، بل انه يثبت سواء نص عليه فى شروط العقد أو لم ينص.

— وجدير بالذكر أن التأمين قد يمثل الحد الأدنى الذى يحق لجهة الادارة اقتضاؤه ، لكنه يقيناً لايمثل الحد الأقصى لما قد يطلب من تعويض ، بحسبان أن ذلك التأمين شرع لمصلحة الادارة ، وليس قيداً عليها ، أو ضار بحقوقها فى التعويض الشامل . بمعنى ، انه إذا كانت قيمة التأمين لا تكفى وحدها بجبر الضرر، فانه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبره إضافة إلى التأمين . ويرجع ذلك إلى اختلاف التعويض عن مصادرة التأمين فى الطبيعة والسبب والغاية. وبناء على ذلك إذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله ، فلا يكون ثمة محل لطلب التعويض^(١).

— عدم جواز الجمع بين مصادرة التأمين والتنفيذ على الحساب :

(٣) — كما وأن مؤدى النصوص القانونية المشار إليها آنفاً، انه لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين عند تقصير المتعاقد مع الادارة فى تنفيذ التزام من التزامات العقد ، وبين إلزامه بالفروق التى تحملتها نتيجة للتنفيذ على حسابه . ذلك المقصود من مصادرة التأمين — على ماتقدم — مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها.

— وهنا ثمة ملاحظة جديرة بلاشارة إليها ، وهى أن تمسك الادارة بالعقد وتنفيذه على حساب صاحب العطاء المقبول ، يحول دون سحب

^١ راجع أحكام الادارية العليا فى الطعون ١١٥٧ لسنة ٢٦ ق ، فى ١/٢/١٩٨٦ ، ٣٢٧ لسنة ٣٥ ق ، فى ١٠/٢٥/١٩٩٤.

قبول العطاء ومصادرة التأمين فلا يجوز الجمع بينهما ، بل ولا يجوز المطالبة بالتعويض فى حالة سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين المؤقت.

(٤) فى مصادرة التأمين فى حالة الغاء العقد – تفرقة هامة :

يجب التفرقة بين حالتى الغاء العقد بسبب التقصير فى دفع التأمين النهائى فى الميعاد. والالغاء بسبب الاخلال بشروط العقد فى الحالة الاولى (الغاء العقد بسبب التقصير فى دفع التأمين النهائى فى الميعاد) ، هنا لا يجوز للادارة سوى مصادرة مادفع فقط من التأمين. بينما فى الحالة الثانية (الالغاء بسبب الاخلال بشروط العقد) ، يكون للادارة الحق فى مصادرة مادفع والمطالبة بما لم يدفع.

– وتطبيقا لذلك ، قضى بأن ثبوت الالغاء كان بسبب العجز عن التوريد ، يحول للادارة مصادرة مادفع والمطالبة بما لم يدفع من التأمين النهائى – تكييف التأمين النهائى فى هذه الحالة بأنه شرط جزائى^(١).

– **مجمل القول :** انه يجوز الجمع بين التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزاماته ، وبين مصادرة التأمين ، مالم يحظر العقد ذلك . مرد ذلك اختلاف التعويض فى طبيعته وغايته ، عن مصادرة التأمين ، الذى يعد أحد الجزاءات المالية ، التى يجرى – دائماً – اشتراطها فى عقود الادارة . بينما التعويض مرده القواعد العامة فى العقود المدنية والادارية

^١ أ.ع – طعن رقم ٨٣٤ لسنة ٧ق ، فى ٢٧/٤/١٩٦٣ ، مج س ٨ – ص ١١٠١ .

على السواء. جبراً لضرر تعاقدى يحكم به القاضى (ويجوز خصم قيمة التأمين من قيمة التعويض).

— وعلى ذلك فإن الجمع بينهما لا يعد ازدواجاً للتعويض محظوراً .
على أن الجمع بينهما رهين بأن لا يحظر العقد صراحة هذا الجمع ^(١).
— كما لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين عند تقصير المتعاقد مع الادارة ، وبين الزامه بفروق الأسعار التى تكون قد تحملتها الجهة الادارية نتيجة التنفيذ على حسابه.

ثانيا : الفوائد التأخيرية :

— تعد المادتين (٢٢٦ ، ٢٢٨) من القانون المدنى — المنظمتين لأحكام الفوائد التأخيرية — من الأصول العامة فى الالتزامات ، تطبق أحكامهما فى نطاق الروابط العقدية الادارية ، وتطبيقاً لذلك قضى بأن :
رفض الحكم بالفوائد التأخيرية (فى مجال العقود الادارية) ، يعتبر خطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ^(٢).

— والمعلوم أن الفوائد التأخيرية ، وفقاً لأحكام المادتين المشار إليهما ، تكون حقاً للدائن (جهة الادارة) ، دون حاجة إلى ثبوت ضرر لحقها من التأخر ، ومن ثم يحق لها الرجوع على المتعاقد معها بها . بل ويجوز الجمع بينها وبين غرامة التأخير التى تعد تعويضاً اتفاقياً جزافياً، وتسرى

^١ أ.ع ، طعن رقم ١٠٨ لسنة ١١ ق فى ٩٦٩/٦/٢١ ، مج س ١١ — ص ٨٢٥ ، طعن رقم ١١٣٦ لسنة ١٥ ق فى ١٩٧٥/٢/٢٢ ، مج س ٢٠ — ص ٢١٨ .

^٢ أ.ع — طعن رقم ٢٠١٤ لسنة ٦ ق ، فى ١٩٦٢/١١/١٧ ، مج س ٨ — ص ٦٦ .

الفوائد التأخيرية عليها أيضاً ، فضلاً عن المصاريف الادارية التي تستحقها الادارة ، باعتبارها مكملة لفرق الثمن^(١). ويكون سريان الفوائد التأخيرية على هذه المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية بها وليس من تاريخ الحكم بها ، بواقع ٤% سنوياً (م/٢٢٦) مدنى^(٢) . ودون اشتراط حصول ضرر من التأخير.

— وعلى ذلك ، تسرى الفوائد التأخيرية على الغرامات المحكوم بها، وعلى التعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية^(٣).

ثالثاً : المصاريف الادارية

— المصاريف الادارية التي تتكبدها الادارة فى حالة إعادة المزايدة والمحددة قانوناً بنسبة (٥%) من قيمة الأعمال أو الأصناف المشتراه على حساب المتعهد ، تسرى على العقود الادارية جميعها ، بحسبانها تفصح عن نية الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التي تتكبدها فى تنفيذ العقد الادارى الذى يتخلف المتعاقد معها عن تنفيذه ، والتي يفترض

^١ أ.ع ، طعن ٥٣١ لسنة ٤ق ، فى ٩٦٠/٣/٢٦ — مج س ٥ — ص ٥٦٤ ، طعن رقم ٩٤ لسنة ٩ق ، فى ١٩٦٥/١٢/١١ ، مج س ١١ — ص ١٢٧ .

^٢ أ.ع ، طعن ٥٣١ لسنة ٤ق ، فى ٩٦٠/٣/٢٦ — مج س ٥ — ص ٥٦٤ ، طعن رقم ٩٤ لسنة ٩ق ، فى ١٩٦٥/١٢/١١ ، مج س ١١ — ص ١٢٧ .

^٣ أ.ع — طعن ١١٣٦ لسنة ١٥ ق ، فى ٩٧٥/٢/٢٢ ، مج س ٢٠ ، ص ٢١٦ .

أن يعلمها ويقبل حكمها عليه . بل وتطبق هذه المصاريف ولو لم ينص على تحديد خاص بها، بالنسبة المحددة قانوناً^(١).

المبحث الثانى الجزاءات الضاغطة

تمهيد :

— تعد الجزاءات الضاغطة من الجزاءات المؤقتة التى لا تنتهى العقد ، وإنما توكل تنفيذه إلى غير المتعاقد الأصلى ، وعلى مسئوليته ، لضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

— وأهم صور هذه الجزاءات :

— سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب.

— الشراء على حساب المتعاقد (فى عقود التوريد).

— وضع المشروع تحت الحراسة (فى عقود الالتزام).

ونعرض — بإيجاز مناسب — لاجراء سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب ، بحسبانه من أهم الاجراءات التى تلجأ اليها الادارة فى تنفيذ العقد الادارى.

سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب (مفهومه — طبيعته القانونية

— آثاره — شروط استخدامه) :

أولاً : مفهوم سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب ، وطبيعته القانونية :

^١ أ.ع — طعن ٩٤ لسنة ٩٩ ق ، فى ١١/١٢/١٩٦٥ ، طعن ١١٦٣ لسنة ١٤ ق ، فى ٢٣/١٢/١٩٧٢.

(١) — يقصد بهذا الجزاء ، قيام الجهة الادارية المتعاقدة بتنفيذ العمل (محل التعاقد) بنفسها، أو بواسطة متعاقد جديد ، فى حالة اخلال المتعاقد الأصلى وتقصيره فى تنفيذ التزاماته ، ومخالفته نصاً صريحاً فى العقد. وقدمنا أن هذا الجزاء لايؤدى إلى انهيار العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر، لانه يظل مسئولاً أمام الجهة الادارية ، والعملية (محل التعاقد) تتم على حسابه وعلى مسئوليته . وان ممارسة الجهة الادارية لهذه السلطة فى فرض الجزاء مرتبطة بالنظام العام ، فلا يكون ثمة حاجة للنص عليها فى العقد .

وتعد عقود مقاولات الأعمال (الأشغال العامة) هى أكثر المجالات تطبيقاً لهذا الجزاء.

— وقد أكدت الادارية العليا ذلك فى العديد من أحكامها ، إذ استقرت أحكام القضاء، على أن سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الادارة ، أو هو وسيلة لارغام المتعاقد على تنفيذ العقود. وقد شرع هذا الجزاء لحمايته سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وكما هو الحال — فى سائر الجزاءات التعاقدية — تتمتع الادارة بسلطة تقديرية فى اللجوء اليه . وللادارة أن توقع هذا الجزاء دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء ، كما لايشترط لتوقيعه حدوث ضرر يصيب المرفق^(١).

^١ أ.ع ، طعن رقم ١١٨١ لسنة ٣٣ ق ، فى ١/٢٥/١٩٩٤.

— وقد نص على هذا الجزاء فى الفصل الثانى (من القسم الرابع) من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، تحت عنوان : شروط تنفيذ عقود مقاولات الأعمال (م/٨٥).

— طبيعة قرار سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب = مدى جواز الجمع بينه وبين جزاءات أخرى :

— وعلى ذلك يعد التنفيذ على الحساب ، وسيلة جهة الادارة فى تنفيذ الالتزام عيناً ، وهو تنفيذ تقوم به الادارة بنفسها ، وعلى حساب المتعاقد وتحت مسؤوليته المالية ، بحيث يتحمل فروق الأسعار الناشئة عن التنفيذ. — ومن ثم لا يعد التنفيذ على الحساب عقوبة عقدية ، ولكنه إجراء تستهدف به الإدارة ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

ولا يؤدي هذا الاجراء إلى انتهاء الرابطة العقدية ، مادامت الادارة لم تلجأ إلى هذا الاجراء بانتهاء العقد مع مصادرة التأمين^(١).

(٢) يجوز الجمع بين هذا الاجراء (التنفيذ على الحساب) وتوقيع جزاء غرامة التأخير ، فضلاً عن المصروفات الادارية :

ومرد ذلك أن التنفيذ العيني للعقود الادارية (سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب) ، يتم بواسطة الجهة الادارية ، تقوم به بنفسها ، على العكس من التنفيذ العيني فى العقود المدنية ، فلا يتم إلا عن طريق القضاء. وفى ذلك يظهر تميزاً العقود الادارية بطالع خاص مناطه احتياجات المرفق العام ...

ونشير إلى أن استخدام هذا الحق (أو الاجراء) أمر تفرضه المصلحة العامة ، وحماية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ، ومن ثم يعد واجباً على الادارة أن تمارسه دون حاجة إلى نص^(٢).

^١ أ.ع ، طعن رقم ٩٩٣ لسنة ٨ ق ، فى ١٩٦٤/٢/٨ ، مج س ٩ — ص ٦٢٢.

^٢ راجع : د. عبد المجيد فياض — نظرية الجزاءات فى العقد الادارى — القاهرة سنة ١٩٧٥ — ص ٢١٤.

(٣) الطبيعة القانونية لقرار سحب الأعمال وتنفيذها على الحساب :

— ولا يعد قرار سحب الأعمال وتنفيذها على الحساب (حساب (المقاول) قراراً إدارياً ، بل هو إجراء تقوم به جهة الادارة تنفيذا للعقد ، وهو كإجراء تمهيدى ، يعقبه إجراء آخر تقوم به جهة الادارة بالعمل بنفسها ، والاتفاق مع مقاول آخر بالاجراءات التى حددها المشرع.

— والمسلم به أن قرار سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب ، لا يؤثر على بقاء العقد ، إذ يظل العقد الأسمى قائماً ، ويتم التنفيذ على حساب المتعاقد الأسمى ، وتحت مسؤوليته.

(٤) كذلك يحق للادارة أن تترخص فى استعمال هذا الإجراء فى الوقت الذى تراه ، متى تبينت تباطؤ المتعاقد معها ، أو إخلاله بنصوص العقد ، فلا يجوز إجبارها على الانتظار إلى حين انتهاء مدة العقد حتى تتخذه. كما والمسلم به ، انه لايلزم استطلاع رأى ادارة الفتوى المختصة قبل اتخاذ هذا الاجراء^(١).

— ويترتب على هذا الاجراء التزام المتعاقد بفروق الأسعار عن تنفيذ العقد فضلاً عن المصروفات الادارية وغرامات التأخير.

^١ أ.ع ، طعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٣٦ ق ، فى ١٣/١٢/١٩٩٤ ، ٨١٤٠ لسنة ٤٤٤ فى ٢٣/١/٢٠٠١.

وتسرى هذه الأحكام — أيضا — فى مجال عقود التوريد ، اذ لا يعدو الأمر أن يكون تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا، تقوم به الادارة من تلقاء نفسها (١).

— ومن ثم فان لجهة الادارة — وفقاً لهذا الاجراء — الحق فى استرداد جميع ماتكبته من مصروفات ، وخسائر زيادة على قيمة العقد ، نتيجة سحب العملية ، ويجوز لها خصم المستحق لها من التأمين من المودع لديها ، وأية مبالغ مستحقة لها قبلها — على ماقدمنا آنفاً .

— وثمة سؤال يدور حول مدى جواز إعادة العملية (محل التعاقد) إلى المفاوض — الأصل — بعد سحبها.

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز ذلك ، وتتمتع الجهة الادارة بتقدير هذه المسألة الموضوعية ، على ضوء الضمانات الجديدة التى تكفل انجاز الأعمال على نحو يحقق المصلحة العامة ، وقالت : " ومن حيث انه يترتب على استمرار الرابطة العقدية بحكم اللزوم ، جواز إعادة العملية إلى الشركة (المتعاقد الأصل) بعد سحبها منه ، متى قدرت الجهة الادارية أن الضمانات الجديدة التى قدمها المتعاقد الأصل ، تجعله اقدر من غيره مع إتمام العمل ، وهى مسألة موضوعية ، تستقل بها الادارة ، إلا أن هذا لا يخل بحقها فى إنهاء العقد، متى ثبت اخلال المتعاقد بالتزاماته " (٢).

١ أ.ع ، طعن ١٢٦٠٦ لسنة ٥٢ ق ، فى ٢٧/١١/٢٠١٢ ، طعن ٥٨٤٣ لسنة ٢٦ ق ، فى ٢٠/١١/١٩٨٢ ، ٢ مج س ٢٨ — ص ٨٦ ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ٦٢٦ ، فى ١٧/٦/١٠٨٧ .

٢ فتوى رقم ٣٩٩ فى ١٦/٥/١٩٦٠ ، ملف ١٥/٩٤/١٨٨ .

وسؤال آخر : هل يجوز للمتعاقد الأصلي فى حالة استخدام الادارة سلطتها فى سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب ، المطالبة بفروق السعر فى حالة الشراء بسعر أقل من تلك التى تقدم بها ؟ . الاجابة لايجوز له ذلك ، بل ولايجوز القول بأن حرمان المتعاقد من المطالبة بهذه الفروق يتضمن إخلالاً بمبدأ وجوب تنفيذ العقود بحسن نية ، ذلك أن النص القانونى واضح فى عدم جواز ذلك ، وأيضا لايجوز للمخفى أن يستفيد من تقصيره ، ولايجوز أن يثرى من إخلاله بتنفيذ التزاماته^(١).

— بيد أنه ، لايجوز للجهة الادارية شراء أصناف تغير الأصناف المتعاقد عليها (فمثلاً ليس لها أن تشتري سيارات نقل إذا كان التعاقد على دراجات) . وتتفق المغيرة ، إذا كان الاختلاف فى الجودة زيادة أو نقصاً ، عند تعذر الحصول على ذات الصنف المتعاقد عليه ، إذ للادارة فى هذه الحالة شراء مايمثل الصنف ، ومحاسبة المتعهد على فرق السعر و فرق الجودة^(٢). فلا يعد شراء أصناف غير الأصناف المتعاقد عليها لاختلاف جودة الصنف زيادة أو نقصاً ، شراء لأصناف غير المتعاقد عليها.

(٥) وتلتزم الادارة متى قامت بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد ، بنفس شروط وأسلوب التعاقد ، فتلتزم بنفس شروط المزايدة الأولى ، ومدتها ، عدا السعر الذى تحدده المزايدة الثانية ، لأنها تقوم بدور الوكيل، فتلتزم بما نص عليه فى المادة (٧٠٤) مدنى ، من أن تبذل فى

^١ أ.ع ، طعن رقم ١٣٤٥ لسنة ٨ق ، فى ١٩٦٤/٢/١ ، مج س ٩ ك ص ٥٧١ .

^٢ أ.ع ، طعن رقم ٢٠١٣ لسنة ٦ق ، فى ١٩٦١/١٢/١٦ ، مج س ٧ — ص ١٠٢ ، طعن رقم ٧١٠ لسنة ١٦ ق ، فى ١٠٧٤/١/٢ ، مج س ١٩ ، ص ١٩٩ .

هذه الوكالة العناية التي تبذلها فى أعمالها الخاصة ويقتضى ذلك أن تقوم بالتنفيذ خلال مدة معقولة ، وقضى بأنه : " لاوجه لتحميل المتعاقد مع الادارة بفروق الأسعار، متى ثبت تأخير الادارة فى التنفيذ على حسابه ^(١). وقد نص على ذلك صراحة فى م/٨٤ (من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨).

فنصت على أن سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه يكون بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها ، والمتعاقد عليها ، وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون المزايدات والمناقصات والأحكام الواردة باللائحة التنفيذية .

(٥) وتجدر الإشارة إلى أنه لامحل للتنفيذ على الحساب ، فى عقود الايجار أو الترخيص فى الانتفاع ، ذلك أن انتهاء العقد وحلول مستأجر محل آخر ، لايعنى التنفيذ على حسابه ، ومن ثم فلايجوز مطالبته بفرق القيمة بين الايجار أو الجعل القديم والايجار أو الجعل الجديد ، وان كان يجوز مطالبته بالأجر عن مدة التوقف لكونه المتسبب فيه ^(٢).

(٧) وفى الآثار المترتبة على قرار الادارة بسحب الأعمال والتنفيذ على الحساب ، نص فى (م/٨٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، والمادة (٥١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ — فقرة (٤). — هنا ، يحق للجهة الادارية المتعاقدة الحجز على المواد والمهمات والآلات المملوكة للمتعاقد المقصر حال سحب الأعمال منه ، وذلك دون

^١ أ.ع ، طعن ١٢٦٢٤ لسنة ٣١ ق ، فى ١٧/١/١٩٨٩ ، مج س ٣٤ — ص ٤٥٠ .

أن تكون مسئولة قبل المداول أو غيره عنها، وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان ، أو دفع أى أجر عنها كما يكون لها حق أيضا فى الاحتفاظ بها حتى انتهاء العمل ، ضماناً لحقوقها، ولها فى سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع . كما يصح التأمين النهائى من حق الجهة الادارية ، وكذلك يكون للجهة الادارية أن تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها ، بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الادارية ، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقدين لديها ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ إجراء قضائية ، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوقها فى الرجوع عليه (قضائياً بالتعويض) ، بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى . ويلحظ انها آثار عديدة وخطيرة جداً .

— بيد أنه يجب الإشارة إلى أن حق الجهة الادارية فى الحجز على أموال المتعاقدين المقصر وبيعها ... يقتصر على ما هو مملوك (لهذا المتعاقدين) . فالقاعدة أنه لايجوز بيع ملك الغير ^(١)

(٧) وأخيراً : الاختصاص القضائى بنظر المنازعة فى قرار سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب ، تدخل فى ولاية القضاء الكامل ، وإذا كان للمحكمة أن تفصل فى الطلبات المستعجلة فى شأن هذا الطلب ، فى الحدود والضوابط المقررة للفصل فى الطلبات المستعجلة إلا أنه ، يشترط لوقف تنفيذ قرار سحب الأعمال ألا يكون قد تم تنفيذه . فإذا

^١ أ.ع — طعن رقم ٢٠٨٤ / ٢٥٤٥ لسنة ٣١ ق ، فى ١٩٩٥/١/٢٤ ، طعن رقم ٩٢٩ لسنة ٣٦ ق ، فى ١٩٩٦/١١/١٩ .

تبين أن الإدارة قد نفذت سحب الأعمال ، وشرعت في التنفيذ على حساب المقاول ، فان شرط الاستعجال ينتفى في طلب وقف تنفيذ هذا القرار^(١).

ثانيا : الحالات التي يجوز فيها أو يحق فيها للجهة الادارية سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب ، وشروط استخدامه :

(١) — تخضع الحالات التي يحق للإدارة سحب الأعمال والتنفيذ

على الحساب ، لقاعدة عامة ، تدور حول حق الإدارة في اتخاذ هذا الاجراء ، إذا أخل المقاول (المتعاقد) بأى شرط من شروط العقد ، أو أغفل القيام به ، أو بأحد التزاماته ، ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اذاره .. للقيام باجراء هذا الاصلاح ، كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ أحد الاجرائين التاليين ، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

(أ) فسخ العقد.

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها.

وبذلك لم يعد ثمة محل للجدل حول ما إذا كان تحديد القانون أو اللائحة التنفيذية حالات سحب العمل والتنفيذ على الحساب قد جاء حصراً أو على سبيل المثال . فكل مامن شأنه يمثل خروجاً على القاعدة العامة السابقة ، يحق للإدارة اتخاذ هذا الاجراء وما يترتب عليه من آثار.

^١ أزع — طعن ٤٧٢٣ لسنة ٤٠ ق ، في ١٩٩٦/٦/٢٥.

ومن أمثلة ذلك : التأخر فى التنفيذ لمدة طويلة أو البطء فى التنفيذ بدرجة كبيرة ، أو توقف عن العمل ولكن أما إذا ثبت استخدامه العش أو التواطؤ أو الاحتيال أو الفساد أو التلاعب .. الخ فيفسخ العقد تلقائياً ، وتتخذ ضد المتعاقد الاجراءات الجنائية المقررة قانوناً.

- (٢) — وقدما أنه — أيضاً — وطبقاً للقواعد العامة ، لايعفى المتعاقد من هذا الاجراء ، إلا إذا ثبت أن توقفه عن التنفيذ كان لسبب لادخل لارادته فيه — كالقوة القاهرة مثلاً .
- (٣) وفيما يتعلق بشروط استخدام الحق فى سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب.

فإنه ولما كان هذا الاجراء من الاجراءات الخطيرة التى تتمتع بها الإدارة ، كذلك يجب توافر شروط معينة ، حتى تستطيع الادارة ممارسة هذه السلطة.

وتتبدى هذه الشروط فى ثلاث شروط هى :

(أ) وجوب انذار المتعاقد قبل اتخاذ هذا الاجراء.

وقد نص على هذا الشرط فى م/٥١ من ق ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م/٨٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والتى تنص على انه : إذا أخل المقلول بأى شرط من شروط العقد ، أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ، ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد

للقيام باجراء هذا الإصلاح ، كان للسلطة المختصة الحق فى اتخاذ أحد الاجرائين التاليين ، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة :

(أ) فسخ العقد.

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على الحساب بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها، والمتعاقد عليها.

— وقد نص على هذا الشرط فى م/٥١ من ق ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ (فقرة ٢).

(ب) أن يكون إخلال المتعاقد بالتزاماته جسيماً ، بما يتناسب مع الجزاء الذى تفرضه الإدارة عليه.

وقضى بأن مرور فترة وجيزة بعد البدء فى التنفيذ ، دون أن يتضح أن ثمة مخالفة يمكن نسبتها إلى المقاول ، لا يصلح سبباً لسحب الأعمال منه^(١).

— وهذا الشرط مستقر فقهاً وقضاءً ، بالنظر إلى خطورة الاجراء الذى تتخذه الإدارة.

(ج) وجوب صدور قرار من الادارة المتعاقدة (من السلطة المختصة) بسحب العمل من المتعاقد المقصر .

^١ أ.ع — طعن ١٧٨٦ لسنة ٠٣ ق ، فى ١٨/١/١٩٨٦ ، مج س ٣١ ، ص ٨٨١ ، طعن رقم ٨٣٢ لسنة ٣٣ ق ، فى ٢٨/٧/١٩٩٢.

— وهذا الشرط مستقر عليه قضائياً ، وقد نص على هذا الشرط صراحة م/٥١ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ونشير إلى أن استخدام الادارة هذا الاجراء أمر تفرضه المصلحة العامة ، وحماية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

وقد نص على هذا الشرط فى م/٥١ من ق . ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
— وإذا كان يجوز الجمع بين هذا الاجراء وجزاءات غرامة التأخير، فضلاً عن المصروفات الادارية ، إلا أنه لايجوز الجمع بين هذا الاجراء وفسخ العقد.

ومرد ذلك — وعلى ماتقدم — ان التنفيذ على الحساب (تنفيذ الالتزام عيناً ، لايعد عقوبة عقدية ، ولكنه اجراء تستهدف به الادارى فان سير المرافق العامة باطراد وقد نص على ذلك صراحة فى الفقرة (٣) من المادة (٥١) — المشار اليها —.

— إما إذا لجأت جهة الادارة إلى توقيع جزاء الفسخ ، فانها يجب أن تقف عند توقيع هذا الجزاء دون أن تجعله مصحوباً باعادة طرح العملية على حساب المتعاقد المقصر ، وتحمله النتائج المالية لعملية الارساء الجديدة ، وذلك لتعارض النتائج المترتبة على فسخ العقد مع نتائج (آثار) التنفيذ على الحساب.

فجزاء فسخ العقد يترتب عليه انتهاء العقد ، فى حين انه فى حالة التنفيذ على الحساب يبقى العقد قائماً ومنتجاً آثاره ، فلا يجوز الجمع بينهما.

— وهنا ملاحظة جوهرية ، إذ العبرة فى تحديد الجزاء الموقع باستخلاص ارادة الادارة الحقيقية — استخلاص هذه الارادة لاينبغى أن يقف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، بل يجب أن يعتد فيه بالآثار التى رتبها جهة الادارة على تصرفها للكشف عما قصدت فى الحقيقة أن توقعه من جزاء (١).

المبحث الثالث

فسخ العقد

تمهيد وتقسيم :

— نص على جزاء فسخ العقد فى المادتين (٥٠) ، (٥١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فبينما تناولت المادة (٥٠) حالات الفسخ الوجوبى (تلقائياً) ، وذلك فى حالات ثلاث هى :

١ أ.ع — طعن ٩٧٨٠ لسنة ٥٢ق ، فى ٢٠١٠/١١/٣٠ ، طعن ١٧٠٥٧ لسنة ٥٣ ق ، فى ٢٠١٢/٥/٢٩ طعن ٣٧٥٩ لسنة ٤٣ق ، فى ٢٠٠١/١٠/٣١ ، طعن ٥٩٥٥ لسنة ٤٣ ق ، فى ٢٠٠١/٥/٨.

١- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الادارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد.

٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكاره .

٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

— وتناولت المادة (٥١) حالات الفسخ الجوازى (حيث تتمتع السلطة المختصة بسلطة تقديرية واسعة فى اتخاذها) ، وحددته فى اخلال المتعاقد بأى شرط جوهرى من شروطه . (ويلاحظ أن م /٥١ — المشار إليها — نصت على القاعدة العامة فى فسخ العقود الادارية).

— والبين أن المشرع فى المادة (٥١) — المشار إليها — قد ساوى بين جزائى الفسخ والتفويض على الحساب ، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها لاعمال أى اجراء منهما (وكذا الآثار المترتبة على الاجراء) ، وهى : شرط الانذار المسبق ، والاخلال الجسيم — بأى شرط جوهرى من شروط التعاقد. واصدار قرار من السلطة المختصة بالاجراء) . وبمراعاة ، عدم جواز الجمع بينهما — على ماتقدم — . وعلى ذلك فثمة تشابه بين الاجرائين فى بعض الحالات . وسوف نتناول — هنا — الأحكام الخاصة بفسخ العقد الادارى ، وذلك على النحو الآتى:

وفيما يتعلق بالفسخ الوجوبى للعقد تلقائياً ، أوجبت اللائحة التنفيذية على المتعاقد مع الإدارة تجنب موجبات فسخ العقد ، وبصفة خاصة فى الحالتين الآتيتين :

— تقديم أى بيانات أو مستندات غير صحيحة بالذات أو الواسطة ،
وذلك بغرض الغش والتلاعب.

— المخالفة للحظر المنصوص عليه بالمادة (٣٣) من القانون ، أو
التورط فى ممارسة إحتيال، أو فساد ، أو إحتكار، ومن ذلك التواطؤ ، أو
منع أى منافسة لآحد أصحاب العطاءات الآخرين ، أو الاتفاق معهم على
أغراض غير مشروعة ، وذلك بما يخل بعدالة المنافسة المشروعة ،
والإخلال بمبادئ الشفافية ، والمنافسة ، وتكافؤ الفرص ، وغير ذلك من
ممارسات تآل بتطبيق أحكام هذا القانون وهذه اللائآة. ونص أيضا على
أن تتولى ادارة التعاقدات فسخ التعاقد تلقائياً فى هاتين الحالآتين ، واعداد
مذكرة للسلطة المختصة لمخاطبة ادارة الفتوى المختصة بمآلس الدولة
للقوف على رأبها فى شطب اسم المتعاقد ، على أن تتولى الإدارة فور
ورود رأى مآلس الدولة اآطار الهيئة العامة للآدمات الحكومية بقرار
الشطب ، لتتولى الهيئة إصدار كتاب دورى متضمناً الآتى : اسم الجهة
مصدرة القرار وتاريخ صدوره ، واسباب الشطب ، بيانات كتاب ادارة
الفتوى بمآلس الدولة من رقم وتاريخ ورقم الملف ورقم السآل ، واسم
صاحب العطاء ، أو المتعاقد المشطوب وبياناته ، وغير ذلك من
البيانات التى تراها الهيئة لازمة.

وتتشر الهيئة الكتاب الدورى من آلال النشرات المصلآية ، وعلى
بوابة التعاقدات العامة، وقيده فى سآل الممنوعين من التعامل ، وتلتزم

جميع الجهات الادارية بقيد الممنوعين من التعامل فى السجل الخاص بذلك ، ويحظر التعامل معهم (م/١٠٠ من اللائحة).

وللمتعاقدين الذى تم شطب اسمه ، طلب إعادة قيده إذا انتفى سبب الشطب ، بصدر قرار من النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده ، أو بحفظها إدارياً ، أو يصدر حكم نهائى ببراءته مما نسب إليه . وعلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية نشر قرار إعادة القيد بطريق النشرات المصلحية ، وعلى بوابة التعاقدات العامة.

أما فيما يتعلق بالفسخ الجوازى للعقد ، فى حالة إخلال المتعاقد بأى شرط جوهري تضمنته شروط العقد ، فقد اشترطت اللائحة لأعمال ذلك الفسخ ، ان تستنفذ إدارة التعاقدات كافة البدائل الممكنة للوصول إلى حلول تتفق مع شروط العقد ، وانه فى حالة عدم إمكانية التوصل إلى حلول منطقية ، وأن للجهة الادارية اتخاذ أحد اجرائين :

— إما فسخ العقد . وفى هذه الحالة لايجوز إعادة طرح العملية فى السنة ذاتها المقرر التنفيذ فيها.

— أو التنفيذ على حساب المتعاقد ، مادام أن الحاجة إلى تنفيذ هذه العملية مازالت قائمة ، على أن يتم التنفيذ بالشروط والمواصفات ذاتها المعلن عنها ، والمتعاقد على أساسها ، وذلك باحدى الطرق القانونية المنصوص عليها بالمادة (٧) من القانون.

أولاً : مفهوم الفسخ وآثاره :

١- الفسخ وثيق الصلة بالمسئولية العقدية :

- ثمة علاقة أو اتصال بين الفسخ والمسئولية العقدية ، فكلاهما جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدى . ويخضع فسخ العقد لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن الذى أجيب إلى فسخ العقد ، أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين ، إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه لاهمال أو تعدد ، وترتب على هذا الخطأ ضرر .

هذه القاعدة العامة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الادارى ، كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء . ومن ثم فإن التعويض الذى مرده الى القواعد القانونية العامة مستقل فى سببه ، كما أنه مختلف فى طبيعته ووجهته وغايته عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية ، التى جرى العرف على اشتراطها فى العقد الادارى .

٢- لامحل للفسخ بعد انتهاء العقد :

- إذاً يكون للإدارة فى حالة فسخ العقد أن تصدر التأمين ، وانه لامحل لفسخ العقد بعد انتهائه ، ولايجوز من ثم مصادرة التأمين^(١) .

^١ أ.ع - طعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٤٣ ق ، فى ١٣/١٢/٢٠٠١ .

٣- آثار الفسخ فى القواعد العامة :

— وفى ما يترتب على الفسخ من آثار — فى القواعد العامة — ، إنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا إستحال ذلك ، جاز الحكم بالتعويض (م/١٦٠ مدنى). وعلى ذلك إذا فسخ العقد فإنه ينحل ويعتبر كأن لم يكن.

ثانيا : يتميز الفسخ فى العقود الادارية ، بخصائص جوهرية — أهمها :

١- الفسخ الوجوبى :

— هناك فسخ يقع تلقائياً (وجوباً) فى حالات استعمال الغش بنفسه أو بواسطة غيره أو التلاعب فى تعامله مع الجهة الادارية ، أو إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار ، أو إذا أفلس المتعاقد أو أعسر . وفى هذه الحالات يتم الفسخ تلقائياً ، ويشطب اسم المتعاقد (عدا حالة الافلاس أو الاعسار) ، وقد اشترط القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، أخذ رأى ادارة الفتوى المختصة فى حال قررت الجهة الادارية شطب المتعاقد (م/٥٠).

بينما — فى ماعدا الحالات السابقة — يخضع الفسخ فى العقود الادارية للقاعدة العامة فى جواز فسخ العقد (أو التنفيذ على حساب المتعاقد)، إذا أخل المتعاقد بأى شرط جوهرى من شروط العقد.

(٢) الفسخ الجوازى :

— أنه فضلا عن الفسخ الوجوبى للعقد (الذى يقع تلقائياً) فى أحوال الغش أو التلاعب أو التواطؤ أو اللجوء إلى ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار ، وفى ذلك نصت (م/٨٩) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على

انه : " مع عدم الاخلال بحق وذى لشأن فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية يؤخذ تأديبياً كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ، أو مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالتعاقدات ، والتي يصدر بها قرارا من وزير المالية.

(٣) خضوع كافة عقود الادارة للفسخ الادارى :

— كما وان للادارة فسخ العقد (سواء العقد الادارى أو عقد الادارة الذى يخضع للقانون الخاص)، ويعد ذلك حقاً أصيلاً قائماً بذاته ، مستقل عن نصوص العقد ، بمعنى أنه يجوز للادارة استخدام حقها فى فسخ العقد (فى حال توافر الشروط القانونية اللازمة لأعماله) ولو لم ينص عليها فى العقد ، بحسبانه من النظام العام ، وقد انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن العقد الذى يفقده الحكومة مع مقال ... سواء اعتبر عقداً مدنياً ، أم عقداً ادارياً ، كفان وصفه لايحول دونم القضاء بفسخه إذا أخل المقال بالتزاماته المحددة فيه (١).

(٤) شروط أعمال الفسخ :

— وانه إذا كان الأمر واضحاً فى شروط أعمال الفسخ ، فيما يتعلق بشرطى الانذار وصدور قرار السلطة المختصة بذلك ، فانه — وعلى ماقدمنا — لايعتبر كل خطأ من جانب المتعاقد سبباً مبرراً لتوقيع جزاء الفسخ عليه بل لابد أن يكون الخطأ الذى يرتكبه المتعاقد جسيماً، وقد عبر عن ذلك " مخالفة شرط جوهرى فى العقد " — م/٥١ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

^١ فتوى رقم ٢٠٨ ، فى ٢٢/٤/١٩٥٤.

والادارة وحدها هي التي تقوم بتقدير مدى جسامة الخطأ وكفايته لتقرير جزاء الفسخ ، تحت رقابة قاض العقد ، إذ يقوم قاضي العقد بناء على طلب المتعاقد المفسوخ عقده برقابة تقدير مدى جسامة الخطأ وكفايته للفسخ الجزائي للعقد.

— وتسرى — هنا — أحكام الرقابة القضائية على قرار الجهة الادارية سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب ، السابق ذكرها، فنحيل إليها — منعاً للتكرار —.

— وتطبيقاً لذلك : قضى بأن تنازل المتعاقد عن عقده للغير ، وتعاقده بشأنه من الباطن بدون موافقة الادارة ، خطأ جسيم ، يبرر للادارة توقيع جزاء فسخ العقد ^(١).

بل ونص — صراحة — على عدم جواز النزول عن العقد (م/٩٢ من ق ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ — ويعد — أيضاً — من قبيل الأخطاء الجسيمة التي تبرر فسخ العقد ، عدم أداء صاحب العطاء التأمين النهائي خلال المدة المحددة رغم اخطاره كتابة بذلك ، بحسبان ان ذلك يشكل اخلافاً بشرط جوهرى فى العقد. ووفاء المتعاقد ، تبرر فسخ العقد أو السماح للورثة بالاستمرار فى تنفيذ العقد — على ماقدمنا قبلاً — . (م/٥٢ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨).

^١ حكم محكمة القضاء الادارى ، فى ١٩٥٧/١/٢٧ — سالف الاشارة إليه ، حكم أ.ع — طعن رقم ٤٣٦ لسنة ٢٢ ق ، فى ١٩٨٥/٤/٩ ، حكم أ.ع — طعن ٣٥١٦ لسنة ٣٥ ق فى ٩٩٧/١١/٢٥ وقضى بعدم مشروعية التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن ولو وافقت الادارة ، هذا التنازل يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، تملك الادارة فسخ العقد متى حدث ذلك.

— وقد أوجب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، على الجهة الادارية إعداد كراسة للشروط والمواصفات ، تتضمن فضلاً عن الاحالة إلى جميع القواعد والأحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ان تتضمن أيضاً بيانات أخرى منها شروط فسخ العقد، والجزاءات والغرامات .. وأى بيانات أخرى بحسب طبيعة العملية (م/١٩).

(٥) فى شطب اسم المتعاقد من سجل المتعاملين :

— فى أحوال الفسخ الوجوبى (التلقائى) — الواردة فى م/٥٠ من القانون ، ونص المشروع — أيضاً — على وجوب شطب اسم المتعاقد فى حالتي استعمال الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة الادارية أو فى حصوله على العقد ، أوإذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار، واشترط المشرع لذلك أخذ رأى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

كما أوجب القانون أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية ، وعلى بوابة التعاقدات العامة.

— ونص — فى ذات المادة أيضاً — على أن : " ويعاد قيد المتعاقد الذى شطب اسمه فى سجل المتعاقدين بناء على طلبه إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً ، أو بصدور حكم نهائى ببراءته مما نسب إليه ، على أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار اعادة القيد لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.

— وقد انتقد البعض شطب اسم المقاول أو المورد فى حالة ادعاء الغش قبله قبل صدور قرار من جهة التحقيق بادانته ، واعتبر ان قرار الشطب يعد بمثابة العقوبة قبل المحاكمة ^(١) . ونحن — من جانبنا لانواقفه على هذا الذى اتجه إليه ، إذ أن حماية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، ومن ثم حماية أموال تلك المرافق ، لانتوازن مع حماية المصالح الخاصة للمتعاملين مع تلك المرافق . بل وقضى بجوار حظر التعامل مع المقاول من الباطن الذى وقع منه الغش فى تنفيذ العقد رغم كونه غير طرف فى العقد.

كما قضى بأن استعمال المتعاقد مع الادارة الغش ، يجعل العقد مفسوخاً بقوة القانون ، من تاريخ علم الإدارة بالغش ، ولاوجه لاعتبار المتعاقد بعد هذا التاريخ متأخراً فى التنفيذ وتوقيع غرامة عليه ^(٢) . وعلى ذلك فانه تجب مراعاة تقدير الجانب الشخصى للمتعاقد مع الادارة ، وحسن سمعته ، ومقدرته المالية والفنية ، وإذا حدث مايمس تلك الاعتبارات (مثل الغش أو التواطؤ أو الاحتيال أو) ، كان للادارة فسخ العقد.

— ولكن حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش (الذى يوجب فسخ العقد تلقائياً ، وشطب اسم المتعاقد من سجل المتهدين أو المقاولين) ، يجب أن يثبت علم المتعهد أو المقاول بهذه المخالفة ، بما ينطوى عليه هذا العلم من خداع من جانب المورد فى حقيقة الشئ المسلم

^١ راجع المستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين — العقود الادارية — مرجع سابق ، ج/٢ ص ٨٠٣ — ٨٠٤.

^٢ أ.ع — طعن رقم ٣٥٩٦ لسنة ٣٦ ق ، فى ١٩١٧/١١/٢٥.

، من حيث نوعه أو صفاته الجوهرية التي جرى التعاقد عليها ، أو أن يأتى المقاول أو المتعهد أعمالاً تتم عن عدم التزام فى تنفيذ التزاماته ابتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة ، وفى هذه الحالات يتوافر سؤال القصد الدال على استعمال الغش أو التلاعب المبرر لعدم التعامل مع المورد أو المقاول ^(١).

(٥) الطبيعة القانونية لقرار الشطب (قرار مستمر) :

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن : قرار الإدارة بشطب اسم المتعهد من سجل الموردين ، يترتب عليه تعديل مركزه القانونى تعديلاً مستمراً ، بحيث يتمتع عليه الدخول فى المناقصات الحكومية فى المستقبل مادام قرار الشطب قائماً ومنتجاً لآثاره .

وعلى ذلك لا يخضع الطعن فى قرار شطب اسم المتعهد لمواعيد الطعن بالالغاء ، بحسبانه قراراً مستمراً ، فيبقى — هذا القرار — محلاً للطعن بالالغاء فى أى وقت ماضٍ قائماً ومستمراً فى انتاج آثاره ^(٢) .

والسؤال الأهم : إذا صدر قرار الشطب فى تاريخ على التعاقد، فهل يستمر المقاول أو المتعهد فى تنفيذ العملية ، أم يعتبر العقد باطلاً ، ولايسوغ استكمالها ؟

بداية ، فإن المشرع قد ألزم الجهة الإدارية بأن تمسك كل منها سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل سواء كانوا موردين أو مقاولين ، متى وجد نص قانونى أو قرار إدارى بهذا المنع — م/٨٥ من القانون ١٨٢

^١ أ.ع — طعن رقم ١٤١٢٧ لسنة ٥٧ ق :، فى ١٦/٨/٢ .

^٢ أ.ع — طعن ١٢٢٥ لسنة ٢٥ ق فى ١٩٨٤/٢/٢٥ ، طعن ٧٢٤ لسنة ٢٧ ق — مج س ٢٧ ص ٢٣٦ .

لسنة ٢٠١٨ - وحظر التعامل مع المقيدین فی هذا السجل ، مالم يتم رفع هذا الحظر بانتفاء نفسه.

ومؤدى ذلك ولازمه أن هذا الحظر يسرى من تاريخ اخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية للجهة الادارية بقرار الشطب ، وحظر التعامل مع الجهات الادارية ، ومن ثم يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لذلك.

وبناء على ، انتهى رأى ادارة فتوى الأزهر (فتاها رقم ١١١٩ فى ١٢/٧/١٩٩٢ إلى وجوب تنفيذ العقد ، حيث أن التعامل مع المتعاقد تم قبل ورود كتاب الهيئة ، ومن ثم يبقى العقد صحيحاً وناظاً ، ولايسرى حظر التعامل إلا من تاريخ اخطار الجهة الادارية بقرار الشطب أو حظر التعامل.

— وهنا للاجابة على السؤال السابق ، نتفق مع ماذهب اليه البعض من وجوب التفرقة بين :

- ١— إذا كان المتعهد أو المقاول قد شطب اسمه من سجل المتعهدين أو المقاولين فى تاريخ سابق على إرساء المناقصة عليه.
- ٢— أو أن يكون قرار الشطب صدر بعد اخطاره بقبول عطائه وانعقاد العقد.

فيبطل العقد فى الحالة الأولى ، حتى ولو لم تعلم به الجهة الإدارية إلا فى تاريخ لاحق على القبول ، وذلك على سند من أن أحكام الأهلية من النظام العام ، فلايجوز أن يعطى شخص أهلية غير متوافرة عنده ، ولايجوز الحرمان من أهلية موجودة أو الانتفاض منها.

أما فى الحالة الثانية ، وهى إذا أخطر المتعهد أو المقاول بقبول عطائه وانعقد العقد ، ثم صدر قرار شطبه من التعامل ، فلا يكون العقد باطلاً ، لأن قرار الشطب ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ، فلا ينسحب على العقود التى أبرمت سابقه عليه وتظل صحيحة منتجة لآثارها^(١).

(٦) ولا ينقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه ، إلا إذا كانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبى ، ولا تسرى هذه القاعدة إلا فى حالة الفسخ الجوازى ، الذى يرجع إلى اخلال المتعاقد بالتزاماته اخلالاً جسيماً ، فإذا كان ذلك الاخلال يرجع إلى سبب أجنبى لادخل لارادة المتعاقد فيه (كالقوة القاهرة)، فإن العقد ينتهى ، ولا يجوز توقيع أى جزاءات (مالية) على المتعاقد.

أما إذا كان الفسخ راجعاً إلى اخلال المتعاقد مع الادارة بشرط جوهرى ، فإنه يجوز للادارة الجمع بين الفسخ ومصادرة التأمين ، والتعويض عما يكون قد اصاب الجهة الادارية من اضرار ، تجاوز قيمة التأمين النهائى . ولا يعد ذلك ازدواجاً للتعويض محظوراً ، حتى ولو لم ينص فى العقد الادارى على ذلك ، بحسبان أن ذلك يعد تطبيقاً للقواعد العامة — على ماتقدم — (٢) .

— وملاحظة أخيرة : أنه لا يمنع من ممارسة حق الادارة فى فسخ العقد ، سبق توقيع بعض الجزاءات المنصوص عليها فى العقد ، إذ أن

^١ راجع : المستشار أحمد منصور — الدليل الاجرائى لقضاة مجلس الدولة — غير منشور — مرجع سابق ، ص ١٠٤ / ١٠٥ .

^٢ أ.ع — طعن ١٧٢٠ لسنة ٤١ ق ، فى ٢٠/٤/١٩٩٩ ، طعن ١١٨٠ لسنة ٨ق ، فى ٢٧/١١/١٩٦٥ .

طبيعة حق هذه الجهة فى فسخ العقد ومصادرة التأمين ، تقتضى بالضرورة سبق إخلال المتعاقد مع الادارة بشروط العقد (١).

— والأثر المترتب على إصدار الادارة جزاء غير مشروع (سواء الفسخ أو خلافه)، يتمثل فى تحريك المسؤولية العقدية . وهنا نؤكد على انه لايجوز للادارة أن تستبدل الجزاء الذى انقضت عليه مع المتعاقد معها بجزاءات أخرى ، لم يرد النص عليها فى العقد.

(٧) الفسخ والبطان :

فسخ العقد حق مكفول لطرفى العقد ، فى حالة مخالفة شروط التعاقد. والفسخ مثل البطان فى الآثار المترتبة على كل منهما ، إذ يؤدى الفسخ (والبطان) إلى اعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ، بمعنى آخر ، ان لكل من الفسخ والبطان أثر رجعى.

— وأن وجه الخلاف بينهما يتبدى فى أن البطان يكون فى مرحلة ابرام العقد ، ويرجع إلى تخلف ركن أو شرط من شروط ابرام العقد ، بينما الفسخ ، يكون فى مرحلة تنفيذ العقد ، وتخلص اسبابه فى إخلال أحد طرفى العقد بالتزاماته التعاقدية فى مواجهة الطرف الآخر.

خاتمة : انقضاء العقد الادارى :

ينقضى العقد الادارى بأحد طريقين : أولهما ، نهاية العقد نهاية طبيعية .

^١ أ.ع ، طعن رقم ٥٢٣ لسنة ١١ ق ، فى ١٩/١/١٩٧١ ، مج س ١٦ — ص ١٣٠.

— ويكون ذلك بالتنفيذ الكامل للالتزامات الناشئة عن العقد ، مثل تمام البناء محل عقد الأشغال العامة ، أو تسليم البضائع ونقلها ، فى عقد التوريد أو النقل.

— كما ينتهى العقد نهاية طبيعية ، بانتهاء المدة ، إذا كان العقد محدداً بمدة معينة.

والمسلم به أن يخضع العقد فى تحديده لارادة الطرفين التى قد يعبر عنها صراحة أو ضمناً.

بيد أنه إذا كان التعبير صريحاً ، فلا يمكن أن يعتد بالتعبير الضمنى.

وثانيهما ، نهاية العقد نهائية غير طبيعية :

إذ قد ينتهى العقد الادارى نهاية مبتسرة قبل الأوان لعدة أسباب :

— منها مايعود إلى أسباب خارجة عن ارادة طرفى العقد (كالقوة القاهرة).

— ومنها مايعود إلى إرادة طرفى العقد . أو أنه يعد جزاء تفرضه وتوقعه الادارة المتعاقد ، حال اخلال المتعاقد معها بالتزاماته اخلالاً جسيماً — على ماقدمنا — .

— كما وان القضاء قد يفسخ العقد قبل الأوان إذا أخلت الادارة بالتزاماتها.

المبحث الرابع

الجزاءات الجنائية فى العقود الادارية

تمهيد :

— بادئ ذى بدء ، نشير إلى أن تناولنا لموضوع الجزاءات الجنائية فى العقود الادارية ، سيكون موجزاً نقف فيه عند حد إلقاء الضوء على مجمل الخطوط العامة فى الموضوع ، مدى قبول العقد الادارى لفكرة الجزاءات الجنائية كوسيلة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية ، وحالات تطبيق تلك الجزاءات ، والشروط المتطلبة لذلك.

— ونجمل دراسة موضوع " الجزاءات الجنائية فى العقود الادارية " فى النقاط الآتية :

أولاً : الأصل العام فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية :

من المسلمات أن الأصل العام هو خضوع العقد الادارى للقواعد العامة التى تحكم الروابط التعاقدية ، بمعنى : ان المسؤولية العقدية هى الأثر المترتب على الاخلال بالالتزامات التعاقدية ، وتنتهى هذه المسؤولية إما بالوفاء بالالتزام بالتنفيذ عيناً ، أو بالتعويض عن الأضرار التى تلحق بالمتعاقد الآخر من جراء الاخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

ثانياً : وبناء على الأصل العام فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية ، فإنه لايمكن أن يكون العقد الادارى مصدراً لجزاء جنائى:

— فلايجوز للجهة الادارية أن تسن لوائح ضبط (بوليس) فى سبيل تقرير الجزاءات الجنائية لضمان تنفيذ عقودها.

إذ أنه مهما كانت جسامة المخالفة التى يرتكبها المتعاقد مع الإدارة ، لايجوز للجهة الادارية المتعاقد أن توقع عليه جزاء جنائياً .

— بيد أن العقوبات الجنائية لمخالفة الالتزامات التعاقدية ، يرد النص عليها فى القوانين واللوائح ، إعمالاً للمبدأ الدستورى بأنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولاتوقع عقوبة إلا بحكم قضائى " (م/٩٥) من الدستور المصرى — دستور سنة ٢٠١٤.

— وهنا ملاحظة جوهرية ، مؤداها أنه على الرغم من أن للجهة الادارية المتعاقدة تضمين عقودها الادارية شروطا استثنائية غير مالوفة، إلا أنه لايجوز أن تصل هذه الشروط إلى حد تخويل الجهة الادارية سلطة فرض عقوبات جنائية على المتعاقد معها ، بل أن مثل هذه الشروط — حتى وإن قبلها المتعاقد مع الادارة — تعتبر باطلة.

فقد أبطل مجلس الدولة الفرنسى لائحة بوليس (ضبط) اصدرتها الجهة الادارية المتعاقدة ، وضمنتها فرض عقوبة جنائية لضمان تنفيذ عقد ادارى ^(١) .

ثالثا : للجهة الادارية الحق فى تنبيه المتعاقد معها إلى اتباع القوانين واللوائح بصفة عامة.

— وهنا نشير إلى أن المشرع قدر فى بعض الحالات خطورة الاخلال فى بعض العقود التى تبرمها الادارة فجرمها (أى جعل من ذلك الاخلال جريمة جنائية) ، ومن أمثلة ذلك :

* (أ) مانصت عليه (م/٣٣) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ، إذ نصت الفقرة الأخيرة من

De Laubadere

^١ انظر

(A.): Traite de droit administrative, T. I ١٩٩٥, ٦ em, Paris, P. ٣٥١.

هذه المادة على أنه : " يجب على الجهات الادارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأى مخالفة لأحكام هذا القانون ، وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥".

* (ب) نص م/٥٠ من ذات القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، فى تقرير وجوب فسخ العقد وجوبياً وتلقائياً وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين :
١- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة الادارية المتعاقدة ، أو فى حصوله على العقد.

٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيا أو فساد أو احتكار.

٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر^(١) .

(ج) وقد جاء القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، بنص عام ، يقضى بأنه :
" مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية، يؤاخذ تأديبياً كل من خال أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ...".
ومؤدى النصوص السابقة ، أن استخدام المتعاقد مع الادارة الغش أو الاحتيال أو الاحتكار أو الفساد...، يوجب تحريك الدعوى الجنائية ضده ، فضلاً عن الفسخ الوجوبى للعقد وشطب أسم المتعاقد من سجل المتعاقدين
— على ماتناولناه بالتفصيل قبلاً — .

بمعنى آخر : أنه فى الحالات — المشار إليها — تتعقد المسؤولية الجنائية للمتعاقد مع الادارة (ومن تواطؤ معه من موظفى ، الجهة

^١ هذا النص يماثل نص م/٢٤ من ق . رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، عدا البند (٢) ، فانه مستحدث بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

الادارية) ، ويكون انعقاد المسؤولية الجنائية فيها بنصوص قانونية واضحة صريحة ، وليست بناء على ارادة الجهة الادارية . ومن ثم يكون توقيع الجزاء الجنائي على المتعاقد مع الإدارة من الجهات الادارية، ليست بوصفها طرف فى العقد ، بل بوصفها سلطة عامة تملك الحق فى إصدار لوائح ضبط (بوليس) ، إذا خالفها المتعاقد مع الادارية ، كان لها توقيع الجزاءات الجنائية عليه ، بوصفها سلطة عامة منوط بها حماية النظام العام.

بيد أنه ليس للجهة الادارية ، بل ولايجوز لها أن تستعمل هذه السلطات من أجل اجبار المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته التعاقدية — بمعنى آخر ، يجب أن تنحصر الجزاءات الجنائية على الالتزامات التنظيمية وليست الالتزامات التعاقدية فى العقد.

بعبارة أخرى : أن مخالفة المتعاقد مع الادارة القواعد التنظيمية المقررة بالقوانين تخضعه للعقاب الجنائي المقرر بتلك القوانين.

رابعاً: حالات تعرض المتعاقد مع الادارة للجزاء الجنائي :

ثمة حالتان يتعرض المتعاقد مع الادارة ، فيهما للجزاء الجنائي :

الحالة الأولى : أن ينص القانون على اعتبار خطأ معين جريمة جنائية (كالغش أو الاحتكار أو الرشوة — الفساد —).

الحالة الثانية : مخالفة المتعاقد مع الادارة الالتزامات المفروضة

بمقتضى لوائح الضبط .

الادارى العام أو الخاص^(١) ، والتي تطبق على الكافة (المتعاقدين غيرهم من الأفراد).

ومن أمثلة ذلك :

(أ) — (م/١١٦) عقوبات ، والتي تنص على أن : " كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاوله أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ، إرتبط به مع احدى الجهات المبينة فى م/١١٩ (وهى وحدات الادارة المحلية ، وفروع السلطة التنفيذية ، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال ، والنقابات والاتحادات ، والمؤسسات ذات النفع العام ، والجمعيات التعاونية ، والشركات التى تساهم فيها هذه الجهات ، وكذلك الشركات المساهمة أو أى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالاً عامة). أو مع أحد الشركات المساهمة ، وترتب عليه ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب غش فى تنفيذ هذا العقد ، يعاقب بالسجن ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت ،

^١ يقصد بالضبط الادارى العام : تلك الوسائل التى تستهدف المحافظة على النظام العام (إلا من العام — الصحة العامة — السكنية العامة). بينما يقصد بالضبط الادارى الخاص : الوسائل التى تهدف إلى تحقيق أغراض محددة ، يرى المشرع اسنادها إلى هيئات ادارية خاصة، بواسطة نصوص تشريعية أو لائحية . الضبط الادارية الخاص إذا يخضع لقانون خاص به ، أو مميز له من حيث مجال تطبيقه فى نطاق معين بالذات (مثل المصنفات الظنية — المسطحات المائية).

إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب ، وترتب عليها إضرار
بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية " .

— والبين من هذا النص أن المشرع يكاد يغطى جميع المخالفات
الجسيمة التى يرتكبها المتعاقد مع الادارة أثناء تنفيذ العقد ، ادارياً
كان أو غير ادارى إذا كان العقد ذا أهمية خاصة ولو كان فى مجال
القانون الخاص.

(ب) (م/٧٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، بشأن
المناقصات والمزايدات ، والتى تنص على أن : " يلتزم
المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات
الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ
النظام وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية ، بإبعاد كل من يهمل أو
يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه
الشروط ... وتعتبر مسئوليته فى هذه الحالات مباشرة دون
تدخل للجهة الادارية".

خامسا : متى يصبح الخطأ التعاقدى جريمة جنائية :

من العرض السابق ، يتبين أنه لى يصبح الخطأ التعاقدى جريمة
جنائية ، لابد من توافر الشروط الآتية :

(١) أن يعتمد المتعاقد مع الادارية الاخلال الجسيم بالالتزامات
التعاقدية ، ومن ثم ترتب ضرر جسيم بالجهة الادارية
جاء ذلك .

(٢) استخدام الغش فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

— وهنا نشير إلى أنه لا يشترط الأعذار لتطبيق العقوبات الجنائية على المتعاقد مع الإدارة ، لعدم جدوى ذلك الأعذار.

— وهكذا تستطيع الجهة الادارية (سلطات الضبط) أن تلزم المتعاقد مع الإدارة بجميع النظام العام التى تفرضها على أن شخص فى الظروف ذاتها ، إذ لاتحمى صفة المتعاقد (مع الإدارة) من تطبيق قواعد الضبط طالما لم تخصصه بالتطبيق بصفة خاصة.